المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٩

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

باب الشجاج وكسر العظام

الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة وهي عشر خمس لا مقدر فيها أولها الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولاتدميه ثم البازلة التي يسيل منها الدم ثم الباضعة التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب [ج ٩ - ص ٣]

وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة

فصل

وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه وفيها خمسة أبعرة [ج ٩ - ص ٤]

وعنه في موضعة الوجه عشرة والأول المذهب فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين وأن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما [ج ٩ - ص ٥]

أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وأن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاثة مواضح وأن أختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه ومثله لو قطع ثلاث أصابع إمرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه وأن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين [ج ٩ - ص ٦]

وأن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة وقيل يلزمه خمس من الإبل

ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظاما ففيها خمسة عشر من الإبل ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة آمة ففيها ثلث الدية ثم الدامغة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة [ج ٩ - ص ٨]

فصل

وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر [ج ٩ - ص ٩]

فإن خرقه من جانب نخرج من جانب آخر فهي جائفتان وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ففيه حكومة ويحتمل أن تكون جائفة

فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك وأن أجافه ووسع أخر الجرح فهي جائفتان وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة وأن التحمت الجائفة ففتحها أخر فهي جائفة أخرى

فصل

وفي الضلع بعير وفي الترقوتين [ج ٩ - ص ١١]

بعيران وفي كل واحد من الذراع والزند والعضدة والفخذ والساق بعيران

[ج ٩ - ص ١٢]

وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته ألا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ بها أرش المقدر [ج ٩ - ص ١٣]

وإذا كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها وإن كانت مما لاتنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم

[ج ٩ - ص ١٤]

فإن لم تنقص شيئا بحال أو زادته حسنا فلا شيء فيها والله أعلم

باب العاقلة وما تحمله عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه

[ج ٩ - ص ١٦]

وعنه أنهم من العاقلة أيضا وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا إمرأة ولاخنثى مشكل ولا رقيق ولامخالف لدين الجاني حمل شيء وعنه أن الفقير يحمل من العقل

[ج ٩ - ص ١٧]

الرعاية وفي هرم وزمن وأعمى وجهان فلو عرف نسب قاتل من قتيله ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ذكره في المذهب ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر للخبر ولأنهم استووا في التعصيب والإرث فاستووا في تحمل العقل كالحاضرين

وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال قدمه في الرعاية والفروع لأن خطأه يكثر فيجحف بهم ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايته في مال الله ونخطإ وكيل وعليها للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره وعنه على عاقلته أي على عاقلتهما قدمه السامري لقول علي لعمر ديته عليك لأنك أفزعتها ولأنه جان فكان خطؤه على العاقلة كغيره ونخطئهما في غير حكم وكذا الخلاف إن زاد سوطا نخطإ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكم بشهادته غير أهل وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين الأصح أنهم يتعاقلون لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين والثانية لا لأن حمل العاقلة يثبت على خلاف الأصل لحرمة قرابة المسلمين فلا يقاس عليهم غيرهم لعدم المساواة في الحرمة فإن اختلفت الملة كاليهود والنصارى فوجهان وفي الترغيب روايتان بناء على توريثهم وعدمه ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي لعدم التوارث وكمسلم وكافر وقيل بلى إن توارثا وقال ابن حمدان يعقل المعاهد إن بقي عهده إلى أصل الواجب وإلا فلا

تذنيب المرتد لا يعقل عنه لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون ولا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة فتكون جنايته في ماله وفيه وجه ومن لا عاقلة له

[ج ٩ - ص ١٨]

أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا وإن كان مسلما أخذ من بيت المال فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل ويحتمل أن تجب في مال القاتل [ج ٩ - ص ١٩]

وهو أولى كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله ولو رمي وهو مسلم فلم يصب السهم حتى أرتد كان عليه في ماله ولو رمي الكافر سهاما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله ولو جنى ابن المعتقة ثم أنجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة فكذا وهذا

فصل

ولا تحمل العاقلة عمدا [ج ٩ - ص ٢٠]

لا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث [ج ٩ - ص ٢١]

كأرش الموضحة نص على ذلك لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف فكان عليه كسائر المتلفات لكن خولف في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى على الأصل والثلث حد الكثير للخبر ويكون ذلك أي دية العمد وما بعده في مال الجاني لما ذكرنا أن مقتضى الأصل وجوب الجناية على الجاني حالا لأنه بدل متلف فكان حالا كقيمة المتلف من المتاع إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه نص عليه لأن ديتهما وجبت في حال واحدة بجناية واحدة مع زيادتها على الثلث وظاهره سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به لأن الجناية واحدة وإنما تأخر بعض أثرها عن بعض وذلك لا يضر وقال أحمد هذا من قبل أنها نفس واحدة وقال الجناية عليهما واحدة فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما فلم يجب بشيء وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها قال فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فإسقطت جنينا فالدية على العاقلة قال في الفروع فيتوجه منه احتمال تحمل القليل وقد يقال هذا مختص بالجنين لكونه ديته دية نفس فيكون منزلا منزلة الدية الكاملة و إن كان دون الثلث لكونه دية نفس وإن ماتا منفردين بجنايتين صرح به في الوجيز لم تحملها العاقلة نص عليه

لنقصها عن الثلث لأن الواجب في ذلك غرة قيمتها خمس من الإبل وهي دون ثلث الدية وتحمل جناية الخطإ على الحر إذا بلغت [ج ٩ - ص ٢٢]

الثلث لحديث أبي هريرة و في تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون الثلث وقال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد هذا رواية وصححه ابن حمدان وقاله ابن شبرمة والزهري وقتادة لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض وهي دية مغلظة أشبهت دية العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين قال في الشرح ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة روي عن عمر وعلي وابن عباس وقال أبو بكر مرة هو في مال الجاني حالا وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات واقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها وقال الخرقي تحمله العاقلة هذا ظاهر المذهب في ثلاث سنين نص عليه قدمه في الكافي لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث لأنه لا يوجب قصاصا كالخطء وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني وقيل حالا قدمه في التبصرة والرعاية كغيره وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين وفي الروضة دية الخطإ في خمس سنين في كل سنة خمسها وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لأن التقدير من الشرع ولم يرد به ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لأنه لا نص فيه فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم كتقدير النفقات فيحمل كل إنسان منهم ما

بسهل ولا يشق نص عليه لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا [ج ٩ - ص ٢٣]

يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة ولأن الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به فإذا لم يشرع في حقه فغيره أولى وقال أبو بكر يجعل على الموسر وهو مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار نصف دينار لأنه أقل ما يتقدر في الزكاة وعلى المتوسط ربعا قوله رواية عن أحمد لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع اليد فيه وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا على وجهين كذا في المحرر والفروع أحدهما يتكرر لأنه حق يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بتكرار الحول كالزكاة والثاني لا لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا فعلى الأول يجب على الموسر دينار ونصف وعلى المتوسط ثلاثة أرباع لتكرره وعلى الثاني نصف على الموسر وربع على المتوسط لأنه لا يتكرر ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالميراث سواء فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم الأقرب فالأقرب ويقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب في الأشهر كالميراث وفي الآخر سواء لأنه لا يستفاد بالتعصيب وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأبوين روايتين وخرج منها مساواة بعيد لقريب ويؤخذ من بعيد لغيبة قريب وقيل يكتب الإمام إلى قاضي بلد الأقرب الغائب ليطالبه بها وإلا أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها انتقل إلى من يليهم لأن الأقربين لم يكونوا موجودين فعلقت الدية بمن يليهم وكذا إذا تحمل

الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم نص عليه لأنهم استووا في [ج ٩ - ص ٢٤]

القرابة فكانوا سواء كما لو قتلوا وكالميراث وقال ابن حمدان ويحتمل أن يأخذ الإمام ممن شاء

فصل

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين لا خلاف في وجوب دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين لقول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف إن كان دية كاملة لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة وحينئذ يجب في آخر كل حول ثلثها ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول أي في آخر السنة الأولى ولم يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب وباقية في رأس الحول الثاني لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة وإن كان دية امرأة أو كتابي لم يقتل عمدا قاله في الوجيز وفيه شيء فكذلك لأن هذا ينقص عن دية كاملة أشبهت أرش الطرف ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لأن ذلك دية نفس كاملة أشبه دية المسلم وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث وكذا إذا قتلت المرأة وجنينها بضربة [ج ٩ - ص ٢٥]

بعد ما استهل لم تزد في كل حول على قدر الثلث وقال القاضي وأصحابه دية نفس في ثلاث سنين وقيل الكل فلو قتل اثنين فديتهما في ثلاث لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه وقيل في ست سنين فأما إذا كان الواجب دون الثلث كدية الاصبع لم تحملها العاقلة ويجب حالا لأنها بدل متلف وابتداء الحول في الجرح من الاندمال لأن الأرش لا يستقر إلا بالبرء وفي القتل من حين الموت لأنه حالة الوجوب سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع لأن تلك حالة الوجوب ولهذا لو قطع يده وهو ذمي فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية ذمي وحاصله أن عنده أن ابتداءه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية وقيل في الكل عند الترافع إلى الحاكم ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقط ما عليه بغير خلاف نعلمه لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة أشبه الزكاة وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين ولأنه وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة وعمد الصبي والمجنون خطأ نص عليه في رواية ابن منصور لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد فوجب أن يكون كخطإ البالغ تحمله العاقلة لأنه لا يوجب القود فحملته كغيره وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله لأنه عمد يجوز تأديبه عليه أشبه البالغ العاقل والمراد به المميز لكن قال ابن [ج ٩ - ص ٢٦]

عقيل والحلواني تجب مغلظة وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر سنين ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة فهذا رواية لا تحمل الثلث والأول أولى وما ذكروه ينتقض بشبه العمد

باب كفارة القتل

الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ النساء 97 فذكر في الآية ثلاث كفارات

إحداهن يقتل المسلم في دار الاسلام خطأ

الثاني يقتل في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه بقوله ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ الثالث يقتل المعاهد وهو الذمي في دار الإسلام لقوله عز وجل ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ النساء 92 فأوجب الكفارة بالقتل في الجملة وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا ومن قتل نفسا محرمة خطأ للأية الكريمة سواء قتلها بمباشرة أو بسبب بعد موته نص عليه بغير حق ولو مستأمنا وظاهره ولو قتل نفسه أو ما أجرى مجراه لأنه أجري مجراه في [ج ٩ - ص ٢٧]

عدم القصاص فكذا يجب أن يجري مجراه في الكفارة أو شارك فيها أي على كل واحد من المشتركين كفارة في قول الأكثر لأن الكفارة موجب قتل الآدمي فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء كالقصاص أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة لأنه قتل نفسا محرمة أشبه قتل الآدمي بالمباشرة وفي الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة وقيل تتعدد قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه والمذهب أنه لابد من إلقاء جنين كامل لأنه قتل نفسا بغير حق فكان فيه الكفارة كالمولود وقيل تجب ولو بإلقاء مضغة لم تتصور مسلما كان المقتول أو كافرا لأن الكافر آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم حرا أو عبدا في قول أكثرهم لعموم قوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ ولأنه يجب بقتله القصاص في الجملة فوجب بقتله الكفارة كالحر ولأنه مؤمن أشبه الحر وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب وكفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول بدليل إحبالهما وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود وعنه لا تجب عليه نقلها بكر بن محمد وزاد أبو حنيفة عليه الصبي والمجنون لأنها عبادة محضة تجب بالشرع فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة [ج ٩ - ص ٢٨]

اليمين وجوابه ما سبق ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له وعنه على المشتركين كفارة واحدة لعموم قوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ الآية و من تتناول الواحد والجماعة ولأن الدية لا تتعدد فكذا الكفارة ولأنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي فأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به والخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه وقيل ليس بمحرم لأن المحرم ما أثم فاعله والاستثناء في الآية منقطع وإلا في موضع لكن وقيل في موضع لا أي ولا خطأ وهو بعيد لأن الخطأ لا يتوجه إليه النهي لعدم إمكان التحرز منه

فصل

لا تلزم قاتلا حربيا قاله في الترغيب وغيره ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة قال الخطابي من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء وجوابه بأنه لا أيمان لهم ولا أمان وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقاء وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان إحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي والأخرى فيه الكفارة أما العمد فالمشهور في المذهب أنه لا كفارة فيه [ج ٩ - ص ٢٩]

قدمه في الكافي ونصره في الشرح لمفهوم قوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ واحتج جماعة بقوله تعالى ﴿ فجزاؤه جهنم ﴾ النساء 93 فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن زاد في عيون المسائل وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ولا فرق في العمد الموجب للقصاص و غيره والثانية تجب اختاره الخرقي وأبو محمد الجوزي لما روى واثلة بن الاسقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب القتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أبو داود بإسناد ضعيف ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فلأن تجب في العمد بطريق الأولى والأولى أصح لأنه يقال ذكر قتل الخطأ وأوجب فيه الكفارة ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كفارة فيه مع أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ وسماه موجبا لأنه فوت النفس بالقتل ويحتمل أنه كان شبه عمد ويحتمل أنه أمرهم تبرعا وأما شبه العمد فالأصح أنها تجب به في الكافي والمستوعب وغيرهما وفي المغني تجب فيه الكفارة ولا أعلم لأصحابنا فيه قولا لأنه أجري مجرى الخطإ في نفس القصاص وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في ثلاث سنين فجرى مجراه في وجوب الكفارة والثانية لا تجب وبعدها ابن المنجا واختارها أبو بكر لأن ديته مغلظة

تذنيب من لزمته ففي ماله وقيل ما حمله بيت المال من خطإ أمام

[ج ٩ - ص ٣٠]

وحاكم ففيه ويكفر عن غير مكلف وليه نقل مهنا القتل له كفارة وكذا الزنى ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنى

باب القسامة

القسامة اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة هي الحلف قال الأزهرى هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضى وإنما هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل أي في دعوى قتل معصوم وظاهر الخرقي موجب للقود والأصل فيها ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود به فجاءه أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال كبر كبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الجماعة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم قال ابن قتيبة

في المعارف أول من 2 قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولا [ج ٩ - ص ٣١]

تثبت إلا بشروط أربعة

أحدها دعوى القتل عمدا كان أو خطأ نص عليه في رواية حنبل لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك وقيل لا قسامة في خطإ ذكرا كان المقتول أو أنثى للخبر السابق ولأن القصاص يجري فيها فشرعت القسامة فيها كذلك حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ولأن العبد والذمي يوجب القصاص في المماثل له فأوجب القسامة في ذلك كالحر والمسلم أما المقتول إذا كان حرا مسلما فلا خلاف فيه سواء كان المدعي عليه مسلما أو كافرا لقضية عبد الله ابن سهل والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن وإن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فظاهر الخرقي لا تجب القسامة وحكاه في الفروع قولا لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود وكقتل البهيمة وقال القاضي وهو ظاهر المتن وكلام الأكثر تشرع لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ولأن ما كان حجة في قتل المسلم الحر كان حجة في قتل العبد والذمي وأما الجراح فلا قسامة فيه لا نعلم فيه خلافا لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة وكالأطراف نص عليه والدعوى فيه كالدعوى في سائر الحقوق البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة لأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلظ بالعدد كالدعوى في المال

الثاني اللوث وهو العداوة الظاهرة ولو مع سيد عبد قال في الرعاية وعصبة مقتول كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر [ج ٩ - ص ٣٢]

الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب وكما بين البغاة وأهل العدل وبين الشرطة واللصوص على الأشهر لأن مقتضي الدليل أن لا تشرع القسامة ترك العمل به في العداوة الظاهرة ونقل علي بن سعيد أو عصبية للخبر وظاهره أنه لا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو نص عليه وهو ظاهر الخرقي ونصره المؤلف لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم وشرطه القاضي لأن الأنصاري قتل في خيبر ولم يكن بها إلا اليهود وهم أعداء ثم ناقض قوله بأن قال في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث فجعل العداوة لوثا مع وجود غير العدو وعنه ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ويعتبر مجيئهم متفرقين لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب ونحو ذلك كشهادة عدل واحد اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي الدين لأنه يغلب على الظن صدق المدعي أشبهت العداوة ورد بأن هذا ليس بلوث لقوله في الذي قتل في الزحام يوم الجمعة ديته في بيت المال وقال فيمن وجد مقتولا في المسجد الحرام ينظر من كان بينه

وبينه في حياته عداوة لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة لقضية الأنصاري ولا يجوز القياس عليها لأن الحكم يثبت [ج ٩ - ص ٣٣]

بالمظنة ولا يقاس في المظان لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون

فرع إذا شهدا أنه قتل أحد هذين القتيلين لم تثبت الشهادة ولم يكن لوثا بغير خلاف علمناه وإن شهدا أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين لم تكمل الشهادة ولم يكن لوثا اختاره القاضي لكن المنصوص أنه إذا شهد أحدهما بقتله والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل واختاره أبو بكر هنا وفيما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين لأنهما اتفقا على القتل واختلفا في صيغته فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث في قول أكثرهم لقوله عليه السلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر وكالولي وقال هو لوث لأن قتيل بني اسرائيل قال فلان قتلني فكان حجة وجوابه أنه لا قسامة فيه فإن ذلك كان من آيات الله تعالى ومعجزات نبيه موسى عليه السلام ثم ذاك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين لكن نقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان سبب بين إذا كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعي عليه يفعل ذلك

تنبيه إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على رجل أو جماعة وليس بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوي وإن كان لهم بينة حكم بها

وإلا قبل قول المنكر وقال الحنفية إذا ادعى أولياؤه قتله على أهل المحلة أو على معين فللولي أن يختار من الموضع خمسين رجلا يحلفون خمسين يمينا

[ج ٩ - ص ٣٤]

والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله فإن نقصوا عن الخمسين كررت الأيمان عليهم حتى تتم فإن حلفوا وجبت الدية على باني الخطة فإن لم يكن وجبت على سكان الموضع فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا لأثر عن عمر على أنه محتمل قال ابن المنذر سن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وسن القسامة في القتيل الذي وجد بخيبر وعلم مما سبق أنه لا تسمع الدعوى على غير معين كسائر الدعاوي وأنه لا يشترط أن يكون بالقتيل أثر في قول الجماعة لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كغم الوجه وعنه يشترط ذلك اختاره أبو بكر لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه فعلى هذه إن خرج دم من أذنه فهو لوث وكذا إن خرج من أنفه في وجه وقيل أو شفته وجوابه ما تقدم ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها هذا رواية قال في الفروع وهي أشهر سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله أشبه الحدود ولا يحكم له بالقسامة لأن من شرطها المرتب عليها القتل أو الدية وجود اللوث وهو منتف هنا وعن أحمد يحلف يمينا واحدة قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وكدعوى المال وهي الأولى والأصح فعلى هذه إن حلف المدعى عليه فظاهر وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية وقيل لا

يجب ويخلى سبيله وعنه يحلف خمسين يمينا لأنه دعوى في قتل أشبه ما لو كان بينهم لوث وإن كان خطأ [ج ٩ - ص ٣٥]

حلف يمينا واحدة لأن النكول هنا يقضى به لأن موجبه مال بخلاف القصاص

الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى لأنها دعوى قتل فاشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض بأن قال قتله هذا أو قال الآخر لم يقتله هذا أو قال بل قتله هذا الآخر لم تثبت القسامة نص عليه سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه بقتل كما لو ادعيا دينا لهما

الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء لقوله عليه السلام يقسم خمسون رجلا منكم ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة ويستثنى منه المرتد وقت موت مورثه الحر لعدم إرثه ولو اسلم بل بعد موته ولا مدخل للنساء في القسامة أي لم يستحلفن لما ذكرناه ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل لهن في إثباته وقال ابن عقيل تقسم في الخطإ فلو كان جميع الذرية نساء فاحتمالان وفي الخنثى وجهان

أحدهما يقسم لأن سبب الاستحقاق وجد في حقه وهو الاستحقاق من الدية ولم يتحقق المانع من يمينه

والثاني لا يقسم كالمرأة والصبيان والمجانين في القسامة لأن قولهما ليس بحجة بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل فكذا لا يقبل قولهما في حق

غيرهما بطريق الأولى عمدا كان القتل أو خطأ لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرتها وأقام رجلا وامرأتين انه لا يقبل فإن كانا اثنين أو أكثر

[ج ٩ - ص ٣٦]

أحدهما غائب أو غير ملكف أو ناكل عن اليمين قاله في المحرر والوجيز فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه كالمال المشترك بينهما وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين كذا في المحرر والفروع أحدهما يحلف خمسين لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هنا هي الأيمان بدليل ما لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما

الثاني يحلف بقسطه جزم به في الوجيز وهو أشهر لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع لكن لا قسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصبي لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة وهي الأيمان هنا ولأن الحق إن كان قصاصا فلا يمكن تبعيضه وغيره لا يثبت إلا بواسطة ثبوت القتل وقال القاضي إن كان القتل عمدا فكذلك وإن كان موجبا للمال فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية وهذا قول أبي بكر وابن حامد ونصره المؤلف وغيره وقال ابن حامد يقسم بقسطه من الأيمان لأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية كما لو كان الجميع حاضرين وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وجها واحدا وله بقيتها لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة وقال أبو بكر والقاضي يحلف خمسين كصاحبه فكذا هو فلو قدم ثالث أو بلغ فعلى قولهما يحلف سبع عشرة يمينا وعلى الآخر خمسين وإذا قدم رابع فهل

يحلف ثلاثة عشر يمينا أو خمسين فيه الخلاف والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر لأن ذلك [ج ٩ - ص ٣٧]

موجب أيمانه وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا لأن اللوث من شروطها وفاقا ولا يتحقق إلا في العمد لأن الخطأ يصدر عن غير قصد فيستوى فيه العدو وغيره وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة توجب القصاص إذا ثبت القتل لأن الغرض من القسامة في العمد القصاص فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم بالكافر لم يوجد الغرض وأن تكون الدعوى على واحد لا يختلف المذهب فيه لقوله عليه السلام فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل من قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه ويشترط في القاتل أن يكون مكلفا لتصح الدعوى وإمكان القتل وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة وقال غيره ليس بشرط لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه لخبر سهل وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية لأنها حجة يثبت بها العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره وهو المال كالبينة

فصل

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين أي ذكور العصبة العدول أولا نص عليه لقوله عليه السلام فيحلف خمسون منكم فيحلفون خمسين يمينا

[ج ۹ - ص ۳۸]

أيمان القسامة خمسون بالإجماع على المدعى عليه أنه قتله فإذا حلف ثبت الحق في قبله لحديث سهل ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الداقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وذكر أنه روى مرسلا وروى أيضا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة مرفوعا كذلك وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين كاللعان وظاهره أنه لا يشترط اتفاق المجلس من جميعهم وفيه قول حكاه في الرعاية ويختص ذلك بالوارث في ظاهر المذهب لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير الوارث كسائر الأيمان فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم أي تقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة فإن كان الوارث واحدا حلفها لأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية فكذا في الأيمان ونقل الميموني لا أجترىء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون فمن احتج للأول يحتج بحديث معاوية فرددها على الثلاثة الذين ادعي عليهم فحلفوا خمسين يمينا وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك فكذا يجب أن تقسم هي فإن كانوا أكثر من خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن

تبعيضها والخبر في كل واحد لعدم المزية فالزوج له الربع اثنى عشر ونصفا

[ج ٩ - ص ٣٩]

فيكمل والابن له الباقي وهو سبع وثلاثون ونصفا فيكمل فيصير كما ذكره فيهما فإن كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينا والابن أربعا وثلاثين ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا لأن لكل ابن ثلث الأيمان ست عشرة يمينا وثلثين ثم تكمل وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا لقوله عليه السلام يحلف خمسون منكم مع علمه أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلا وارثا لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا ولأنه خاطب ابني عمه وهما غير وارثين لكن يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه فإن لم يبلغوا يؤخذ الأقرب فالأقرب من قبيلته التي ينسب اليها ويعرف لنفسه نسبه من المقتول فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يقسم ذكره جماعة وسأله الميموني إن لم يكن له أولياء قال فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه فرع إذا مات المستحق فوارثه كهو ويستأنف وارثه الأيمان سواء حلف قبل موته شيئا أو لا لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا بيمين غيره ولو حلف المستحق بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم فإنه يبني فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء في ظاهر المذهب وهو قول الأكثر لقوله عليه السلام فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم أي يبرؤون منكم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وأنه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فتبرأ بها كسائر الأيمان وعنه أنهم يحلفون [ج ٩ - ص ٤٠]

ويغرمون الدية لقضاء عمر بالدية مع اليمين والأول أولى لأن عمر إنما قضى على أهل المحلة وليس ذلك مذهبا لأحمد ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة وحضور المدعي ذكره المؤلف وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال أي أدى ديته من بيت المال لقضية عبد الله بن سهل ولم يجب على المدعى عليهم شيء وإن طلبوا أيمانهم أي أيمان المدعى عليهم فنكلوا لم يحبسوا في الأشهر لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليه كسائر الأيمان وعنه يحبس حتى يقرأ أو يحلف لأنها دعوى فيحبس فيها بالنكول كالمال وعلى الأولى لا يجب قود بنكول لأنه حجة ضعيفة كشاهد ويمين ذكره في المغني وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين أظهرهما تلزمه الدية اختارها أبو بكر وقدمها في الرعاية وهو الصحيح لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم كسائر الدعاوي ولو لم يجب على المدعي عليه مال بنكوله ولم يجبر على اليمين لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية والثانية في بيت المال لأنهم امتنعوا عن اليمين أشبه امتناع المدعيين إذا لم يرضوا بيمين المدعي عليه

فائدة يقول تالله وبالله ووالله بالجر فإن قاله مضموما أو منصوبا فقد لحن قال القاضي ويجزئه إن تعمد أو لم يتعمد لأنه لحن لا يحيل المعنى ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا فرع سأله ابن

منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروذي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب [ج ٩ - ص ٤١]

إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به وعن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما رواه أحمد في مسنده [ج ٩ - ص ٤٢]

كتاب الحدود

وهي جمع حد وهو المنع وحدود الله تعالى محارمه لقوله تعالى ﴿ تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ البقرة 187 وهي ما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى كتزويج الأربع ونحوه وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان والحدود العقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب وأن تكون سميت الحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله

لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق فعليه الحد بغير خلاف نعلمه لكن لو أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة به ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد للإحتمال ولا يجب على نائم ولا نائمة عالم بالتحريم لعموم النصوص وقاله الأئمة سواء جهل تحريم الزنى أو تحريم عين المرأة زاد في الوجيز ملتزم وهو مراد ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن معه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله في

خلقه ولأنه عليه السلام كان يقيم الحدود في حياته وخلفاؤه من بعده واختار الشيخ تقي الدين إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله وعلى الأول لو أقامه غيره لم يضمنه نص عليه لكنه تعدى على الإمام وذلك لا يوجب ضمانا كالمرتد ولا يلزم الإمام حضور إقامته لقوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولغيره فرع من اقام على نفسه ما لزمه من حد زنى أو قذف بإذن إمام أو نائبه لم يسقط عنه قاله ابن حمدان إلا السيد الحر المكلف العالم فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن أي الكامل رقه في قول عامتهم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها متفق عليه وعن علي مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني ولأن للسيد تأديب أمته بتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان وبهذا فارق الصبي وعنه ليس له ذلك لأنه يفتقر إلى اجتهاد فلم يملكه كالقطع وحد الحر وعلى الأول له سماع بينة تقتضي العقوبة والعمل بها إن عرف شروطها وإلا سمعها الحاكم أو سيده بإذنه وقيل لا يسمعها غير حاكم قدمه في الكافي والشرح وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين

إحداهما لا يملكه قدمه في الكافي ونصره في الشرح وذكر أنه قول أكثر أهل العلم لأنه عليه السلام إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن في

الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما والثانية له ذلك لأن عمر قطع [ج ٩ - ص ٤٤]

عبدا له سرق وحفصة قتلت أمة لها سحرتها ولا يملك إقامته على مكاتبه قطع به في المغني والوجيز والآدمي وابن عبدوس وغيرهم لأنه معه كالأجنبي وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد ولا من بعضه حر لأنه ليس له ولاية على كله والحد تصرف في الكل ولا أمته المزوجة نص عليه لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة لأنه لم يكمل أشبه من بعضه حر وفيها وجه صححه الحلواني ونقل مهنا إن كانت ثيبا ونقل ابن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وإنه لا يبيعها حتى تحد ويخرج في مرهونة ومستأجرة وجهان وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ومكاتبة أصلا كمزوجة وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب والمرأة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل ولأن فاطمة جلدت أمة لها وعائشة قطعت أمة لها سرقت ويحتمل ألا يملكه لأنها ولاية وليسا من أهلها فعلى هذا يختص بالذكر العدل وقيل يقيمه ولي امرأة وهل للوصي حد رقيق موليه فيه وجهان ولا يملكه المكاتب صححه في المستوعب وغيره لأنه ليس من أهل الولاية وملكه على عبده ناقص بدليل أنه لا تجب عليه الزكاة ويحتمل أن يملكه لأنه يستفاد بالملك أشبه تصرفاته وسواء ثبت ببينة أو إقرار إن كان يعلم شروطه لأن كل واحد منهما حجة في ثبوته فوجب ألا يختلف حال السيد فيه فعلى هذا للسيد أن يسمع إقراره ويقيم الحد عليه ويقدم سماع البينة وإن ثبت بعلمه فله [ج ٩ - ص ٤٥]

إقامته نص عليه لأنه قد ثبت عنده فملك إقامته كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه بعلمه فكذا هنا ويحتمل ألا يملكه كالإمام هذا رواية واختارها القاضي لأن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها فإذا لم يثبت الحد بالعلم فها هنا أولى ولأن الحاكم متهم ولا يقيم الإمام الحد بعلمه لقوله تعالى ﴿ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ ثم قال ﴿ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ النور 13 ولأنه متهم في حكمه بعلمه وذلك شبهة يدرأ بها الحد

مسألة نقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في رابعة قال الشيخ تقي الدين إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي ألا تجب عليه إقامته بل يتخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما تخير الشهود على إقامة الحد عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح عنده أنه يتوب ستروه وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام ولا تقام الحدود في المساجد جلدا كان أو غيره لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد روي أن عمر أتى برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد واضربوه وعن علي أنه أتى بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه وفي المذهب ينبغي تنزيه المسجد عنه وروي عن الشعبي أنه أقام

الحد على ذمي في المسجد ويضرب الرجل في الحد قائما في الأشهر وقاله علي ونصره المؤلف لأن قيامه وسيلة [ج ٩ - ص ٤٦]

إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ونقل حنبل قاعدا لأنه أستر له بسوط قال في شرح المذهب للحنفية السوط فوق القضيب ودون العصا وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له فتعين أن يكون من غير الجلد لا جديد ولا خلق نص عليه بفتح اللام وهو البالي لخبر رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا وروي عن علي ولأن الغرض الإيلام دون الجرح إذ الجديد يجرح والبالي لا يؤلم فلو كان السوط مغصوبا أجزأ على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد ولا يمد نص عليه لأنه محدث ولا يربط ولا يجرد لأنه لم ينقل قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه القميص والقميصان صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه نقل أبو الحارث والفضل عليه ثيابه وعنه يجوز تجريده لأنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله والمبالغة تؤدي إلى ذلك ويفرق الضرب على أعضائه لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل وأوجبه القاضي ولا يبدي إبطه في رفع يده نص عليه إلا الرأس والوجه لقول علي للجلاد أضرب وأوجع واتق الرأس والوجه ولأنهما أجمل ما في الإنسان وفي إصابة الضرب لهما خطر لأنه ربما عمي أو ذهب عقله أو قتله والفرج

وموضع المقتل لأن ضرب ذلك يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه ويكثر منه في مواضع اللحم [ج ٩ - ص ٤٧]

كالإليتين والفخذين ولا تعتبر الموالاة في الحد ذكره القاضي وغيره في موالاة العضو لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة قال الشيخ تقي الدين فيه نظر ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه بدليل أن الإمام لو أمر عبدا عجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية في اعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود والمرأة كذلك أي المرأة كالرجل فيما ذكرنا عملا بالأصل السالم عن المعارض إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليهما وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها وهو مطلوب في نظر الشرع بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب نص عليه ثم التعزير قال مالك كلها واحد لأن المقصود بها الزجر فيجب تساويها في الصفة وقال أبو حنيفة أشدها التعزير ثم الزنى ثم شرب الخمر ثم القذف قال في الكشاف لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا بمن هتكها وجوابه أن الله خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله تعالى ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ النور 2 ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي وحد

الشرب محض حق الله والتعزير لا يبلغ به الحد وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا [ج ٩ - ص ٤٨]

هو أربعون جلدة ثم حد القذف وإن رأى الإمام أو نائبه الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك لأنه عليه السلام أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب وفي المذهب والبلغة وأيد للخبر وفي الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزىء بيد وطرف ثوب وفي التبصرة لا يجزىء بطرف ثوب ونعل ويؤخر سكران حتى يصحو نص عليه فلو خالف وفعل احتمل السقوط وهو أولى واحتمل عدمه فرع يحرم حبسه بعد حد نص عليه وأذاه بكلام كاتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض وقاله في الوجيز وزاد والضعف لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما وكذا إن كان جلدا عند أكثر الأصحاب وقاله إسحاق وأبو ثور لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ولأن الحد واجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة وقال القاضي ظاهر قول الخرقي له تأخيره وهو قول الأكثر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ومرض قدامة يحتمل أنه كان خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله وكذا الحكم في تأخيره لحر أو برد

مفرط فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط لم يتعين على الأصح أقيم بأطراف الثياب والعثكول لما روى أبو أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا شمراخا فيضربوه بها ضربة رواه أحمد وابن ماجة ورواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار ورواه سعيد عن سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد سمعا أبا أمامة مرسلا قال ابن المنذر في إسناده مقال ولأنه لا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة ولا جلده تاما لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرنا ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله لأن في تأخيره استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارق المريض الذي لا يرجى زواله لأنه يخاف فوات الحد فرع ذكر الخرقي أن العبد يضرب بدون سوط الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف سوطا والظاهر التسوية بينهما فيه لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ النساء 25 ولا يتحقق التنصيف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي الشريطين وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر نص عليه أو تأديب أو تعزير ولم يلزم تأخيره فالحق قتله ولا ضمان على أحد جلدا كان أو غيره لأنه حد وجب لله تعالى فلم يجب فيه شيء كالقطع في السرقة وهذا إذا أتى به على الوجه المشروع من غير زيادة لأنه نائب عن الله تعالى فكان التلف منسوبا إليه وقيل يضمن المؤدب وإن

زاد سوطا أو في السوط أو أكثر فتلف ضمنه بغير خلاف نعلمه لأنه تلف بعدوانه أشبه [ج ٩ - ص ٥٠]

ما لو ضربه في غير الحد وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين

أحدهما وهو رواية أنه تجب الدية كلها ذكر القاضي في الخلاف أنه أشبه بالمذهب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله وكما لو ضربه بسوط لا يحتمله

والثاني نصف الدية وقاله الأكثر لأنه تلف بفعل مضمون وغيره فوجب نصفها كما لو جرح نفسه أو جرحه غيره فمات وسواء زاد خطأ أو عمدا لأنه يضمن كالعمد وكذا إن قال له الإمام اضرب ما شئت وقيل ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كذا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فقرقها بهما في أقوى الوجهين والثاني بالقفيز وكذا الشبع والري والسير بالدابة فراسخ والسكر بالقدح أو الأقداح كما ينشىء الغضب بكلمة بعد أخرى ويمتلىء الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد فرع إذا أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر وإلا فوجهان وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة وقيل نخطأ فيه الروايتان وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين نص عليه لأنه عليه السلام لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا رواه أحمد [ج ٩ - ص ٥١]

ومسلم والمرأة كذلك نصره في المغني وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر اختاره في الهداية والفصول والتبصرة وصححه أبو الخطاب لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر رواه أبو داود ولأن الحفر أستر لها ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب بخلاف من أقرت لأن رجوعها عن الإقرار مقبول والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولا وأطلق في عيون المسائل وابن رزين يحفر لها فهو ستر بخلاف الرجل وإذا ثبت ذلك شد عليها ثيابها لئلا تنكشف لأمره عليه السلام بذلك رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم أي إذا ثبت بها ويجب حضور الإمام أو نائبه وقال أبو بكر عن قول ماعز ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني يدل على أنه عليه السلام لم يحضر رجمه فبهذا أقول وحضور طائفة ولو واحدا ذكره أصحابنا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة وهو منقطع واختار في البلغة اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان نقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة لقوله تعالى ﴿ وليشهد عذابهما طائفة ﴾ لأنه أول شهود الزنى وأن ثبت بإقرار استحب أن يبدأ الإمام به أو من يقيمه ومتى رجع المقر بالحد

أي بحد الزنى أو سرقة أو شرب عن إقراره قبل منه أي يشترط لإقامة الحد بالإقرار البقاء عليه [ج ٩ - ص ٥٢]

إلى تمام الحد فإن رجع قبله كف عنه وهو قول أكثر العلماء قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب وقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولأن رجوعه شبهة وكالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد عليه وقيل يقبل رجوعه في الزنى فقط وقيل يقبل رجوع مقر بمال وعلى الأول إذا تمم ضمن الراجع بالمال لا الهارب ولا قود للاختلاف في صحة الرجوع وكان شبهة وإن رجع في أثناء الحد لم يتم لأن جميعه يسقط بالرجوع فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى وإن رجم ببينة فهرب لم يترك لأنه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه أشبه سائر الأحكام وإن كان بإقرار ترك لقوله عليه السلام هلا تركتموه فإن لم يترك وقيل فلا ضمان لقصة ماعز ولأن بذلك ليس بصريح في رجوعه فإن قال ردوني إلى الحاكم وجب رده ولم يجز إتمام الحد فإن أتم فلا ضمان لما ذكر في هربه

مسائل إذا أتى حدا ستر نفسه نقل مهنا رجل زنى يذهب يقر قال بل يستر نفسه واستحب القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه وقال ابن حامد إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر وإن قال لإمام أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه نقله الأثرم ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سمنه كذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت

بعد بعثه وعوقب ذكره في الفنون فالحد كفارة لذلك الذنب للخبر نص عليه

[ج ٩ - ص ٥٣]

فصل

وإذا اجتمعت حدود الله تعالى فيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها قال في المغني لا يشرع غيره لقول ابن مسعود رواه سعيد من رواية مجالد وقد ضعفه الأكثر ولم نعرف له في الصحابة مخالفا وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله ولأن هذه الحدود لمجرد الزجر وقتله بخلاف القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه قال ابن المنذر أجمع عليه كل من نحفظ عنه قال أحمد يقام عليه الحد مرة لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد لأن الواجب هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات وذكر ابن عقيل رواية لا تداخل في السرقة وفي البلغة يقطع واحد على الأصح وفي المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد قال أبو بكر العمل على خلافها ثم قال شيخنا قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام وعلى ذلك نص الأئمة قال أحمد في لحم خنزير ميت فأثبت فيه تحريمين وإن كانت من أجناس استوفيت كلها بغير خلاف علمناه لأن التداخل إنما هو في الجنس الواحد فلو سرق وأخذ المال في المحاربة قطع لذلك ويدخل فيه القطع في السرقة لأن محل القطعين واحد ويبدأ بالأخف فالأخف [ج ٩ - ص ٥٤]

وجوبا قاله في الفروع فعلى هذا يبدأ بالحد للشرب ثم للسرقة ثم للزنى لأن الأول أخف ولا يوالي بين هذه الحدود لأنه ربما يقضي إلى التلف وفي المغني والشرح إنه على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن لأنها حقوق آدميين أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم لا يقال يكتفى بالقتل في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على السهولة بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق ويبدأ بغير القتل لأن البداءة به تفوت استيفاء باقي الحقوق وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بديء بها أي إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدميين فهي أنواع

أحدها ألا يكون فيها قتل فهذه تستوفى كلها في قول الأكثر فيبدأ بحد القذف إلا إذا قلنا حد الشرب أربعون فإنه يبدأ به لخفته ثم حد القذف وأيهما قدم فالآخر يليه ثم الزنى ثم القطع وقال أبو الخطا يبدأ بالقطع قصاصا ثم بالقذف ثم للشرب ثم للزنى

الثاني إذا كان فيها قتل فإنها تدخل حقوق الله تعالى في القتل سواء كان من حدود الله كالرجم في الزنى أو لحق الآدمي كالقصاص وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها وإن كان القتل حقا لله تعالى استوفيت الحقوق كلها متوالية لأنه لابد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير وإن كان

القتل حقا لآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني برءه من الأول لأن الموالاة بينهما يحتمل أن [ج ٩ - ص ٥٥]

تفوت نفسه قبل القصاص فيفوت حق الآدمي ولأن العفو جائز فيحتمل بتأخيره أن يعفو الولي فيحيى

الثالث أن يتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا قدم القصاص على الرجم في الزنى ويبدأ بالأسبق من القتل في المحاربة والقصاص لأن كلا منهما حق آدمي وإن سبق القصاص قتل قصاصا ولم يصلب كما لو مات ويجب لولي المقتول في المحاربة ديته وإن مات القاتل في المحاربة وجبت الدية في تركته وقدم القصاص على الحد المتمحض في القطع ولو تأخر سببه فإن عفا ولي الجناية استوفى الحد والقطع في المحاربة حد محض وليس بقصاص والقتل يتضمن القصاص ولهذا لو فات القتل في المحاربة وجبت الدية ولو فات القطع لم يجب له بدل فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا لأنه متمحض حق آدمي بدليل سقوطه بإسقاطه ثم حد للقذف لأنه مختلف في كونه لآدمي ثم للشرب لأنه أخف ثم للزنى لأنه أشد الحدود وفي المحرر والوجيز إذا اجتمع عليه قتلان بردة وقود وقطعان بسرقة وقود قطع وقتل لهما وقيل للقود خاصة وفي الشرح إذا سرق وقتل في المحربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله لئلا يؤدي إلى تلفه بتوالي الحدود عليه

فصل

ومن قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم أي حرم مكة المشرفة للنص وفي [ج ٩ - ص ٥٦]

التعليق وجه أن حرم المدينة كمكة لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا قال إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ثم لجأ إليه أي إلى الحرم لم يستوف منه فيه في ظاهر المذهب قال أبو بكر والعمل عليه وعنه يستوفى فيه كل شيء إلا القتل لقوله عليه السلام لا يسفك فيها دم ولا شك أن حرمة النفس أعظم فلا يقاس عليها غيرها وقال بعض الأئمة يستوفى منه الكل للعمومات ولأنه عليه السلام قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه أشبه الكلب العقور وجوابه قوله تعالى ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ آل عمران 97 أي فأمنوه لأنه خبر أريد به الأمر ولأنه عليه السلام حرم سفك الدم بها وقوله عليه السلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ما احتجو به من قتل ابن خطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي شريح وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته رواه أحمد وكذا إذا لجأ إليه حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه كحيوان صائل ذكره المؤلف ولكن لا يبايع ولا يشاري لقول ابن عباس وفي المستوعب والرعاية ولا يكلم نقله أبو طالب زاد في الروضة ولا يأكل ولا يشارب لأنه لو أطعم أو أووي لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق حتى يخرج فيقام عليه في قول ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم

يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاه أحمد نقله الأثرم وروي عن عمر وابن الزبير قال الزهري من قتل في الحل ثم دخل الحرم أخرج إلى الحل فيقتل فيه ومن قتل في الحرم قتل فيه وهذا هو السنة والآدمي حرمته عظيمة وإنما أبيح قتله لعارض أشبه الصائل من الحيوانات المباحة فإن الحرم لا يعصمها فلو استوفى من له الحق فيه أساء ولا شيء عليه فرع ذكر جماعة أن من أتى حدا ثم لجأ إلى داره فهو كالحرم وحينئذ لا يخرج منها بل يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه روى الأثرم عن ابن عباس أنه قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ﴾ الآية البقرة 191 فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم وفاتت المصالح التي لابد منها

تذنيب إذا قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط لقوله تعالى ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ﴾ قرىء بهما واستدلالهم بالخبر المشهور صححه ابن الجوزي في تفسيره وقاله الماوردي وذكر ابن الجوزي أن مجاهدا وغيره قالوا الآية محكمة وفي التمهيد أنها نسخت بقوله ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ التوبة 5 وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم [ج ٩ - ص ٥٨]

إلا به لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء ونص عليه الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك وذكر أبو بكر بن العربي لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع وذكر الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه ومن أتى حدا في الغزو وفي المغني و الشرح أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو لأنه ربما يحمله الغضب على أن يدخل والعياذ بالله في الكفر حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه وقاله الأوزاعي وإسحاق قال أحمد لا تقام الحدود بأرض العدو ونقل صالح وابن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع لما روى بشر بن أرطأة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك رواه أبو داود وغيره وهو إجماع الصحابة ولأنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم الآيات والأخبار فإن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز فإذا زال أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعارض

مسألة تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه لأنها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم وقد كتب عمر

رضى الله عنه إلى أبي عبيدة أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام بالثغور والله أعلم [ج ٩ - ص ٥٩]

باب حد الزنى

وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من أكبر الكبائر لقوله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ الإسراء 32 ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ الآية الفرقان 68 ولما روى ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك متفق عليه وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام لقوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ الآية النساء 15 والمراد الثيب لأن قوله ﴿ من نسائكم ﴾ إضافة زوجية لقوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ البقرة 226 ولا فائدة في الإضافة هنا إلا اعتبار الثيوبة وقد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى فأثبت الأغلظ للثيب والأخرى للبكر ثم نسخ بما رواه مسلم من حديث عبادة مرفوعا خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ونسخ القرآن بالسنة جائز ومن منع قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير وتبين له ويمكن أن يقال نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه قاله في المغني والشرح إذا زنى الحر المحصن وإنه لا يجب

الرجم إلا عليه باتفاق فحدة الرجم حتى يموت وهو قول عامتهم وحكاه

[ج ٩ - ص ٦٠]

ابن حزم إجماعا وقد ثبت أنه عليه السلام رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر وقد أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه لقول عمر كان فيما أنزل الله آية الرجم الخبر متفق عليه فإن قيل لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها قال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل عليه السلام إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طرق الوحي وأقلها قوله فحده الرجم حتى يموت أي يرجم بالحجارة وغيرها قال في اللغة ولتكن الحجارة متوسطة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على روايتين

إحداهما يجلد ثم يرجم قال ابن هبيرة هي أظهر وأثبت اختارها الخرقي والقاضي وجماعة قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب وجزم بها في الوجيز وهي قول ابن عباس وأبي بن كعب لقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني ﴾ الآية النور 2 ولهذا قال علي جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولحديث عبادة وهذا صريح فلا يترك إلا بمثله وله أن يوالي بين الجلد والرجم

والثانية ترجم فقط قدمه في المحرر والرعاية ونقله الأكثر واختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وهو وفاق وروي عن عمر وعثمان

لأنه عليه السلام رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال [ج ٩ - ص ٦١]

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بجلدها وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل وإن حديث ماعز بعده وليس فيه الجلد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه كالردة والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران أقول يشترط للإحصان شروط

أحدها الوطء في القبل ولابد من تغييب الحشفة في الفرج فلو وجد النكاح من غير وطء أو وطىء دون الفرج أو في الدبر لم يحصل ذلك لأنها لا تصير ثيبا ولا تخرج عن حد الإبكار

الثاني أن تكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ النساء 24 يعني المزوجات ولا خلاف أن وطء الزنى والشبهة لا يصير به الواطىء محصنا وأن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه

الثالث أن يكون صحيحا وهو قول أكثرهم

الرابع البلوغ والعقل في قول الجماهير فلو وطىء وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا لقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائة فاعتبر الثيوبة خاصة ولو كانت تحصل قبله لكان عليه الرجم قبل بلوغه وعقله وهو خلاف الإجماع

الخامس الحرية في قول الجميع إلا أبا ثور لقوله تعالى ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ النساء 25 والرجم لا يتنصف وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع وعلى كل حال فلابد أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء فيطأ الرجل البالغ العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهو قول عطاء [ج ٩ - ص ٦٢]

والحسن وابن سيرين وذكر القاضي أن أحمد نص أنه لا يحصل إحصان بوطئه في حيض وصوم وإحرام ونحوه وفي الارشاد وهو وجه وفي المحرر يحصن مراهق بالغة ومراهقة بالغا وذكره الشيخ تقي الدين رواية وفي الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة وجوابه أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما لأن ما كان معلقا على شروط لا يوجد بدونها ولا يثبت الاحصان بالوطء بملك اليمين وهو التسري ولا في نكاح فاسد خلافا لأبي ثور وهو مروي عن الليث والأوزاعي وجوابه أنه وطء في غير ملك أشبه وطء الشبهة ويثبت الإحصان للذميين لأن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما متفق عليه ولأن الجناية بالزنى استوت بين المسلم والذمي فوجب أن يستويا في الحد وكذا يثبت لمستأمنين وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين

إحداهما تحصنه ولا يشترط الإسلام قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح لحديث ابن عمر السابق المتفق عليه واقتصر عليه في الكافي

والثانية لا تحصنه لأن الإحصان من شرطه الحرية فكان من شرطه الإسلام كإحصان القذف وجوابه أنه لا يصح القياس بإحصان القذف لأن من شرطه العفة وليست شرطا هنا ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت احصانه ولا يرجم إذا زنى لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله والاحصان [ج ٩ - ص ٦٣]

لا يثبت إلا بحقيقة الوطء فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة ويثبت بقوله وطئتها أو جامعتها والأشهر أو دخلت بها فرع إذا زنى محصن ببكر فلكل حده نص عليه

وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ولا يجب غيره نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار لقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني ﴾ الآية النور 2 ولقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وذلك وإن كان عاما فيخرج منه الرقيق كما يأتي والمحصن لما سبق فيبقى ما عداه على مقتضاه ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن وانتشر ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع وغرب عاما في قول الجمهور إلى مسافة القصر لأن ما دون ذلك في حكم الحضر فإن عاد قبل الحول أعيد تغريبه ويبني على ما مضى ونقل الأثرم أنه لا يشترط مسافة القصر بل ينفى من عمله إلى عمل غيره وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى بلد آخر وظاهره أن المرأة تغرب إلى مسافة القصر لوجوبه كالدعوى وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لتقرب من أهلها فيحفظوها وعنه تغرب إلى مسافة قصر مع محرمها ومع تعذره إلى دونها ويخرج معها محرمها وجوبا إن تيسر لأنه سفر واجب أشبه سفر الحج والمراد إذا كان بادلا فإن أراد أجرة بذلت من مالها لأن ذلك من مؤنة سفرها أشبه المركوب والنفقة فإن تعذر [ج ٩ - ص ٦٤]

فمن بيت المال لأن فيه مصلحة أشبه نفقة نفسها وهذا قول ويقيد بما إذا أمكن فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة اختاره جماعة لأنه لابد من شخص يكون معها لأجل حفظها وحينئذ لم يكن بد من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ وأجرتها على الخلاف فإن تعذر نفيت بغير محرم قاله إمامنا والشافعي كسفر الهجرة والحج إذا مات المحرم في الطريق وفي الترغيب وغيره مع الأمن وعنه بلا محرم تعذر أو لا لأنه عقوبة ذكره ابن شهاب ويحتمل أن يسقط النفي عنها إذن كسقوط سفر الحج عنها فكذا هنا قال المؤلف وهذا الاحتمال هو اللائق بالشريعة فإن نفيها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتعريض لها بالفتنة لا يقال حديث التغريب عام لأنه يخص بقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها الخبر متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين رواه عبد الله بن أحمد ورواه مالك عن عمر بكل حال سواء كان مزوجا أو غير مزوج للعموم وخرق أبو ثور الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات كما خرق داود الإجماع في تكميل الحد على العبد وتضعيف حد الأبكار على المحصنات ولا يغرب ولا يعير نص عليهما وهو المشهور لأنه عليه السلام لم

يذكره ولو كان واجبا لبينه كغيره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولأنه مشغول بخدمة السيد وفي تغريبه ضياع لها [ج ٩ - ص ٦٥]

من غير جناية منه بدليل سقوط الجمعة ويتوجه احتمال بالنفي لأن عمر نفاه رواه البخاري قال في كشف المشكل يحتمل قوله نفاه أي أبعده من صحبته وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة لأن أرش جراحه على النصف من الحر والنصف من العبد فكذا حده وفي الأول خمسون وفي الثاني خمس وعشرون وفي الفروع وغيره والمعتق بعضه بالحساب وهو أولي وتغريب نصف عام في المنصوص لأن الحر تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف عام وإن كان بعضه فبالحساب كالحد ويحتمل ألا يغرب لأن حق السيد بعضه فيقتضي بقاءه في بلده ليتمكن من الانتفاع بحصته فغلب حقه على التغريب لما في حق السيد من التأكيد فرع إذا زنى عبد ثم عتق فعليه حد الرقيق وإن كان أحد الزانيين حرا والآخر رقيقا فعلى كل منهما حده وإن زنى بعد العتق وقبل العلم به فعليه حد حر وإن عفا السيد عنه لم يسقط حده في قول عامتهم وحد اللوطي كحد الزاني سواء قدمه في المحرر والمستوعب والرعاية وجزم به في الوجيز لقوله عليه السلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه زنى فكان فاحشة كالإيلاج في فرج المرأة فعلى هذا إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب عاما وإن كان عبدا جلد خمسون من غير تغريب وعنه حده الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا محصنا أو غيره وهي قول علي وابن عباس وغيرهما قال بعضهم وهي أظهر الروايتين [ج ٩ - ص ٦٦]

وصححه ابن هبيرة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده ثقات وعن ابن عباس في البكر يرجم رواه أبو داود بإسناد جيد واحتج به أحمد وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه وقد عابه الله في كتابه وذم فاعله ولهذا قال أبو بكر الصديق يحرق اللوطي وهو قول ابن الزبير وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا وأنه لما كان مقيسا على الزاني في الغسل كذلك الحد وإن الغسل قد يجب ولا حد لأنه يدرأ بالشبهات بخلاف الغسل فدل أنه يلزم من نفي الغسل نفي الحد وأولى ونصره ابن عقيل لأنه أبعد من أحد فرجي الخنثى المشكل لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها

مسائل يعزر غير البالغ منهما ولا حد على من وطىء زوجته أو مملوكته في دبرها بل يعزر قال في الفروع ومملوكه كأجنبي وفي الترغيب ودبر أجنبية كلواط وقيل كزنا وزان بذات محرم كلواط ونقل جماعة ويؤخذ ماله لخبر البراء وأوله الأكثر على عدم وارث وأول جماعة ضرب العنق فيه على ظن الراوي قال أحمد يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء إلا رجلا يراه مباحا فيجلد قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد يقتل وقال أبو بكر هو محمول عند أحمد على المستحل وإن غير المستحل كزان ومن أتى بهيمة ولو سمكة فعليه حد اللوطي عند القاضي لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة [ج ٩ - ص ٦٧]

رواه أحمد وأبو داود والترمذي واختار الخرقي وأبو بكر والأكثر وجزم به في الوجيز وهي قول ابن عباس وعطاء أنه يعزر وهو المشهور لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها والنفوس تعافه ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة وقال الترمذي لا يعرف الحديث الأول إلا من رواية عمرو بن أبي عمرو وهو مخرج عنه في الصحيحين وقال الطحاوي هو ضعيف وقد صح عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو ولأن الحد يدرأ بالشبهة وتقتل البهيمة عليهما مأكولة كانت أو غير مأكولة له أو لغيره للخبر وذكر ابن أبي موسى في قتلها على الثاني روايتين قال أبو بكر والاختيار قتلها وإن تركت فلا بأس ولا يجوز قتلها حتى يتبين ذلك إما بالشهادة على فعله بها أو بإقراره إن كانت ملكه فإن كانت لغيره لم يجز قتلها بحال لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقر لغير مالكها وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة وكره أحمد أكل لحمها لاختلاف الناس في حل الأكل وهل ذلك حرام على وجهين

أحدهما يحرم قدمه في الفروع وغيره روي عن ابن عباس ولأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كسائر المقتولات فعلى هذا يضمن الواطىء كمال قيمتها وفي الانتصار احتمال

والثاني يحل أكلها لقوله تعالى ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ المائدة 1 ولأنه حيوان ذبحه ذابح من أهل الزكاة فجاز [ج ٩ - ص ٦٨]

أكله كما لو لم يفعل به ذلك لكن يكره للشبهة فعليها يضمن نقصها

فصل

ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة لما يأتي

أحدها أن يطأ في الفرج أي فرج أصلي سواء كان قبلا أو دبرا أصليين لأن الدبر فرج مقصود أشبه القبل ولأنه إذا وجب بالوطء في الفرج وهو مما يستباح فهذا أولى ويقال إن أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الرجال وأقل ذلك تغييب الحشفة الأصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به فإن وطىء دون الفرج فلا حد عليه لما روى ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح فقال استغفر الله رواه النسائي فلم يوجب عليه حدا وظاهره أنه لا يعزر إذا جاء تائبا أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما أي إذا تساحقت امرأتان فهما ملعونتان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان رواه مسلم ذكره في الشرح وأما كونه لا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا أشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه أشبه مباشرة الرجل الأجنبية من غير جماع وكذا لو جامع الخنثى المشكل بذكره أو جومع في قبله فلا حد

فرع إذا وجد رجل مع امرأة كل منهما يقبل الآخر ولم يعلم أنه وطئها

فلا حد فإن قالا نحن زوجان قبل قولهما في قول الأكثر فإن شهد عليهما بالزنى فقالا نحن زوجان فقيل عليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح وقيل لا إذا لم يعلم أنها أجنبية منه لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه

فصل

الثاني انتفاء الشبهة لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن وطىء جارية ولده فلا حد عليه في قول أكثرهم لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه كوطء الجارية المشتركة يدل عليه قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك أضاف مال ولده إليه وجعله له فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد الذي يدرأ بالشبهة وفي الرعاية من وطىء أمة ولده ولم ينو تملكها به ولم يكن ابنه وطئها وقيل أو كان عزر في الأشهر بمائة سوط وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر وإن كان ابنه وطئها حد الأب مع علمه به أو جارية له فيها شرك فكذلك لأنه فرج له فيه ملك أشبه المكاتبة والمرهونة وظاهره ولو لبيت المال صرح به في الرعاية إذا كان له فيه حق أو لولده لأن الشرك في إسقاط الحد كملك الكل أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته فوطئها فلا حد عليه لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه أشبه ما لو قيل له هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي أو دعا الضرير

امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها وظنها المدعوة كما لو زفت اليه غير زوجته وقيل له هذه زوجتك بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن لأنه لا تعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا أو وطىء في نكاح أو ملك مختلف في صحته يعتقد تحريمه كمتعة وبلا ولي وشراء فاسد بعد قبضه وقيل أو قبله لأن الوطء فيه شبهة وعنه يحد اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار ولو لم يجد ذكره أبو الحسين وغيره فلو حكم بصحته توجه خلاف وكذا وطؤه بعقد فضولي وفي ثالث إن وطىء قبل الإجازة حد وإلا عزر واختار في المحرر يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها وحكى رواية أو وطىء امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها لأن الوطء قد صادف ملكا فكان شبهة وقد حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه أنه يدرأ بالشبهة أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة قبل منه لأنه يجوز أن يكون صادقا وظاهره أنه إذا لم يكن كذلك أو نشأ بين المسلمين أنه لا يقبل منه لأنه لم يخف عليه أو أكره على الزنى فلا حد عليه نقول لا حد على مكرهة على الزنى في قول عامتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد رواه

الأثرم ورواه سعيد عن عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ولا فرق في الإكراه [ج ٩ - ص ٧١]

بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها أو بالتهديد بالقتل ونحوه نص عليه في راع أو منع طعام مع اضطرار وكذا المفعول له لواطا قهرا وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد نص عليه وقدمه في الفروع وهو المذهب لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث والاختيار بخلاف الإكراه وعنه لا حد عليه صححه في المغني والشرح لعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم وعنه فيهما لا حد إلا بتهديد ونحوه قال الشيخ تقي الدين بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل لا القول قال القاضي وغيره إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف وإن وطىء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين وهما روايتان

إحداهما يحد بوطء ميتة قدمها في الرعاية لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه أشبه الحية ولأنه أعظم ذنبا

والثانية لا يحد اختارها أبو بكر وجزم بها في الوجيز لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه فعليها يعزر ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه قال أبو بكر وهو قول الأوزاعي وهذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة لعدم وجود قتل بخلاف الوطء وأما من تحرم عليه بالرضاع إذا وطئها فعنه يحد وذكره القاضي عن أصحابنا لأنه لا يستباح بحال كالمحرمة بالنسب وكفرج الغلام وعنه لا وجزم بها في الوجيز

لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد يبنى على الدرء والإسقاط [ج ٩ - ص ٧٢]

فإذا لم يحد عزر وعنه مائة سوط وكذا إذا وطىء أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة والمجوسية وإن وطىء في نكاح مجمع على بطلانه والمنصوص مع علمه كنكاح المزوجة لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد عملا بالمقتضى وقد روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما فقالا لا فقال لو علمتما لرجمتكما رواه أبو نصر المروزي ولأنه إذا وجب الحد بوطء المعتدة فلأن يجب بوطء المزوجة بطريق الأولى والمعتدة فلو قال جهلت فراغ المعتدة وأمكن صدقه صدق والخامسة لعدم إباحتها وذوات المحارم من النسب والرضاع للعموم وعنه فيمن وطىء ذوات محارمه يقتل بكل حال رجحه في الشرح لأخبار وعنه ويؤخذ ماله لبيت المال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله رواه أبو داود والجوزجاني

مسألة حكم من زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنى كذلك نص عليه وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف أو استأجر امرأة للزنى أو لغيره وزنى بها لعموم الآية والأخبار ووجود الإجارة كعدمها ولأنه وطء في غير ملك أشبه ما لو كان له عليها دين وتغير الحال لا يسقط الحد كما لو مات أو زنى بامرأة له عليها القصاص لأن استحقاق قتلها لا يوجب إباحة وطئها فلا تؤثر فيه شبهة فوجب أن يجب الحد عملا بالنصوص وقيل من

وطىء أمة له عليها قود لم يحد إن قلنا إنه يملكها به وسئل أحمد هل عليه عقرها قال لا شيء عليه هي له أو بصغيرة يوطىء مثلها [ج ٩ - ص ٧٣]

نقله الجماعة وصححه في المغني والشرح لأنها كالكبيرة في ذلك وقيل أو لا وهو ظاهر كلامه هنا وقال القاضي لا حد على من وطىء صغيرة لم تبلغ تسعا لأنه لا يشتهى مثلها وكما لو استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشرا ورده المؤلف لعدم التوقيف فيه أو مجنونة لأن الواطىء من أهل وجوب الحد وقد فعل ما يوجبه فوجب أن يترتب عليه مقتضاه أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها لأن النكاح والملك وجدا بعد وجوب الحد فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه أو أقر عليها فجحدت كسكوتها أو أمكنت العاقلة أي المكلفة من نفسها مجنونا أو صغيرا وقيل ابن عشر فوطئها فعليهم الحد أي عليها الحد لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر كما لو زنى المستأمن بمسلمة

فصل

الثالث أن يثبت الزنى ولا يثبت زناه ولا يلزمه الحد إلا بشيئين

أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس نص عليه لما روى أبو هريرة قال أتى رجل من الأسلميين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال هل أحصنت قال نعم قال [ج ٩ - ص ٧٤]

اذهبوا به فارجموه متفق عليه وفي مختصر ابن رزين بمجلس سأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث وقال الحكم وابن أبي ليلى يكفي الإقرار مرة لقوله عليه السلام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وغيره من الأحاديث المطلقة وجوابه ما سبق وبأنه لو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى وروى نعيم بن هزال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلتها أربع مرات قال نعم رواه أبو داود وهو بالغ عاقل حر وعبد محدود في قذف أو لا ولا نعلم خلافا أن المكره لا يجب عليه حد وكذا النائم لرفع القلم عنه والسكران سبق حكمه وفي الكافي والشرح لا يصح إقراره به لكن عليه حد الزنى والسرقة والشرب والقذف إذا فعله حال سكره لفعل الصحابة فأما الأخرس إن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار وإن فهمت إشارته فإنه يؤاخذ بها فإن أقر العاقل أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها لحديث سهل بن سعد رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ويصرح بذكر حقيقة الوطء لتزول التهمة ولقوله عليه السلام لماعز لعلك قبلت أو غمزت قال لا قال أفنكنها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري وعنه وبمن زنى بها وفي الرعاية وهي أظهر وأطلق في الترغيب وغيره الخلاف ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام

الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه في قول الجمهور لقصة ماعز

[ج ٩ - ص ٧٥]

فرع إذا شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقتهم دون أربع فلا حد عليه في الأظهر ولا على الشهود وهما في الترغيب إن أنكر وإنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه الثاني أن يشهد عليه أي على فعله أربعة إجماعا لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ الآية النور 4 ولقوله عليه السلام لسعد بن عبادة حين قال له أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه مالك رجال فلا تقبل فيه شهادة النساء إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة وامرأتان وهو خلاف النص لأن في شهادة النساء شبهة لما في قبولها من الاختلاف والحدود تدرأ بالشبهات أحرار في الأشهر وقاله الأكثر وعنه يقبل العبد لعموم النص وهو عدل مسلم ذكر فقبل كالحر وجوابه أنه مختلف في قبول شهادته وذلك شبهة فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهة عدول ولا خلاف في اشتراطها كسائر الشهادات فلا تقبل فيه شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا واكتفى بذلك عن ذكر الإسلام لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم فلا تقبل روايتهم ولا خبرهم الديني كعبدة الأوثان وسواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي يصفون الزنى أي زنى واحد يصفونه نقله أبو طالب فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى وقال طائفة يجوز أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة

الشهادة عليهما ليحصل الردع بالحد فإن شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها كفى ويجيئون في مجلس [ج ٩ - ص ٧٦]

واحد على الأصح لأن عمر شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولو اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا يفارق سائر الشهادات والثانية ليس بشرط لقوله تعالى ﴿ لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ﴾ النور 3 ولم يذكر المجلس ولأن كل شهادة مقبولة إذا افترقت كغيرها وجوابه أن الآية لم تتعرض للشروط سواء جاؤوا متفرقين أي واحدا بعد آخر لقصة المغيرة فإنهم جاؤوا مفترقين وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كمالها وفي الحديث أن أبا بكرة قال لعمر أرأيت لو جاء آخر فشهد أكنت ترجمه فقال عمر أي والذي نفسي بيده ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاؤوا أو مجتمعين ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه ولهذا يجزىء فيه القبض فيما هو شرط فيه فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفه لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة أشبه ما لو لم يشهد أصلا وعليهم الحد أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد في قول أكثر العلماء لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ النور 4 وهذا يوجب الحد على كل رام لم يشهد بما قاله أربعة ولأن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حيث لم يكمل الرابع شهادته

بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع وحكى أبو الخطاب رواية أنه لا حد عليهم [ج ٩ - ص ٧٧]

لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق فرع كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبرها ووطء البهيمة إن قلنا يجب الحد به وإن قلنا يعزر فيقبل بشاهدين وقيل بأربعة وعلى قياس هذا كل وطء يوجب التعزير فقط فإن لم يكن وطئا كمباشرة دون الفرج تثبت بشاهدين وجها واحدا وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم أو بأن فيهم صبي مميز أو امرأة أو عبد ولم يقبله فعليهم الحد على المذهب وصححه القاضي كما لو لم يكمل العدد وكما لو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء وعنه لا حد عليهم وهو قول الحسن والشعبي لأنهم أربعة فدخلوا في عموم الآية وكما لو شهد أربعة مستورون ذكره في المغني والشرح أو مات أحدهم قبل وصفه الزنى وإن شهدوا عليها عذراء نص عليه وفي الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة والثالثة تحد العميان خاصة وقاله الثوري وإسحاق لأنه معلوم كذبهم والباقي يجوز صدقهم وقد كمل عددهم أشبه مستوري الحال وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة لأنهم قذفة حيث لم تكمل البينة لأن شهادة الزوج غير مسموعة ولا عن الزوج إن شاء لأن الزوج إذا قذف زوجته له الخيرة بين اللعان وتركه وعلى الثانية لا حد ولا لعان بحال وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر أو اختلفا في اليوم فهم قذفة وعليهم الحد اختاره الخرقي وقدمه في الرعاية ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز [ج ٩ - ص ٧٨]

وصححه في الفروع لأنه لم يكمل أربعة على زنى واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وعنه يحد المشهود عليه فقط اختاره أبو بكر وفي التبصرة والمستوعب وظاهرها أنه لا تعتبر شهادة الأربع على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية وهو بعيد لأنه لم يثبت زنى واحد بشهادة أربعة فلم يجب الحد ولآن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر كمالها في حق واحد فالموجب للحد أولى ولأنه مما يحتاط له ويندرئ بالشبهات قال أبو بكر لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء وآخران بامرأة سوداء فهم قذفة ذكره القاضي وهذا يناقض قوله وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت صغير وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى كملت شهادتهم إن كانت الزاويتان متقاربتين وحد المشهود عليه على المذهب لأن التصديق ممكن فلم يجز التكذيب لا يقال يمكن أن يكون المشهود به فعلين فلم أوجبتم الحد مع الاحتمال وهو يدرأ بالشبهة لأنه لا شبهة فيه بدليل ما لو اتفقا على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة على فعلين بأن يكون قد فعل ذلك مرتين أما لو كانت الزاويتان متباعدتين فالقول فيهما كالقول في البيتين وعلى قول أبي بكر تكمل الشهادة سواء تقاربتا أو تباعدتا أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد ألآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم على المذهب لأنه لا تنافي بينهما فإنه يمكن أن يكون عليها قميصان فذكر كل اثنين واحدا منهما كما لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كتان

وآخران في قميص خز ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها وقاله أبو الخطاب لأن شهادتهم مختلفة أشبه ما لو اختلفوا في البيتين [ج ٩ - ص ٧٩]

فعلى هذا هل يحدون للقذف على وجهين وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم على الأشهر لأن فعل المطاوعة غير المكرهة فعلى هذا لا يحد الرجل اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب ولا المرأة بغير خلاف نعلمه لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد عليهما وهل يحد الجميع أي الأربعة لقذفهم الرجل أو شاهدا المطاوعة على وجهين

أحدهما يجب الحد على شاهدي المطاوعة اختاره أبو بكر لأنهما قذفا المرأة بالزنى ولم تكمل شهادتهم عليها ولا يجب على شاهدي الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الرجل وإنما انتفى الحد للشبهة

والثاني يحد الجميع لأنهم شهدوا بالزنى فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم وعند أبي الخطاب يحد الزاني المشهود عليه واختاره في التبصرة لأن الشهادة كملت على وجود الزنى منه واختلافها إنما هو في فعلها فلا يمنع كمال الشهادة عليها دون المرأة لأنه لم يشهد عليها أربعة بزنى يوجب الحد لأنه لا حد مع الاكراه والشهود لأن المقتضي له لم يوجد وفي الواضح لا حد على أحد منهم

فرع إذا شهد اثنان أنها بيضاء وآخران غيره لم تقبل لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة وكما لو اختلفوا في تعدد المكان أو الزمان بخلاف السرقة وحدوا للقذف وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على

الراجع ويحد الثلاثة اختاره أبو بكر وابن حامد وجزم به في الوجيز

[ج ٩ - ص ٨٠]

لأن الراجع كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي تحصل به مصلحة المشهود عليه وإنما حد الثلاثة لأن برجوع الراجع نقص عدد الشهود فوجب أن يحدوا كما لو كانوا في الابتداء كذلك والثانية يحد الجميع قدمها في المحرر لنقص العدد كما لو كانوا ثلاثة قال في المحرر ويتخرج ألا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد ولو رجع الكل فهل يحدون على الروايتين في الواحد وإن كان رجوعه بعد الحكم فلا حد على الثلاثة لأن الشهادة كملت واتصل بها الحكم فلم يجب عليهم شيء لعدم كونهم قذفة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه لأنه أقر على نفسه برجوعه أن التلف حصل بفعله وفعل غيره فيقبل على نفسه فقط وظاهره أنه لا حد على الراجع أيضا ونقله أبو النصر لأنه تائب والمذهب أنه يحد وحده إن ورث حد القذف فإن كان رجما ضمن ربع المتلف بدية أو غيرها إن صرح بالخطإ وإن قال عمدنا الكذب ليقتل قتل وحده وإن قال عمدت ذلك وحدي فهل يلزمه قود على الروايتين في مشاركة العامد للمخطىء وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها لأن البكارة تثبت بشهادة النساء ووجودها يمنع من الزنى ظاهرا والشهود صدقهم محتمل فإنه يحتمل أنه وطئها ثم عادت عذرتها لكن ذكر في الشرح أنه يكتفي بشهادة واحدة لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال ونقل أبو النصر في مسألة المجبوب أن

الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم فذكر له قول الشعبي العذراء قال عنه اختلاف فإن رجمه [ج ٩ - ص ٨١]

القاضي فالخطأ منه قلت فترى في هذا أو في من شهد عليه بالزنى فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه أن الدية في بيت المال لأن الحاكم ليس عليه غرم قال نعم وأطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء وفي الشرح إن شهد بأنها رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب فينبغي أن يجب الحد على الشهود لأنه متيقن كذبهم ولا على الشهود نص عليه لأن صدقهم محتمل وفي الرعاية ولا على الرجل وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه لأن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين وشهادة الآخرين تتطرق إليها التهمة وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى على روايتين كذا في المحرر والفروع

إحداهما لا يجب الحد عليهم لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم والآخرون تتطرق إليهم التهمة

والثانية يحدون لها اختارها أبو الخطاب لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها وعلى كلتيهما في حدهم القذف روايتان أشهرهما بأنهم يحدون وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده نقله الجماعة وذكر ابن هبيرة أنها الأظهر لكنها تسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنى لم تحد وهو قول الأكثر من العلماء وعن أحمد بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية ولو ادعت شبهة

وأقوال الصحابة مختلفة في ذلك حتى بالغ بعض العلما وقال إن المرأة تحمل من غير [ج ٩ - ص ٨٢]

وطء بأن تدخل ماء الرجل في فرجها ولهذا تصور حمل البكر ووجد

مسألة إذا شهد عليه بزنى قديم أو أقر به وجب عليه الحد لعموم الآية وكسائر الحقوق وقال ابن حامد لا أقبل بينة على زنى قديم وأحده بالإقرار به وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد وهو مروي عن عمر لأن تأخير الشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة وتقبل الشهادة به من غير مدع نص عليه لقضية أبي بكرة

باب حد القذف

وهو محرم بالإجماع وسنده قوله تعالى ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ النور 23 وقوله عليه السلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه وهو الرمي بالزنى فبيان لمعنى القذف وكذا رميه بلواط أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة وأصله الرمي بالحجر بخلاف الخذف بالخاء المعجمة فإنه الرمي بالحصى وهو في الأصل رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنى ونحوه من المكروهات يقال قذف يقذف قذفا فهو قاذف وجمعه قذاف وقذفه كفاسق وفسقة وكافر وكفرة ومن قذف وهو مكلف [ج ٩ - ص ٨٣]

مختار حرا محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا أجمعوا على وجوب الحد على من قذف محصنا حرا كان القاذف أو عبدا وأن حده ثمانون إن كان حرا لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ والرقيق على النصف من ذلك في قول أكثر العلماء ويروى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدا قذف حرا ثمانين وبه قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز لعموم الآية والصحيح الأول لإجماع الصحابة قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين رواه مالك كحد الزنى والآية وإن كانت عامة فدليلنا خاص والخاص مقدم وتقدم قول الخرقي يكون بدون سوط الحر وظاهره ولو ذات محرم أو مجبوبا سوى ولده وإن نزل نص على الثلاثة ولو عتق قبل حد ومعتق بعضه بالحساب وقيل كعبد وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدميين على روايتين

إحداهما وهي الأظهر والأشهر وقاله الجمهور هو حق لآدمي فعليه يسقط بعفوه عنه قال القاضي وأصحابه لا عفوه عن بعضه

والثانية هو حق لله قدمها في الرعاية وعليها لا يسقط بالعفو أو الإبراء ولا بستوفيه إلا الإمام أو نائبه وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ويتوجه على الثانية وبدونه ولا

يستوفيه بنفسه خلافا لأبي الخطاب وإنه لو فعل لم يعتد به وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد وفي البلغة لا يستوفيه بدونه [ج ٩ - ص ٨٤]

فإن فعل فوجهان وإن هذا في القذف الصريح وإن غيره يبرأ به سواء على خلاف في المذهب كاعتبار الموالاة أو النية وقذف غير المحصن كمن قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون عشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين أو من ليس بعفيف يوجب التعزير ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم وقيل سوى سيد لعبده

فرع يحد أبواه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعيضه وفي الترغيب لا يحد أب وفي أم وجهان والمحصن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله هذه صفة المحصن الذي يحد بقذفه أما الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلم ينتهض لإيجاب الحد والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرهما ليس في معناهما وأما العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنى لعدم تكليفه وغير العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنى إليه لكونه غير مكلف وأما العفة عن الزنى فلأن غير العفيف لا يشينه القذف والحد إنما وجب من أجل ذلك وقد أسقط الله الحد عن القاذف إذا كان له بينة بما قال وأما كونه يجامع مثله فلأن غير ذلك لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف وأقله أن يكون له عشر سنين إن كان ذكرا أو تسع سنين إن كانت أنثى وظاهره أنه لا تشترط فيه العدالة بل لو كان المقذوف فاسقا كشربه الخمر أو لبدعة ولم يعرف بالزنى أنه يجب الحد بقذفه وقال

الشيرازي لا يجب الحد بقذف مبتدع ولا مبتدعة وقال ابن أبي موسى إذا قذف أم ولد رجل وله منها ولد [ج ٩ - ص ٨٥]

حد وإذا قذف مسلم ذمية تحت مسلم أو لها منه ولد حد في رواية وإن قذف عبد عبدا جلد أربعين قاله في الرعاية وهل يشترط بلوغه على روايتين

إحداهما يشترط قيل إنها مخرجة وليست بمنصوصة لأن غير البالغ غير مكلف أشبه المجنون

والثانية ليس بشرط وهو مقتضى كلام الخرقي وقطع بها القاضي والشريف وأبو الخطاب وصاحب الوجيز لأن ابن عشر سنين ونحوه يلحقه الشين بإضافة الزنى إليه ويعير بذلك ولهذا جعل عيبا في الرقيق أشبه البالغ وفي اشتراط سلامته من وطء الشبهة وجهان ولعله مبني على أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أم لا فذكر عن القاضي أنه وصفه به وظاهر كلام جماعة عدم وصفه بذلك وظاهر كلام آخرين أنه لا تشترط السلامة في ذلك

فرع إذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ لم يقم عليه حتى يبلغ ويطالب لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ وليس لوليه المطالبة حذارا من فوات التشفي ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته فيقام على المذهب وقيل لا لاحتمال عفوه ولو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم حتى يفيق ويطالب وإن كان بعد الطلب جازت إقامته

مسألة يشترط لإقامة الحد على القاذف أمران

أحدهما مطالبة المقذوف لأنه حق له كسائر حقوقه

الثاني ألا يأتي ببينة فإن كان القاذف زوجا اعتبر آخر وهو امتناعه من اللعان وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامته فلو طلب ثم عفا سقط ويحد بقذف على جهة الغيرة بفتح الغين ويتوجه احتمال [ج ٩ - ص ٨٦]

وأنها عذر في غيبة ونحوها وإن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد لأن حد القذف أنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار وهو منتف للصغر بل يعزر زاد في المغني إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه وإلا خرج على الروايتين وكذا في الفروع في اشتراط البلوغ جزم في الوجيز بالحد وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد لأنه يعلم كذبه وإن لم يثبت ذلك على الأصح فإن ثبت فلا حد على الأصح وإن كانت كذلك لم يحد على الأشهر وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فهل يحد أو يعزر على وجهين الأصح أنه لا حد عليه لأن ظاهر لفظه يقتضي تعليق وأنت نصرانية أو أمة بقوله زنيت فيصير كأنه قال لها زنيت حال النصرانية أو الرق ولا حد مع ذلك لأن ارتباط الكلام بعضه ببعض أولى من عدم ارتباطه قال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون وفي الترغيب إن كان ممن يجن لم يقذفه وفي المغني إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حالة جنون وإفاقة فوجهان وإن ادعى رق مجهولة فروايتان وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال زنيت مكرهة أو قال يا زانية ثم ثبت زناها في كفر لم يحد كثبوته في إسلام وفي المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد وذكر القاضي لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد [ج ٩ - ص ٨٧]

وهو سهو ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف نص عليه حكم حاكم بوجوبه أم لا لأن الحد يعتبر بوقت وجوبه وكما لا يسقط بردته وجنونه وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة وعلله المؤلف بأنه حق آدمي وبأن الزنى نوع فسق واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة

فصل

والقذف محرم إلا في موضعين

أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج وفي المغني أو تقر به فيصدقها فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه أي من الزاني زاد في المحرر والرعاية وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني فيجب عليه قذفها لأن نفي الولد واجب ولا يمكن إلا بالقذف لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ونفي ولدها لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ولا شك أن الرجل مثلها وكذا لو أقرت بالزنى ووقع في نفسه صدقها

الثاني ألا تأتي بولد يجب نفيه لأن بالزوج حاجة إلى فسخ النكاح ليتخلص من زوجة شأنها كذلك لحديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية أو استفاض في الناس زناها وقدم في المغني [ج ٩ - ص ٨٨]

والشرح لا تكفي استفاضة بلا قرينة أو أخبره به ثقة فلو كان يخبر من لا يوثق به لم يجز لأنه غير مأمون على الكذب عليها أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة فيباح قذفها لأنه يغلب على ظنه بجورها ولا يجب لأنه يمكنه فراقها والسكوت هنا أولى لأنه أستر ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو يقر فيفتضح

فرع قال الشيخ تقي الدين إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله اللعان ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه واختار أبو محمد الجوزي المباح أنه براها تزني أو يظنه ولا ولد وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما كأبيض بين أسودين أو بالعكس لم يبح نفيه بذلك اختاره ابن حامد لخبر أبي هريرة وهو متفق عليه وقال لعله نزعة عرق ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية بدليل قضية سعد وعبد بن زمعة وقال القاضي وأبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته لقوله عليه السلام إن جاءت به جعدا الخبر فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه والأول أصح وهذا الحديث إنما يدل على نفيه عنه مع ما تقدم من لعانه ونفيه إياه عن نفسه فجعل الشبه مرجحا والمذهب أن له نفيه بقرينة جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وإن استبرأها بحيضة جاز النفي في الاشهر وإن كان يعزل عنها فلا لخبر أبي سعيد فصل [ج ٩ - ص ٨٩]

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية لأنها ألفاظ ترتب عليها حكم شرعي فانقسمت إلى ذلك كالطلاق فالصريح قوله يا زاني يا عاهر زنى فرجك ونحوه كزنيت ويا منيوك مما لا يحتمل غير القذف فلا يقبل قوله بما يحيله لأنه صريح فيه أشبه صريح الطلاق وإن قال يا لوطي يا معفوج هو مفعول من عفج يعني نكح فكأنه بمعنى منكوح أي موطوء فهو صريح في المنصوص وعليه الحد فيهما إذا قذفه بعمل قوم لوط فاعلا أو مفعولا اختاره الأكثر لأن اللوطي الزاني بالذكور أشبه ما لو قال يا زاني وحينئذ لا يسمع تفسيره بما يحيل القذف وعنه مع غضب لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف حالة الرضى وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه وهذا رواية نقلها المروذي لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد كما لو فسره به متصلا بكلامه وهو بعيد لأن إطلاق لفظه وإرادة مثل ذلك فيه بعد مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحد ولو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها فعليه الحد وقيل لا ومبنى الخلاف هنا على الخلاف في وجوب حد الزنى على من فعل ذلك وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال احتمل وجهين

أشهرهما أنه لا يقبل لأنه فسر اللفظ بما لا يحتمله غالبا أشبه ما لو قال يا

زاني

والثاني أنه لا يحد لأن ما فسر به كلامه محتمل الارادة والحد يدرأ بالشبهات فرع إذا فسر يا منيوكة بفعل زوج فليس قذفا ذكره في الرعاية والتبصرة وزاد إن أراد بزاني العين أو يا عاهر اليد لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه في المنصوص إلا منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه لأن ذلك يقضي أن أمه أتت به من غير أبيه وذلك قذف لها وكذا إن نفاه عن قبيلته وقال المؤلف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد لنفي الرجل عن قبيلته لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنى أشبه ما لو قال لأعجمي إنك عربي وإن قال لست بولدي فعلى وجهين

أظهرهما أنه كناية في قذفها نص عليه لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده

والثاني هو صريح لأنه نفاه عن نفسه أشبه نفي ولد غيره عن أبيه فرع إذا قال إن لم تفعل كذا فلست ابن فلان فلا حد لأن القذف لا يتعلق بالشرط وإن قال لست ابن فلانة عذر نص عليه لأنه لم يقذف أحدا بالزنى وإن قال أنت أزنى الناس فهو قاذف في قول أبي بكر وقدمه في الرعاية لأنه أضاف اليه الزنى بصيغة المبالغة أو أزنى من فلانة فكذلك في قول القاضي لأن أزنى معناه المبالغة ففيه الزنى وزيادة وقدم في الكافي لا

لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل وقال ابن حامد ليس بقذف إلا أن يريده لأن موضوع اللفظ يقتضي ذلك [ج ٩ - ص ٩١]

مسألة إذا قال أنت أزنى من زيد فقد قذفهما صريحا وقيل كناية وقيل ليس بقذف لزيد وهو أقيس أو قال لرجل يا زانية أو لمرأة يا زاني فصريح نصره في الشرح وقدمه في الفروع لأن اللفظ صريح في الزنى وزيادة الهاء وحذفها خطأ لا يغير المعنى كاللحن وكفتح التاء وكسرها لهما خلافا للرعاية في عالم بعربية واختار ابن حامد كما يأتي أنه ليس بصريح إلا أن يفسر به لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنه علامة في الزنى كما يقال للعالم علامة أو قال زنت يداك ورجلاك فهو صريح في القذف عند أبي بكر لأن ذلك يطلق ويراد به زنى الفرج وليس بصريح عند ابن حامد في ظاهر المذهب في الأخيرة لأن زنى هذه الاعضاء لا يوجب الحد لقوله عليه السلام العينان تزنيان وزناهما النظر قال في الشرح والأولى أن يرجع إلى تفسيره انتهى وكذا الخلاف لو أفرد فلو قال زنت يدك فقذف قاله في الرعاية وكذا العين في الترغيب وفي المغني وغيره لا

مسألة إذا قال يا زاني ابن الزانية لزمه حدان فإن تشاحا قدم حد الابن وعنه حد واحد وقيل إن كانت أمه حية فقد قذفها معه وإن كانت ميتة فقد قذفه وحده وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر وأبي الخطاب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف وقال ابن حامد إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا لأن معناه في العربية طلعت وعليهما إن

قال أردت الصعود في الجبل قبل وإن لم يقل في الجبل أي زنأت فهل هو صريح أو كالتي قبلها على وجهين

أحدهما أنه صريح قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن مع عدم القول في الجبل يتمحض القذف وقيل هو كالتي قبلها أحدهما يكون صريحا في حق العامي والعالم بالعربية والثاني الفرق بينهما وقيل لا قذف قال في الفروع ويتوجه مثلها لفظة علق وذكرها شيخنا صريحة ومعناه قول ابن رزين كل ما يدل عليه عرفا والكناية نحو قوله لامرأته قد فضحته أي بشكواك وغطيت أو نكست رأسه أي حياء من الناس من ذلك وجعلت له قرونا أي أنه مسخر لك مطيع منقاد كالثور وعلقت عليه أولادا من غيره أي من زوج آخر أو وطء شبهة وأفسدت فراشه أي بالنشوز أي بالشقاق وبمنع الوطء أو يقول لمن يخاصمه يا حلال يا ابن الحلال لأنه كذلك حقيقة ما يعرفك الناس بالزنى حقيقة النفي أي ما أنت بزان ولا أمك زانية يا عفيف كونه كذلك حقيقة وكذا يا نظيف يا خنيث بالنون وذكره بعضهم بالباء أو يا فاجرة أي كونها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه يا قحبة قال السعدي قحب البعير والكلب سعل وهي في زماننا المعدة للزنى يا خبيثة وهي صفة مشبهة من خبث الشيء فهو خبيث أو يقول لعربي يا نبطي منسوب إلى النبط وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين يا فارسي منسوب إلى فارس وهي بلاد معروفة وأهلها الفرس وفارس أبوهم يا رومي نسبة إلى الروم [ج ٩ - ص ٩٣]

وهو في الأصل الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت أي في غير الإخبار المذكور أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر أي موافق للكذب أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية فهذا كله كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف وعنه بقرينة ظاهرة قبل قوله في أحد الوجهين قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وصححه في المغني والشرح لأنه يحتمل غير الزنى كما ذكرناه فهو إذا فسر الكلام بما يحتمله وعليه يعزر وفي الآخر جميعه صريح فيحد به اختاره القاضي وجماعة وذكره في التبصرة عن الخرقي لأن الظاهر من حاله أنه لم يرد شيئا فوجب حملها عليه بظاهر الحال والاستعمال فعلى هذا إذا قال أردت هذه الاحتمالات لم يقبل كالزاني وعنه لا يحد إلا بنية اختارها أبو بكر وغيره والقرينة ككناية طلاق وفي الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها ويلزمه الحد باطنا وفي لزوم إظهارها وجهان

تنبيه لا حد بالتعريض كقوله يا حلال ابن الحلال نص عليه في رواية حنبل وهو ظاهر الخرقي واختاره أبو بكر وقاله أكثر العلماء لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه فلم يلزمه بذلك حد ولأن الله تعالى أباح التعريض بالخطبة دون التصريح بها ونقل الآثرم عليه الحد روى عن عمر وعثمان وهي أظهرهما قاله ابن هبيرة فأما في غير حالة خصومة ولا وجدت قرينة فلا يكون قذفا وإن

قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عادة وعرفا عزر ولم يحد [ج ٩ - ص ٩٤]

لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف ويعزر على ما أتى به من المعصية والزور كما لو سبهم بغير القذف وظاهره أنه يعزر ولو لم يطلبه أحد وفي المغني لا يحتاج التعزير إلى مطالبة وفي مختصر ابن رزين يعزر حيث لا حد

مسائل يعزر في يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا مخنث نص على ذلك وقيل فاسق كناية ومخنث تعريض ويعزر في قرنان وقواد وسأله حرب عن ديوث فقال يعزر وفي المبهج ديوث قذف لامرأته ومثله كشخان وقرطبان ويتوجه في مأبون كمخنث وفي الرعاية لم أجدك عذراء كناية وإن من قال لظالم ابن ظالم جبرك الله ورحم سلفك يعزر قاله في الفروع وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد أو يعزر على وجهين

أحدهما يعزر جزم به في الوجيز لأن المقذوف رضي بقذفه أشبه ما لو قذف نفسه

والثاني يحد لأن الموجب له القذف وقد وجد وقوله لا أثر له لأن القذف لا يباح بالإباحة وفي النهاية والشرح هما مبنيان على الاختلاف في حد القذف وهل هو حق لله فلا يسقط بالإذن فيه كالزنى أو لآدمي فيسقط كما لو أذن في إتلاف ماله ويعزر لأنه فعل محرما لا حد فيه وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة لأنها صدقته فيما قال فلم

يجب حد كما لو قالت صدقت ويسقط عنه الحد بتصديقها لأنه يمكن الزنى منها به من غير أن [ج ٩ - ص ٩٥]

يكون زانيا بأن يكون قد وطئها بشبهة ولا يجب عليها حد لأنها لم تقر أربع مرات وإن قال زنى بك فلان فقد قذفها نص عليه وخرج فيها روايتان فعلى أنها لم تقذفه يتخرج لو أقر بأنه زنى بامرأة لم يقذفها لاحتمال أنها مكرهة أو نائمة وجزم به في الترغيب في الزوجة ولو كان قولها أنت أزنى مني أو زنيت وأنت أزنى مني فقد قذفته وفي الرعاية وجه وإن قال يا زانية قالت بل أنت زان حدا وعنه لا لعان وتحد هي فقط وهي سهو عند القاضي وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص وظاهره أنها إذا ماتت وورثت حد القذف فلوارثه المطالبة إذن وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما ذكره الخرقي لأنه قدح في نسب الحي لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنى ولا يستحق ذلك بطريق الإرث فكذلك يعتبر الإحصان فيه ولا يعتبر في أمه لأن القذف له وشرط فيه الطلب لأنه حق من الحقوق فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق واسلامه وحريته لأن الحد وجب للقدح في نسبه وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة وذكره المؤلف ظاهر المذهب في غير أمهاته وقطع به في المبهج لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة أشبه قذف المجنون أو يقال الميتة لا تعير والحي لم يقدح فيه وذلك شبهة يدرأ بها الحد والمذهب

الأول لأنه إذا قذف ميت محصن أو لا حد القاذف إذا طالب وارث محصن خاصة [ج ٩ - ص ٩٦]

فعلى هذا لو كان الوارث عبدا أو مشركا فلا حد وإن قذفت جدته فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه إن كانت حية فيعتبر إحصانها وليس لغيرها المطالبة وإن كانت ميتة فله المطالبة إذا كان محصنا لأنه قدح في نسبه وإن قذف أباه أو أحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم يجب الحد وإن مات المقذوف سقط الحد عن القاذف إذا كان قبل المطالبة بالحد فإن كان بعدها قام وارثه مقامه لأنه حق له يجب بالمطالبة كالرجوع فيما وهب ولده وكالشفيع فعلى هذا هو حق للورثة نص عليه وقيل سوى الزوجين وفي المغني للعصبة وإن عفا بعضهم حد الباقي كاملا وقيل يسقط ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا يعني أن حده القتل ولا تقبل توبته نص عليه لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر وعنه إن تاب لم يقتل وقاله أكثر العلماء مسلما كان أو كافرا لأن هذا منه ردة والمرتد تصح توبته وجوابه أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف آحاد الناس قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها فلو كان كافرا فأسلم فأشهر الروايتين عنه أنه لا يسقط بإسلامه كقذف غيرها وعنه بلى لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل ولأن الإسلام يجب ما قبله والخلاف إنما هو في سقوط القتل فأما في ما بينه وبين الله تعالى فمقبولة وقذفه عليه السلام كقذف أمه ويسقط سبه بالإسلام كسب الله تعالى فرع قال

الشيخ تقي الدين قذف نسائه كقدحه في دينه وإنما لم تقتلهم لأنهم

[ج ٩ - ص ٩٧]

تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره وقيل لا وقيل في غير مدخول بها وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة يتصور منهم الزنى فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ثم لا حد نقله الجماعة وهو المشهور لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ الآية النور 5 لم يفرق بين قذف واحد أو جماعة لأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ونزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في الآخر ولا تزول المعرة فإن طلبوه أو واحد منهم أقيم الحد لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طلب واستوفى سقط ولم يكن لغيره الطلب به كحق المرأة على أوليائها في تزويجها وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا لأنه إذا طالب واحد أولا لزم إقامة الحد من أجله ثم إذا طلب الآخر لزم أيضا وعنه لكل واحد حد وقاله أبو ثور وابن المنذر لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته فإن قال يا ناكح أمه الروايات ونص فيمن قال لرجل يا ابن الزانية

يطالبه قيل إنما أراد أمه قال اليس قد قال له هذا قصد له وإن قذفهم بكلمات حد [ج ٩ - ص ٩٨]

لكل واحد حدا على الأصح كالديون والقصاص وعنه إن طالبوا مجتمعين فحد واحد وإلا تعدد وعنه حد واحد مطلقا كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر فلو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما بكلمة واحدة فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما ولم يجب إلا حد واحد وإن قال يا زاني ابن الزاني فهو قذف لهما بكلمتين فإن كان أبوه حيا فلكل منهما حد وإن كان ميتا فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد في قول عامتهم لأنه حد به مرة فلم يحد به ثانية بخلاف السرقة وعلم منه أنه إذا تعدد قذفه ولم يحد فحد واحد رواية واحدة نص عليه وقيل يتعدد وإن أعاده بعد لعانه فنقل حنبل يحد اختاره أبو بكر والمذهب يعزر وعليهما لا لعان وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنى لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة واختار ابن عقيل يلاعن لنفي تعزير ولو قذفها بزنى آخر بعد حده فروايات ثالثها يحد مع طول الفصل فرع إذا تاب من زنى حد قاذفه وقيل يعزر واختار في الترغيب يحد بزنى جديد لكذبه يقينا بخلاف من سرق عينا ثانية فإنه وجد منه ما وجد في الأولة وإن قذف من أقرت به مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد به أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر وفي المستوعب لا

مسألة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه وحرمه القاضي والشيخ عبد القادر ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه قال

الشيخ [ج ٩ - ص ٩٩]

تقي الدين والأشبه أنه يختلف وعنه يشترط وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وظاهره أنه لو أصبح وتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح ولا يصح إسقاط الحق قبل وجود سببه وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه وهي كإذنه في دمه وماله

باب حد المسكر

المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة يفعل ذلك قال الجوهري السكران خلاف الصاحي والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة

وهو محرم بالإجماع وما نقل عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنها حلال فمرجوع عنه نقله المؤلف وسنده قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ﴾ الآيات المائدة 90 و 91

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر خمر وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواهما مسلم

كل شراب أسكر كثرة فقليله حرام لما روي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه من أي شيء كان لما روى ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي

صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إن الله نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر [ج ٩ - ص ١٠٠]

والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه واباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر قال الحلال فتياه على قول أبي حنيفة قال الامام أحمد ليس في الرخصة حديث صحيح وقال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة وقيل إن خبر ابن عباس أنه عليه السلام قال حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب موقوف عليه مع أنه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب ويسمى خمرا لقوله عليه السلام كل مسكر خمر لأن الخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره وهذا موجود في كل مسكر وحكم عصير غير العنب كحكمه روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد وأبي وأنس وعائشة وهو قول الأكثر وقال أبو حنيفة عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ ولم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والشعير نقيعا كان أو غيره حلال إلا ما بلغ السكر وجوابه ما روت عائشة مرفوعا ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أحمد وسعيد وأبو بكر والترمذي وحسنه وإسناده ثقات وظاهره يقتضي أن الحشيشة لا تسكر لكن قوله كل مسكر خمر يقتضي أنه تسكر قال في الفتاوى المصرية الحشيشة المسكرة حرام وإنما توقف بعض الفقهاء في الحد لأنه ظن أنها تغطي العقل كالبنج والصحيح أنها تسكر وإنما كانت نجسة بخلاف البنج وجوزه الطبيب لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر يسكر بالاستحالة والبنج يغيب العقل ويسكر بغير الاستحالة كجوزة الطبيب ولا يحل شربه للذة لعموم ما أسكر كثيره فقليله

حرام ولا للتداوي لما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر [ج ٩ - ص ١٠١]

فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري ورواه أحمد من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة مرفوعا وصححه ابن حبان ولأنه يحرم لعينه فلم يحل شربه للتداوي كلحم الخنزير ولا لعطش لأنه لا يذهبه ولا يزيله ولا يدفع محذوره فوجب بقاؤه على تحريمه عملا بالأدلة المقتضية لذلك مع سلامته من المعارض ولا لغير إلا لدفع لقمة غص بها فيجوز تناوله إذا لم يجد غيره وخاف التلف لقوله تعالى ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ البقرة 173 ولأن حفظ النفس مطلوب بدليل أنه تباح الميتة عند الاضطرار إليها وهو موجود هنا فوجب جوازه تحصيلا لحفظ النفس المطلوب حفظها ويقدم عليه بولا ويقدم عليهما ماء نجسا ومن شربه وهو مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر وظاهره أنه إذا لم يعلم فلا حد عليه وهو قول عامتهم وكذا إذا ادعى الجهالة بإسكار غير الخمر أو تحريمه أو بوجود الحد به ومثله يجهله صدق ولم يحد وكذا اذا شربها مكرها لحله له وعنه لا تحل له اختارها أبو بكر وفي حده روايتان والظاهر أنهما مبنيان على حله له وعدمه والصبر أفضل نص عليه وكذا كل ما جاز فعله للمكره ذكره القاضي وغيره قال الشيخ تقي الدين يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب أحمد

قليلا كان ما شربه أو كثيرا فعليه الحد لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه رواه [ج ٩ - ص ١٠٢]

أحمد وأبو داود والنسائي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا شاربها ولأن القليل خمر فيدخل في العموم ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد به كالكثير ويلحق بذلك ما لو احتقن بها في المنصوص كما لو استعط أو عجن به دقيقا فأكله ونقل حنبل أو تمضمض حد وذكره في الرعاية قولا وهو غريب وفي المستوعب إن وصل جوفه حد وفي عيون المسائل يثبت بعدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب لأن كل مسكر يوجب الحد فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما فعليه الحد ثمانون جلدة قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لإجماع الصحابة لما روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضربه عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام وروي أن عليا قال في المشورة إذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون رواه الجوزجاني والداقطني وجوزهما الشيخ تقي الدين للمصلحة وأنه الرواية الثانية وعنه أربعون إن كان حرا اختاره أبو بكر والمؤلف وغيرهما لما روي أن على بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم لا يقال فعل عمر كان بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا ولأن فعله عليه السلام حجة لا يجوز تركه لفعل غيره ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة أبي بكر وعلي بل يحتمل أن عمر فعل الزيادة على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآها الإمام

وضرب علي النجاشي بشربه في رمضان ثمانين ثم حبسه ثم عشرين من الغد نقل صالح أذهب [ج ٩ - ص ١٠٣]

إليه ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل وفي المغني عزره بعشرين لفطره والرقيق عبدا كان أو أمة على النصف من ذلك كالزنى والقذف فكذا من شرب الخمر من باب أولى فعلى الأولى يحد أربعين وعلى الثانية عشرين صرح به في المغني والشرح إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب لأنه يعتقد حله فلم يحد بفعله كنكاح المجوس ذوات محارمهم والثانية بلى لأنه شرب مسكرا عالما به مختارا أشبه شارب النبيذ إذا اعتقد حله قال في المحرر وعندي يحد إن سكر وإلا فلا والمذهب خلافه قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه وهل يجب الحد بوجود الرائحة على روايتين

أظهرهما لا يجب وقدمه في الكافي والرعاية والفروع وهو قول أكثر العلماء فعلى هذا يعزر نص عليه واختاره الخلال كحاضر مع من يشربها نقله أبو طالب

والثانية أنه يحد قال ابن أبي موسى في الإرشاد وهي الأظهر عنه روي عن عمر وابن مسعود لأن الرائحة تدل على شربه لها فجرى مجرى الإقرار قال في الشرح والأول أولى لأن الرائحة تحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب تفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر والحد يدرأ بالشبهة

فائدة يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة وعرق البنفسج والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية [ج ٩ - ص ١٠٤]

فرع إذا وجد سكران أو تقيأ الخمر فعنه لا حد قال بعضهم وهي الأظهر وعنه بلى على الثانية التي يحد بالرائحة لفعل عثمان وهو بمحضر من الصحابة رواه مسلم

تنبيه لا يثبت الحد إلا بأحد شيئين إما البنية العادلة أو الإقرار ويكفي مرة كحد القذف وعنه مرتين نصره القاضي واصحابه وجعل أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه وهذا متجه قاله في الفروع والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام زاد بعضهم بلياليها حرم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء ثالثة ثم يأمر به فيسقي الخدم أو يهراق رواه مسلم وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال في ثلاث قال أحمد فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تشربه ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبا إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه إذا غلى العصير وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر فإذا أسكر فحرام وعنه الوقف فيما نش وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا لقوله عليه السلام اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولأن علة التحريم الشدة المطربة وذلك في المسكر لا غيره

وأجاب عن إطلاق أحمد بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا

[ج ٩ - ص ١٠٥]

فرع إذا طبخ منه قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نقله الجماعة وذكره أبو بكر إجماع المسلمين قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلا فقال إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال لا بأس قال يقولون إنه يسكر فقال لا لو كان يسكر ما أحله عمر وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير وإنه إن صب فيه خل أكل ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته لما روي أنه عليه السلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه ما لم يشتد عليه أو يأتي عليه ثلاث تمام نص عليه ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ونقل ابن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة وشربه عشية وبالعكس هذا نبيذ أكرهه ولكن يطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس بنبيذ فإن غلي العنب وهو عنب فلا بأس به نقله أبو داود فرع أذا سكر من النبيذ فسق وكذا إن شرب قليله على الأصح ولا يكره الانتباذ في الدباء وهي القرعة اليابسة المجعولة وعاء والحنتم وهي جدار مدهونة واحدتها حنتمة والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه التمر فعيل بمعنى مفعول والمزفت وهو الوعاء المطلي بالزفت نوع من القار لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا رواه مسلم وعنه يكره قال الخلال وعليها العمل لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها وعنه يحرم ذكرها في الهدي والأول أصح لأن دليله ناسخ وعنه وغيره من الأوعية

إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب أو المذنب وحده نقله الجماعة لما روت عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة رواه أبو داود وابن ماجة فلما كانت مدة الإنباذ قريبة وهي يوم أو ليلة لا يتوهم الإسكار فيها فعلى هذا لا يكره ويكره إذا كان في مدة تحتمل إفضاؤه إلى الإسكار لأنه عليه السلام نهى عن الخليطين وأدنى أحوال النهي الكراهة وعنه يحرم واختاره في التنبيه لما روى أبو قتادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة متفق عليه وعنه لا يكره اختاره في الترغيب واختاره في المغني ما لم يحتمل إسكاره قال القاضي هو حرام إذا اشتد واسكر وإذا لم يسكر لم يحرم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ولا بأس بالفقاع أي يباح ولا أعلم فيه خلافا لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي وليس المقصود منه الإسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة وعنه يكره وعنه يحرم ذكرها في الوسيلة والمذهب الأول وسئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء أما ما كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع فلو وضع فيه ما

يحمضه كالخل والليمون كما يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقا فإن حموضته تمنعه أن يشتد والله أعلم [ج ٩ - ص ١٠٧]

باب التعزير

التعزير في اللغة المنع يقال عزرته أي منعته ومنه سمي التأديب ولأنه يمنع من تعاطي القبيح ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه منع لعدوه من أذاه وقال السعدي يقال عزرته ووقرته وأيضا أدبته وهو من الأضداد وهو طريق إلى التوقير لأنه إذا امتنع به وصرف عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة وهو التأديب فبيان لمعنى التعزير وفسره في المغني بالعقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها وهو قريب مما ذكره هنا قاله ابن المنجا وفيه نظر وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وكذا ذكره في المحرر والوجيز وغيرهما من كتب الأصحاب قال الشيخ تقي الدين إن عنى به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع وإن عنى فعل المحرمات فقط فغير جامع بل التعزير على ترك الواجبات أيضا ولأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإدا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير لتحقيق المانع من فعلها وفي الشرح هو واجب إذا رآه الإمام فيما شرع فيه التعزير وعنه يعزر المكلف ندبا نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان والأشهر كما ذكره المؤلف ونص عليه الإمام في سب صحابي كحد وكحق آدمي طلبه وقولنا ولا كفارة فيه فائدته في الظهار وشبه العمد لكن يقال يجب التعزير فيه لأن الكفارة حق الله تعالى [ج ٩ - ص ١٠٨]

بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لأجل الفعل بل بدل النفس الفائتة فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يتلف شيئا استحق التعزير ولا كفارة ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام لا في اليمين الغموس إذ وجبت الكفارة لاختلاف سببها لأن سبب الكفارة الحنث ويمين الغموس كذبة نزلت منزلة الحنث وسبب التعزير شيء آخر وهو إقدامه على الحلف كذبا وحاصله أن ما كان من التعزير منصوصا عليه وجب وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحد وإن رأى العفو جاز للأخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الإمام فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره وإلا وجب وقال القاضي ومن تبعه إلا أذا شتم نفسه أو سبها ولا يحتاج إلى مطالبة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد لأنه عليه السلام جعله سيئة وإتيان المرأة المرأة لقوله عليه السلام إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان وسرقة ما لا يوجب القطع لدخوله في قوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه والجناية على الناس بما لا قصاص فيه لأنه تعد على الغير أشبه التي فيها القصاص لا يقال القياس يقتضي مشروعية القصاص في ذلك أيضا والتقدير خلافه لأنه تعذر القصاص لمعنى يختص به وهو لا يمنع من ثبوت الحرمة لأن

الجناية تقتضي الإيجاب مطلقا ترك العمل به لما ذكرنا فيبقى

[ج ٩ - ص ١٠٩]

ما عداه على مقتضاه والقذف بغير الزنى بأن يرميه بالكذب أو بالفسق فعلى هذا إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه فدل أنما رآه تعين فلا يبطله غيره وأنه يتعين قدر تعزير عينه ونحوه روي عن علي أنه سئل عن قول الرجل لآخر يا خبيث قال هو فاسق فيه تعزير وهذا كله معصية لله تعالى لأنه إما جناية على الشرع أو على آدمي والجناية على الآدمي عمدا محرمة وفاعلها مقدم على مخالفة الله تعالى بأدى المسلمين فيكون واجبا كالحد ومن وطىء أمة امرأته فعليه الحد لحديث النعمان بن بشير ولأنه وطء في فرج في غير عقد ولا ملك فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته إلا أن تكون قد أحلتها له فيجلد مائة ولا رجم ولا تغريب لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال أنا أتقى هذا الحديث وقال الخطابي ليس بمتصل وقال غيره رجاله ثقات إلا حبيب ابن سالم قال البخاري فيه نظر وقد روى له مسلم ووثقه أبو حاتم وعنه يعزر مائة إلا سوطا وعنه يعزر بعشر وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين

إحداهما يلحقه جزم بها في الوجيز كوطء الجارية المشتركة

والثانية لا يلحقه الولد نقله الجماعة قال أبو بكر العمل عليه لأنه وطء لا في ملك ولا شبهة ملك أشبه الزنى المحض وقال الشيخ تقي [ج ٩ - ص ١١٠]

الدين إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده وعنه يحد فلا يلحقه لعدم حلها ولو ظن حلها نقله مهنا ولا يسقط الحد بالإباحة لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني في غير هذا الموضع وهو إباحة الزوجة أمتها لزوجها وإنما سقط الحد هنا لحديث النعمان

تنبيه نقل الميموني فيمن زنى صغير لم ير عليه شيئا ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل يا زاني ليس قوله شيئا وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وذكر الشيخ تقي الدين أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع وفي الواضح من بلغ عشرا صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ومثله زناه وهو ظاهر كلام القاضي وظاهر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاشتفاء المظلوم وأخذ حقه قال في الفروع فيتوجه أن يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر لم نكب اصبع الرجل قال الشيخ تقي الدين القصاص موافق لأصول الشريعة ولا يزاد في التعزير على عشر

جلدات في غير هذا الموضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا [ج ٩ - ص ١١١]

في حد من حدود الله تعالى متفق عليه من حديث أبي بردة ونص عليه أحمد في مواضع وجزم به في الوجيز والمراد عند الشيخ تقي الدين إلا في محرم لحق الله تعالى وعنه يتبع قال بعضهم ولا وجه له وعنه لا يبلغ به الحد جزم به الخرقي وقدمه في المذهب والمحرر فيحتمل أنه أدلى حد مشروع وهو قول الأكثر ويحتمل أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما كجارية ولده أو أحد أبويه والمحرمة برضاع وميتة عالما بتحريمه ضرب مائة لما سبق من حديث النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها فيتعدى إلى وطء أمته المشتركة والمزوجة لأنها في معناها وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد والمذهب كما قاله القاضي أنه لا يزاد على عشر فأقل إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة إلا سوطا نقله الجماعة وما عداه يبقى على العموم لحديث أبي بردة قال في المغني والشرح وهذا قول حسن ويسقط عنه النفي أي يضرب مائة جلدة بلا نفي وله نقصه ويرجع في أقله إلى اجتهاد الإمام مع أنه اختار طائفة من أصحابنا أنه يقتل للحاجة وأنه يقتل مبتدع داعية ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش في الدعاة من الجهمية وعن أحمد وكذا كل وطء في فرج وهي أشهر عند جماعة وعنه أو دونه نقله يعقوب جزم به في

المذهب والمحرر وغيرهما واحتج بأن عليا وجد رجلا مع امرأة في

[ج ٩ - ص ١١٢]

لحافها فضربه مائة والعبد بخمسين إلا سوطا وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة إذا قلنا إنه لا يحد بل يعزر لأنه وطء في فرج أشبه وطء أمة امرأته وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وكتب عمر إلى أبي موسى لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود

تنبيه التعزير يكون بضرب وحبس وتوبيخ وقيل في حق الله تعالى وحده ولا يقطع عضوا ولا يجرحه ولا يأخذ ماله وإن عفا عنه مستحق الحد سقط مع التعزير وإن عفا مستحق التعزير لم يسقط

فائدة من عرف بأدى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي للوالي فعله وفي الترغيب للإمام حبس العائن قال بعضهم ولا يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا وفيه نظر

ومن استمنى بيده لغير حاجة حرم وعزر لأنه معصية ولقوله تعالى ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ المؤمنون 5 ولحديث رواه الحسن ابن عرفة في جزئه وعنه يكره تنزيها نقل ابن منصور لا يعجبني بلا ضرورة قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به وعنه يحرم مطلقا ونقله البغوي في تفسيره عن أكثر العلماء وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شيء ففعله خوفا على دينه

أولى ويجوز في هذه الحالة وهذا إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نص عليه وعنه [ج ٩ - ص ١١٣]

يكره والمرأة كالرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل

فرع لو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء اتفاقا

باب القطع في السرقة

وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ المائدة 38 ولقوله عليه السلام في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا إلى غيره من النصوص ولا يجب القطع إلا بسبعة أشياء يأتي حكمها

أحدها السرقة لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا وهي أخذ المال أي المحترم على وجه الاختفاء هذا بيان لمعنى السرقة ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك وشرطه أن يكون عالما به وبتحريمه من مالكه أو نائبه نص عليه وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه والأصح ولو من غلة وقف وليس من مستحقه وهو مكلف مختار وعنه أو مكره ولا قطع على منتهب لما روى جابر مرفوعا قال ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن لقوله عليه السلام ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير لأن [ج ٩ - ص ١١٤]

لا جاحد وديعة ولا عارية وعنه يقطع جاحد العارية ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه [ج ٩ - ص ١١٥]

وعنه لا يقطع .

فصل

الثاني أن يكون المسروق مالا محترما سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا ، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب

++++++++++++++++++++++++++++++++على وجه

الاختفاء أشبه السارق وسواء بط ما أخذ منه أو قطعه فأخذه فعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع نص عليه وعنه لا يقطع لأنه لا يسمى سارقا كالمختلس

فصل

الثاني أن يكون المسروق مالا لأن ما ليس بمال لا حرمة له فلم يجب به قطع والأحاديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به لا يقال الآية مطلقة لأن الأخبار مقيدة به فيحمل المطلق على المقيد فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما لأنه ليس بمال ولا بحر لما يأتي محترما لأنه إذا لم يكن كذلك كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب لعموم قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما ﴾ المائدة 38 ولقوله عليه السلام في الثمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده ورواه الشافعي عن مالك وقال هي الأترجة التي يأكلها الناس ولأن هذا مال يتمول [ج ٩ - ص ١١٦]

ويقطع بسرقة العبد الصغير ، ولا يقطع بسرقة حر ، وإن كان صغيرا ، وعنه أنه لا يقطع بسرقة الصغير فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع ++++++++++++++عادة ويرغب فيه فيقطع سارقه كالمجفف وسواء كان أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن ونورة وفخار وزجاج وملح وفيه وجه وسرجين طاهر والأظهر وثلج وفي ماء وجهان وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان ونقل ابن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا قال في الفصول قال شيخنا لعله أخذه من غير حرز وفيه نظر إذ كل الأموال كذلك وعندي أن قصد الأشياء المباحة في الأصل كالصيود وما شاكلها لا قطع فيها وفي الروضة إن لم يتول عادة كماء وكلإ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامتهم لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات والمراد به غير المميز لأن مثل ذلك لا يفهم ولا يميز بين سيده وغيره فإن كان كبيرا عاقلا لم يقطع بسرقته إلا أن يكون نائما أو مجنونا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة فيقطع سارقه كأعجمي لا يميز ولو كان كبيرا وفي الشرح إن كان المسروق في حال نومه أو جنونه أو أم ولد فوجهان وفي الكافي لا يقطع كبير أكرهه وفي الترغيب في عبد نائم وسكران وجهان $ فرع إذا سرق المكاتب لم يقطع بخلاف ماله إلا أن يكون سيده هو السارق ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا في ظاهر المذهب وهو قول أكثرهم لأنه ليس بمال أشبه الكبير وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير كالمجنون لأنه

مسروق أشبه المال والبهيمة وجوابه أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي أو [ج ٩ - ص ١١٧]

فعل يقطع على وجهين ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع ويقطع ويقطع بسرقة سائر كتب العلم ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر وإن++++++++++++++++++++++++++++ ثياب تبلغ قيمتها نصابا فهل يقطع على وجهين

أحدهما وقدمه في الشرح لا قطع لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له وكذا لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه وثيابه لم يقطع لأن يده عليه

والثاني يقطع وجزم به في الوجيز لظاهر الآية وكما لو سرقه مفردا ولا يقطع بسرقة مصحف في قول أبي بكر والقاضي لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه وعند أبي الخطاب يقطع وهو ظاهر كلام أحمد جزم به في الوجيز لعموم الآية والأخبار وكتب التفسير والفقه وقيل إن سرقه ذمي قطع وإن سرقه مسلم فوجهان فإن قلنا لا يقطع وعليه حلية تبلغ نصابا فوجهان ويقطع بسرقة سائر كتب العلم المباحة لأن ذلك مال حقيقة وشرعا وقيل إن سرق كتاب فقه أو حديث يحتاجه لم يقطع وذكر القاضي في الخلاف أنه لا يقطع إلا بسرقة دفاتر الحساب وعلم منه أنه لا يقطع بسرقة كتب البدع والتصاوير وهو كذلك ولا يقطع بسرقة آلة لهو كطنبور ومزمار ونحوه ولو بلغت قيمته مفصلا نصابا لأنه معصية

إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر وقيل إن سرقه وكسره لم يقطع وإلا قطع فإن كان عليه حلية تبلغ نصابا فوجهان

أحدهما وهو قياس قول أبي بكر لا قطع لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب والأوتار

والثاني وقاله القاضي يقطع لأنه سرق نصابا من حرز أشبه المفرد ولا محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها سواء سرقه من مسلم أو كافر لأنها

الثالث

أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض وعنه [ج ٩ - ص ١١٨]

سرق إناء فيه خمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع وعند أبي الخطاب يقطع

الفصل

عين محرمة فلم يقطع بسرقتها كالخنزير ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال مسلم لا يقطع بسرقته من الذمي كالدم وعنه ولم يقصد سرقة وفي الترغيب مثله في إناء نقد وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة للصوفية يحتمل كآلة لهو ويحتمل القطع وإن سرق إناء فيه خمر لم يقطع على المذهب لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره بحيث تبلغ قيمته بالشركة نصابا قال في المستوعب لو سرق إناء فيه ماء أو خمر لم يقطع على قول أكثر أصحابنا أو صليبا أو صنم ذهب أو فضة وعبارة الفروع أو صنم نقد وهي أولى لم يقطع وهو قول القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وعند أبي الخطاب يقطع وهو ظاهر كلام أحمد ووجههما ما سبق في سرقة آلة لهو وهذا بخلاف ما لو كسر آلة النقدين بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ولأنهما جوهران يغلبان على الصنعة ولأنه مجمع على تحريمه وكذا يقطع بإناء نقد بها تماثيل وقيل إن لم يقصد إنكارا

فصل

الثالث أن يسرق نصابا فلا قطع بسرقة دون النصاب في قولهم إلا الحسن وابن بنت الشافعي فإنه يقطع في القليل كالكثير لعموم الآية وجوابه قوله عليه السلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وهو إجماع الصحابة وما روي أنه عليه السلام قال لعن الله السارق تقوم العروض إلا بالدراهم وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته [ج ٩ - ص ١١٩]

أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما وعنه لا يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده محمول على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصابا أو أن المراد بالبيضة بيض النعام لما فيه من الجمع بين الأدلة وهو ثلاثة دراهم لأن غيرها يقوم بها لما يأتي فلان يقطع بها نفسها بطريق الأولى أو قيمة ذلك من الذهب والعروض لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم متفق عليه قال ابن عبد البر هذا أصح حديث روي في هذا الباب وفيه على أن العرض يقوم بالدراهم لأن المجن قوم بها وأما كونه يقوم بالذهب فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا كنصاب الزكاة والديات وقيم المتلفات وقد روى أنس أن سارقا سرق مجنا يساوي ثلاثة دراهم فقطعه أبو بكر وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطع وقال علي فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع ويعتبر في الدراهم أن تكون خالصة فلو كانت مغشوشة فلا خلافا للشيخ تقي الدين فيها وعنه أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما نصره القاضي في الخلاف وذكر في الكافي أنها أولى وقدمها في الرعاية والفروع وجزم بها في الوجيز لخبر عائشة ولقوله اقطعوا في ربع دينار لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر رواه أحمد وهذا تقييد لإطلاق الآية قوله يبلغ إلى أخره أي يسرق عرضا قيمته كأحدهما وعنه لا تقوم العروض إلا

بالدراهم لأن التقويم حصل بها لا بالذهب واختلف في الذهب هل هو أصل في القطع نفسه فعنه نعم وهو المذهب وعنه [ج ٩ - ص ١٢٠]

أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع وإن دخل الحرز فذبح لا فعلى هذه يقوم بالدراهم فما ساوى منه ثلاثة دراهم قطع به وإن لم يبلغ ربع دينار وما لا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع به وإن بلغ ربع دينار وعلى المذهب أقله ربع دينار فلو كان دونها ويساوي ثلاثة دراهم لم يقطع وعلى هذا هو أصل في التقويم وهو اختيار ابن عقيل والمؤلف لأنه أحد النقدين فكان التقويم به كالآخر وعلى الثانية ليس بأصل وإنما الأصل الدراهم وعلى الأول متى بلغت قيمة المسروق أدنى الناصبين قطع وعلى الأخرى الاعتبار بالدراهم فقط وفي تكميله بضم من النقدين وجهان ويكفي تبر في المنصوص أي يكفي وزن التبر اقتصر عليه في الكافي وقدمه في الرعاية وقيل تعتبر قيمته بالمضروب وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أي بعد الإخراج لإن النقصان وجد في العين بعد استحقاقها القطع أشبه ما لو نقص باستعماله ولأنه تعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من الحرز وهو موجود أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع لما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول الله لم إن هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به رواه ابن ماجة ولأن النصاب شرط فلم تعتبر استدامته كالحرز لكن إن ملك العين قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع بغير خلاف علمناه قال أحمد إذا رفع إليه لم يكن

لرافعه عفو وظاهر الواضح وغيره قبل الحكم قال أحمد تدرأ الحدود بالشبهات فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك وقال أبو بكر منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر لم يقطع وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء اخرجوه جملة أو اخرج كل واحد جزءا وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فاخرج أحدهما نصبا وحده أو دخل أحدهما [ج ٩ - ص ١٢١]

شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم اخرجها لم يقطع وإن سرق فرد خف قيمته وجزم به آخرون لو ملكه سارقه قطع وجزم به ابن هبيرة عن أحمد وإن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجها لم يقطع لأن من شرط وجوب القطع أن يخرج من الحرز العين وهي نصاب ولم يوجد وإن كانت قيمتها مذبوحة نصابا قطع بإخراجها وإن قلنا إنها ميتة فلا وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا والمشروط عدم عند عدم شرطه فلو كانت قيمة كل منهما منفردا درهما ومعا عشرة غرم ثمانية المتلف ونقص التفرقة وقيل درهمين وكذا جزءا من كتاب ذكره في التبصرة فرع إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت إلا بها ففي الزامه ما تضمنته احتمالان أقواهما يلزمه ومثله يتعلق بالضمان في كتمان الشهادة ويقطع بسرقته منديلا بطرفة دينار مشدود يعلمه وقيل أو يجهله صححه في المذهب كجهله قيمته

إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ذكره الخرقي والأصحاب كهتك الحرز وكالقصاص سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا نص عليه لأنهم اشتركوا في هتك الحرز واخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلا فحملوه وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثلة ولا توجد المماثلة إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وهنا القصد الزجر من غير اعتبار مماثلة وعنه يقطع من أخرج نصابا وهو قول أكثرهم قال في المغني وهذا

فأخذه الاخر فالقطع على الداخل وحده وإن نقب أحدهما ودخل

[ج ٩ - ص ١٢٢]

فقدمه إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج أحب إلي لأن القطع هنا ليس هو في معنى المجمع عليه فلا يجب والاحتياط في سقوطه أولى من الاحتياط في إيجابه لأنه مما يدرأ بالشبهة وقيل إن لم يقطع بعضهم لشبهة فلا قطع قال في المستوعب والأول أصح وعليه التفريع فإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته منه لولادة أو سيادة أو عدم تكليف قطع غيره في الأصح إن أخذ نصابا وقيل أو أقل ولم يذكر في المستوعب والمحرر إلا أن أحدهم إذا لم يقطع قطع الأجنبي فلو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ولم يقر الآخر ففي القطع وجهان

فرع إذا سرق نصابا لجماعة من حرز قطع على الأصح فلو سرق ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد لم يقطع ذكره في المستوعب والرعاية

وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده قطعا نص عليه لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وجها واحدا قاله في المستوعب لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع كما لو حملاه وأخرجاه وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج وفيه في الترغيب وجهان وإن شده بحبل فأدخل الآخر يده فأخذه أو جذب الحبل قال في الرعاية أو أخذه الذي رماه قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا أو أعاده فيه أحدهما فالقطع على الداخل وحده وإن اشتركا

في النقب لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به لا يقال هما اشتركا في ويأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا يقطع

فصل الرابع

أن يخرجه من الحرز فإن سرق من غير حزر أو دخل الحرز فأتلفه فيه فلا قطع عليه [ج ٩ - ص ١٢٣]

الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ويحتمل أن يقطعا إلا أن ينقب أحدهما ويذهب الهتك لأن شرطه الاشتراك في الهتك والاخراج ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه وفي الترغيب وجه هما وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز وقيل بلى إن تواطئا على السرقة قاله في الوجيز وهو ظاهر ويحتمل أن يقطعا لأن فعل كل منهما وقع بقوة الآخر أشبه ما لو اشتركا في النقب والإخراج إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ويأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا يقطع وجها واحدا لأنه لم يهتك الحرز ومن شرط وجوب القطع هتكه

مسائل إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها فروايتان وإن فتح هو بابها فوجهان وإن كان وحده مفتوحا قطع وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا وفي الكافي والشرح إنه إن كان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه وإلا فلا وكذا الخان في الأقيس قاله ابن حمدان وإن تطيب في الحرز بطيب ثم خرج ولو اجتمع فبلغ نصابا فاحتمالان وإن لم يبلغ نصابا فلا قطع في الأشهر لأنه حين إخراجه ناقص عن نصاب

فصل الرابع

أن يخرجه من الحرز في قول أكثرهم وعن عائشة والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع قال سعيد ثنا هشيم به أو في ماء

جار فأخرجه أو قال لصغير أو معتوه أدخل فأخرجه [ج ٩ - ص ١٢٤]

وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت أنا يحيي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال ذكر لعائشة قول من يقول لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع فقالت عائشة لو لم أجد إلا شفرة لحززت بها يده وعنه لا يشترط الحرز قال ابن المنذر ليس فيه خبر ثابت والأول شبيه بالإجماع لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجة وبهذا تخص الآية كما خصصناها بالنصاب فإن سرق من غير حرز أو دخل الحرز فأتلفه فيه بأكل أو غيره فلا قطع عليه لفوات شرطه لكن يلزمه ضمانه لأنه اتلفه ولا يقطع حتى يخرجه من الحرز سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به من الحرز فعليه القطع أشبه ما لو أخرجه في كمه وكلامه شامل ما إذا خرجا منه أو لا لكن إن لم يخرج ما ابتلعه فلا قطع ذكره في الكافي والشرح وهو قول القاضي وابن عقيل وقيل يقطع قدمه في المحرر والرعاية وإن خرج منه فقيل يقطع كما لو أخرجه من كمه وقيل لا لأنه ضمنها بالبلع فكان إتلافا لها لا سرقة أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به من غير سوقها لأن العادة مشي البهيمة بما وضع عليها أو في ماء جار وقيل وراكد فأخرجه المتاع إلى حائل من الدار فأطارته الريح فهذا فيه وجهان

أحدهما لا قطع لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج وإنما هو بسبب حادث من غير فعله

والثاني يقطع لأن فعله سبب خروجه أشبه الأموال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر [ج ٩ - ص ١٢٥]

ففعل فعليه القطع وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف ما لو ساق البهيمة

فرع إذا رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته أو فتح طاقا فسقط منه طعام أو غيره قدر نصاب أو أخرجه من الحرز ورماه خارجا عنه أو رده إليه قطع لأنه متى ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح كما لو رمى صيدا فأعانت الريح السهم حتى قتل فإنه يحل ولو رمى الجمار فأعانتها الريح حتى وقع في المرمى احتسب به أو قال لصغيره أو معتوه ادخل فأخرجه ففعل فعليه القطع لأنه لاختيار لهما فهما كالآلة ولو أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر

تنبيه إذا أخرج خشبة أو بعضها من الحرز لم يقطع لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذا لو أمسك عمامة وطرفها في يد صاحبها وإن أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه وقرب قطع وكذا إن بعد في وجه وقدمه في الترغيب وقيل إن كان في ليلة قطع لا ليلتين وإن علم المالك بهتكه وأهمله فلا قطع قال القاضي قياس قول أصحابنا يبنى فعله على فعل غيره ولو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا قطع

فرع إذا علم قردا السرقة فالغرم فقط ذكره أبو الوفا وابن الزاغوني وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه لأنه لما لم يثبت في الشرع علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه طريق إلى معرفته فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض

والفرقة في البيع وأشباه ذلك إليه هذا ظاهر قول أصحابنا فحرز الأثمان البقل والباقلاء ونحوه وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر [ج ٩ - ص ١٢٦]

والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة وحرز والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وهو اسم للقفل خشبا كان أو حديدا أو يكون فيها حافظ لأن العادة في حرز ذلك بذلك وفي الترغيب وغيره في قماش غليظ وراء غلق وفي تفسير ابن الجوزي ما جعل للسكنى وعن أحمد في البيت الذي ليس عليه غلق فسرق منه أراه سارقا وهذا محمول على أن أهله فيه فإن كانت الأبواب مفتوحة وفيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها والبيوت التي في البساتين أو الطرق أو الصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرزا وإن كانت مغلقة وفيها حافظ فهي حرز وإن كان نائما وإن كانت مفتوحة فلا إلا أن يكون الحافظ يقظان

تتمة الخيمة والحركاة كذلك سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر بالبناء فإن سرق صندوقا فيه متاع أو دابة عليها متاع ولا حافظ لم يقطع وإن سرق المتاع الذي فيه قطع وعنه إن الصناديق التي في السوق وإن حملت كما هي قطع وحمله القاضي وابن عقيل على أن معها شيئا وحرز البقل والباقلاء ونحوه وقدوره وراء الشرائج واحدها شريجة وهو شيء يعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره إذا كان في السوق حارس لأن العادة جرت بإحرازها به وحرز الخشب والحطب والقصب الحظائر واحدتها حظيرة وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي اليه وأصل الحظر المنع فيعبىء بعضه على بعض

ويقيده بقيد بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة إلا أن يكون في فندق مغلقا بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها وحرز الثياب في الحمام بالحافظ [ج ٩ - ص ١٢٧]

وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها وحرز حمولة الإبل عليه فيكون محرزا وإن لم يقيد ذكره في الكافي والشرح وفي التبصرة حرز حطب تعبئته وربطه بالحبال وكذا ذكره أبو محمد الجوزي

فرع حرز السفن في الشط بربطها

وحرز المواشي جمع ماشية الصير واحدها صيرة وهي حظيرة الغنم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها لأن العادة حرزها بذلك فما غاب عن مشاهدته فقد خرج عن الحرز لأن الراعية هكذا تحرز وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها وجملته أن الإبل تنقسم إلى ثلاثة أقسام باركة وراعية وسائرة فحرز الباركة المعقولة بالحافظ يقظان كان أو نائما لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام فإن لم تكن معقولة فحرزها بحافظ يقظان وحرز الراعية بنظر الراعي إليها فما غاب عن نظره أو نام عنها فليس بمحرز لأن الراعية إنما تحرز بالراعي ونظره إليها وحرز السائرة الحمولة بسائق يراها مقطرة كانت أو غير مقطرة أو بتقطيرها مع قائد يراها وفي الترغيب والشرح يكثر الالتفات إليها ويراها إذا التفت وأما الأول منها فهو محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد ولو سرق مركوبه من تحته فلا قطع وفيه احتمال وإن سرقه براكبه الرقيق وهما يساويان صابا قطع وإن كان حرا ومعه ما يساوي نصابا فوجهان وحرز الثياب في الحمام بالحافظ جزم به المؤلف وفي الوجيز وقدمه في الفروع كما لو كان في

البيت وعنه لا قطع إلا أن يكون على المتاع قاعد صححه المؤلف لأنه مأذون [ج ٩ - ص ١٢٨]

وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع وحرز للناس في دخوله فجرى مجرى سرقة الضيف من البيت المأذون في دخوله ولأنه لا يمكن الحافظ من حفظه فيه وإن فرط في الحفظ فنام أو اشتغل فلا قطع ويضمن وفي الترغيب إن استحفظه ربه صريحا وفيه لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه وظاهره أنه إذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع في قول عامتهم فرع وحرز الثياب في أعدال أو غزل في سوق وخان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ على الأصح وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات

وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع روي عن ابن الزبير وقاله الحسن وعمر بن عبد العزيز لقول عائشة سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ولأنه سرق مالا محترما من حرز فوجب القطع به كغيره ولأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا وعنه لا قطع وعنه إلا أن يخرج الميت من القبر ويأخذه منه ذكرها في النهاية وظاهره لا فرق في القبر أن يكون في حرز أو لا كالصحراء قاله جماعة وفي الواضح من مقبرة مصونة بقرب البلد ولم يقل في التبصرة مصونة ولابد أن يكون الكفن مشروعا وأن يخرجه من القبر لأنه الحرز فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة والرابعة أو ترك معه طيبا فلا قطع في شيء من ذلك وفي الخلاف يقطع بسرقة الطيب لأنه من السنة وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان وعليهما هو خصمه فإن

عدم فنائب الإمام ولو كفنه يقطع بسرقة ستارتها وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين

[ج ٩ - ص ١٢٩]

الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأزيره قطع ولا أجنبي وقيل هو ويستثنى على المذهب ما إذا أكله ضبع فإن كفنه إرث ولايقطع سارقه وهل يفتقر في فقطع النباش إلى مطالبة فيه وجهان وحرز الباب تركيبه في موضعه مفتوحا كان أو مغلقا لأنه هكذا يحفظ وفي الترغيب حرز باب أو خزانة بغلقه أو غلق باب الدار عليه وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيه إذا كان في العمران أو في الصحراء إذا كان ثم حافظ فإن أخذ شيئا من الجدار أو خشبة تبلغ نصابا قطع وإن هدم الحائط ولم يأخذه فلا قطع وأبواب الخزائن في الدار إن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة وإن كان مفتوحا فلا إلا أن يكون فيها حافظ فرع حلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة وإلا فلا

فلو سرق رتاج الكعبة وهو بابها العظيم ويقال أرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة

أو باب مسجد أو تأزيره وهو ما جعل من أسفل حائطه من لباد أو دفوف ونحوه قطع كباب بيت الآدمي والمطالبة بذلك للإمام أو من يقوم مقامه وقيل لا قطع لأنه ينتفع بهما الناس فيكون له فيه شبهة كالسرقة من بيت المال وقيل لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها في الأصح ولا يقطع بسرقة ستارتها أي الخارجة منها نص عليه وهو ظاهر المذهب قاله ابن الجوزي كغير المخيطة ولأنها غير محرزة وقال القاضي يقطع بسرقة

المخيطة عليها وهو رواية وقدمه في الرعاية لأن ذلك حرز مثلها في العادة وحمل ابن حمدان النص على غير المخيطة وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين

أحدهما يقطع لأن المسجد حرز لها فقطع كالباب

والثاني لا وهو الأصح وجزم به في الوجيز كالسرقة من بيت المال وذكره

[ج ٩ - ص ١٣٠]

وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع وإن مال رأسه عنه لم يقطع في المغني وجها واحدا والأشهر أنه لا يقطع إذا كان السارق مسلما وفي الكافي إنه إذا سرق قناديل مسجد أو حصره ونحوه مما جعل لنفع المصلين فلا قطع وإن نام إنسان على ردائه في المسجد أو غيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله فسرقه سارق قطع لما روى صفوان بن أمية انه نام في المسجد على ردائه فأخذه من تحت رأسه سارق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه رواه أبو داود وظاهر كلامهم لا فرق بين أن يكون في البلد أو برية وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته لأنه لم يبق محرزا وفي المستوعب أنه يجب القطع ما دام عليه شيء من أعضائه حال نومه فإن انقلب عنه ولم يبق عليه شيء من أعضائه فلا ذكره في الرعاية وجها وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع لأن حرزه بحافظه وإلا فلا أي إذا لم يكن ثم حافظ فلا قطع لأنه مال غير محرز وفي المحرر هل حرزه بحافظ أم لا فيه روايتان ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه وفاقا وقال أبو ثور إن كان من بستان محرز ففيه القطع وقال ابن المنذر لظاهر الآية وكسائر المحرزات وجوابه ما روي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وظاهره ولو كان عليه حائط وحافظ لكن إن كانت الشجرة في داره وهي محرزة فسرق منها نصابا قطع ويضمن عوضها مرتين

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب [ج ٩ - ص ١٣١]

وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر بفيه من ذي حاجة غير متخذ غبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه وقال أكثر العلماء لا يجب أكثر من مثله قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بوجوب غرامة مثليه واحتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من ميزنة مثلي قيمتها رواه الأثرم قال القاضي في الخلاف وفي هذا دلالية على أن السرقة في عام المجاعة يضاعف الغرم فيها على قول أحمد ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ عليه في القيمة ردعا له وزجرا بخلاف بقية المواضع فإنها في العادة محرزة فاليد لا تسرع إليها ومقتضاه وإن كان المأخوذ دون نصاب ومن غير حرز وقاله القاضي والزركشي فرع لا قطع في عام مجاعة غلاء نص عليه إذا لم يجد ما يشتريه أو يشتري به قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال وفي الترغيب ما يحيي به نفسه وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر لأن الشرع ورد من غير تفصيل وحمله أبو الخطاب على قوة السلطان وعدله وبسط الأمن والأصح الأول لأنه إنما رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة فالجواهر لا تحرز في الصير فإن أحرزها فيها عد مفرطا فكان العمل بالعرف أولى فرع قال أصحابنا في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها للخبر وما عدا هذين الموضعين لا

يضمن بأكثر من قيمته من مال أبيه وإن علا والاب والام في هذا سواء ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده [ج ٩ - ص ١٣٢]

فصل الخامس

انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا الولد أو مثله إن كان مثليا لأنه الأصل خولف في هذين للأثر وذهب أبو بكر إلى غرامة من سرق من غير حرز بمثليه وهو رواية وقدم في المحرر أنها تضاعف عليه القيمة نص عليه

فصل

الخامس انتفاء الشبهة لأن القطع حد فيدرأ بالشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل لأن له فيه شبهة لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك ولأنه أخذ ماله أخذه لقوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ولأنه يدرأ بالشبهة ولا الولد من مال أبيه وإن علا لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه فلم يقطع بالسرقة منه كالأب لأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال وعنه يقطع وهو ظاهر الخرقي لظاهر الآية ولأنه يقاد به ويحد بالزني بجاريته فيقطع بسرقة ماله كالإجنبي وجوابه ما سبق والزنى بجاريته ففيه منع وإن سلم فإنما وجب عليه الحد لأنه لا شبهة له فيها والأب والأم في هذا سواء لأنها أولى بالبر وإذا لم تكن فالمساواة والجد والجدة من قبلهما سواء ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده نص عليه لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمرو بن

الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي قد سرق فإقطع يده فقال عمر خادمكم أخذ مالكم وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع وقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك والمكاتب وأم الولد والمدبر كالقن ولا يقطع سيد بسرقة بالسرقة منه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده لم يقطع وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين [ج ٩ - ص ١٣٣]

ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع مال مكاتبه فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف وفي الانتصار فيمن وارثه حر يقطع ولا يقتل به وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله

ولا مسلم بالسرقة من بيت المال نص عليه لما روى ابن ماجة عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا وقال عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وقال سعيد ثنا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع وكذا لا يقطع بالسرقة من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء فلو سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع نص عليه قاله في المحرر والمذهب خلافه ولا من مال له فيه شركة كالمال المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شبهة فلأن لا يقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كمال مشترك لأبيه وابنه لأن له فيه شبهة لكون أبيه وابنه ونحوهما له فيه شركة ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أي لم تخمس أو لولده أو سيده لم يقطع لأن له في المال المسروق حقا أو شبهة حق وكل منهما يمنع الحد وحكى ابن أبي موسى أنه يحرق رحله كالغال وإن أخرج الخمس فسرق من الأربعة أخماس قطع

وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين وكذا في المحرر

إحداهما لا قطع اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع وذكر أنها اختيار الأكثر وهي قول عمر الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله [ج ٩ - ص ١٣٤]

ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال أقاربهم ويقطع المسلم بالسرقة من مال رواه سعيد بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط بماله أشبه الولد والوالد وكما لو منعها نفقتها قاله في الترغيب

والثانية يقطع كحرز مفرد قاله في التبصرة كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز عنه ولم يمنع الضيف قراه قال في الشرح وهي ظاهر الخرقي لعموم الآية وكالأجنبي وفرق قوم فقالوا يقطع الزوج بسرقة مالها لأنه لا حق له فيه بخلافها لأن لها النفقة فيه فأما إن لم يكن مال أحدهما محرزا عن الآخر فلا قطع رواية واحدة فرع لا تقطع الزوجة بسرقة نفقتها أو نفقة ولدها الواجبة مع منعها منهما سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه لأنها تستحق قدر ذلك فالزائد يكون مشتركا فاستحق أخذه ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم نصره القاضي والمؤلف وجزم به في الوجيز لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة فلا تمنع القطع ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه ما تقدم فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وقيل إلا ذي رحم محرم وفي الواضح قطع غير أب ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه لأن ماله صار معصوما بأداء الجزية فوجب القطع بسرقته كمال المسلم والمستأمن لأن ماله مال الذمي بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه ويقطعا 4 ن بسرقة ماله لأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهم فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى وكقود وحد قذف نص عليهما وضمان متلف وقال ابن حامد لا يقطع مستأمن كحد

خمر وزنى نص عليه بغير مسلمة وسوى في المنتخب بينهما في عدم بالسرقة وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع وقال القاضي يقطع [ج ٩ - ص ١٣٥]

ومن سرق عينا وأدعى أنها ملكه لم يقطع وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا القطع ومن سرق عينا أو بعضها وادعى أنها ملكه لم يقطع نصره القاضي في الخلاف وذكر أنها أصح وذكر ابن هبيرة أنها ظاهر المذهب وسماه الشافعي السارق الظريف لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد وعنه يقطع قدمها في المحرر والرعاية ولأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى عدم وجوب القطع فتفوت المصلحة بالكلية وذلك غير معتبر وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة اختاره في الترغيب للعلم بكذبه وكذا إذا ادعى أنه أذن له في دخول الدار ونقل ابن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه قال في الفروع ويتوجه مثله حد زنى وذكر القاضي وغيره لا يحد وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع لأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأن المال المسروق منه أخذ من غير حرز وقيل بلى إن تميز لأنه لا شبهة له فيه كما لا يجوز أخذ قدر ماله إذا عجز عن أخذه وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع لأنه لا شبهة له فيه إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع نصره المؤلف وغيره لأن بعض العلماء أباح له الأخذ فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة للحد كالوطء في نكاح مختلف في

صحته فإن سرق أكثر من حقه فهل يقطع هنا فيه وجهان وقال القاضي يقطع قدمه في الرعاية لأنه لا يجوز له مال المستعير أو المستأجر قطع

فصل السادس ثبوت السرقة

[ج ٩ - ص ١٣٦]

ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها قطع ومن آجر داره أو اعارها ثم سرق منها الأخذ قال في المغني وهذا لا يلغي الشبهة الناشئة عن الاختلاف ثم قال في الرعاية وقيل إن أخذه ولا بينة أو عجز عنه فلا وعلى كل حال لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم نص عليه ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها من ذلك المنزل أو غيره قطع لأنه لم ينزجر أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد القذف فإنه لا يعاد مرة أخرى لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر وهنا المقصود ردعه وزجره عن السرقة ولم يوجد فيردع بالثاني كما لو سرق عينا أخرى ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع لأنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة فيه فقطع كما لو سرق من ملكهما واختار ابن حمدان لا قطع على المعير لما تقدم ولأن هذا قد صار حرزا لملك غيره فلا يجوز له الدخول إليه وإنما يجوز له الرجوع في العارية وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع قال في الفنون له الرجوع بقول لا سرقة

تنبيه إذا تكرر منه السرقة قبل القطع قطع مرة قدمه في الرعاية وصححه في الشرح لأن القطع خالص حق الله تعالى فتداخل كحد الزنى والشرب وعنه إن سرق من جماعة وجاؤوا متفرقين لم تتداخل كحد القذف والفرق أن حد القذف حق لآدمي

فصل السادس ثبوت السرقة

لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق ولا يتحقق [ج ٩ - ص ١٣٧]

بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ذلك إلا بعد ثبوته بشهادة عدلين قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها شاهدان حران مسلمان بشرط أن يصفاها ولا تسمع قبل الدعوى في الأصح فإن كان المسروق منه غائبا فطالب وليه احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه بحيث يتميز عن غيره فإن وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بموتهما ولا غيبتهما فإن شهدت في غيبته ثم حضر أعيدت فإن اختلفا في الزمان والمكان والمسروق فلا قطع في قولهم جميعا وإن اختلفا في اللون أو قال أحدهما سرق هرويا وقال الآخر مرويا فوجهان أو إقرار مرتين لما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع رواه أبو داود وروي عن علي أنه قال لسارق سرقت قال فشهد على نفسه مرتين فقطع رواه الجوزجاني ولأنه يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنى أو يقال أحد حجتي القطع فيعتبر فيها التكرار كالشهادة ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة بخلاف إقراره بزني فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب بخلاف القذف لحصول التغيير وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه وصدقه المقر له على سرقة نصاب وفي المغني أو قال فقدته ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا بالقطع وعنه أو لم يطالبه اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنى أمة غيره وجب

قطعه وليس لحاكم حبسه قال في عيون المسائل لأنه لا يتعلق به حكم حاكم بخلاف السرقة فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس وإن كذب مدع أبو بكر ليس ذلك بشرط [ج ٩ - ص ١٣٨]

ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع

فصل السابع

مطالبة المسروق منه بماله وقال نفسه سقط قطعه ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع في قول أكثرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إخالك سرقت عرض له ليرجع ول لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة ولأن قطع السارق حد ثبت بالاعتراف فسقط بالرجوع كحد الزنى ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود

فائدة قال أحمد والأكثر لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره للآثار

فصل السابع

مطالبة المسروق منه بماله اختاره الخرقي ونصره القاضي في الخلاف والمؤلف في لمغني وذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على طائفة المسلمين أو على جماعة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة وقال أبو بكر ليس ذلك بشرط وهو رواية وصححها في الرعاية لعموم الآية ولأن موجب القطع السرقة وقد وجدت فوجب القطع من غير مطالبة كالزنى والفرق ظاهر لأن الزنى لا يستباح بالإباحة بخلاف السرقة ولأن القطع أوسع في الإسقاط لأنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع ولو زنى بجاريته حد ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق

فلم يستوف من غير مطالب به والزنى حق لله فلم يفتقر إلى المطالب به فعلى هذا لو قال المالك غصبتني ونحوه لم يقطع ولو كان المال لاثنين فتخالفا في إقراره لم يقطع إلا أن يكون لمن وافقه نصاب فيقطع مغلي فإن عاد قطعت رجله اليسرى من [ج ٩ - ص ١٣٩]

فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وهو أن تغمس في زيت وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن البطش بها أقوى فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها من مفصل الكف لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وإرادة الأول متيقنة وما سواه مشكوك فيه ولا يجب القطع مع الشك وحسمت وجوبا وقال المؤلف يستحب وهو أن تغمس في زيت مغلي لقوله عليه السلام في سارق اقطعوه وحسموه قال ابن المنذر في إسناده مقال والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في ذلك الزيت المغلي استدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته ويسن تعليق يده في عنقه زاد في البلغة والرعاية ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة فيكون كالإجماع وإنما قطعت الرجل اليسرى لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا ثبت ذلك في المحاربة ثبت في هذا قياسا عليه

ولأن قطع اليسرى أرفق به لأن مشي الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى ويبعد [ج ٩ - ص ١٤٠]

مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولم يقطع وعنه انه تقطع يده اليسرى في الثالثة في العادة من أن يتمكن من المشي عليها فوجب ذلك لئلا تتعطل به منفعته بلا ضرورة من مفصل الكعب لأنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة فيقطع من المفصل كاليد روي سعيد ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان عمر يقطع السارق من المفصل وروي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها واقتصر عليه في الفروع فقال من مفصل كعبة يترك عقبه نص عليه وحسمت قال أحمد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم

تذنيب يقطع السارق بأسهل ما يمكنه فيجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشد يده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين تجر بقوة لتقطع في مرة واحدة

فإن عاد حبس حتى يتوب كالمرة الخامسة وفي الإيضاح ويعذبه وفي التبصرة أو يغرب وفي البلغة يعزر ويحبس حتى يتوب ولم يقطع أي يحرم قطعه قدمه في الرعاية ونصره في الخلاف وصححه وانها اختيار الخرقي وأبي بكر وجزم بها في الوجيز وهو قول علي رواه سعيد ولأن قطع الكل يفوت منفعة الجنس فلم يشرع كالقتل فعلى هذا يمنع من تعطيل منفعة الجنس وعنه أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة واختارها أكثر العلماء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في

السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله رواه الداقطني ورواه سعيد عن أبي بكر وعمر بإسناد جيد والمذهب الأول ثم هو معارض بقول علي وروي أن عمر رجع إلى قول علي رواه سعيد [ج ٩ - ص ١٤١]

ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى وإن سرق وله يمنى فذهبت

تنبيه علم مما سبق أنه لا يجوز أن ينتهي إلى القتل وقد روي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل في الخامسة لحديث رواه مصعب ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه قال أحمد وابن معين مصعب ضعيف وقال أبو حاتم لا يحتج به وقيل هو حسن وقيل لمصلحة اقتضته وقال أبو المصعب المالكي يقتل في الخامسة وقياس قول الشيخ تقي الدين أنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه وجوابه بأنه يحمل في حق رجل استحق القتل أو على وجه التغليظ والمثلة ويؤيده أن الأصول تشهد بنفي القتل لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجب بعد ذلك كسائر المعاصي ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى لأن اليمنى لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل اليسرى لكن إن كانت يمناه شلاء فعنه تقطع رجله اليسرى وعنه يسأل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت ورقي دمها وانحسمت عروقها قطعت وإن قالوا لا برقى دمها فلا وذكر السامري روايتين ولم يذكر هذا فإن كانت أصابع اليمنى ذاهبة فقيل لا تقطع وتقطع الرجل وقيل بلى وإن ذهب بعض الاصابع كخنصر وبنصر أو واحدة سواهما قطعت وإن لم يبق إلا واحدة فهي كالتي

ذهب جميع أصابعها وإن بقي اثنان فالأولى قطعها وفيه وجه وكذا حكم ما لو ذهب معظم نفعها كقطع إبهام أو إصبعين فصاعدا ذكره في المحرر وإن سرق وله يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه أو مع رجليه أو إحداهما الرواية الأخرى وإن وجب يمناه فقطع القاطع يسراه يسراه عمدا فعليه القود وإن قطعها خطأ فعليه ديتها وفي قطع يمنى السارق وجهان ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن [ج ٩ - ص ١٤٢]

سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على سقط القطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية تعلقت برقبته فمات وإن ذهبت يده اليسرى أو كانت مقطوعة أو شلاء لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى وهي أن السارق يحبس في الثالثة ولا يقطع لأن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقاءه بلا يد يبطش بها وهو غير جائز وتقطع على الرواية الأخرى لأن غايته تعطيل منفعة الجنس وبقاؤه بلا يد يبطش بها واقع على الرواية المذكورة بل أولى لأن اليمنى تعلق بها القطع وفاقا وإنما الخلاف في سقوطه

تنبيه إذا ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق وإن ذهبت يده اليسرى قبل سرقته أو يده لم تقطع رجله اليسرى وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يده اليمنى في الأصح وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود لأنه قطع طرفا معصوما وإن قطعها خطأ فعليه ديتها لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطؤه الدية بدليل القتل واختار المؤلف يجزىء ولا ضمان وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف الدية وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو ظنها تجزئ كفت ولا ضمان وفي قطع يمنى السارق وجهان

أحدهما لا قطع لأن قطعها يفضي إلى قطع يد السارق وتفويت منفعة الجنس منه فلم يشرع كقتله

والثاني بلى وجزم به في الوجيز بناء على قطعها في الثالثة فعلى الأولى في قطع رجله وجهان أصحهما لا ويجتمع القطع والضمان نقله الجماعة لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك فترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت مال السارق على وجهين

باب حد المحاربين تالفة غرم قيمتها وقطع وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من باقية وإن كانت تالفة غرم قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية وقطع موسرا كان أو معسرا وفي الانتصار يحتمل لا يغرم شيئا وهو قول أبي يوسف لما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما وجوابه بأنهما حقان لمستحقين وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي وقال بعض المحدثين فيه سعد بن إبراهيم وهو مجهول ول سلم صحته فيحتمل أنه لا غرم عليه في أجرة القاطع وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق على وجهين

أحدهما أنه من بيت المال كأجرة القاطع لأنه من المصالح لم يذكر في الكافي غيره فإن لم تحسم فذكر القاضي أنه لا شيء عليه لأن عليه القطع لا مداواة المحدود

والثاني أنهما من مال السارق قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنه مداواة كمداواته في مرضه ويستحب للمقطوع حسم نفسه فإن لم يفعل لم يأثم لأنه ترك التداوي في المرض

باب حد المحاربين

المحاربون واحدهم محارب وهو اسم فاعل من حارب يحارب وهو فاعل من الحرب قال ابن فارس الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر حرب ماله أي سلبه والحريب المحروب والأصل فيهم قوله تعالى ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية المائدة 33 قال ابن

وهم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح عباس وأكثر العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ المائدة 34 والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها فلما خصه بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين لأن ذلك الحكم يجب عليهم حدا لا كفرا والحد لا يسقط بالتوبة وعن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين وقاله الحسن وعطاء لأن سبب نزولها قضية العرنيين وحكاه ابن أبي موسى رواية وأنها منسوخة لأن قضيتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ثم قال فحكم من خرج لقطع الطريق مرتب على ما نزل من الحدود ولولا قيام الدليل على وجوب قطع اليد مع الرجل للمحارب لقلنا لا تقطع إلا يده اليمنى كالسارق قال ابن أبي موسى فعلى هذا يجيء أن يصح عفو ولي الدم عن المحارب ويكون الإمام مخيرا فيه وهو وجه في الرعاية وهم قطاع الطريق وهم كل مكلف ملتزم ليخرج الحربي ولو أنثى وقاله الأكثر والعبد والذمي كضدهما وعنه ينتقض عهده فيحل دمه وماله بكل حال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح هذا أحد الشروط فيهم وظاهره أنه إذا لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين لأنهم لا يمنعون من قصدهم والأصح ولو كان بعصا وحجر لأن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على النفس أشبه المحدد وفي البلغة وغيرها وجه ويد وفي الشرح وإن قتل في المحاربة بمثقل قتل كما لو قتل بمحدد وإن قتل بآلة لا يجب القصاص بالقتل بها فالظاهر أنهم يقتلون أيضا لدخولهم في العموم فرع

من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل منهم دون غيره ذكره ابن ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر [ج ٩ - ص ١٤٥]

في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة فأما من يأخذه سرقة فليس محارب وإن فعلوا أبي موسى في الصحراء لأن ذلك عادة المحاربين فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة أي يأخذون المال قهرا اختاره الأكثر ونصره القاضي في الخلاف وذكره المذهب فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب لأنهم لا برجعون إلى منعة وقوة وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء لأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون مختلسين لا قطاع طريق وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو قول كثير من الأصحاب لعموم الآية فيهم ولأن ضررهم في المصر أعظم فكانوا بالحد أولى وفي الفروع قيل في صحراء وقيل ومصر إن لم يغث وحكى في الكافي والشرح عن القاضي أنه قال إذا كبسوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين وإن حصروا قرية أو بلدا لا يلحقهم الغوث عادة فهم قطاع طريق ولم يذكر في الرعاية فيه خلافا ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كسرقة ذكره القاضي وغيره وفي سقوطه بشبهة كسرقة وجهان قاله في المستوعب وغيره وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرىء

مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة [ج ٩ - ص ١٤٦]

وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب وعن متفق عليه وقال ابن عباس ما كان في القرآن ب أو فصاحبه بالخيار وجوابه بأنه قد عرف من القرآن أن ما أريد به التخيير فيبدأ بالأخف ككفارة اليمين وما أريد به الترتيب فيبدأ بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل ولأن العقوبات تختلف باختلاف الأجرام ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق ولأن القتل وجب لحق الله تعالى فلم يخير الإمام فيه كقطع السارق وروى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض وروي نحوه مرفوعا وإذا ثبت هذا قتل وصلب في ظاهر المذهب قاله في المغني والشرح وقتله متحتم لا يدخله عفو بالإجماع والصلب بعد القتل وقيل يصلب أولا ثم يقتل والأول أولى لأنه تعالى قدم القتل على الصلب كقوله تعالى ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ البقرة 158 ولقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولأنه شرع ردعا لغيره ليشتهر أمره ولو شرع لردعه فقط لسقط بقتله كما تسقط سائر الحدود مع القتل والصلب حتم في حق من قتل وأخذ المال فلا يسقط بعفو ولا غيره ويكون حتى يشتهر ذكره معظم الأصحاب لأن المقصود منه زجر غيره ولا يحصل إلا به وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب اقتصر ابن

هبيرة على حكايته عن أحمد لأن بذلك يصدق اسم الصلب وقال ابن رزين يصلب ثلاثة أيام وهذا توقيت بغير عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استفاؤه على روايتين [ج ٩ - ص ١٤٧]

أحمد أنه يقطع مع ذلك وإن قتل من لا يكافئه فهل يقتل على روايتين وإن جنى توقيف مع أنه في الظاهر يفضي إلى تغيره ونتنه وعن أحمد أنه يقطع مع ذلك اختاره أبو محمد الجوزي لأن كل واحد منهما يوجب حدا مفردا فإذا اجتمعا وجب حدهما كما لو زنى وسرق فعلى هذا يقطع أولا ثم يقتل ثم بعد ذلك يدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإن مات قبل قتله لم يصلب لأنه تابع للقتل فسقط بفواته وإن قتل من لا يكافئه كولده وعبد وذمي فهل يقتل على روايتين

إحداهما يقتل ويصلب قدمها في الرعاية وجزم بها في الوجيز للعموم ولأن القتل حد لله تعالى فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنى والسرقة

والثانية لا ذكر القاضي في الخلاف أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية جماعة لقوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر فعلى هذا إذا قتل مسلم ذميا أو حر عبدا وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف لأخذ المال وغرم دية ذمي وقيمة عبد وإن قتله ولم يأخذ مالا غرم ديته ونفي وقيل إن قلنا القتل حق لله فلم يقتل من يكافئه وإلا فلا وفي الشرح عن القاضي أنه قال إنما يتحتم قتله إذا قتله ليأخذ المال فإن قتله لغير ذلك كعداوة فالواجب قصاص غير متحتم وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس كالطرف فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين وكذا في الفروع

إحداهما قال في الشرح وهي أولى لا يتحتم لأن الله تعالى لم يذكره وحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص

والثانية يتحتم قدمها في الرعاية وحزم بها في الوجيز لأنه نوع قود فتحتم استيفاؤه كالقود في النفس ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين ويحتمل سقوطه بتحتم قتله وذكره بعضهم ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى [ج ٩ - ص ١٤٨]

وحكم الردء حكم المباشر ومن قتل ولم يأخذ المال قتل وهل يصلب على روايتين فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف قال في الفروع وهذا وهم وحكم الردء والطليع حكم المباشر لأن حد المباشر حكم يتعلق بها فاستوى فيها الردء والمباشر كالغنيمة يحققه أن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمباشر لا يتمكن إلا بالردء فوجب التساوي في الحكم وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم جاز قتلهم وصلبهم فردء غير مكلف كهو وقيل يضمن المال آخذه وقيل قراره عليه وفي الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط واختار الشيخ تقي الدين الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك وإن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل والمراد بالردء هو العون للمباشر كقوله تعالى ﴿ ردءا يصدقني ﴾ القصص 34

ومن قتل مكافئه ولم يأخذ المال قتل حتما لأنه قاتل فيدخل في عموم النص وحينئذ فلا أثر لعفو الولي وهل يصلب على روايتين

إحداهما لا يصلب قدمه في المحرر وصححه في الشرح وجزم به في الكافي لأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل أعظم فكانت عقوبتهم أغلظ

والثانية بلى لأنه محارب يجب قتله فيصلب كمن أخذ المال ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت حتما يده اليمنى ورجله اليسرى لقوله تعالى ﴿ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ وإنما قطعت يده اليمنى للمعنى الذي تقدم في السارق لأنه سارق وزيادة ثم رجله اليسرى لتحقق المخالفة وليكون أرفق به في مكان مشيه [ج ٩ - ص ١٤٩]

في مقام واحد وحسمتا وخلي ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ولا ينتظر اندمال اليد بل يقطعان في مقام واحد لأن الله تعالى أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهما فيبدأ بيمينه فتقطع وتحسم ثم برجله كذلك وهذا الترتيب واجب ذكره ابن شهاب وغيره وحسمتا لقوله اقطعوه واحسموه لأن الحسم يسد أفواه العروق ويمنع الدم من النزف ويكون ذلك حتما وخلي بعد ذلك لأن الحق الذي عليه قد استوفي أشبه المدين إذا أدى دينه ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله لقوله عليه السلام لا قطع إلا في ربع دينار ولم يفصل ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغليظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل وظاهره أنه يعتبر الحرز أيضا فإن أخذوا من مال لهم فيه شركة أو شبهة على ما ذكرنا في المسروق لم يقطع ذكره في الشرح وغيره وفي المستوعب وجهان فإن كانت يمينه مقطوعة بأن قطعت في سرقة أو غيرها أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى كما لو كانت يمناه موجودة لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه وكذا إن كانت اليمنى موجودة واليسرى معدومة فإنا نقطع الموجود منها حسب ويسقط القطع في المعدوم لأن ما تعلق به الفرض قد زال فيسقط كالغسل في الوضوء وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه وهل تقطع يسرى يديه أي إذا قطع للمحاربة ثم حارب ثانيا فهل تقطع بقية أربعته فيه وجهان وذلك ينبني على

الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة فإن قلنا يقطع ثم قطعت هاهنا لأنها مستحقة القطع في الجملة كما لو سرق ولا تعزيره بما يردعه ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل [ج ٩ - ص ١٥٠]

ومن لم يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد ولا يترك يأوي إلى بلد وعنه أن نفيه يمنى له ولا رجل وإن قلنا لا تقطع وهو الأصح سقط لأن قطعها يفضي إلى تفويت منفعة البطش وتتعين دية لقود لزمه بعد محاربته كتقديمها بسبقها وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة فرع إذا عدم يده اليسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله اليسرى دون يده اليمنى وقيل يقطعان ويتخرج عكسه فلو كان ما وجب قطعه أشل فذكر أهل الطب أن قطعه يفضي إلى تلفه سقط وبقي حكمه كالمعدوم وإن قالوا لا يفضي إلى تلفه ففي قطعه روايتان ومن لم يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد أي طرد ولو عبدا ولا يترك يأوي إلى بلد ذكره الأصحاب ونصروه لقوله تعالى ﴿ أو ينفوا من الأرض ﴾ المائدة 33 وظاهره يتناول نفيه من جميعها وهو يبطل بنفي الزاني إلى مكان فعلى هذا ينفون مدة تظهر فيها توبتهم وتحسن سيرتهم قدمه في الرعاية والفروع وقيل ينفون عاما كالزاني وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه من ضرب وحبس ونفي لأن الغرض الردع وهو حاصل بما ذكر وفي التبصرة بهما وعنه نفيهم حبسهم اختاره ابن أبي موسى حتى يحدثوا توبة وفي الواضح وغيره رواية أن نفيهم طلب الإمام لهم ليقيم فيهم حدود الله تعالى وروي عن ابن عباس فإن كانوا جماعة نفوا متفرقين ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن

الله غفور رحيم ﴾ فعلى هذا يسقط عنهم جميع ما ذكر أطلق عليه حد الله تعالى سوى ذلك فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة [ج ٩ - ص ١٥١]

وأخذ بحقوق الادميين من النفس والمال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها ومن وجب في المبهج في حق الله تعالى روايتين وأخذ بحقوق الآدميين من النفس والمال والجرح إلا أن يعفى لهم عنها لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها فلم تسقط لغير المحارب لا يقال الآية عامة فما وجه التخصيص لأن الأدلة دالة على أن حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه لأنه مبني على الضيق ولاشح بخلاف حق الله وذلك يقتضي عدم التسوية بينهما وعلم منه أنه إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء لأن الله تعالى شرط في المغفرة لهم كون توبتهم قبل القدرة فدل على عدمها بعدها ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص وبعدها تقية من إقامة الحد ولأن في إسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته والرجوع عن محاربته وبعد القدرة لا حاجة في ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة وهذا كله فيمن هو تحت حكمنا وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم وقيل تقبل توبته ببينة وقيل وقرينة وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك كالزنى والسرقة وشرب الخمر فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه ذكره أبو بكر المذهب وقاله أكثر العلماء لعموم أية الزنى والسارق ولأنه عليه اللسلام رجم ماعزا والغامدية وقد جاءا تائبين ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين ولأ نه مقدور عليه كالمحارب بعد القدرة عليه وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة نصره القاضي في الخلاف وصححه وقدمه في المحرر

والفروع وقال اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز لقوله تعالى ﴿ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ النساء 16 ولقوله ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب ﴾ قبل إصلاح العمل ومن مات وعليه حد سقط عنه فصل عليه [ج ٩ - ص ١٥٢]

المائدة 39 وفي الخبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب قبل إصلاح العمل وكذا في الوجيز لأن الله تعالى علق الحكم على شرطين وأجاب القاضي بأن هذا على طريق التأكيد والمبالغة لقوله تعالى ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ الايات الفرقان 68 ومعلوم أنه لا يعتبر صلاح العمل في توبة المشرك قال القاضي لا يعتبر صلاح العمل وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني وأبي الحارث لأنها توبة مسقطة للحد أشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه كالإسلام فعلى هذا فلابد من مضي مدة قبل ثبوته وقيل قبل القدرة وقيل قبل إقامته وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة وعنه إن ثبت الحد بنفيه لم يسقط ذكرها ابن حامد وغيره وعليهما يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة عليه ويحتمل لا كما قبل المحاربة وفي المحرر والوجيز لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه وذكره ابن أبي موسى في ذمي ونقله فيه أبو داود وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف ومن مات وعليه حد سقط عنه لفوات محله كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة

تذنيب إذا وجد رجلا يزني مع امرأته فقتله فلا قود ولا دية رواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر فإن ادعى ذلك لم يقبل في

الحكم إلا ببينة وهي شاهدان في رواية اختارها أبو بكر وأربعة لقول علي وإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه [ج ٩ - ص ١٥٣]

ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به وإن كانت مكرهة ضمنها وأثم وإن كانت مطاوعة فلا

فائدة من عرف بأذى الناس وأموالهم فإن لم ينزجر حبس وأطعم من بيت المال حتى يموت وكذا من ابتدع ببدعة وحمل الناس عليها حبس حتى يكف المسلمين عن بدعته نص عليه

فصل

ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله وإن قل كافأه أم لا فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم والمذهب أنه يدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه جزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع دفعه به لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج لأن الزائد عليه لا حاجة إليه لحصول الدفع به وقيل إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه وجزم به في المستوعب فعلى ما ذكرنا متى علم أو ظن الدافع أن الصائل عليه يندفع بالقول لم يجز ضربه بشيء قال أحمد لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه وقال الميموني رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وإن علم أنه يندفع بعصا لم يضربه بحديد وإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك لأن ضرره إذا لم يندفع إلا به تعين طريقا إلى الدفع المحتاج إليه ولا شيء عليه بالقتل لأنه قتل لدفع شر الصائل فلم يجب به شيء كفعل الباغي وروي عن

عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقال عمر [ج ٩ - ص ١٥٤]

وإن قتل كان شهيدا وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين وسواء والله لا يودي به وإن قتل كان شهيدا لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه ولأنه قتل لدفع ظلم فكان شهيدا كالعادل إذا قتله الباغي وإن قتله فهدر ولا يجوز في حال مزح ذكره في الانتصار ويقاد به ذكره آخرون وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين كذا في المحرر الأصح أنه يلزمه الدفع عن نفسه لقوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ البقرة 195 وكما يحرم قتل نفسه تحرم عليه إباحة قتل نفسه ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به كالمضطر إذا وجد الميتة وكذا عن نفس غيره لا في فتنة في الأصح فيهما والثانية لا يلزمه قدمها في الرعاية وصححها ابن المنجا لما روى عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة رواه أحمد وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم فتنة فليكن كخير ابني آدم رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأن عثمان ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره من قتالهم وصبر على ذلك ولو لم يجز لأنكر

الصحابة عليه ذلك وعلى اللزوم إن أمكنه أن يهرب أو يحتمي أو يختفي ففي جواز الدفع وجهان وظاهره أنه لا يجب الدفع عن حرمته وليس ذكرنا [ج ٩ - ص ١٥٥]

كان الصائل آدميا أو بهيمة وإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما كذلك بل هو قويل فإنه إذا رأى مع امرأته رجلا أو ابنته أو أخته يزنى بها أو تلوط بابنه فإنه يجب الدفع عن ذلك في المنصوص لأنه اجتمع فيه حق الله وهو منعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق ولا عن ماله وهو الأصح كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكره القاضي وغيره وفي التبصرة في الثلاثة يلزمه في الأصح وله بذله وذكر القاضي أنه أفضل ونقله حنبل وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل وأطلق روايتي الوجوب في الكل زاد في نهاية المبتدىء على الثلاثة وعرضه وقيل يجب وأطلق في التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره وسواء كان الصائل آدميا مكلفا أو غير مكلف وفي الترغيب وعندي ينتقض عهد الذمي أو بهيمة لاشتراكهما في المجوز للدفع وهو الصول ولأن البهيمة لا حرمة لها فيجب عليه الدفع إذا أمكنه كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا أي إذا ادعى صيالة بلا بينة ولا إقرار لم يقبل فحكمه حكم ما ذكرنا أي إذا دخل منزل غيره بغير إذنه فلصاحب المنزل أمره بالخروج من منزله سواء كان معه سلاح أو لا فإن خرج بالأمر لم يكن له غيره لأن المقصود إخراجه لكن روي عن ابن عمر أنه رأى لصا فأصلت عليه السيف قال الراوي فلو تركناه لقتله وجاء رجل إلى الحسن فقال رجل دخل بيتي ومعه حديدة أقتله قال نعم

وجوابه أنه أمكن إزالة العدوان بغير القتل فلم يجز القتل وكما لو غصب منه شيئا وأمكن أخذه [ج ٩ - ص ١٥٦]

وان عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا وإن بغير القتل وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب فإن لم يخرج فله ضربه بأسهل ما يعلم أو يظن أنه يندفع به فإن خرج بالعصا لم يكن له ضربه بالحديد وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه كالبغاة وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أرش لأنه لقي شره وإن ضربه فقطع يمينه فولى مدبرا فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية لأنه في حال لا يحل له ضربه واليد غير مضمونة فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية وإن عاد إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى فاليدان غير مضمونتين وإن مات فعليه ثلث الدية كما لو مات من جراحة ثلاثة أنفس وقياس المذهب أن يضمن نصف الدية كما لو جرحه اثنان ومات منها وإن لم يمكنه إلا بالقتل أو خاف أن يبدره به فله قتله وهو هدر كالباقي وإن قتل صاحب المنزل فهو شهيد للخبر وكالعادي وعلى الصائل ضمانه وإن أمكن دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه وإن عض إنسان إنسانا عضا محرما فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا لما روى عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته وفي لفظ بثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه ولفظه لمسلم ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يكن الدافع إلا بقطع يده وسواء كان المعضوض ظالما أو

مظلوما لأن العض محرم إلا أن يكون العض مباحا كمن لا يقدر على التخلص إلا بعضه وقال القاضي تخليص المعضوض يده [ج ٩ - ص ١٥٧]

نظر في بيته من خصاص الباب ونحوه فخذف عينه ففقأها فلا شيء عليه بأسهل ما يمكنه فإن أمكنه فك لحييه وإن لم يمكنه لكمه وإن لم يمكنه جذب يده من فيه فإن لم يخلص فله أن يعصر خصيتيه فإن لم يمكنه فله أن يبعج بطنه وإن أتى على نفسه قال في المغني والصحيح أن هذا الترتيب غير معتبر وينبغي أن يجذب يده أولا فإن أمكنه ذلك فعدل إلى لكم فكه فأتلف شيئا ضمنه لإمكان التخلص بما هو أولى منه

وإن نظر في بيته من خصاص الباب وهو الفروج الذي فيه ونحوه وظاهره ولو لم يتعمد لكن ظنه متعمدا قال في الترغيب أو صادف عورة من محارمه وأصر وفي المغني ولو خلت من نساء فقذف عينه ففقأها وفي الفروع فتلفت فلا شيء عليه كذا في المحرر والوجيز وغيرهما لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرءا أطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك لظاهر الخبر ولا يتبعه وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فينذره أولا كمن استرق السمع لم يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب وقيل باب مفتوح كخصاصة وجزم به بعضهم وعن أبي ذر مرفوعا وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فينظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت رواه أحمد وأبو داود وفيه ابن لهيعة

ولو كان إنسانا عريانا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه لأنه مفرط فرع إذا اطلع فرماه فقال المطلع ما تعمدته لم يضمنه على ظاهر ولهم منعة وشوكة وعلى [ج ٩ - ص ١٥٨]

باب قتال أهل البغي

وهم القوم الذين يخرجون عن طاعة الامام بتأويل سائغ كلامه وعلى قول ابن حامد بلى وإن اطلع أعمى لم يجز رميه وقال ابن عقيل بلى إن كان سميعا كالبصير وسواء كان الناظر في ملكه أو غيره والله أعلم

باب قتال أهل البغي

البغي مصدر بغى يبغي بغيا إذا اعتدى والمراد هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه قال الله تعالى ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ إلى قوله ﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ الحجرات 10 وفيها فوائد منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان ومنها أنه أوجب قتالهم ومنها أنه أسقط قتالهم إذا رجعوا إلى أمر الله تعالى ومنها أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم ومنها أنها أجازت قتال كل من منع حقا عليه والأحاديث مشهورة منها ما روى عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله متفق عليه وأجمع الصحابة على قتالهم فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة وعليا قاتل أهل الجمل وأهل صفين وهم القوم الذين يخرجون عن طاعة الإمام العادل ذكره في الرعاية بتأويل سائغ سواء كان صوابا أو خطأ وقيل بل خطأ فقط ذكره في الرعاية ولهم منعة وشوكة لا جمع يسير خلافا لأبي بكر فإن فات شرط فقطاع طريق فعلى هذا لو امتنع قوم من

طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته بغير تأويل أو كان لهم تأويل ولا منعة لهم ما يدعونه من شبهة [ج ٩ - ص ١٥٩]

الامام ان يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف كالعشرة فقطاع طريق وفي الترغيب لا تتم الشوكة إلا وفيهم واحد مطاع وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته وفي عيون المسائل تدعو إلى نفسها أو إلى إمام غيره وإلا فقطاع طريق

أصل من كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين فهم بغاة في قول الجماهير تتعين استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم وقال طائفة من المحدثين هم كفار حكمهم حكم المرتدين للأخبار وهذا رواية عن أحمد ذكر في الترغيب والرعاية أنها اشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه وحكى ابن أبي موسى عن أحمد الخوارج كلاب النار صح الحديث فيهم من عشرة أوجه قال والحكم فيهم على ما قال علي وفيما قال لا نبدأكم بقتال وقال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على كفرهم قال ابن عبد البر في الحديث الذي رويناه قوله يتمادى في الفوق يدل على أنه لم يكفرهم قال المؤلف والصحيح أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم وعلى الإمام أن يراسلهم للنص إذ المراسلة والسؤال طريق إلى الصلح لأن ذلك وسيلة إلى رجوعهم إلى الحق وقد روي أن علي بن أبي طالب راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ولما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله ابن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة لأن ذلك وجب مع إفضاء الأمر إلى القتل والهرج

والمرج فلأن يجب في حال يؤدي إلى ذلك بطريق الأولى ويكشف ما يدعونه من شبهة لأن كشفها طريق إلى رجوعهم إلى الحق وذلك مطلوب إلا أن يخاف كلبهم رجوعهم فيها انظرهم فإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم [ج ٩ - ص ١٦٠]

فإن فاؤوا وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته على حربهم فإن استنظروه مدة رجا فلا يمكن ذلك في حقهم فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم فإن فاؤوا أي رجعوا إلى الطاعة وإلا قاتلهم أي يلزم القادر قتالهم لإجماع الصحابة على ذلك وقال الشيخ تقي الدين الأفضل تركه حتى يبدؤوه وهو ظاهر اختيار المؤلف وقالا في الخوارج له قتلهم ابتداء وتتمة الجريح وفي المغني والشرح في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم وفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وغيرهم وعلى رعيته معونته على حربهم لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ النساء 59 ولقوله عليه السلام من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه فإن استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه وفي الرعاية ثلاثا ولإن الإنظار المرجو به رجوعهم أولى من معالجتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج فإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم لأن الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريقا إلى قهر أهل الحق وذلك لا يجوز وإن أعطوه عليه مالا أو رهنا لأنه يخلي سبيلهم إذا انقضت الحرب كما يخلي الأساري ولا يجوز قتلهم فإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليه ويكفوا عن المسلمين فإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك وإلا جاز وقاتلهم حيث قوي

على ذلك فإن ضعف عنه أخره حتى يقوى فإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله وإذا قاتل معهم عبيد أو نساء أو صبيان حربهم بكافر وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح ولا يغنم لهم مال [ج ٩ - ص ١٦١]

ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة ولا يستعين في فهم كالرجل البالغ الحر وفي الترغيب ومراهق وعبد نكيل ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز إلا لضرورة كما في دفع الصائل فإن رماهم البغاة به جاز رميهم ولا يستعين في حربهم بكافر لأنه لا يستعان في قتال الكفار به فلأن لا يستعان به في قتال مسلم بطريق الأولى ولأن القصد كفهم لا قتلهم وهو لا يقصد قتلهم فإن احتاج فقدر عن كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم وإلا فلا

وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكرعهم أي خيلهم على وجهين

أحدهما لا جزم به ابن هبيرة عن أحمد وحكاه القاضي والمؤلف عن أحمد وصححه ابن حمدان لأن الإسلام عصم أموالهم وإنما أتيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق إلا أن تدعو ضرورة فيجوز كأكل مال الغير في المخمصة والثاني يجوز جزم به في الوجيز وذكر القاضي أن أحمد أومأ إليه قياسا على أسلحة الكفار وعليه لا يجوز في غير قتالهم ويجب رده بعد أن تنقضي الحرب كما يرد سائر أموالهم ولا يرده حال الحرب لئلا يقاتلونا به ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح ولا يجوز قتلهم إذا تركوا القتال في قول الأكثر لما روى مروان قال خرج خارج يوم الجمل لعلي لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق عليه

بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن رواه سعيد وعن عمار نحوه وكالصائل وفي الترغيب إن المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع آخر فعلى هذا إذا قتل أنسانا منع من قتله ضمنه وهل يلزمه القصاص فيه وجهان ولا يغنم لهم مال لأنهم صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلي في الحال يحتمل وجهين وإذا [ج ٩ - ص ١٦٢]

ولا تسبي فهم ذرية ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم برسل وإن أسر لم يكفروا ببغيهم وقتالهم وعصمة الأموال تابعة لدينهم ولا تسبى لهم ذرية لا نعلم فيه خلافا لأحد لأنهم لم يحصل منهم سبب أصلا بخلاف أهل البغي فإنه وجد منهم البغي والقتال

ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب لأن في إطلاقهم ضررا على المسلمين ثم يرسل بعد ذلك لأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة أصحابهم وقد زال وفي الترغيب لا مع بقاء شوكتهم وقيل يرسل إن أمن ضرره فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان فرع إذا أسر رجلا مطاعا خلي زاد في الرعاية إن أمن شره فإن أبى أن يدخل في الطاعة وفي الكافي والشرح وكان رجلا جلدا حبس وأطلق بعد الحرب زاد في الشرح وشرط عليه ألا يعود إلى القتال

وإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل وجهين

أحدهما يحبسون لأن فيه كسر قلوب البغاة وكالرجل

والثاني يخلون في الحال قدمه في الرعاية وصححه في الكافي والشرح لأنه لا يخشى من تخليته فرع لا يكره للعادل قتل ذوي رحمه الباغين ذكره القاضي لأنه قتل بحق أشبه إقامة الحد عليه والأصح يكره وقدمه في الفروع لقوله تعالى ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ لقمان 15 قال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين [ج ٩ - ص ١٦٣]

انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه ولا يضمن أهل العدل ما قتل أبيه وقال بعضهم لا يحل وذكره في الفروع احتمالا لأنه تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف

تنبيه يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة فإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم فإن اقتتلت طائفتان من البغاة فقدر الإمام على قهرهما لم يعن إحداهما على الأخرى وإن عجز وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى فإذا هزمها لم يقاتل من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة وإذا انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه لقول علي من عرف شيئا أخذه ولأنه مال معصوم بالإسلام أشبه مال غير البغاة ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال لأنه إذا لم يمكن دفع البغاة إلا بقتلهم جاز ولا شيء على قاتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة لأنه فعل ما أمر به كما لو قتل الصائل عليه وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين

أحداهما لا ضمان قدمها في الكافي والفروع ونصرها في الشرح والقاضي في الخلاف وصححها لقول الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على

تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به رواه الخلال قال القاضي وهذا إجماع منهم مقطوع به ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه ومن

ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب وكأهل العدل

والثانية يضمنون جزم بها في الوجيز لقول أبي بكر لأهل الردة تودون قتلانا ولا نودي قتلاكم ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غير حال الحرب وجوابه أن أبا بكر رجع عنه إلى قول عمر ولم يمضه ثم لو وجب التعزير في حق المرتدين لم يلزم مثله هنا فإن هؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ وأولئك كفار لا تأويل لهم وإذا ضمن المال ففي القود وجهان فإن أهدر فالقود أولى ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه أي من الفريقين رواية واحدة قاله في المستوعب لأن الاصل وجوب الضمان ترك العمل به في حال الحرب للضرورة فيبقى ما عداه وهل يتحتم قتل الباغي إذا قتل أحدا من أهل العدل في غير المعركة فيه وجهان الأصح أنه لا يتحتم فأما الخوارج فالصحيح إباحة قتلهم فلا قصاص على أحد منهم ولا ضمان عليه في ماله وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه روي عن عمر وسلمة بن الأكوع وقاله أكثر العلماء لما روي أن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه ولأن في ترك الاحتساب بها ضررا عظيما ومشقة كبيرة فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلو لم يحتسب بما أخذوه لحصل الضرر وظاهره لا فرق بين الخوارج وغيرهم وقال أبو عبيد يجزء دفع الزكاة إلى بغاة

وخوارج ونص عليه أحمد في الخوارج ويقع موقعه قال القاضي في الشرح هذا إلا ببينة وإن ادعى انسان دفع خراجه اليهم فهل يقبل بغير بينة على وجهين وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم ألا ما ينقض من حكم غيره [ج ٩ - ص ١٦٥]

ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم يقبل محمول على أنهم خرجوا بتأويل وذكر في موضع آخر إنما يجوز أخذهم إذا نصبوا لهم إماما وفي الأحكام السلطانية أنه لا يجزيء الدفع إليهم اختيارا وعن أحمد الوقف فيما أخذوه من زكاة فلو صرفه أهل البغي في جهته صح قال ابن حمدان ودفع سهم المسترزقة إلى أجنادهم يحتمل وجهين ومن ادعى دفع زكاته اليهم قبل بغير يمين لأن الزكاة لا يستحلف فيها قال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة لأنهم غير مأمونين ولأنها عوض أشبهت الأجرة وقيل يقبل قولهم إذا مضى الحول لأن الظاهر أن البغاة لا يدعون الجزية لهم وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل يقبل بغير بينة على وجهين

أشهرهما لا يقبل إلا ببينة قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأنه عوض أشبه الجزية

والثاني يقبل لأنه حق على مسلم فقبل قوله كالزكاة وقيل بلى إن حلف وتجوز شهادتهم لأنهم أخطأوا في فرع من فروع الإسلام باجتهادهم أشبه المختلفين من الفقهاء في الأحكام وإذا لم يكونوا من أهل البدع قبلت شهادتهم كأهل العدل بغير خلاف نعلمه قال ابن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة انتهى فأما الخوارج وأهل البدع إذا

خرجوا على الإمام فلا تقبل لهم شهادة لأنهم فساق ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره لأن نفيهم في أمر يسوغ فيه التأويل أشبه الاختلاف في الفروع فعلى هذا إن خالف حكم حاكمهم نصا أو إجماعا أو كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم نقضه حكمه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال وإن استعانوا بأهل وإن

وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه فرع إذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه لأنه قاض ثابت القضاء وفي المغني والشرح والترغيب الأولى رد كتابه قبل حكمه كسرا لقلوبهم فأما الخوارج إذا ولوا قاضيا لم يجز قضاؤه للفسق وفي المغني والشرح احتمال يصح قضاؤه دفعا للضرر كما لو أقام الحد أو أخذ جزيته وخراجا وزكاة وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز انتقض عهدهم قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز وصححه ابن أبي موسى كما لو انفردوا بقتالهم وحكمهم حكم أهل الحرب وقيل لا ينتقض لأن أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل فيكون ذلك شبهة لهم فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقبلهم والكف عن أسيرهم ومدبرهم وجريحهم والمعاهد كالذمي قاله في الرعاية وفي الكافي والشرح إن حكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم بينة على الإكراه لأن عقد الذمة مؤبد ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم ويلزم الدفع عنهم والمستأمنون بخلاف هذا إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم وجها واحدا لأن ما ادعوه محتمل فلا ينتقض عهدهم مع الشبهة وفي الرعاية في الأصح وفي الترغيب وجهان ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال في الأصح حال الحرب وغيره بخلاف أهل البغي لأن هؤلاء لا تأويل لهم لأن سقوط الضمان عن المسلمين كيلا يؤدي إلى تنفيرهم عن

الرجوع إلى الطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم والثاني لا يضمنون كالمسلمين يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم [ج ٩ - ص ١٦٧]

استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم أو عقدوا لهم ذمة لم يصح أمانهم لأن الأمان من شرط صحته إلزام كفهم عن المسلمين ولأهل العدل قتلهم لمن لم يؤمنوه وحكم أسيرهم حكم أسير أهل الحرب قبل الاستعانة بهم فأما البغاة فلا يجوز لهم قتلهم لأنهم أمنوهم فلا يجوز لهم الغدر بهم قال في الفروع إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى بغاة

أصل أذا استعانوا بمستأمنين فأعانوهم انتقض عهدهم وصاروا كأهل الحرب لأنهم تركوا كفهم عن قتال المسلمين فإن فعلوا ذلك مكرهين لم ينتقض عهدهم وإن ادعوه لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدمه وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة ولم يجتمعوا لحرب ولم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا دما حراما فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم ولهذا قال لم يتعرض لهم وهذا قول جمهور الفقهاء لما روي أن علي بن أبي طالب كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة فعلى هذا حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين وسأله المروذي عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون قال لا تعرضوا لهم قلت وأي شيء يكره

من أن يحبسوا قال لهم والدات وأخوات وقال في رواية ابن منصور الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون

[ج ٩ - ص ١٦٨]

وإن سبوا الامام عزرهم وإن جنوا جناية أو اتوا حدا اقامه عليهم وان وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل صريحا عزرهم لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه ولا كفارة وإن عرضوا بالسب ففي تعزيرهم وجهان وقال في الإباضية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم وإن جنوا جناية أو أتوا حدا أقامة عليهم لقول علي في ابن ملجم لما جرحه أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به ولأنهم ليسوا ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم ولأن في إسقاط ذلك عنهم تجرئتهم على الفعل وذلك مطلوب العدم

أصل قال أحمد في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه وكذا في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة وقال أحمد أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة ونقل ابن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه اختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين وقال أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى وذكر ابن عقيل عن الأصحاب تكفير من خالف في أصل نكوارج ورافضة ومرجئة وذكره غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وإن

استحله كفر وفي المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج وفي نهاية المبتدىء من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا فسق وذكر ابن حامد كفر الخوارج على الأخرى

باب حكم المرتد كل واحدة ما أتلفت والرافضة والقدرية والمرجئة ومن لم يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان والذي ذكره هو وغيره من رواية المروذي وأبي طالب ويعقوب وغيرهم أنه لا يكفر قال الشيخ تقي الدين وهي ظاهر نصوصه بل صريحة فيه وإنما كفرنا الجهمية لا أعيانهم وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان لأن كل واحدة باغية على صاحبتها وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما قال الشيخ تقي الدين فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف قال وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين واحد عند الجمهور قال وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا ومن دخل للإصلاح فقتلته طائفة ضمنته وإن جهلت ضمنتاه قال ابن عقيل ويخالف المقتول في زحام الجامع والطواف لأن الزحام هنا ليس فيه تعد بخلاف الأول

باب حكم المرتد

المرتد لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع وشرعا هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر إما نطقا أو اعتقادا أو شكا وقد يحصل بالفعل ولهذا قال وهو الذي يكفر بعد إسلامه لأنه بيان له قال تعالى ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴾ البقرة 217 وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قال الترمذي هو حسن صحيح صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله أو رسوله كفر ومن [ج ٩ - ص ١٧٠]

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله والعمل عليه عند أهل العلم وأجمعوا على وجوب قتل المرتد ﴿ من يشرك بالله ﴾ أي إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه وقيل وكرها والأصح بحق فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف وحينئذ لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة ولا أن يصالحوا بما يقرون به على ردتهم بخلاف أهل الحرب ذكره القاضي أو جحد ربوبيته أو وحدانيته لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى أو جحد صفة من صفاته اللازمة قاله في الرعاية لأنه كجاحد الوحدانية وفي الفصول شرطه أن تكون الصفة متفقا على إثباتها أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك أو جحد نبيا لأنه مكذب لله جاحد لنبوة نبي من أنبيائه أو جحد كتابا من كتب الله أو شيئا منه لأن جحد شيء منه كجحده كله لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى أو سب الله أو رسوله كفر لأنه لا يسب واحدا منهما إلا وهو مكذب جاحد به وكذا إذا ادعى النبوة قال الشيخ تقي الدين أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا فرع إذا كذب على نبي من الأنبياء وقيل مستحلا أو قذفه كفر وإن استحل الكذب المحرم على غيره كفر وإن كذبه فيما يعلم صدقه فيه غير مستحل أثم فإن اعترف به عزر فإن تاب من الكذب عليه عليه السلام قبلت في ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم وحكى ابن الصلاح عن أحمد وطائفة أنها لا تقبل ونقل عبد الله الحلبي عن أحمد

تقبل فيما بينه وبين الله تعالى المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر [ج ٩ - ص ١٧١]

جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنى أو الخمر أو شيئا من ولا يكتب عنه حديث رواه الخلال

وإن كذب نصراني موسى عليه السلام خرج من دينه لأن عيسى صدق به لا العكس لأنه لم يصدق بعيسى ولا بشر له

ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو الطهارة لها أو أحل الزنى أو الخمر أو شك فيه أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كالدم لجهل عرف ذلك ليصير عالما به وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشيء بين المسلمين في الأمصار كفر لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ولسائر الأمة فرع قال جماعة أو سجد لشمس أو قمر وفي الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين قال الشيخ تقي الدين أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وذكر بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر الظاهر أن المراد بها مباني الإسلام ولا شك أن تارك الشهادتين تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب وأما بقية ذلك فكما ذكره إلا الصلاة فإنه يدعى إليها فإن امتنع فإنه يستتاب كمرتد فإن أصر كفر بشرطه وإذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كان كتركها وإن كان مختلفا فيه

وهو معتقد وجوبه فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة وقال المؤلف عليه والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه [ج ٩ - ص ١٧٢]

وعنه يكفر إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال فمن ارتد عن الاسلام من الرجال الإعادة ولا يكفر من أجل ذلك بحال وفي المحرر إذا ترك تهاونا فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم ألا يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله استتيب كالمرتد فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا نقلها أبو بكر واختارها وعنه يختص الكفر بالصلاة وعنه تهاونا كزكاة اذا قاتل الإمام عليها وعنه يكفر إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال لأن في وجوبه على الفور خلافا وعنه لا كفر ولا قتل في الصوم والحج خاصة فرع من أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر كعبد الله بن أبي بن سلول فإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه ألا يفعل فنفاق لقوله تعالى في ثعلبة ﴿ ومنهم من عاهد الله ﴾ الاية التوبة 75 وهل يكفر على وجهين

فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء روي عن أبي بكر وعلي وقاله أكثر العلماء لعموم قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولقوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنى وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة فمحمول على أنه تقدم لهم إسلام وأما نهيه عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية بدليل أنه لا يقتل الشيوخ ولا المكافيف وهو بالغ عاقل مختار لأن الطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو

شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف في المذهب دعي اليه أي لا يقتل حتى يستتاب وهو قول أكثر العلماء وهي واجبة نصره القاضي والمؤلف لأنه قتله في الحال [ج ٩ - ص ١٧٣]

ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يتب قتل وعنه لا تجب استتابته بل تستحب ويجوز عليه السلام أمر باستتابته رواه الدارقطني ولقول عمر رواه مالك وغيره ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان بدليل نساء الحرب ثلاثة أيام في قول الأكثر لما روى محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه قال قدم رجل على عمر من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك ولأنه لو لم يجب لما برىء من فعلهم ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس ولأنها مدة يتكرر فيها الرأي ويتقلب النظر فلا يحتاج إلى أكثر منها وعنه لا يجوز تأجيله بل يجب قتله في الحال إلا أن يطلب الأجل فيؤجل ثلاثا وضيق عليه بالحبس وغيره ليرجع إلى الحق فإن لم يتب قتل لحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه ولا يجوز أخذ فداء عنه لأن كفره أغلظ وعنه لا تجب استتابته روي عن الحسن وطاووس لأنه عليه السلام لم يذكر ذلك ولقول معاذ لا أجلس حتى يقتل ولأنه يقتل لكفره فلم تجب استتابته كالأصلي بل تستحب للاختلاف في وجوبها وأقلها الاستحباب ويجوز قتله في الحال كالأصلي والأول أصح لأن الخبر محمول على القتل بعد الاستتابة والخبر الآخر روي فيه أن المرتد استتيب قبل قدوم معاذ

رواه أبو داود وقال الزهري يدعى ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه وقال النخعي يستتاب أبدا وهذا وعزر ولا ضمان عليه سواء قتل قبل الاستتابة أو بعدها وإذا عقل الصبي الاسلام صح إسلامه وردته

ويقتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله غيره بغير إذنه أساء يفضي إلى أنه لا يقتل أبدا وهو مخالف للسنة والاجماع ويقتل بالسيف لقوله رضي الله عنه قربناه فضربنا عنقه ولأنه إذا أطلق انصرف إليه لأنه أسرع لزهوق النفس ولا يجوز حرقه بالنار وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بتحريقهم والأول أولى لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار رواه البخاري ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان أو عبدا في قول عامة العلماء ونصره في الشرح لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام أو نائبه كقتل الحر ولقوله عليه السلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم لا يتناول القتل في الردة لأنه قتل لكفره ولا حد في حقه وخبر حفصة لما بلغ عثمان تغيظ عليها وشق عليه والجلد في الزنى تأديب عنده بخلاف القتل فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لافتئاته على الإمام أو نائبه ولا ضمان عليه أي على القاتل لأنه محل غير معصوم سواء قتل قبل الاستتابة أو بعدها لأنه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها فإن لحق بدار الحرب فلكل واحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مال وما تركه بدارنا معصوم نص عليه وقيل يصير فيئا في الحال وصححه المجد فرع رسول الكفار لا يقتل ولو كان مرتدا حكاه في الفروع عن الهدي بدليل رسول مسيلمة وفي الفنون في مولود برأسين فبلغ نطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح

إن تقدم الإسلام فمرتد وإذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته

[ج ٩ - ص ١٧٥]

في ظاهر المذهب لإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي وعد ذلك من مناقبه وسبقه وقال % سبقتكم إلى الإسلام طرا % صبيا ما بلغت أوان حلمي % ويقال هو أول من أسلم من الصبيان ومن الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال وقال عروة أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين ولم يرد على أحد إسلامه من صغير أو كبير لقوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولأن من صح إسلامه صحت ردته كالبالغ وقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وأمرت أن أقاتل الناس الخبرين والصبي داخل في ذلك وإذا صح إسلمه كتب له لا عليه وتحصل له سعادة الدارين لا يقال الإسلام يوجب عليه الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم وحرمة ميراث قريبه الكافر وفسخ نكاحه لأن الزكاة نفع محض لأنها سبب النماء والزيادة محصنة للمال والميراث والنفقة أمر متوهم وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار ثم هو ضرر مغمور بالنسبة إلى ما يحصل له من سعادة الآخرة والخلاص من الشقاء والخلود في الجحيم وشرطه أن يعقل الإسلام ومعناه أن يعلم أن الله ربه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وهذا لا خلاف في اشتراطه فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام وإنما كلامه لقلقة بلسانه لا يدل على شيء ذكره في المغني وغيره وشرط الخرقي مع ذلك وتبعه في الوجيز أن يكون له عشر سنين لأنه عليه السلام أمر بضربه على الصلاة لعشر وجوابه بأن أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك ولم

يجدوا له حدا من السنين وحكاه ابن المنذر عن أسلم ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الاسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه [ج ٩ - ص ١٧٦]

وعنه يصح إسلامه دون ردته وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ والمذهب الاول وإن أحمد لأن المقصود متى حصل لا حاجة إلى زيادة عليه وعنه يصح إسلامه دون ردته قال في الفروع وهي أظهر لأن الإسلام محض مصلحة ونفع فصح منه بخلاف الردة فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد فإن بلغ وأصر على الكفر كان مرتدا وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث الخبر ولأنه قول تثبت به الأحكام فلم يصح من الصبي كالهبة والعتق ولأنه غير مكلف أشبه الطفل وعنه يصح من ابن سبع سنين لأمره بالصلاة وقال ابن أبي شيبة يصح من ابن خمس سنين وأخذه من إسلام علي والمذهب الأول نصره القاضي في الخلاف وعليه فقهاء الأصحاب وعليهن يحال بينه وبين الكفار قال في الانتصار يتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم وإن فرضيته مترتبة على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان وإن أسلم ثم رجع ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله كالبالغ وأجبر على الإسلام لأنه محكوم بإسلامه لمعرفتنا بعقله لأنه كفر بعد إسلامه ولهذا صح إسلامه لأنه محض مصلحة أشبه الوصية وعنه ينتقل منه ولا يجبر على الإسلام لأنه في مظنة النقص وصدقه جائز ذكره أبو بكر والعمل على الأول لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به وفعله فعل العقلاء وقد تكلم بكلامهم ولا يقتل حتى يبلغ أي الصبي لا يقتل إذا ارتد حتى يبلغ سواء قلنا بصحة ردته أو لا لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا

يتعلق به حكم الزنى والقتل فكذا لا يجب أن يتعلق به حكم الردة ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه لأجل وجوب استتابته ثلاثا أيام من وقت ردته فإن مات في سكره مات كافرا وعنه لا تصح ردته [ج ٩ - ص ١٧٧]

فإن ثبت على كفره قتل ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة فإن ثبت على كفره قتل لأنه مرتد مصر على ردته فوجب قتله سواء كان مرتدا قبل بلوغه أو لا وسواء كان مسلما أصليا فارتد أو كافرا فأسلم صبيا ثم ارتد فرع من أسلم وقال لم أدر ما قلت أو لم أعتقد الإسلام وإنما أظهرت الشهادتين صار مرتدا نص عليه في مواضع وعنه يقبل منه مع ظن صدقه نقلها عنه محمد بن الحكم

ومن ارتد وهو سكران صحت ردته في ظاهر المذهب وجزم به الأكثر وصححه في الرعاية كإسلامه لقول علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبدوا مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي ولأنه لا يزول عقله بالكلية ولهذا يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويغتم بما يضره ويزول سكره عن قرب أشبه الناعس بخلاف المجنون لم يقتل حتى يصحو فيكمل عقله ويفهم ما يقال له وتزول شبهته لأن القتل جعل للزجر وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته لأن زوال العقل حصل بتعديه بخلاف الصبي فإن استمر سكره أكثر من ثلاث لم يقتل حتى يصحو ثم يستتاب عقب صحوه فإن تاب وإلا قتل في الحال فإن مات أو قتل في سكره مات كافرا لأنه هلك بعد ارتداده ولم ترثه ورثته من المسلمين وعنه لا تصح ردته لأن ذلك متعلق بالاعتقاد والقصد والسكران لا يصح عقده أشبه المعتوه ولأنه زائل العقل غير مكلف أشبه المجنون وجوابه المنع بأنه ليس بمكلف فإن

الصلاة واجبة عليه وعنه يصح إسلامه فقط حكاها ابن البنا روايتين احداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال [ج ٩ - ص ١٧٨]

وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله ورسوله أو الساحر على

تنبيه علم مما سبق أنه لا تصح ردة مجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له فإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه يقتل بالإصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالإصرار فإن قتل أحد هؤلاء عزر القاتل ولا ضمان عليه لأنه قتل كافرا لا عهد له أشبه قتل نساء أهل الحرب

وهل تقبل توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله أو الساحر أي من كفر بسحره على روايتين

إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال الأشهر أنها لا تقبل توبتهم جزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع وذكر ابن حمدان أنها أظهر واختارها أبو بكر لأن عليا أتي بزنادقة فسألهم فجحدوا فقامت عليه البينة فقتلهم ولم يستتبهم رواه أحمد في مسائل عبد الله ولأن في قبول توبته خطرا لأنه لا سبيل إلى الثقة به ولأن إبقاءه يؤدي إلى السلطة في الباطن على إفساد عقائد المسلمين وفيه ضرر عظيم فرع من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب ذكره ابن عقيل وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه وكذا من تكررت ردته لقوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم

يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ﴾ النساء ولما روى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة أن ابن مسعود أتي برجل فقال له إنه قد أتي بك مرة فزعمت أنك تبت وأراك قد عدت فقتله وعنه لا تقبل إن تكررت ثلاثا أما من سب الله أو رسوله فالإصح أنها لا تقبل توبته لأن

عظيم جدا أشبه الزنديق ونقل حنبل أو تنقصه وقيل ولو تعريضا نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهو مذهب أهل المدينة وفي الفصول عن أصحابنا لا تقبل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه وإنها تقبل إن سب الله لأنه يقبل التوبة في خالص حقه وجزم به في عيون المسائل لأن الخالق منزه عن النقائص فلا تلحق به بخلاف المخلوق فإنه محل لها فافترقا وأما الساحر فنقل ابن هبيرة أنها لا تقبل توبته في ظاهر المذهب وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا وحديث عائشة في المرأة التي أتت هاروت وماروت يدل عليه ولأن السحر معنى في القلب لا يزول بالتوبة أشبه الزنديق والأخرى تقبل توبته كغيره وهو ظاهر الخرقي زنديقا كان أو غيره روي عن علي وابن مسعود واختاره الخلال وقال إنه أولى على مذهب أبي عبد الله وقدمه في الكافي والرعاية لقوله تعالى ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ الأنفال 38 ولقوله عليه السلام لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس متفق عليه ورجح هذا في الشرح وأجاب عن قتل ابن النواحة بأنه إنما قتله لظهور كذبه في توبته لأنه أظهرها وما زال عما كان عليه من الكفر ويحتمل أنه قتله لغير ذلك وقال في رواية أبي طالب إن أهل المدينة يقولون في الزنديق لا يستتاب قال أحمد كنت أقول ذلك أيضا ثم هبته قال القاضي وظاهره

أنه رجع فلو زعم أن لله ولدا فقد سب الله بدليل قوله عليه السلام إخبارا عن ربه إلا [ج ٩ - ص ١٨٠]

وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يشتمنى ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمنى أما شتمه إياي فزعم أن لي ولدا ولا شك أن توبته مقبولة بغير خلاف فإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فمن سب نبيه أولى أن تقبل والصحيح الأولى لأن أدلتها خاصة والثانية عامة والخاص مقدم على العام فرع الخلاف في قبول توبتهم إنما هو في الظاهر في أحكام الدنيا من ترك قتالهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم وأما قبولها في الباطن فلا خلاف فيه حيث صدق ذكره ابن عقيل والمؤلف وجماعة وفي إرشاد ابن عقيل رواية لا تقبل توبة زنديق باطنا وضعفها وقال كمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية فتاب منها وإن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها كتوبة قاطع طريق بعد القدرة وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وفي الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح

وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه وهو أن يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل متفق عليه وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد ولا يحتاج مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته وهذا يمكن لمن كانت ردته بجحد الوحدانية أو

بجحد رسالة محمد عليه السلام وظاهره لا يغني قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن كلمة التوحيد وعنه يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما بجحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام [ج ٩ - ص ١٨١]

أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو إلى دين من بلى قدمها في الرعاية لأن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ذكره أحمد في رواية مهنا محتجا به ولأنه لا يقر برسالة محمد إلا ويقر بمن أرسله وعنه من مقر به قال في الشرح وبهذا جاءت الأخبار وهو الصحيح لأن من جحد شيئين لا يزول جحده إلا بإقرارهما جميعا قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار ولخبر أسامة وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف عليه الإسلام ومستلزم له وفاقا للشافعية وغيرهم فلو قال أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده لأن ردته بجحده فإذا لم يقر بما جحده بقي الأمر على ما كان عليه من الردة الموجبة لتكفيره فإذا كانت ردته باعتقاد أن محمدا بعث إلى العرب فلا بد وأن يشهد أن محمدا بعث إلى العالمين ولابد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين ولا يكفي مجرد إقراره بما جحده أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده ولأن الرجوع إلى الإسلام لا يكون إلا بذلك فرع يكفي جحده لردته بعد إقراره بها في الأصح كرجوعه عن

حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه قال جماعة يأتي بالشهادتين ونقل ابن الحكم [ج ٩ - ص ١٨٢]

وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله قال الشيخ تقي الدين اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم ولا يحتاج إلى أن يقر بما شهد عليه به فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبا ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار كالإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئه

تنبيه ظاهر كلامه أنه إذا قال أنا مؤمن أو مسلم لم يكتف بذلك ونقل أبو طالب في اليهودي أذا قال قد أسلمت أو أنا مسلم يجبر عليه قد علم ما يراد منه ونصر القاضي وابن البنا الاكتفاء بذلك عن الشهادتين لما روى المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب أحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله رواه مسلم ولأن ذلك اسم لشيء فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء وذكر المؤلف احتمالا أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه فلا يصير مسلما بهذا لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم مسلمون ومنهم من هو كافر فرع إذا شهد عليه بأنه كفر وادعى الإكراه قبل مع قرينة ولو شهد عليه بكلمة

كفر فادعاه قبل مطلقا في الأصح لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس

وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه لقوله الاسلام

فصل ومن ارتد لم يزل ملكه

[ج ٩ - ص ١٨٣]

ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى عليه السلام من صلى صلاتنا الخبر سواء صلى في جماعة أو منفردا في دار الحرب أو الإسلام لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه كالشهادتين ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين ومقتضاه أنها إذا شهدت بأنه أتى بغيرها من زكاة أو صوم أو حج لا يحكم بإسلامه ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة تتميز عن صلاة الكهان ولا تحصل بمجرد القيام وذكر ابن تميم أن من حج أو صام يقصد رمضان أو آتى ماله على وجه الزكاة أو أذن في غير محل الأذان قال ابن حمدان أو غير وقته هل يحكم بإسلامه على وجهين واختار القاضي أنه يحكم بإسلامه بالحج فقط ولا يبطل إحصان المسلم بردته يعني إذا كان محصنا فارتد ثم أسلم لم يزل إحصانه بل إذا زنى فإنه يرجم لأنه ثبت له حكم الإحصان والأصل بقاء ما كان عليه ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها فلم تعد إلى ذمته كدين الآدمي وفي الرعاية في الصوم وجهان في وجوب القضاء وقدم فيها وفي المحرر أنه إذا صلى ثم كفر ثم أسلم في وقتها لم يعدها وقيل بلى وإن حج ثم كفر ثم أسلم فروايتان أشهرهما لا يعيد

فصل

ومن ارتد لم يزل ملكه أي لا يحكم بزوال ملكه قدمه في الكافي والمحرر والمستوعب ونصره في الشرح لأن الردة سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه بها

كزنى المحصن لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل ديونه وأروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته وما أتلف من شيء ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ألا تضمن [ج ٩ - ص ١٨٤]

بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة فإن اسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإلا بطلت وتقضي في المحاربة وأهل الحرب بل يكون موقوفا وتصرفاته من البيع والهبة والوقف ونحوه موقوفة على المذهب قاله ابن المنجا لأنه مال تعلق له حق الغير فكان التصرف فيه موقوفا كتبرع المريض ولكن المذهب أنه يمنع من التصرف فيه قاله القاضي وأصحابه وفي الوسيلة نص عليه ونقل ابن هانيء يمنع منه واختار المؤلف أنه يترك عند ثقة وجعل في الترغيب كلام القاضي والمؤلف واحدا وكذا ذكره ابن البنا وغيره ونص عليه أحمد ولم يقولوا يترك عند ثقة بل قالوا يمنع منه فإن اسلم ثبت ملكه وتصرفاته وكان ذلك صحيحا وإلا بطلت أي إذا مات أو قتل في ردته كان باطلا تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض وينتقل ماله فيئا من حين موته وفي المحرر على ذلك تنفذ معاوضته ويقر بيده وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا وتقضى ديونه لا دين متجدد في الردة وأروش جناياته لأن ذلك حق واجب عليه وينفق على من تلزمه مؤنته لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع أشبه الدين وما أتلف من شيء ضمنه نص عليه لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلأن يوجب على المرتد بطريق الأولى وعنه إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا اختاره الخلال وصاحبه والمؤلف لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا وقيل هم كبغاة قال وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا فرع يؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه كقبلها وظاهر نقل مهنا واختاره جماعة إن أسلم فلا

كعبادته ويتخرج في الجماعة الممتنعة ألا تضمن تمليكا مستأنفا وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات على روايتين [ج ٩ - ص ١٨٥]

ما أتلفته وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه وإن أسلم رد إليه +++++ما أتلفته لأنها في معنى البغاة ولأن الباغي إنما لم يضمن ما أتلفه لأن في تضمينه تنفيرا له عن الرجوع إلى قبضة الإمام وهذا المعنى موجود في الجماعة المرتدة الممتنعة وصحح في الشرح والرعاية أنه لا ضمان عليهم فيما أتلفوه حال الحرب وقال أبو بكر يزول ملكه بردته وأختاره أبو إسحاق وصاحب التبصرة والطريق الأقرب وهو رواية لأن عصمة نفسه وماله إنما يثبت بإسلامه فزوال إسلامه مزيل عصمتهما كما لو لحق بدار الحرب ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته فوجب أن يملكوا أمواله بها وعنه إن مات أو قتل تبينا زواله من حين ردته فلو باع شقصا مشفوعا أخذ بالشفعة على الأولى وعلى الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه لأن ملكه قد زال بردته وجوابه أن ملكه قد تعلق به حق غيره في بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفا كتصرف المريض

وإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا أي جديدا لزواله بردته

تذنيب إذا تزوج لم يصح لأنه لا يقر على النكاح كنكاح الكافر مسلمة وكذا لو زوج موليته لأن النكاح لا يكون موقوفا فلو وجد منه سبب يقتضي التمليك كالصيد والاتهاب والشراء ثبت الملك إن بقي ملكه وإلا فلا واحتج به في الفصول على بقاء ملكه وأن الدوام أولى وعلى رواية يرثه مسلم أو أهل دينه الذي اختاره فكمسلم فيه وفي الانتصار لا قطع بسرقته

لعدم عصمته وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات الخمس على روايتين

إحداهما يقضي صححها في الرعاية وجزم بها في الوجيز لأنها استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الاسلام ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة وهل يقرون على كفرهم على روايتين

فصل

[ج ٩ - ص ١٨٦]

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا عبادة واجبة التزم بوجوبها واعترف به في زمن إسلامه فلزمه القضاء كغير المرتد

والثانية لا يلزمه وهي الأشهر لقوله تعالى ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ الأنفال 38 وكالحربي ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم وقدم المجد وابن تميم أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة وصوم وزكاة وقيل يقضي غير الحج رواية واحدة وذكر ابن تميم وابن حمدان أنه لو جن بعد تركه لم تسقط عنه الصلاة وإن حاضت سقطت

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما لأنه لا يقر على الردة يدل عليه قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا يثبت لهم حكم الردة وقول علي تسبي المرتدة ضعفه أحمد ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده وكولد من أسر من ذمة ومن لم يسلم منهم قتل للخبر ويعتبر فيه بلوغهم ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة في المنصوص لأنه محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد نص عليه وهو ظاهر كلام جماعة كولد الحربيين وعنه لا يجوز استرقاقهم فرع الحمل حال ردته ظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره واقتصر

عليه في الشرح وفي الكافي الحمل كالولد الظاهر لأنه موجود ولهذا يرث وهل يقرون أي من ولد بعد الردة على كفرهم على روايتين

إحداهما وجزم بها في الوجيز يقر على كفره كأولاد أهل الحرب وكالكافر

[ج ٩ - ص ١٨٧]

الأصلي والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق

والثانية لا يقرون فإذا أسلموا رقوا لأنهم أولاد من لا يقر على كفر فلا يقرون كالموجودين قبل الردة قال في الفروع وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل فيه روايتان فرع إذا لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي وما بدارنا فيء من حين موته ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم ما لهم وولد حدث بعد الردة وعلى الإمام قتالهم

فصل

اعلم أن السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة في قول الأكثر فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يمنع الرجل من وطء امرأته ومنه ما يفرق بينهما وقال بعض العلماء إنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل لقوله تعالى ﴿ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾ طه 66 وجوابه قوله تعالى ﴿ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ﴾ يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن ولولا أن له حقيقة لما أمر بالاستعاذة منه

قال الأصحاب يكفر الساحر بتعلمه وتعليمه كاعتقاد حله وعنه لا اختاره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أبو بكر بعمله قال في يسحر

بالادوية والتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر

[ج ٩ - ص ١٨٨]

فصل

والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل فأما الذي الترغيب هو أشد تحريما وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حدا و هو الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر لقوله تعالى ﴿ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴾ البقرة 103 ويقتل بالسيف لما روى جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح عن جندب موقوف وعن بجالة بن عبد قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة رواه أحمد وسعيد وفي رواية فقتلنا ثلاث سواحر في يوم واحد وقتلت حفصة جارية لها سحرتها رواه مالك وروي عن عثمان وابن عمر وعن أحمد لا يقتل به لحديث عائشة في المدبرة التي سحرتها فباعتها ولقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الخبر فإن قتل به قتل وعلى الأول هذا في الساحر المسلم فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل بسحره على الأصح وفي التبصرة إن اعتقد جوازه فأما الذي يسحر بالإدوية والتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر ولا يقتل ذكره الأصحاب لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم ويبقي من

سواهم من السحرة على أصل العصمة ولكن يعزر إذا ارتكب معصية وفي عيون المسائل إنه يعزر بما يردعه وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون [ج ٩ - ص ١٨٩]

ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها المكر والحيلة أشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين والمتقاربين لا سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية فهنا أولى ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص كما يقتص من المسلم وإلا فالدية

وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل وهو المعزم وكذا من يحل السحر وقد توقف أحمد عنها قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال رخص فيه بعض الناس ثم قال ما أدري ما هذا وفيه وجهان وفي الشرح إن كان يحله بشيء من القرآن أو الذكر فلا بأس به وإن كان بشيء من السحر فقط توقف أحمد وذكره أبو الخطاب تبعا للقاضي وقدمه في المحرر في السحرة الذين يقتلون لما ذكرنا وذكر القاضي في هذا تفصيلا فقال الساحر إن اعتقد أن الكواكب فاعلة ويدعي بسحره معجزات لا يجوز وجود مثلها إلا للأنبياء مثل أن يدعي أن الجن تخبره بالمغيبات وأنه يقدر على تغيير صور الاشياء والطيران في الهواء والمشي على الماء فهو كافر وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل المدبر لذلك عند وجود هذا الفعل من جهته لم يصدقه وقال ابن عقيل لا يكفر إلا بالاعتقاد لأن السحر صناعة تعود بفساد أحوال وأخذ أموال وقتل نفوس وهذا القدر بالمباشرة لا يوجب التكفير

أصل مشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى وشعير وقداح إن

[ج ٩ - ص ١٩٠]

لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عزر وكف عنه وإلا كفر ويحرم طلسم ورقية بغير عربية وقيل يكره فرع من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم لأنه لم يجب غير القتل وقد سقط والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفي لم تجز الزيادة عليه كسائر الحدود قال الشيخ تقي الدين فيمن شفع عنده في شخص فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما قبل إن تاب بعد القدرة عليه قبل لا قبلها في أظهر قولي العلماء ويسوغ تعزيره أي بعد التوبة

مسائل الأولى إذا أسلم أبو حمل أو طفل أو أحدهما لا جد وجدة والمنصوص أو مميز لم يبلغ ونقل ابن منصور لم يبلغ عشرا فمسلم

الثانية إذا ماتا أو أحدهما في دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح نقله واختاره الأكثر وفي الموجز والتبصرة لا بموت أحدهما نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكما تصح الوصية لأم ولده ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين كما قالوا الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت مالكا يوم الموت لكن في حكم المالك ذكره القاضي

الثالثة أطفال الكفار في النار وعنه الوقف واختار ابن عقيل وابن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونا واختار الشيخ

[ج ٩ - ص ١٩١]

تقي الدين تكليفهم في القيامة ويتبع أبويه في الإسلام كصغير فيعايا بها نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع أبويه وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما قال في الفروع وتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة

الرابعة من أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر وذكر ابن حامد روايتين

إحداهما تشديد وتأكيد والثانية يجب الوقف ولا نقطع بأنه ينقل عن الملة نص عليه

خاتمة قال الأصحاب معرفة الله تعالى وجبت شرعا نص عليه وقيل بلى وكذا إن عدما أو أحدهما بلا موت كزنى ذمية ولو بكافر واشتباه ولد مسلم بكافر نص عليهما والله أعلم

كتاب الأطعمة

كتاب الاطعمة

وهي جمع طعام قال الجوهري هو ما يؤكل وربما خص به البر والمراد هنا ما يؤكل ويشرب فيتبين ما يباح أكله وشربه وما يحرم

والأصل فيها الحل لقوله تعالى ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ البقرة 29 ولقوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ﴾ الأعراف 157 لكن قال

الشيخ تقي الدين لمسلم وقال أيضا الله أمر بالشكر وهو العمل بطاعته بفعل المأمور وترك المحذور فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لقوله تعالى ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ الآية المائدة 93 ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يعطي الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش وقوله تعالى ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ أي عن الشكر عليه فيحل كل طعام طاهر يحترز به عن النجس لا مضرة فيه على ما فيه مضرة كالسموم ثم مثل ذلك بقوله من الحبوب والثمار فهو بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المذكورة وغيرها أي غير الحبوب والثمار مما يجمع الطعم والطهارة وعدم المضرة وقد سأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس به فأما النجاسات كالميتة والدم فمحرمة لقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ المائدة 3 ولأن أكل الميتة أقبح من الإدهان بدهنها والاستصباح وهو حرام فلأن يحرم [ج ٩ - ص ١٩٣]

وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة والحيوانات مباحة إلا الحمر ما هو أقبح منه بطريق الأولى وغيرهما أي غير ذلك من النجاسات محرم فلأنه خبيث وقد حرم الله أكل الخبيث وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال لا تقربوه وفي الأكل قربانه وهو منهي عنه وهو يقتضي التحريم وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة لقوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ البقرة 195 ولأن ذلك يقتل غالبا فحرم أكله لإفضائه إلى الهلاك ولذا عد من أطعم السم لغيره قاتلا وفي الواضح المشهور أن السم نجس وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة والحيوانات مباحة لقوله تعالى ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ المائدة 1 ولعموم النصوص الدالة على الإباحة إلا الحمر الأهلية فإنها محرمة في قول أكثر العلماء قال أحمد خمسة وعشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها قال ابن عبد البر لا خلاف في تحريمها وسنده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وعن ابن عباس وعائشة أنهما قالا بظاهر قوله تعالى ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ﴾ الآية الأنعام 145 وأجاب في الخلاف بأن معناه قل لا أجد فيما نزل من القرآن وحديث غالب بن أبجر مختلف الإسناد ولا يعرج عليه مع ما عارضه مع أن الإذن بالتناول منها محمول على حال الاضطرار فرع حكم

ألبانها كهي ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري والأول أصح لأن حكم اللبن كاللحم

وما له ناب يفرس به نص عليه كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب

[ج ٩ - ص ١٩٤]

والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام رواه مسلم قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت مجمع على صحته وهو نص صريح يخص به عموم الآيات فيدخل فيه الأسد ونحوه وقيل يختص بمن يبدأ بالعدوى وروي عن الشعبي أنه سئل عن رجل يداوى بلحم كلب قال لا شفاه الله فدل على أنه محرم والخنزير وهو محرم بالنص والإجماع مع أنه ليس له ناب يفرس به وابن آوى سئل أحمد عنه وعن ابن عرس فقال كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع وكل شيء يأخذ بمخاليبه فمما نهى الله عنه قال ابن عقيل هذا منه يعطي أنه لا يراعى فيهما القوة وأنه أضعف من الثعلب وإن الأصحاب اعتبروا القوة ولأنه مستخبث غير مستطاب ولأنه يشبه الكلب ورائحته خبيثة فيدخل في قوله تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ الأعراف 157 والسنور الأهلي لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال غريب قال أحمد أليس يشبه السباع قال الشيخ تقي الدين ليس في كلامه إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا وأنه يقال يعمها اللفظ ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع ونقل فيه جماعة يكره قال الحسن هو مسخ وابن عرس وقد تقدم والنمس لأنه من جملة السباع والقرد قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين

العلماء في تحريم أكله وأنه لا يجوز بيعه وروي الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع له ناب فيدخل في عموم التحريم وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمة والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والابقع [ج ٩ - ص ١٩٥]

إلا الضبع وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشهين

تنبيه لم يتعرض المؤلف لذكر الدب وهو محرم مطلقا خلافا لابن رزين وفي الرعاية وقيل كبير وهو سهو قال أحمد إن لم يكن له ناب فلا بأس به وهو محمول على الصغير والأشهر أنه حرام مطلقا وكذا الفيل إلا الضبع فإنه مباح وإن كان له ناب لما روي جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم رواه أبو داود لا يقال بأنه داخل في عموم النهي لأن الدال على حله خاص والنهي عام ولا شك أن الخاص مقدم على العام وما له مخلب بكسر الميم وهو بمنزلة الظفر للإنسان من الطير يصيد به نص عليه كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة في قول أكثر العلماء لما روى ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه وقال أبو الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه وقال الليث والأوزاعي لا يحرم شيء من الطير لعموم الآيات المبيحة وجوابه الخبر وبه يخص عموم الأيات وكذا كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه وفي الترغيب تحريما إذ لو حل لقيده بغير مأكله وما يأكل الجيف نص عليه كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع لقوله عليه السلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب والباقي كهو للمشاركة بينهما في أكلها

الجيف ولأنه عليه السلام أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه بل يذبح ويؤكل ونقل عبد الله وغيره يكره وجعل فيه الشيخ [ج ٩ - ص ١٩٦]

وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحشرات كلها تقي الدين روايتي الجلالة وإن غالب أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ونقل حرب لا بأس به لأنه لا يأكل الجيف وما يستخبث أي ما تستخبثه العرب والأصح ذو اليسار وقيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة والمروءة فهو محرم لقوله تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ وما استطابته فهو طيب لقوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ﴾ والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من اهل الأمصار لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع مطلق ألفاظها إلى عرفهم ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورات والمجاعة يأكلون ما وجدوا ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال كل ما دب ودرج إلا أم جنين وما لا تعرفه العرب ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأسماء شبها به وعن أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل قاله الشيخ تقي الدين كالقنفذ لقوله عليه السلام هو من الخبائث رواه سعيد وأبو داود قال أبو هريرة هو حرام رواه سعيد وعلل أحمد القنفذ بأنه يبلغه أنه مسخ أي لما 4 مسخ على صورته دل على خبثه ولأنه يشبه المحرمات ويأكل الحشرات أشبه الجرذ والفأرة وهي الفويسقة نص عليه والحيات جمع حية لأمره عليه السلام محرما بقتلها رواه مسلم ولأن لها نابا من السباع نص عليه والعقارب والوطواط نص عليهما لقوله تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ والحشرات كلها كالديدان وبنات وردان والخنافس

والزنابير والنحل وفيهما رواية في الإشارة وفي الروضة يكره ذباب وزنبور وفي التبصرة في خفاش وخطاف الذئبه من الذيخ وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان [ج ٩ - ص ١٩٧]

وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد وجهان وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ قال الشيخ تقي الدين هل هي للتحريم فيه وجهان وما تولد من مأكول وغيره كالبغل وهو محرم نص عليه عند كل من حرم الحمار الأهلي والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئبة من الذيخ وهو الذكر من الضبعان فيكون العسبار عكس السمع وظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب قاله الشيخ تقي الدين لا متولد من مباحين كبغل من وحش وخيل وما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء يؤكل تبعا لا أصلا في الأصح فيهما وقال ابن عقيل يحل بموته قال ويحتمل كونه كذباب فيه روايتان

قال أحمد في الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو وقال عن تفتيش الثمر المدود لا بأس به إذا علمه فرع إذا كان أحد أبويه المأكولين مغصوبا فهو تبع لأمه حلا وحرمة وملكا وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان وفيه مسائل

الأولى أكثر الروايات عن أحمد تحريم الثعلب واختارها الخلال وصححها الحلواني وقدمها في الفروع نقل عبدالله أنه قال فيه لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر

والثانية يباح اختارها الشريف وأبو بكر لأنه يفدي في الحرم والإحرام والأول أظهر للنهي عن كل ذي ناب من السباع

الثانية الوبر هو مباح قاله في الشرح واقتصر عليه في الكافي وقاله عطاء وطاووس لأنه يأكل النبات وليس له ناب يفرس به وليس

[ج ٩ - ص ١٩٨]

وما عدا ذلك مباح كبهيمة الانعام والخيل هو من المستخبثات فكان مباحا كالأرنب والثانية حرام وقاله القاضي قياسا على السنور

الثالثة سنور البر والأشهر أنه محرم وصححه الحلواني وقدمه في الفروع لأنه عليه السلام نهى عن أكل الهر فيدخل فيه البري والثانية مباح لأنه بري أشبه الحمار البري

الرابعة اليربوع وهو مباح نصره في الشرح وقدمه في الكافي وقاله عطاء وعروة لقضاء عمر فإنه حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة والثانية حرام لأنه يشبه الفأر وكبق وهذا الخلاف في هدهد وصرد وفي سنجاب وجهان

أحدهما محرم واختاره القاضي لأنه ينهش بنابه أشبه الجرذ والسنور

والثاني يباح أشبه اليربوع وكذا الخلاف في الغداف والفنك وما عدا هذا مباح بلا كراهة لعموم الأدلة الدالة على الإباحة كبهيمة الأنعام لقوله تعالى ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ المائدة 1 وهي الإبل والبقر والغنم والخيل عرابها وبراذينها نص عليه وهو قول أكثر الفقهاء لما روى جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب ولا مخلب فكان حلال كبهيمة الأنعام وقال الأوزاعي يكره لقوله تعالى ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ النحل 8

وعن خالد بن الوليد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وجوابه بأن قال أبو داود هو منسوخ وقال النسائي حديث الإباحة أصح ويشبه إن كان صحيحا أن [ج ٩ - ص ١٩٩]

والدجاج والوحشي من البقر والظباء والحمر والزرافة والنعامة والارنب والضبع يكون منسوخا قال النووي اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف وقال الإمام أحمد ليس له إسناد جيد وقال فيه رجلان لا يعرفان وأما الآية فإنهم يتمسكون بدليل خطابها وهم لا يقولون به مع أن نصه على ركوبها لكونه أغلب منافعها لا يدل على تحريم أكلها وفي برذون رواية بالوقف والدجاج على اختلاف أنواعها وقال أبو موسى رايت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج والوحشي من البقر والظباء والحمر والتيس والوعل والمها وسائر الوحش من الصيود كلها وظاهره ولو تأنس وهو مجمع عليه إلا ما روي عن طلحة بن مصرف أن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف هو بمنزلة الأهلي قال أحمد وما ظننت أنه روي في هذا شيء وليس الأمر عندي كما قال ولأن الضب إذا تأنست لم تحرم كالأهلي إذا توحش لم يحل والزرافة في المنصوص لأنها تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه وأعلا منه وذلك لا أثر له في تحريمها ولأنها مستطابة ليس لها ناب ولا هي من المستخبثات أشبهت الإبل وعنه الوقف فيها وحرمها أبو الخطاب والأول أصح والنعامة بغير خلاف علمناه لقضاء الصحابة فيها بالفدية إذا قتلها المحرم والأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله متفق عليه وأمر بأكلها رواه أبو داود ولأنه حيوان مستطاب ليس بذي ناب أشبه الظباء ولا نعلم قائلا بتحريمه إلا ما روي عن عمرو بن العاص قاله في الشرح وذكر السامري وابن حمدان

رواية بتحريمها والضبع وقد علم حكمها فيما سبق وفيها رواية قاله ابن البنا وهي قول أكثر العلماء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع [ج ٩ - ص ٢٠٠]

والضب والزاغ وغراب الزرع وسائر الطير وجميع حيوان البحر إلا الضفدع والحية لكن هذا حديث تفرد به عبد الملك بن المخارق وهو متروك الحديث

لكن هذا حديث تفرد به عبد الملك بن المخارق وهو متروك الحديث وفي الروضة إن عرف منه أكل ميتة فكجلالة والضب قال ابن هبيرة رواية واحدة وقاله الأكثر لما روى ابن عباس قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاحتزته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه وحديث النهي فيه ليس بثابت والزاغ وهو صغير أغبر وغراب الزرع وهو أسود كبير يطير مع الزاغ ولأن مرعاهما الزرع والحبوب أشبها الحجل وقيل هما واحد وسائر أي باقي الطير كالفواخت والقنابر والقطى والكركي والكروان والبط والأوز والحبارى لقول سفينة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى رواه أبو داود وكذلك الغرانيق والطواويس وطير الماء وأشباه ذلك

ونقل مهنا يؤكل الأيل قيل إنه يأكل الخبائث فعجب من ذلك وجميع حيوان البحر لقوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ المائدة 96 ولقوله عليه السلام لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل

ميتته رواه مالك وفي الخبر أن الله أباح كل شيء في البحر لابن آدم إلا الضفدع نص عليه وقدمه أكثر الأصحاب وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقول الشعبي لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم لا يعارضه والحية لأنها من الخبائث وفيها وجه وأطلقهما ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة [ج ٩ - ص ٢٠١]

والتمساح وقال ابن حامد وإلا الكوسج وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحر في الفروع والتمساح وفي الوجيز ك المقنع والأصح أنه محرم ونص عليه وعلله بأنه يأكل الناس قال أحمد يؤكل كل شيء في البحر إلا الضفدع والحية والتمساح وفيه رواية أنه يباح لأنه حيوان البحر وقال ابن حامد والقاضي وإلا الكوسج وهو مقتضى تعليل أحمد في التمساح وصحح في الرعاية أنه حلال وهو مقتضى مذهب الشافعي والأول أشهر وهو سمكة في البحر لها خرطوم كالمنشار تفترس وربما التقمت ابن آدم وقصمته نصفين وهي القرش ويقال إنها إذا صيدت ليلا وجدوا في جوفها شحمة طبية وإن صيدت نهارا لم يجدوها وقال أبو على النجاد وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد وحكاه في التبصرة رواية لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه لأن ذلك غير مباح في البر ويدخل فيه كلب الماء والمذهب أنه مباح لما روى البخاري أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه جلد من جلود كلاب الماء وهو قول أكثر العلماء وتحرم الجلالة التي أكثر علفها أي غذائها النجاسة كذا في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها

رواه أحمد وأبو داود والنسائي قال القاضي هي التي تأكل العذرة فإذا كان أكثر علفها النجاسة ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما

[ج ٩ - ص ٢٠٢]

ولبنها وبيضها حتى تحبس وعنه تكره ولا تحرم وتحبس ثلاثا وعنه يحبس الطائر حرم لحمها ولبنها وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم قال المؤلف وتحديدها يكون أكثر علفها النجاسة لم أسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير ولبنها لما روى ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وإسناده ثقات وبيضها ولحمها ولبنها ولأنه متولد من النجاسة حتى تحبس وتطعم الطاهر إذ المنع بزول بحبسها وعنه تكره ولا تحرم قال في الشرح والعمل عليها لأنهم مختلفون في حرمته ولأنه حيوان أصله الإباحة لا ينجس بأكل النجاسات لأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يحكم بنجاسة ظاهره إذ لو نجس لما ظهر بالإسلام والاغتسال وعلى الأول وتحبس ثلاثا أي تحبس ثلاثة أيام نص عليه وهو المذهب لأن ابن عمر كان إذا أرادا أكلها حبسها ثلاثا وأطعمت الطاهرات وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك من الإبل والبقر أربعين يوما قدمها في الكافي لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة رواه الخلال ولأنها أعظم جسما وعنه يحبس غير طائر أربعين وعنه والبقر ثلاثين ذكره في الواضح وهو وهم قاله ابن بطة وجزم به في الروضة

وقيل الكل أربعين وهو ظاهر رواية الشالنجي قال في المحرر لا يجوز أن تعلف الإبل والبقر التي لا يراد ذبحها ابن عقيل ليس بنجس ولا يحرم بل يطهر بالاستحالة [ج ٩ - ص ٢٠٣]

وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار محرم وإن سقي بالطاهر طهر وحل وقال بالقرب الأطعمة النجسة أحيانا انتهى ويحرم علفها نجاسة تؤكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه وعنه يكره إطعام الميتة كلبا معلما أو طائرا معلما والنص جوازه ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا وقيل يجوز مطلقا فرع كره أحمد ركوبها لأنها ربما عرقت فأصابه وعنه يحرم وسأله ابن هانئ بقرة شربت خمرا أيجوز أكلها قال لا حتى تنتظر أربعين يوما ذكره ابن بطة وأطلق في الروضة تحريم الجلالة وأن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا وهو معنى كلام غيره وما سقي أو سمد بالماء النجس من الزروع والثمار محرم نجس نص عليه جزم به في الكافي والوجيز وقدمه السامري وابن حمدان لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة ولأنه يتغذى بالنجاسة وتتربى فيها أجزاؤه والاستحالة لا تطهر ذكر أبو بكر في التنبيه أنه لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة ولم يفرق قال السامري هو محمول عندي على المقبرة العتيقة وإن سقي بالطاهر أي بالطهور بحيث يستهلك عين النجاسة طهر وحل لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات وقال ابن

عقيل وهو قول أكثر الفقهاء وجزم به في التبصرة ليس بنجس ولا يحرم بل هو طاهر مباح بل يطهر بالاستحالة لأن [ج ٩ - ص ٢٠٤]

كالدم يستحيل لبنا

فصل

ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له ما يسد النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا فطهر بالاستحالة وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ونقل جعفر أنه كره العذرة ورخص في السرجين

مسائل كره أحمد أكل طين لضرورة وسأل رجل يزيد بن هارون عن أكل المدر فقال حرام قال الله تعالى ﴿ كلوا مما في الأرض حلالا ﴾ البقرة 168 ولم يقل كلوا الأرض وذكر بعضهم أن أكله عيب إن كان يتداوى به كالأرمني أو كان لا مضرة فيه ولا نفع كاليسير جاز قاله في الشرح وكذا يكره أكل غدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضجه بطبخ نص عليه وحب ديس بحمر ومداومة أكل لحم ولا بأس بلحم نيء ولحم منتن نص عليه وذكر جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا ويكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجأهم والخبز الكبار وقال ليس فيه بركة ووضعه تحت القصعة لاستعماله له وحرمه الآمدي وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من طعام من عادته السماحة

فصل

ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا سوى سم ونحوه بأن يخاف تلفا وقيل أو ضررا وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية أكل وجوبا نص عليه وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا وقيل ندبا وهو المراد بقوله حل له ما يسد محرم فقال اصحابنا يأكل الميتة

[ج ٩ - ص ٢٠٥]

رمقه وهل له الشبع على روايتين وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميته وصيدا وهو رمقه اختاره الأكثر لقوله تعالى ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ البقرة 173 ويحرم ما زاد على الشبع إجماعا وهل له الشبع على روايتين

أظهرهما أنه لا يباح وهو ظاهر الوجيز والفروع لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء

والثانية يباح اختارها أبو بكر لما روى جابر ابن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غني يغنيك قال لا قال فكلوها رواه أبو داود ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح وقيل هذا مقيد بدوام الخوف وينبني عليهما تزوده قاله في الترغيب وجوزه جماعة ونقل ابن منصور والفضل يتزود إن خاف الحاجة واختاره أبو بكر قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف كذا هنا وهذا إن لم يكن في سفر محرم فإن كان فيه ولم يتب فلا ويجب تقديم السؤال قبل أكله نص عليه وقال لسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله قال القاضي يأثم إذا لم يسأل ونقل الأثرم إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه

وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه أي جهله وميتة وصيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة وقاله سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق وحقه يلزمه غرامته بخلاف حق الله فإنه لا عوض فيه وفي الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله [ج ٩ - ص ٢٠٦]

ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة وإن لم يجد إلا هذا ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة هذا وجه لأنه قادر على الطعام الحلال أشبه ما لو بذله مالكه وفي الكافي هي أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر وفي مختصر ابن رزين ولو بقتاله ثم صيدا ثم ميتة فلو علمه وبذله ففي بقاء حله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم فإن بذله بثمن مثله لزمه وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال فإن وجد صيدا وطعاما أكل من الطعام وإن وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من الصيد قاله القاضي وقال أبو الخطاب يأكل من الميتة فإن اشتبهت ميتة بمذكاة تحرى على الأشهر ولو وجد ميتتين إحداهما مختلف فيها أكل منها وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه فهو أحق به ولا يجوز لغيره أخذه لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك أشبه غير حالة الاضطرار وهذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وعلى الأول إن أخذه منه أحد فمات لزمه ضمانه لأنه قتله بغير حق فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه في ثاني الحال فهل يملكه أو يدفعه إلى المضطر إليه في الحال فيه وجهان أظهرهما له إمساكه قاله في الرعاية واختاره المؤلف وظاهره أنه لا يجوز له إيثاره وفي الهدي له ذلك وأنه غاية الجود لقوله تعالى ﴿ ولو كان بهم خصاصة ﴾ الحشر 9 ولفعل جماعة من الصحابة وعد ذلك في مناقبهم وإلا أي وإن

لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه لزمه بذله لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله كما [ج ٩ - ص ٢٠٧]

بقيمته فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته فإن منعه فله قتاله على ما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق بقيمته نص عليه وظاهره ولو في ذمة معسر وفيه احتمال وفي زيادة لا تجحف وجهان وفي الانتصار وعيون المسائل فرضا بعوضه وقيل مجانا اختاره الشيخ تقي الدين كالمنفعة في الأشهر فإن أبى للمضطر أخذه بالأسهل فإن امتنع أخذه قهرا لأنه يستحقه دون مالكه ويعطيه قيمته أي يعطي المالك قيمته لئلا يجتمع عليه فوات العين وفوات المالية فإن منعه فله قتاله جزم به في الكافي والوجيز وصححه في الرعاية وفي الترغيب وجه وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أنه لا يجوز قتاله كما ذكر في دفع الصائل على ما يسد رمقه وهو الأولى قاله في الشرح أو قدر شبعه لأنه منعه من الواجب عليه أشبه مانعي الزكاة على اختلاف الروايتين للتنبيه على أن المبيح للقتال منع ما يباح له لأنه الواجب لكن لو لم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل أخذه وأعطاه قيمته وقال القاضي يقاتله فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه لأنه ظالم بقتاله أشبه الصائل وإن قتل المضطر فعليه ضمانه لأنه قتل ظلما فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع فلو وجده ميتا فله أكله وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان

أحدهما لا يجوز صححه في الرعاية وهو قول أكثر الأصحاب لأن الحي والميت يشتركان في الحرمة بدليل قوله عليه السلام كسر عظم الميت

ككسر عظم الحي

والثاني بلى اختاره أبو الخطاب وابن عقيل وجزم به في الوجيز لأن الأكل من اللحم لا من العظم [ج ٩ - ص ٢٠٨]

فصل

ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه والمراد بالخبر التشبيه في أصل الحرمة لا بمقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقود قال المؤلف وهو أولى وظاهره أنه إذا كان حيا أنه لا يحل قتله ولا إتلاف عضو منه مسلما كان أو كافرا وهذا لا اختلاف فيه لأن المعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له أن يبقي نفسه بإتلافه

تنبيه إذا لم يجد المضطر شيئا لم يبح له أكل بعض أعضائه لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم فلو وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع منه ولا العدول إلى الميتة إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام فيه مضرة أو يخاف أن يمرضه ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كدفع برد واستقاء ماء وكونه وجب بذله مجانا مع عدم حاجته إليه وقيل يجب العوض

مسألة سئل أحمد عن الجبن فقال يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له تعمل فيه الانفحة الميتة قال سموا اسم الله وكلوا ولا يجوز أن يشتري جوزا أو بيضا قومر به

فصل

ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه نص عليه ولم يذكره في الموجز ولا ناظر ولم يذكره في الوسيلة فله الأكل منه هذا هو المشهور في المذهب ونصره في الشرح ولا ضمان عليه وفي المستوعب إنه اختيار أكثر [ج ٩ - ص ٢٠٩]

ولا يحمل وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة شيوخنا لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان فناد صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد رواه أحمد وابن ماجة ورجاله ثقات وروى سعيد بإسناد عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحوه وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمر وابن عباس وقيده ابن الزاغوني بأنه يأكل بقدر شهوته ولا يشبع ومقتضى كلامه أنه يجوز الأكل من الساقط وصرح به في المحرر والوجيز وهو ظاهر وحكاه في الفروع رواية وفي الترغيب يجوز لمستأذن ثلاثا للخبر وظاهره أنه إذا كان محوطا بحائط أو ناطور فلا يأكل منه لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه وكذا إذا كان مجموعا إلا لمضطر ولا يرمي شجرا نص عليه ولا يصعدها ولا يحمل شيئا بحال سواء كان محتاجا أو لا لأن الأدلة دلت على جواز الأكل فقط فإن في حديث أبي سعيد فكل من غير أن تفسد وفي حديث عمر ولا تتخذ خبنة وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة وقال قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قوله فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الخبر يدل على حرمة الأكل من مال الغير مطلقا ترك العمل به مع الحاجة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثله والعقوبة رواه الترمذي وحسنه وعنه الرخصة للمسافر فقط وهو وجه في الرعاية وفي المستوعب لا

يختلف قوله فيما سقط للمحتاج وغيره واحتج في الكافي والشرح لها بقوله عليه السلام لرافع لا ترم وكل [ج ٩ - ص ٢١٠]

وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز ما وقع صححه الترمذي وعنه ويضمنه اختارها في المبهج للعمومات وفي الزرع القائم وشرب لبن الماشية روايتان كذا في المحرر والفروع وفيه مسألتان

الأولى أنه لا يأكل من الزرع القائم شيئا لأن الرخصة إنما وردت في الثمار لأن الله تعالى خلقها رطبة فالنفس تتوق إليها بخلاف الزرع

والثانية وهي أشهر أنه يأكل من الفريك لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر والحق به المؤلف وغيره الباقلاء

والحمص الأخضر وهو ظاهر الثانية في شرب لبن الماشية يجوز في رواية لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل رواه الترمذي وصححه وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية لا يجوز لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه وحملها في الرعاية على ما إذا لم يكن لها حائط أو حافظ وهذا إذا لم يكن مضطرا فإن كان كذلك جاز مطلقا ويقدمه على الميتة لأنه مختلف فيه فهو أسهل

ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به قال أحمد الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف كان عليه أن يضيفه لما روى المقداد بن كريمة أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات وصححه في الشرح وروى أحمد وأبو داود فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وفي حديث عقبة فإن لم يفعلوا فلهم حق الضيف ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا ألا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه [ج ٩ - ص ٢١١]

وليلة فان أبى فللضيف طلبه عند الحاكم وتستحب ضيافته ثلاثا فما زاد فهو صدقة الذي ينبغي لهم متفق عليه وظاهره أن ضيافة الكافر لا تجب وهو كذلك بل في رواية وتجب لذمي نقله الجماعة واختاره في المغني والشرح لأن الضيافة كصدقة التطوع وأنها لا تجب إلا للمسافر لكن ظاهر نصوصه أنها تجب لحاضر وفيه وجهان للأصحاب في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان جزم في المحرر والوجيز أن المسلم تجب عليه ضيافة المسلم المجتاز به في القرى لا الأمصار يوما وليلة وهو الأشهر فيه نقله الجماعة لما روى أبو شريح الخزاعي مرفوعا قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة متفق عليه وذكر ابن أبي موسى أنها تجب ثلاثة أيام لهذا الخبر وهي قدر كفايته مع أدم وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورفيق ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز له قسمته لأنه أباحه ذكره في الانتصار وغيره فإن أبى فللضيف طلبه عند الحاكم أي يحاكمه ويطلب حق ضيافته فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله نص عليه ونقل الشالنجي إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام فإن أبوا أخذوا منهم مثل ذلك وتستحب ضيافته ثلاثا لخبر أبي شريح فما زاد أي على الثلاثة فهو صدقة لأنه تبرع فكان كصدقة النفل ولا يجب عليه إنزاله في بيته لما فيه من الحرج والمشقة والخبر إنما ورد في الضيافة فقط وأوجبه في المفردات مطلقا كالنفقة إلا ألا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه فيلزمه إنزاله في بيته

للضرورة وعن عائشة مرفوعا من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم وشبهه والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له وعنه [ج ٩ - ص ٢١٢]

باب الذكاة وابن ماجة وإسناده ضعيف قال في كشف المشكل في النهي عن صوم الأضحى الناس فيه تبع لوفد الله تعالى عند بيته وهم كالضيف فلا يحسن صومه عند مضيفه

فائدة من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع والمنقول عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له كذب ذكره الشيخ تقي الدين

باب الذكاة

يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها والاسم الذكاة والمذبوح ذكي فعيل بمعنى مفعول

لا يباح شيء من الحيوان المباح المقدور عليه بغير ذكاة وقاله في الوجيز وغيره لقوله تعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ المائدة 3 وقال ابن عقيل في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد وشبهه فإنه يباح بغير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان الحوت والجراد رواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وعبد الرحمن مختلف فيه ولأنه لا دم له ويباح بما فيه والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له لا نعلم فيه خلافا للأخبار ولا فرق بين ما مات بسبب أو بغيره وأجمعوا على إباحة ما مات بسبب مثل أن صاده

إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه واختلف في الطافي ونصوصه لا بأس به ما لم يتقذره وعنه [ج ٩ - ص ٢١٣]

في السرطان وسائر البحري انه يحل بلا ذكاة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت لا يباح لحديث جابر وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه رواه أبو داود والدارقطني وذكر أن الصواب أنه موقوف وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله قال وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه ولعل المراد عند قائله لقوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ المائدة 96 وهو ما رمى به قال ابن عباس ما مات فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وعن أبي شريح مرفوعا قال إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم رواه الدارقطني وذكره البخاري عنه موقوفا وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل بموته ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان فإن حرم لم ينجس وعنه بلى وعنه مع دم فرع كره أحمد شيء سمك حي لا جراد وقال ابن عقيل فيهما يكره على الأصح ويحرم بلعه حيا ذكره ابن حزم إجماعا وفي المغني والشرح يكره وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة لأن السرطان لا دم فيه قال أحمد السرطان لا باس به قيل له يذبح قال لا وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم وتطييب اللحم بإزالته عنه فأما ما لا دم له فلا حاجة إلى ذبحه ومقتضاه أن ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء فلا يحل إلا بذبحه وهذا هو الصحيح في المذهب وعنه بلى وذهب إليه قوم للأخبار والأصح في السرطان أنه لا يحل إلا بالذكاة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت

يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو انثى وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب [ج ٩ - ص ٢١٤]

بسبب ككبسه وتغريقه ويشترط للذكاة شروط أربعة

أحدها أهلية الذابح وهو أن بسبب ككبسه وتغريقه لأن ذلك بمنزلة الذبح له فوجب اعتباره فيه كالذبح في عيره والأول المذهب للخبر ولأن ما أبيحت ميتته لم يعتبر له سبب بدليل السمك ويشترط للذكاة وفي الروضة والعمدة للنحر شروط أربعة قاله معظم الأصحاب

أحدها أهلية الذابح وهو المذكي وهو أن يكون عاقلا ليصح قصد التذكية ولو مكرها ذكره في الانتصار وغيره قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب وظاهر كلامهم لا يعتبر قصد الأكل وفي التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم تبح وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله أو وطئه آدمي إذا قتل وفي الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لابد من قصد الإحلال فيه وجهان مسلما أو كتابيا لقوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ المائدة 5 قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب والعدل والفاسق سواء ولو مميزا وفي الموجز والتبصرة لا دون عشر فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى ولو قنا وهو كالحر إجماعا ذكره ابن حزم واختلف في ذبح الصبي وقيده أحمد بإطاقة الذبح والجنب والآبق نقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام ونقل

الجماعة لا بأس وفي المستوعب يكره جنب ومثله حائض وظاهره إباحة ذكاة أعمى وذكره في المحرر والوجيز وغيرهما وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب في الأظهر ولا وثني ولا مجوسي ولا مرتد [ج ٩ - ص ٢١٥]

ولا من أحد أبويه غير كتابي ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير مميز قاله ابن هبيرة لما روى سعيد ثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب

وظاهر المتن والفروع وصححه في الكافي والشرح الإباحة لعموم الآية وفي الترغيب في الصابئة روايتان مأخذهما هل هم من النصارى أم لا ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته ولا من أحد أبويه غير كتابي قاله في الكافي والمستوعب تغليبا للتحريم والأشهر الحل مطلقا للعموم قال ابن حمدان من أقر بجزية حلت ذكاته وإلا فلا ولا تباح ذكاة مجنون وفي معناه المغمي عليه في حال إغمائه ولا سكران ولا طفل غير مميز لأنه لا يصح منهم القصد أشبه ما لو ضرب إنسانا بالسيف فقطع عنق شاة ولا وثني ولا مجوسي أما المجوس فلا تحل ذبائحهم لمفهوم الآية ولخبر رواه أحمد وكسائر الكفار غير أهل الكتاب وشذ أبو ثور فأباح صيده وذبيحته لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي وفيه انقطاع ولأنهم يقرون بالجزية كأهل الكتاب قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع وفيه نظر فإن ما صاده المجوس من سمك وجراد ففيه روايتان أصحهما عند ابن عقيل التحريم وأما الوثني فحكمه كالمجوس بل هم شر منهم لأن المجوس لهم شبه كتاب ولا مرتد لأنه لا يقر كالوثني ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين وقال ابن حمدان إن انتقل إلى دين

يقر أهله بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلا فلا غيره إلا السن والظفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر فان ذبح بآلة مغوضبة حل في أصح الوجهين

فصل الثالث

أن يقطع الحلقوم والمريء وعنه [ج ٩ - ص ٢١٦]

فصل الثاني الآلة

وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قضيب أو

فصل الثاني الآلة

وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره نكحشب إلا السن والظفر نص على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه من حديث رافع ولأن جارية كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحته به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها رواه البخاري وفيه فوائد وفي عظم غير سن روايتان كذا في المحرر والفروع

أشهرهما أنه يباح لدخوله في عموم اللفظ قال في الشرح وهي أصح

والثانية لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح كما لو كان المذبوح مغصوبا والثاني لا لأنه منهي عنه أشبه ما لو استجمر بالروث وعنه إن كان المذكى مغصوبا فهو ميتة واختارها أبو بكر ومثلها سكين ذهب ونحوها ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة وفي الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم

فصل

الثالث أن يقطع من الحيوان المقدور عليه الحلقوم والمري وهي الوهدة التي تربط بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك إجماعا قال عمر

يشترط مع ذلك قطع الودجين النحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به أحمد وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج بيتنا ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطني بإسناد جيد وأما حديث أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك رواه أحمد وقال أبو العشراء ليس بمعروف وحديثه غلط وأبو داود والترمذي وقال غريب وقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر وقال المجد في أحكامه هذا فيما لم يقدر عليه فعلى هذا يشترط قطع الحلقوم والمري وهما مجرى الطعام والنفس اختاره الخرقي وقدمه في الرعاية والكافي وذكر أنه أولى ورجحه في الشرح لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه أشبه ما لو قطع الأربعة واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين اختاره أبو محمد الجوزي وجزم به في الروضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج رواه أبو داود وقال سعيد ثنا إسماعيل بن زكريا عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس قال إذا اهريق الدم وقطع الودج فكل إسناده حسن وهما عرقان محيطان بالحلقوم وعنه أو أحدهما وفي الايضاح الحلقوم والودجين وفي الإرشاد المرى والودجين وفي الكافي والرعاية يكفي قطع

الأوداج وحدها لكن لو قطع أحدهما مع الحلقوم أو المري أولى بالحل قاله الشيخ تقي الدين وذكر وجها يكفي ما سواه فان عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر [ج ٩ - ص ٢١٨]

وإن نحره أجزأه وهو أن يطعنه بمحدد في لبته والمستحب أن ينحر البعير ويذبح قطع ثلاث من الأربعة وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل فرع إذا أبان رأسه بالذبح لم يحرم به المذبوح قدمه في المحرر وأكله مباح قاله في المستوعب وفي الرعاية يكره ويحل وعنه لا يحل والأول المذهب قال أحمد لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكل روي عن علي وعمران لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح وإن نحره أجزأه أي إذا نحر ما يذبح أجزأه في قول الأكثر كعكسه لقوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وقالت أسماء نحرنا فرسا وفي رواية ذبحنا وقالت عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة ولأنه ذكاه في محله فجاز أكله كالحيوان الآخر ونقل ابن أبي موسى أنه توقف في ذبح البقر قال والأول عنه أظهر وعنه يكره ذبح إبل وعنه ولا تؤكل وهو أن يطعنه بمحدد في لبته فبيان لمعنى النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا يفعلون ونقل الميموني أن ابن عباس وابن عمر قالا النحر في اللبة والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه بغير خلاف قاله في الشرح لقوله تعالى ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ الكوثر 2 ولقوله تعالى ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ البقرة 67 وأمر النبي

صلى الله عليه وسلم بالنحر لأن أغلب ماشية قومه الإبل وأمر بنو إسرائيل بالذبح لأن غالب ماشيتهم البقر ولأنه عليه السلام نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده [ج ٩ - ص ٢١٩]

فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله إلا متفق عليه وفي الترغيب رواية ينحر البقر وعند ابن عقيل إن ما صعب وضعه بالأرض نحر فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أي إذا ذهب على وجهه شاردا أو يتردى أي يسقط في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة وقاله أكثر العلماء لما روي رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة فكذلك الأهلي إذا توحش وذكر أبو الفرج يقتل مثله غالبا وقال مالك لا يجوز أكله إلا أن يذكى قال أحمد لعله لم يبلغه حديث رافع إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح نص عليه وهو قول الأصحاب لأنه لا يعلم أن الذبح قتله ولأن الماء أعان على قتله فحرم كما لو جرح الصيد مسلم ومجوسي وقيل يحل إن جرحه بجرح موح وإن ذبحها من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين ولو عبر بالآلة لعم على موضع ذبحها وهي في الحياة أي فيه حياة مستقرة ويعلم ذلك بوجود الحركة وعنه أو لا وفي المغني غلب بقاؤها أكلت قدمه في المستوعب والفروع وجزم به في المحرر

والوجيز لأنها حلت بالذبح وفي الترغيب رواية يحرم مع حياة مستقرة وهو ظاهر ما رواه جماعة [ج ٩ - ص ٢٢٠]

وإن فعله عمدا فعلى وجهين وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية وإن فعله عمدا فعلى وجهين وفي المحرر والفروع هما روايتان إحداهما لا تباح روي عن علي وهو ظاهر الخرقي لأنه في غير محل الذبح كما لو بقر بطنها والثانية تحل إذا بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرىء وقاله القاضي وهي أصح لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة حل كالمتردية وعنه ما يدل على إباحته مطلقا وفي الشرح إن ذبحها من قفاها ولم يعلم هل كانت فيه حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرىء أو لا نظرت فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى إباحته وإن كانت كآلة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح

فرع ملتو عنقه كمعجوز عنه قاله القاضي وقبل حكمه كذلك وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت لقوله تعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ المائدة 3 ولحديث جارية كعب ولما روي سعيد ثنا سفيان حدثني الزبير بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال أتيت ابن عباس فسمعته يقول في شاة وقع قصبتها أي الأمعاء بالأرض فأدركها فذبحها بحجر يلقي ما أصاب الأرض ويأكل سائرها وسواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش قاله في الشرح وقدم السامري أنها إذا بلغت مبلغا لا تعيش لمثله لم تحل قال ابن هبيرة هو أظهر الروايتين وذكره ابن أبي موسى إن رجى حياتها حلت وفي المحرر والوجيز أنها تحل بشرط أن

تتحرك عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف ذنب وحكاه في الفروع قولا

[ج ٩ - ص ٢٢١]

صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل

فصل الرابع

أن يذكر اسم الله عند الذبح وقيل أو لا ونقل الأثرم وغيره ما تيقن أنه يموت بالسبب وعنه لدون أكثر يوم لم يحل والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون بالموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح وعنه يحل مذكى قبل موته مطلقا وفي كتاب الآدمي البغدادي وتشترط حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي وعنه إن تحرك ذكره في المبهج ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب وفي الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص ومرادهم بالحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل لأنه صار في حكم الميتة كما لو ذبحها بعد ذبح الوثني وكذا في الكافي وغيره فرع ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة أو نخ أو أنقذه من مهلكة فهو كمنخنقة

فصل الرابع

أن يذكر اسم الله عند الذبح وذكر جماعة أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا كالطهارة فعلى هذا إن سمى على شاة ثم أخذ السكين أو كانت بيد مفتركها واخذ أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت لأنه سمى عليها لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ الأنعام 121 والفسق

حرام لقوله تعالى ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ﴾ الاية الأنعام 145 ولأنه أمر به وأطلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى السماء فان ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت

وعنه [ج ٩ - ص ٢٢٢]

وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إلا الاخرس فانه يوميء إلى فحمل المطلق على المقيد وهو أن يقول بسم الله لأن إطلاق التسمية تنصرف إليها ولو بغير العربية لأن المقصود ذكر اسم الله وقد حصل بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه وفي المحرر أنه إن سمى بغير العربية من لا يحسنها فعلى وجهين صحح في الرعاية عدم الإجزاء لا يقوم غيرها مقامها كالتسبيح والتهليل والتكبير وسؤال المغفرة وقدمه في المستوعب والرعاية وهو احتمال في الشرح وقيل يكفي تكبير ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت واختار في النوادر لغير شافعي قال في الفروع ويتوجه يضمنه النقص إن حلت إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء لأن إشارته تقوم مقام النطق وكذا إذا علم أنه أشار إشارة تدل على التسمية فرع يسن التكبير معها نص عليه وقيل لا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص وفي المنتخب لا يجوز ذكره معها شيئا واختار ابن شاقلا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندها فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت ذكر في الكافي أنها المذهب وجزم بها في الوجيز وذكر السامري أنها أكثر الروايات عنه لحديث الأحوص بن حكيم بن حزام عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد رواه سعيد لكن الأحوص ضعيف وعن ابن عباس فيمن نسي التسمية قال المسلم فيه اسم الله تعالى وإن لم يذكر التسمية رواه سعيد بإسناد جيد وعن

القاسم بن محمد قال عمر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه رواه سعيد والآية محمولة على تركها عمدا لقوله تعالى وإنه [ج ٩ - ص ٢٢٣]

تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج لفسق والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وقال أحمد في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة نقلها الميموني وعنه تباح في الحالين لما روي أنه رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال اسم الله على كل مسلم رواه ابن عدي والدارقطني ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم إتيانهم بها بل الظاهر أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك وعنه لا تباح فيهما قدمها في المحرر والفروع لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ولأن الشيء متى كان شرطا لا يعذر في تركه سهوا كالوضوء مع الصلاة وعنه يختص المسلم باشتراطها ونقل حنبل عكسها لأن المسلم فيه اسم الله وسيأتي الكلام على الصيد فرع إذا شك في تسمية الذابح حل فلو وجد شاة مذبوحة في موضع يباح ذبح أكثر أهله حلت وإلا فلا

وتحصل ذكاة الجنين المأكول بذكاة أمه أذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح روي عن علي وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ولأحمد والترمذي وحسنه [ج ٩ - ص ٢٢٤]

لم يبح إلا بذبحه وسواء أشعر أو لم يشعر وابن ماجة مثله من حديث أبي سعيد من رواية مجالد وهو ضعيف قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاتها بذكاتها كأعضائها ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة ولا يمكن ذبح الحيوان قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه وعنه لا بأس وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه نقله الجماعة لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته وقدم في المحرر وجزم به في الوجيز أنه كالمنخنقة ونقل الميموني إن خرج حيا فلابد من ذبحه وعنه يحل بموته قريبا وسواء أشعر أو لم يشعر لإطلاق الخبر وقال ابن عمر ذكاته ذكاة أمه إذا اشعر وقاله جماعة لما روى سعيد ثنا سفيان ثنا الزهري عن أبي بن كعب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين وجوابه ما سبق وحكم بإباحته تيسيرا على عباده ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحة يذكى والأم ميتة ذكره الأصحاب

فائدة قوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه من رفع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ذكاة أمه فلا يحتاج الجنين إلى تذكيته هذا مذهبنا

والجمهور ومن نصب قدره كذكاة الجنين فلما حذف الجار نصب فعليه

[ج ٩ - ص ٢٢٥]

فصل

ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة والذبح بآلة كالة وان يحد السكين يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنف لكن قدره ابن مالك في رواية النصب تقديره ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة

فصل

ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة قاله ابن عمر وابن سيرين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال وجهت وجهي الآيتين الأنعام 79 80 ولأنه قد يكون قربة كالأضحية فكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة كالأذان فيسن توجيهها إلى القبلة على شقها الأيسر ورفقه بها وحمله على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط والذبح بآلة كآلة لقوله عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحذكم شفرته وليرح ذبيحته

قال الشيخ تقي الدين في هذا الحديث إن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها ولأن الذبح بآلة كالة فيه تعذيب للحيوان وأن يحد السكين والحيوان يبصره لأن عمر رأى رجلا وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة ويكره ذبح شاة والآخر ينظر إليه كذلك وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه لقوله عليه السلام لا تعجلوا الأنفس أن تزهق رواه

الدارقطني بإسناد ضعيف وعن عمر معناه ولأن في ذلك تعذيبا للحيوان وحرمهما القاضي وغيره نقل حنبل لا يفعل وفي الترغيب يكره قطع رأسه

[ج ٩ - ص ٢٢٦]

فإن فعل أساء وأكلت وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتل قبل سلخه ونقل حنبل لا يفعل وكذا يكره قطع عضو منه قبل الزهوق وقاله الأكثر فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد حلها وذبحها سئل أحمد عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها فقال يأكلها قيل له والذي بان منها قال نعم قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به فلو قطع منه شيئا وفيه حياة مستقرة فهو ميتة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم ولأن إباحته إنما تحصل بالذبح وليس هذا بذبح نقل ابن منصور أكره نفخ اللحم قال في المغني الذي للبيع لأنه غش وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتل مثله فهل يحل على روايتين

أنصهما لا يحل وذكره الخرقي وجزم به في الوجيز لأن ذلك يعين على زهوق النفس فيحصل من سبب مبيح ومحرم

والثانية بلى قدمها في الرعاية وذكر في الكافي والشرح أنها قول أكثر أصحابنا وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه وطرئان الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم بحله وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر من الإبل ونحوها لم يحرم علينا في ظاهر كلام أحمد قال ابن حمدان وهو أظهر لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم وقدم في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز أنه يحرم وقيل لا

كظنه تحريمه عليه فلم يكن ذكر أبو الحسين أن الخلاف في ذي الظفر كالخلاف في تحريم الشحوم المحرمة عليهم وعلم منه أنها تحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا [ج ٩ - ص ٢٢٧]

وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب مسألة ذو الظفر ما ليس بمنفرج الأصابع كإبل ونعام وبط ووز قاله ابن عباس وجمع وقيل هي الإبل خاصة وعند ابن قتيبة هي كل ذي حافر من الدواب ومخلب من الطير وإن ذبح أي الكتابي حيوانا غيره أي ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب وهو بوزن فلس يغشي الكرش والأمعاء رقيق والكليتين واحدها كلية وكلوة بضم الكاف فيها والجمع كليات وكلى في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد وابو الخطاب وجزم به في الوجيز وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد لما روى عبد الله بن مغفل قال أصبت من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما رواه مسلم ولأنها ذكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم كذكاة المسلم وكذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه وعلم منه أنه يحرم على اليهود شحم الثرب والكلية من بقر وغنم نص عليه لقوله تعالى ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ الأنعام 146 أي حرمنا على اليهود كل ذي ظفر وجميع شحوم البقر والغنم وهي الثرب والكلى إلا ما حملت ظهروهما ما علق بالظهر والجنب من داخل أو الحوايا وهي المصارين أو ما اختلط بعظم هو شحم الإلية لما فيها من العظم واختار أبو الحسن التميمي والقاشي وأبو بكر وأبو حفص البرمكي واختاره الأكثر قاله في الواضح وصححه في عيون المسائل تحريمه لقوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ المائدة 5

وهذا ليس من طعامهم ولأنه جزء من البهيمة لم تبح لذابحها فلم تبح لغيره كالدم فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم [ج ٩ - ص ٢٢٨]

وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم نص عليه ومن ذبح حيوانا وعلله القاضي بأن الذكاة تفتقر إلى القصد والكتابي لم يقصد ذكاة هذا الشحم وجوابه أن الآية حجة لنا فإن معنى طعامهم ذبائحهم فعلى هذا يجوز تملكها منهم فرع يحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه وقال ابن عقيل نسخ في حقهم أيضا

وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم نص عليه لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته وعنه لا تحل اختاره الشيخ تقي الدين لأنه أهل به لغير الله تعالى والأول هو المعول عليه لما روي عن العرباض بن سارية قال كلوا وأطعموني رواه سعيد من رواية إسماعيل بن عياش عن بشر بن كريت الأملولي وعن أبي أمامة وأبي الدرداء كذلك رواهما سعيد من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الشامي وهو ضعيف وفي الرعاية إنه مكروه نص عليه ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله وذكر الآية وعلم منه أن ما ذبحه مسلم لكتابي أو مجوسي من ذلك فإنه يحل نص عليه

ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في بطن أخرى أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم صححه المؤلف والمجد ونصره في الشرح لقوله عليه السلام أحل لنا ميتتان [ج ٩ - ص ٢٢٩]

وعنه يحرم ودمان الخبر ولأنه حيوان طاهر في محل طاهر لا تعتبر له ذكاة فأبيح كالطافي وعنه يحرم لأنه رجيع فيكون مستخبثا وفي عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام لا العكس كحل ميتة صيد البحر

تنبيه يحرم بول طاهر كروثه وأباحه القاضي وذكر رواية في بول الإبل وفاقا لمحمد بن الحسن ونقل الجماعة فيه لا وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه لأنه معتاد يحلله كاللبن وبأنه تبع للحم واحتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن ودلت على الوصف قصة العرنيين

كتاب الصيد

كتاب الصيد

وهو في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد ثم أطلق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر

وأجمعوا على إباحته وسنده قوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ المائدة 96 وقوله تعالى ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ الاية المائدة 4 والسنة شهيرة بذلك منها حديث عدي وأبي ثعلبة متفق عليهما

وهو ما كان وحشيا حلالا غير مقدور عليه وهو مباح لنا صيده قدمه في الرعاية والفروع واستحبه ابن أبي موسى ويكره لهوا وهو أطيب مأكول وقال الأزجي الزراعة أفضل مكسب وقيل عمل اليد وقيل التجارة وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصوف وأفضل الصنائع خياطة مع أنه نص على أن كل ما نصح فيه فهو حسن وأدناها حياكة وحجامة ونحوهما وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها

ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم حيل إلا بالذكاة يعني إذا أدركه متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ذكره معظم الأصحاب وقدمه في المحرر والفروع لأنه مقدور عليه

فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه ليقتله في إحدى أشبه سائر ما قدر على ذكاته ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي بدليل قصة عمر رضي الله عنه وعنه يحل بموته قريبا وعنه دون معظم يوم وفي التبصرة دون نصفه فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه ليقتله في إحدى الروايتين واختاره الخرقي قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وصححه جماعة منهم السامري لأنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتا وعبارة الخرقي أشلى الصائد وفي المغني معنى أشلى في العربية دعاه إلا أن العامة تستعمله بمعنى أغراه ويحتمل أن الخرقي أراد دعاه ثم أرسله وهو ظاهر ومقتضاه أنه إذا لم يخش موته أو وجد معه ما يذكيه بها لم يحل إلا بها لأنه مقدور على ذكاته وكما لو لم يمكنه الذهاب به إلى منزله فيذكيه فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر لأن الإرسال ذكاة ولو قدر على ذكاته فلم يذكه حتى مات لم يحل فكذا هنا وقال القاضي وعامة أصحابنا يحل بالإرسال قاله في التبصرة لأن إدارك الصيد بلا آلة تذكية كلا إدراك ولو لم يدركه حيا لحل فكذا إذا أدركه بلا آلة والرواية الأخرى لا يحل إلا أن يذكيه وهي قول أكثرهم لأنه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وصححه في المغني لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كانت معه فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته ومسألة الخرقي على ما يخاف موته إن لم يقتله الحيوان أو يذكى فإن

كان فيه حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي إلى منزله فليس فيه اختلاف لأنه لا يباح إلا بالذكاة قاتله إلا أن يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده [ج ٩ - ص ٢٣٢]

وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على فرع إذا امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا حل ذكره القاضي واختار ابن عقيل خلافه لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء وإن رمى صيدا فأثبته أي منعه من الامتناع وحبسه عنه ملكه ثم رماه آخر فقتله لم يحل لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح إلا بذبحه ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله لأنه أتلفه عليه إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل لأنه ذكاة فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل منهما وبرىء من الضمان لأن الأصل براءة ذمته وإن اتفقا على السابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته قبل قوله لأن الأصل بقاء امتناعه ويحرم على الأول لاعترافه بتحريمه ويحل للثاني فإن رمياه ووجداه ميتا ولم يعلم من أثبته منهما فهو بينهما وإن وجداه ميتا حل لأن الأصل بقاء امتناعه وعلى الثاني ما خرق من جلده لأنه لم يتلف سوى ذلك قال في الرعاية إذا رمى صيدا فأثبته ملكه ثم إن رماه آخر فقتله فإن كان الأول اصاب مقتله والثاني مذبحه قصدا حل وعليه للأول غرم ما خرق من جلده وقيل بل ما بين كونه حيا مجروحا وكونه مذكى وفي غير ذلك يحرم وعلى الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه بل ميتا أو كمذبوح وإن أدركه حيا حياة مستقرة فلم يذبحه فمات ضمنه الثاني كذلك قال في المحرر وقال القاضي يضمن

نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش نقصه وعندي إنما يضمن نصف قيمته مجروحا [ج ٩ - ص ٢٣٣]

وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت ومتى أدركه ميتا حل بشروط بالجرح الأول لا غير

وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت أي لا يحتاج إلى ذكاة لأن عقره كذكاته ومتى أدركه ميتا حل لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح له آلة السكين وعقره بمنزلة قطع الأوداج بشروط أربعة

أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة لقوله عليه السلام فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي فتشترط فيه الأهلية وفي المجوسي رواية في ما صاده من سمك وجراد أنه لا يحل لما روى سعيد ثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن الحسن قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من صيد المجوس إسماعيل عن الشاميين حجة

وفي الأعمى قويل لابن حمدان إنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا وظاهر ما ذكروه أن ما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت إذا صاده من لا تباح ذكاته أنه يباح واختاره الخرقي وصححه في الكافي أنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجده ميتا فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو جارحا غير معلم أو غير مسمى عليه أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو مع سهمه سهما كذلك لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك

المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على [ج ٩ - ص ٢٣٤]

غيره متفق عليه ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ولأن الأصل الحظر فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله وكذا لو أرسل كلبه المعلم فاسترسل معه آخر بنفسه فرع إذا أرسل جماعة كلابا بشرطه وسموا فوجدوا الصيد قتلا لا يدرون من قتله حل وإن اختلفوا أو كانت الكلاب متعلقة به فهو بينهم وإلا كان لمن كلبه متعلق به وعلى من حكمنا له به اليمين وإن كان قتيلا والكلاب ناحية وقف الأمر حتى يصطلحوا وقيل يقرع بينهم وعلى الأول إن خيف فساده باعوه ثم اصطلحوا على ثمنه

وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له قدمه في المحرر والرعاية والفروع لأنه هو القاتل فوجب أن يترتب عليه الحكم وفي الشرح فإن أصاب أحدهما مقتله دون الآخر مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول وإن كان الجرح الثاني موحيا فهو مباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به ويحتمل ألا يحل هذا رواية وجزم بها في الروضة كما لو أسلم بعد إرساله له لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له فرع إذا رمى سهما ثم ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله حل لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم

وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل وعنه لا يحل وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم فقتله أو أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولو كان في ملكه ذكر في الكافي أنه المذهب وفاقا وهو غير مكروه ذكره أبو الخطاب وأبو الوفا وابن الزاغوني لأنه آلة أشبه ما لو صاده بقوته وسهمه وعنه لا يحل وإن كان لمسلم لقوله تعالى ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ المائدة 4 وكلب المجوسي غير معلم من مسلم وجوابه أن الآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا فهو في معناه وكرهه جماعة منهم جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل في قول الجميع كما لو صاد بقوسه ولأنه ليس من أهل الذكاة وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي فزاد عدوه أو ذبح ما أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه غير موح حل لأن الصائد هو المسلم وهو من أهل الذكاة وإن أرسله المجوسي فزجره المسلم وقيل ولم يزد عدو كلبه بزجر المسلم لم يحل لأن الصائد ليس من أهل الذكاة إذ العبرة بالإرسال

فصل

الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لألة الذكاة لأنها مما لابد منها فيجب أن يشترط للمحدد ما يشترط لآلة الذكاة ولابد من جرحه به نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي ما رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله متفق عليه فإن قتله بثقلة لم يبح لأنه

وقيذ عند نصبها فقتلت صيدا أبيح وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على ظنه ان السم أعان على قتله [ج ٩ - ص ٢٣٦]

وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى فيدخل في عموم الآية وسواء أكان بشبكة أو فخ أو بندقة ولو شدخته نقله الميموني وإن صاد بالمعراض قال في المشارق هو خشبة محددة الطرف وقيل فيه حديدة أكل ما قتل بحده قال أحمد المعراض بشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق فهو مباح دون عرضه للخبر وفي الترغيب والمستوعب ولم يجرحه وهو ظاهر نصوصه لأنه وقيذ وهو قول الأكثر وحكم الصوان الذي له حد كالمعراض وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح إذا جرحه روي عن ابن عمر وقاله الحسن وقتادة لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان فكذا في الإباحة وقال الشافعي لا يباح بحال كما لو نصب سكينا فذبحت شاة ولأنه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا فقتل صيدا لم يحل وهذا أولى وجوابه قوله عليه السلام كل ما ردت عليك يدك ولأنه قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها وإذا رمى سهما وهو لا يرى صيدا فليس ذلك بمعتاد والظاهر أنه لا يصيب صيدا فلم يصح قصده بخلاف هذا وقيل يحل مطلقا فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصائد وحيث حل فظاهره يحل ولو ارتد أو مات وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم أعان على قتله كذا عبر به في الهداية والمذهب والمحرر والوجيز لأنه اجتمع مبيح ومحرم فغلب المحرم وكسهمي

مسلم ومجوسي ولأنه يخاف من ضرر السم فعلى هذا إن لم يغلب على ظنه أن السم أعان على قتله فهو مباح وفي الكافي يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل على روايتين وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل

[ج ٩ - ص ٢٣٧]

ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يحل إلا أن وغيره إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد أو بسهم مسموم وغيره إلى آخره لم يبح لقوله عليه السلام وإن وجدت معه غيره فلا تأكل وبأن الأصل الحظر فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله ونقل ابن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل قال في الفروع وليس هذا في كلام أحمد بمراد وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يحل لأنه يغلب على الظن موته بالمشارك إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل على روايتين كذا في المحرر

أشهرهما واختارها الخرقي أنه يحرم لأنه اجتمع مبيح ومحرم أشبه المتولد بين مأكول وغيره

والثانية يحل وجزم به أكثر الاصحاب لأنه قد صار في حكم الميت بالذبح وجوابه قوله عليه السلام فإن وجدته غريقا في الماء فلا متفق عليه وهذا ظاهر قول ابن مسعود رواه سعيد وإسناده ثقات ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراح غير موحية ويستثنى من ذلك ما لو وقع في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف

في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف هنا وإن رماه في الهواء أو على شجرة أو جبل ولو عبر بالعلو لعم فوقع على الأرض فمات حل لأن الظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع وعنه يحل بجرح موح جزم به في الروضة لقوله تعالى موحية حل وإلا فلا وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا

[ج ٩ - ص ٢٣٨]

وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح ﴿ والمترديةِ ﴾ المائدة 3 وجوابه أن سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه فوجب أن يحل كما لو أصابه فوقع على جنبه والماء يمكن الاحتراز عنه بخلاف الأرض وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل في الأشهر عن أحمد وهو الأصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفتني في سهمي قال ما رد عليك سهمك فكل قال فإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك رواه أبو داود ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا والمعارض له مشكوك فيه وكما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ولا فرق فيه بين أن تكون الجراحة موحية أو لا وجده ميتا في يومه أو في غيره لكن لو غاب قبل تحقق الاصابة ثم وجده عقيرا وحده والسهم والكلب ناحية لم يبح وعنه إن كانت الجراح موحية حل لأنه إذا كان كذلك ظهر إسناد الزهوق إليه وإلا فلا أي إذا لم يكن موحيا لم يظهر إسناد الزهوق إليه وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا لما روى ابن عباس قال إذا رميت فأقعصت فكل وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل وإن غاب عنك فلا تأكل لأنك لا تدري ما حدث بعدك لا يقال الأول مطلق وهذا مقيد فيحمل عليه لأنه متبين له وقد جاء مصرحا به في حديث عدي مرفوعا قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يومين ليس فيه

إلا أثر سهمك فكل وعنه إن غاب مدة قريبة حل وإلا فلا ونقل ابن منصور إن غاب نهارا حل لا ليلا قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من قابان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه وإن بقى معلقا بجلدة حل وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع وعنه لا يباح ما أبان منه وإن أخذ قطعة من [ج ٩ - ص ٢٣٩]

وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح وإن ضربه حال الليل تخطف الهوام وعنه يكره أكل ما غاب وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح نص عليه للأخبار وكما لو وجد مع كلبه كلبا سواه ولم يعتبروا هنا بالظن كالسهم المسموم قال في الفروع وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال فأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله فهو مباح لأن هذا يعلم أنه لم يقتله فرع إذا غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب والمغني إنه حلال وعنه يحرم كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحيته وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله وجزم به في الروضة وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه هذا المذهب لقوله عليه السلام ما أبين من حي فهو ميت وعنه إن ذكي حل البائن وإن كثر كبقيته وإن قطعه قطعتين أو قطع رأسه حل الجميع فإن لم تبق فيه حياة معتبرة فروايتان

أشهرهما إباحتهما روي عن علي

والثانية لا يباح ما أبان منه لعموم الخبر والأول المذهب لأن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لجميعه كما لو قده نصفين والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا

وإن بقي معلقا بجلدة حل رواية واحدة لأنه لم يبن وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع على المشهور كما لو قطعه قطعتين وعنه لا يباح ما أبان

منه للخبر ولأن ما أبين منه لا يمنع بقاء الحياة في العادة فلم يبح كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة وجوابه سبق بدليل المذبوح فإنه ربما بقي ساعة وربما مشى حتى يموت ومع هذا هو حلال وإن أخذ قطعة من والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل لأنه وقيذ [ج ٩ - ص ٢٤٠]

حوت ونحوه وافلت حيا أبيح ما أخذ منه وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر حوت ونحوه وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه لأن أقصى ما فيه أنه ميتة ومميتته حلال للخبر

تذنيب قال أحمد لا بأس بصيد الليل قال يزيد بن هارون ما علمت أحدا كرهه ولم يكره أحمد صيد الفراخ الصغار من أوكارها وفي المستوعب لا بأس بصيد الصيد الوحشي بالليل من غير أوكارها ويكره في غيرها وقال الحسن لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه أبو عبد الله ومعناها أن يقع الصيد بين القوم فيقطع كل منهم قطعة بسيفه حتى يؤتى على آخره وهو حي قال وليس هو عندي إلا أن بصيد الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته ويأخذونه قطعا ذكره في المغني والشرح وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الذي لا حد له والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به بغير خلاف نعلمه إلا عن الحسن وروى شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال عمار إذا رميت بالحجر أو المعراض أو البندقة فذكرت اسم الله فكل وإن قل وجوابه قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم ﴾ الآية المائدة 3 لأنه وقيذ لأنه قتله بغير محدد فوجب ألا يباح كما لو ضرب شاة بعصا فماتت قال ابن قتيبة الموقوذة التي تضرب حتى توقذ أي تشرف على الموت قال قتادة كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها دليل الأكثر ما روى سعيد

ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عدي مرفوعا إذا رميت البهيم فلا يباح صيده [ج ٩ - ص ٢٤١]

النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ورواه أحمد أيضا وإبراهيم لم يلق عديا قال في المغني ولو شدخه أو خرقه نص عليه

فائدة يكره الصيد بمثقل لا يجرح وعن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين أخرجاه في الصحيحين

النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة لقوله تعالى ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ المائدة 4 قال ابن حزم اتفقوا فيما إذا قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم يدرك فيه حياة أصلا أنه لا يحل ولو ذكي وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا وعنه وصدما وخنقا اختاره ابن حامد وأبو محمد الجوزي فيباح إلا الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه نص عليه وذكر السامري والمؤلف هو الذي لا يخالط لونه لون سواه وقال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل لهما من كل لون قالا نعم قال أحمد ما أعلم أحدا يرخص فيه يعني من السلف فلا يباح صيده نص عليه لأنه عليه السلام أمر بقتله وقال إنه شيطان رواه مسلم وهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب

السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة أرسل وينزجر إذا زجر وإذا امسك لم يأكل ولا يعتبر تكرر ذلك منه فإن أكل بعد تعلمه [ج ٩ - ص ٢٤٢]

والجوارح نوعان ما يصيد بنانه كالكلب والفهد بثلاثة أشياء بأن يسترسل إذا وأباحه الأكثر لعموم الآية والخبر وكغيره من الكلاب والأول المذهب وعنه بلى ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض جزم به في المغني والشرح ويحرم اقتناؤه كخنزير قال جماعة يقتل فدل على وجوبه ونقل موسى بن سعيد لا بأس به والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وفي المذهب والترغيب والنمر فتعليمه بثلاثة أشياء بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر لا في وقت رؤيته للصيد قاله في المغني وغيره وإذا أمسك لم يأكل لقوله عليه السلام فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه ولأن العادة في المعلم ترك الأكل فكان شرطا كالانزجار إذا زجر وهذا لم يذكره الآدمي البغدادي قال في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجر والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما ولا يعتبر تكرر ذلك منه اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع وقال القاضي يعتبر تكرر ذلك منه حتى يصير في العرف معلما وأقل ذلك ثلاث نصره في المغني لأن ترك الأكل يحتمل أن يكون لشبع أو عارض فيعتبر تكراره وحينئذ يعتبر ثلاثا كالاستجمار والأقراء والشهور في العدة والصنائع لا يمكن من فعلها إلا من تعلمها وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم وغيره فعلى هذا يحل في الرابعة

وقيل مرتين فيحل في الثالثة فإن أكل بعد تعلمه والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح وقال ابن حامد يباح [ج ٩ - ص ٢٤٣]

لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل لم يحرم ما تقدم من صيده رواية واحدة قاله في المستوعب واقتصر عليه في الكافي والشرح وصححه في المحرر وهو قول أكثرهم لعموم الآية والأخبار ولأنه قد وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال وقيل يحرم لأنه لو كان معلما ما أكل ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين وهي الصحيحة لقوله عليه السلام فإن أكل فلا تأكل ورواه سعيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ورواه ايضا عن أبي هريرة وقيل حين الصيد جزم به ابن عقيل وقيل قبل مضيه ولا يخرج بأكله عن كونه معلما فيباح صيده بعد ذلك وفيه احتمال والاخرى يحل روي عن سعد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم أحمد ولقوله تعالى ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ المائدة 4 ولا حجة فيها مع أن حديثنا هو المعمول به وأصح فلو شرب من دمه ولم يأكل منه لم يحرم نص عليه وفي الانتصار من دمه الذي جرى وكرهه الشعبي والثوري

والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل رواه الخلال ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب ولابد أن يجرح الصند فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح قدمه في

الكافي والمستوعب والرعاية وجزم به في الوجيز وقاله الأكثر لأنه قتل بغير جرح أشبه ما لو قتله بالحجر والبندق وقال ابن حامد يباح لعموم للصيد فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجر إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل [ج ٩ - ص ٢٤٤]

وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله على وجهين

فصل

الثالث إرسال الآلة قاصدا الآية والخبر والأول أولى لأن العموم فيهما مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله على وجهين كذا في المحرر وهما روايتان في الفروع

أحدهما يجب قدمه في الكافي والرعاية وصححه في المستوعب كغيره من المحال

والثاني لا وجزم به في الوجيز لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله

فصل

الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد فعلى هذا لو سقط سيف من يده عليه فعقره أو احتكت شاة بشفرة في يده لم تحل فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده في قول أكثرهم وقال عطاء والأوزاعي يؤكل إذا جرحه الصائد وقال إسحاق إذا سمى عند انفلاته أبيح وروى باسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتصيد الصيد قال إذا سمى فكل قال الخلال هذا على معنى قول أبي عبد الله وجوابه قوله عليه السلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه وإن

زجره أي لم يحل لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل لأن زجره له أثر في عدوه فصار كما لو أرسله لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار بفعل الآدمي بدليل ما لو عدا على إنسان فأغراه آدمي فاصابه ضمن فلو أرسله بغير تسمية ثم لم يحل صيده إذا قتله وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل ويحتمل أن يحل [ج ٩ - ص ٢٤٥]

وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا سمى وزجره فزاد عدوه فظاهر كلام أحمد إباحته لأنه انزجر بتسميته وزجره أشبه التي قبلها وقال القاضي لا لأن الحكم تعلق بالإرسال الأول بخلاف ما إذا استرسل بنفسه ونقل حرب إن صاد من غير أن يرسله لا يعجبني واحتج بأنه لم يذكر اسم الله عليه وفي الروضة إن استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل وأكل منه بخلاف الكلب وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف وهو كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد وقيل لا يحرم في السهم وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل قدمه السامري وجزم به في الوجيز لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة وكما لو أرسله على غير شيء أو ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا ويحتمل أن يحل اختاره في المغني لأن صحة القصد تنبني على الظن وقد وجد وصح قصده وكما لو رمى صيدا فأصاب غيره أو هو وغيره نص عليه فإن شك هل هو صيد أم لا لم يبح لأن صحة القصد تنبني على العلم ولم يوجد

تتمة إذا قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله لم يحل لأنه لم يقصد صيدا لكون القصد لا يتحقق إلا بعلمه وإن ظنه صيدا فإذا هو صيد حل وإن ظنه كلبا أو خنزيرا لم يبح قال في الرعاية وإن رمى ما ظنه حجرا أو آدميا فبان صيدا أو رمى حجرا ظنه صيدا فأصاب صيدا أو سمع

حسا ليلا أو رأى سوادا فأرسل عليه جارحة أو سهمه فأصاب صيدا فوجهان صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل وإن رمى صيدا فأثبته ملكه فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه ولو وقع في شبكته [ج ٩ - ص ٢٤٦]

وإن رمى صيدا فأصاب غيره حل وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل وإن أرسل سهمه على وقيل إن ظنه آدميا معصوما أو بهيمة أو حجرا فقتله فإذا هو صيد لم يبح وإن رمى صيدا فأصاب غيره حل والجارح كالسهم في هذا نص عليه لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده كما لو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار أو كما لو أخذ صيدا في طريقه وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل لأن شرط الحل قصد الصيد في الجملة لا قصد الصيد بعينه وهو موجود فيهما وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل لأنه قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها وإن رمى صيدا فاثبته ملكه لأنه أزال امتناعه أشبه ما لو قتله فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده لأنه ملكه فلزمه كما يلزمه رد ملك غيره كالشاة ونحوها وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان أو غيرها فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فملكه الثاني بأخذه وقال ابن حمدان إن خرج منها وإلا فلا وقيل هو لصاحب الخيمة ولو نصب خيمة للأخذ ملكه وإن مات فيها فهو له فرع إذا رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي لأنه ملكه بإزالة امتناعه ذكره في الشرح وفي عيون المسائل إن حمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط فيها فهو لهم وفي الرعاية لغيره أخذه

على الأصح والمنصوص أنه للموحي ولو وقع في شبكته أو فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة [ج ٩ - ص ٢٤٧]

صيد فإن خرقها وذهب بها فصاده آخر فهو الثاني وإن كان في سفينة فوثبت سمكة نخه أو شركه صيد فهو له لأنه أثبته بآلته فإن خرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني لأنه لم يملكه الأول وما معه لقطة فإن كان يمشي بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لكن إن أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت منه لم يزل ملكه عنه كما لو شردت فرسه أو ند بعيره ويستثنى من ذلك ما لو صاده فوجد عليه علامة كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه فلو وجد طائرا مقصوص الجناح فلقطة ويملك الصيد بإلجائه إلى مضيق يعجز عن الانفلات منه وكذا إذا وقع في دبق يمنعه من الطيران وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في المستوعب والشرح لأن السمك من الصيد المباح فملكت بالسبق إليها كما لو فتح حجره للأخذ زاد في الوجيز ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال وقيل هو قبل أن يأخذه على الإباحة فيكون لمن أخذه ومقتضاه أنها إذا وقعت في السفينة فهي لصاحبها لأن السفينة ملكه ويده عليها لكن إن كانت السمكة وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي له دون من وقعت في حجره لأن الصائد أثبتها بذلك فرع إذا دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها ومثله إحياء أرض بها كنز ملكه كنصب خيمة وفي الترغيب إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو برجه فسد المنافذ أو حصلت السمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل يملكه وقيل إن سهل

تناوله منه وإلا كمتحجر للأحياء ويحتمل اعتبار يملكه وكذلك أن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه ويكره صيد السمك بالنجاسة وصيد الطير بالشباش [ج ٩ - ص ٢٤٨]

وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم قصد التملك بغلق وسد فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة فتعشعش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الطيور مملوكة فهي لأربابها نص عليه ولو تحول طير من برج زيد إلى برج عمرو لزم عمرو رده وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه لأنها آلة للصيد قصد بها السمك فملكه وكما لو وقع في شبكة أو فخ أو منجل وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه كما لو توحل الصيد في أرضه وفي الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه لأن الأرض ليست معدة لذلك أشبه البركة التي لم يقصد بها الاصطياد نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم هو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها ولغيره أخذه على الأصح قاله في الرعاية كما يجوز له أخذ الماء والكلأ ولأنه باق على الإباحة الأصلية لكن يأثم بدخولها بدون إذن ربها وقيل مستأجرها أولى من ربها والمنصوص أنه للمؤجر ويكره صيد السمك بالنجاسة قدمه في المستوعب والرعاية وجزم به في الوجيز لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة وعنه يحرم قدمه في الفروع ونقله الأكثر وقال استعن عليهم بالسلطان وفي المبهج فيه وبمحرم روايتان وكره أحمد الصيد ببنات وردان وقال مأواها الحشوش وكذا بالضفادع

وصيد الطير بالشباش وهو طائر تخيط عينيه ويربط لأن فيه تعذيبا للحيوان الرابع التسمية [ج ٩ - ص ٢٤٩]

وإذا أرسل صيدا وقال لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن يزول ويملكه من أخذه

فصل

وكذا يكره من وكره أطلقه في الترغيب وغيره لا بليل وظاهر رواية ابن القاسم لا كالفرخ منه ولا بما يسكر نص على ذلك وفي مختصر ابن رزين يكره بليل

فائدة لا بأس بشبكة ونخ ودبق قال أحمد وكل حيلة وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق وكره الشيخ تقي الدين الرمي به مطلقا لنهي عثمان ونقل ابن منصور لا بأس ببيع البندق يرمى به الصيد لا للعبث وقال ابن هبيرة هو معصية فلو منعه الماء حتى صاده حل أكله وحرمه في الرعاية ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا وإذا أرسل الصيد وقال اعتقتك لم يزل ملكه عنه في ظاهر المذهب وذكره ابن حزم إجماعا كبهيمة الأنعام وكانفلاته أو ند أياما ثم صاده آخر نص عليه ولأن الإرسال والإعتاق لا يوجب زوال ذلك قال ابن عقيل لا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية ويحتمل أن يزول ويملكه من أخذه لأن الأصل الإباحة والإرسال يرده إلى أصله بخلاف بهيمة الأنعام ولأن الإرسال هنا بعيد وهو رد الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين ولهذا روي عن أبي الدرداء أنه اشترى عصفورا من صبي فأطلقه ولأنه

يجب إرساله على المحرم إذا أحرم بخلاف بهيمة الأنعام قال بعض أصحابنا العتق إحداث قوة تصادف الرق وهو ضعف شرعي يقوم بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء عنه والرق غير المالية

فصل

الرابع التسمية في الجملة لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر ﴾ ظاهر المذهب وعنه إن نسيها على السهم ابيح وإن نسيها على الجارحة لم تبح

عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها لم يبح سواء تركها عمدا أو سهوا في ﴿ اسم الله عليه ﴾ الأنعام 121 وللأخبار عند إرسال السهم أو الجارحة لأن ذلك هو الفعل الموجود من المرسل فاعتبرت التسمية عنده كما يعتبر عند الذبح وذكر جماعة أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا فإن تركها لم يبح سواء تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وذكر القاضي في الخلاف أنه المذهب الصحيح وأنه رواه الجماعة للآية والأخبار والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد ولأن في الصيد نصوصا خاصة ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها وعنه إن نسيها على السهم أبيح لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وإن نسيها على الجارحة لم تبح والفرق بينهما أن السهم آلة حقيقة وليس له اختيار بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره وعنه تسقط مع السهو مطلقا ذكره ابن حزم إجماعا قال الخلال سها حنبل في نقله وعنه سنة نقل الميموني الآية في الميتة قد رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه وعنه يختص المسلم باشتراطها ونقل حنبل عكسها لأن المسلم فيه اسم الله وليس بجاهل كناس الصوم ذكره في المنتخب وسبق ما يتعلق بذلك

مسألة إذا مسى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره لم يبح ما صاد به جزم به في الشرح والرعاية لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت

على الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة وقيل يباح كما لو سمى على سكين وأخذ غيرها [ج ٩ - ص ٢٥١]

كتاب الأيمان

كتاب الايمان

وهي جمع يمين واليمين القسم والجمع أيمن وأيمان سمي بذل لأنه كان أحدهم يضرب يمينه على يمين صاحبه فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص فهي جملة خبرية تؤكد بها أخرى وهما كشرط وجزاء والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ المائدة 89 وقوله تعالى ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ النحل 91 والسنة شهيرة بذلك منها لعبد الرحمن ابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك متفق عليه ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه لقوله تعالى ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ﴾ يونس 53 و ﴿ قل بلى وربي لتبعثن ﴾ التغابن 7 ويصح من كل مكلف مختار قاصد لليمين ولا يصح من غير مكلف للخبر ولأنه قول يتعلق به حق فلم يصح من غير مكلف كالإقرار وفي المميز وجه قاله في المذهب وفي السكران وجهان بناء على التكليف وعدمه قاله في المغني والشرح وبناه في الكافي على طلاقه وتصح من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث نص عليه في مواضع وقاله جمع وقال لا تنعقد يمينه لقوله تعالى ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا

أيمان لهم ﴾ التوبة 12 ولأنه ليس بمكلف وجوابه أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمره [ج ٩ - ص ٢٥٢]

واليمين النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره ولأنه من أهل القسم لقوله تعالى ﴿ فيقسمان بالله ﴾ المائدة 106 قال القاضي في الخلاف ولا خلاف أنه يستحلف عند الحاكم وكل من صحت يمينه عند الحاكم صحت يمينه عند الانفراد كالمسلم وعن الآية أنهم لا يفون بها لقوله تعالى ﴿ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ﴾ ولا نسلم أنه غير مكلف واليمين تنقسم خمسة أقسام

واجب كالتي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكه وكذا إنجاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ

ومندوب كحلف يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين وإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية فقيل هو مندوب لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعة وترك المعصية وقيل لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ولو كان طاعة لم يخلوا به ولأن ذلك يجري مجرى النذر

ومباح كالحلف على فعل مباح أو تركه والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق

ومكروه كالحلف على ترك مكروه ولا يلزم حديث الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركها ولو تركها لم ينكر عليه ومنه الحلف على البيع والشراء

وحرام وهو الحلف الكاذب ومنه الحلف على معصية أو ترك واجب تعالى قسمان أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق ورازق العالمين فهذا القسم به يمين بكل حال والثاني ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله أو أطلق فهو يمين وإن نوى غيره فليس بيمين [ج ٩ - ص ٢٥٣]

التي تجب بها الكفار هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته وأسماء الله ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم فحلها حرام وإن كانت على مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه وإن كانت على مباح فحلها مباح

قال في الرعاية وحفظ اليمين أولى وإن كانت على فعل مكروه وترك مندوب فحلها مندوب وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب

التي تجب بها الكفارة بشرط الحنث هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته لأن اليمين إذا أطلقت تنصرف إليه ولأن صفات الله تعالى قديمة فكان الحلف بها موجبا للكفارة كالحلف بالله تعالى وكوجه الله تعالى نص عليه وعظمته وإرادته وقدرته وعلمه وأسماء الله تعالى قسمان

أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورازق العالمين وكذا رب العالمين ومالك يوم الدين ورب السموات والأرض فهذا القسم به يمين بكل حال نوى به اليمين أولا لأن اليمين بذلك صريح في مقصوده فلم يفتقر إلى نية كصريح الطلاق ونحوه

والثاني ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين لأنه بإطلاقه ينصرف إليه وإن نوى غيره

فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره قال الله تعالى ﴿ ارجع إلى ربك ﴾ يوسف 5 يمينا وقال القاضي لا يكون يمينا أيضا [ج ٩ - ص ٢٥٤]

وأما ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود فإن لم ينوبه الله تعالى لم يكن و ﴿ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ يوسف 42 ﴿ فارزقوهم منه ﴾ النساء 8 ﴿ بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ التوبة 128 ومثل رحمان اليمامة ورجل رحيم والمولى المعتق والقادر باكتسابه والعالم في البلد ورازق الجند لأنه لما أراد به غيره لم يبق يمينا لعدم تناوله لما يوجب القسم وفي المغني والكافي إن الرحمن من القسم الأول قال في الشرح وهو أولى لأن ذلك إنما يسمى به غير الله مضافا لقولهم في مسيلمة رحمان اليمامة والذي ذكره المؤلف هنا أورده السامري وابن حمدان مذهبا وذكر القاضي في الخلاف والتعليق أنه إذا قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وأطلق ولم ينو اليمين أنه يخرج على روايتي أقسم وقيل يمين مطلقا وقاله طلحة العاقولي وأما ما لايعد من أسمائه ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم فإن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينا لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصد ولا اللفظ ظاهر في إرادته فوجب ألا يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله تعالى وإن نواه كان يمينا على المذهب لأنه يصح أن يقسم بشيء يصح أن يراد به الله تعالى قاصدا به الحلف فكان يمينا مكفرة كالملك والقادر وقال القاضي لا يكون يمينا أيضا لأن اليمين إنما تنعقد بحرمة الاسم فمع الاشتراك لا تكون له حرمة والنية المجردة لا تنعقد بها اليمين وجوابه أنه أقسم باسم الله تعالى قاصدا الحلف به فكان يمينا وما انعقدت بالنية المجردة

وإنما انعقدت بالاسم المحتمل المراد به اسم الله تعالى فإن النية تصرف اللفظ إلى وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين [ج ٩ - ص ٢٥٥]

وإن قال وحق الله وعهد الله وأيم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته بعض محتملاته فيصير كالمصرح به كالكنايات وإن قال وحق الله وعهد الله وايم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين وفيه مسائل

الأولى إذا قال في حلفه وحق الله فهي يمين مكفرة وقاله الأكثر لأن لله حقوقا يستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة وقد اقترن عرف الاستعمال بالحلف بها فينصرف إلى صفة الله تعالى كقوله وقدرة الله

الثانية إذا قال وعهد الله وكفالته فهي يمين مكفرة لأن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا به ونهانا لقوله تعالى ﴿ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ﴾ يس 60 وكلامه قديم صفة له ويحتمل أنه استحقاق لما تعبدنا به وقد ثبت عرف الاستعمال فيجب أن يكون يمينا بإطلاقه كقوله وكلام الله وإذا ثبت هذا فإنه إذا قال علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا فهو يمين وفيه رواية ذكرها ابن عقيل لأن العهد من صفات الفعل فلا يكون الحلف به يمينا كما لو قال وخلق الله

الثالثة إذا قال وايم الله فهي يمين مكفرة في الأصح لأنه عليه السلام كان يقسم به وانضم إليه عرف الاستعمال فوجب أن يصرف إليه كالحلف بعمر والله وعنه إن نوى اليمين وإلا فلا اختارها أبو بكر

فائدة ايم كايمن وهمزته همزة وصل تفتح وتكسر وميمه مضمومة وقالوا ايمن الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها وقال الكوفيون

[ج ٩ - ص ٢٥٦]

وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا ألفها ألف قطع وهي جمع يمين فكانوا يحلفون باليمين فيقولون ويمين الله قاله أبو عبيد وهو مشتق من اليمن والبركة

الرابعة إذا قال في حلفه وأمانة الله فهي يمين مكفرة نص عليه ولا يختلف المذهب فيه إذا نوى صفة الله تعالى لما ذكر في عهد الله

الخامسة إذا قال في حلفه وميثاق الله وقدرته كعلم الله تعالى فإن نوى القسم بالمعلوم والمقدور فقدم في الرعاية أنه ليس يمينا والمنصوص أنه يمين

مسألة يكره الحلف بالأمانة لما روى بريده مرفوعا قال ليس منا من حلف بالأمانة رواه أبو داود ورجاله ثقات

السادسة إذا قال في قسمه وعظمة الله وكبريائه وجلاله فهو يمين مكفرة في قولهم جميعا كعزة الله وعلمه لأن هذه من صفات ذاته لم يزل موصوفا بها وقد وردت الأخبار بالحلف بعزة الله تعالى

وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك أي بقايه ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير الله فلم يكن يمينا كالشيء والموجود إلا أن ينوي بإطلاقه صفة الله تعالى فيكون يمينا على المذهب لأن النية تجعل للعهد ونحوه كأمانة الله تعالى ولأنه حلف بصفة من صفات الله تعالى وعنه بإطلاقه يكون يمينا لأن اللام إذا كانت للتعريف صرفته إلى عهد

الله تعالى وإن كانت للاستغراق دخل في ذلك والأول أشهر وجزم به في المستوعب والوجيز لأنه يحتمل غير [ج ٩ - ص ٢٥٧]

وإن قال لعمرو الله كان يمينا وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي ما تجب به الكفارة مع أن أحمد غلظ أمر العهد وقال هو شديد في عشرة مواضع من كتاب الله تعالى

وحلفت عائشة لا تكلم ابن الزبير فلما كلمته اعتقت أربعين رقبة وكانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول واعهداه قال ويكفر إذا حلف بالعهد وحنث بأكثر من كفارة يمين

وإن قال لعمرو الله كان يمينا نصره القاضي في الخلاف وذكر أنه المذهب وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهو كالحلف ببقاء الله تعالى كقوله تعالى ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ الحجر 72 وقال الشاعر % إذا رضيت كرام بني بشير % لعمرو الله أعجبني رضاها %

إذ العمر بفتح العين وضمها الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي هذا رواية لأنه إنما يكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال لعمرو الله ما أقسم به فيكون مجازا والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق والأول أصح لأن احتياج الكلام إلى تقدير لا يضر لأن اللفظ إذا اشتهر في العرف صار من الأسماء العرفية فيحمل عليه عند الإطلاق دون موضوعه الأصلي وعنه بكل آية كفارة وإن قال

أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو عزام بالله كان يمينا

[ج ٩ - ص ٢٥٨]

وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة فرع إذا قال لعمرك الله فقيل هو مثل نشدتك الله وإن قال لعمرك أو لعمري أو عمرك فليس بيمين في قول أكثرهم لأنه أقسم بحياة مخلوق ونقل الجوزجاني إذا قال لعمري كان يمينا وقاله الحسن فتجب به الكفارة

وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن أو آية منه فهي يمين في قول عامتهم لأن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع فيها كفارة واحدة قدمه الأئمة منهم الجد وهو قياس المذهب وقاله الأكثر لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة فهذا أولى وكسائر الأيمان وعنه بكل آية كفارة إن قدر قال في الكافي هي المنصوصة عنه واختارها الخرقي وهي قول الحسن لما روى مجاهد مرفوعا من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة ويمين صبر ورواه الأثرم ورواه بمعناه أبو نصر السجزي وابن أبي داود في فضائل القرآن من حديث أبي هريرة وروي عن ابن مسعود أيضا قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه وعنه يجب مطلقا وفي الفصول وجه بكل حرف وفي الروضة من حلف بالمصحف فحنث فكفارة واحدة رواية واحدة وإن قال أحلف أو

حلفت بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا في قول الأكثر سواء نوى اليمين أو أطلق ويشهد [ج ٩ - ص ٢٥٩]

وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا إلا أن ينوي وعنه يكون يمينا لذلك قوله تعالى ﴿ فيقسمان بالله ﴾ المائدة 106 و ﴿ أقسموا بالله ﴾ الأنعام 109 ﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴾ النور 6

وقال عبد الله بن رواحة % أقسمت بالله لتنزلنه % طائعة أو لتكرهنه % وأنشد أعرابي % أقسم بالله لنفعلنه %

ولأنه لو قال بالله ولم يذكر الفعل كان يمينا فإدا ضم إليه ما يؤكده كان أولى وحكاه ابن هبيرة عن الأكثر في أقسم وأشهد بالله وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم بغيره فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما إلا أن ينوي لأن النية تصرف اللفظ إلى القسم بالله فيجب جعله يمينا كما لو صرح به وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال وعنه يكون يمينا لقول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر رواه أبو داود ولقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أقمست عليك لتبايعنه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبررت قسم عمي

لكن قال في المغني والشرح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى

تنبيه إذا قال آليت وآلي بالله يمين فيها كفارة صرح به جماعة وإن نوى الخبر عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا فليس يمينا قدمه في الرعاية وكذا إن قال على يمين وأراد عقد اليمين لأنه لم يأت باسم الله تعالى ولا صفته وإن قال قسما بالله فهو يمين تقديره أقسمت قسما القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب [ج ٩ - ص ٢٦٠]

فصل

وحروف القسم الباء والواو والتاء باسم الله خاصة ويجوز القسم بغير حرف

فصل

وحروف القسم الباء وهي الاصل لأنها الحرف التي تصل بها الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها وتدخل على المضمر والمظهر والواو وهي بدل منها ويليها المظهر وهي أكثر استعمالا والتاء وهي بدل من الواو وتختص باسم الله خاصة فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لأنه موضوع له وقد جاء في كتاب الله العزيز وكلام العرب فإن ادعى أنه لم يرد القسم بها لم يقبل وقيل بلى في تالله لأقومن إذا قال أردت قيامي بمعونة الله تعالى ولا يقبل في الحرفين الآخرين والآول أولى

مسألة جوابه في الايجاب إن خفيفة وثقيلة وباللام في المبتدأ والفعل المضارع مقرونا بنوني التوكيد وقد يتعاقبان وفي الماضي مع قد وقد تحذف معها اللام لطول الكلام وفي النفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لامه لفظا نحو والله أفعل

ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب والمراد انقعاد اليمين لأنه لغة صحيحة وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع فروى ابن مسعود أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل

قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قتلته قال آلله إني قتلته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما طلق امرأته آلله ما أردت إلا واحدة به اليمين ويكره الحلف بغير الله تعالى [ج ٩ - ص ٢٦١]

وإن قال الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي وفي اللغة قال امرؤ القيس % فقلت يمين الله أبرح قاعدا % ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي %

وإن قال الله لأفعلن موفوعا كان يمينا لأنه في العرف العام يمين ولم يوجد ما يصرفه عنه فوجب كونه يمينا كالقسم المحض وفي المغني لا كما لو كان القائل من أهل العربية إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا نواها مقتضاه أنه إذا نواها كان يمينا لأنه قصد القسم أشبه ما لو جر وفي الشرح فإن قال الله لأفعلن بالرفع ونوى اليمين فهو يمين إلا أنه قد لحن وإن لم ينو فقال أبو الخطاب يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية وقيل لا يكون يمينا في حق العامي انتهى قال القاضي ولو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعنى وقال الشيخ تقي الدين الأحكام تتعلق بما إراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا والله باصوم أو باصلي ونحوه وكقول الكافر أشهد أن محمدا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني فرع هاء الله يمين بالنية قاله أكثر الأصحاب وعدها في المستوعب حرف قسم وإن لم ينو فالظاهر لايكون يمينا لأنه لم يقترن بها عرف ولا نية ولا جوابه حرف يدل على القسم

ويكره الحلف بغير الله تعالى وصفاته قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب قيل لأحمد يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء قال

[ج ٩ - ص ٢٦٢]

ويحتمل أن يكون محرما ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله تعالى سبحان الله لم لا يكره لا يحلف إلا بالله تعالى لما روى عمر مرفوعا قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ويحتمل أن يكون محرما قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز قال ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا قال الشيخ تقي الدين لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يؤيده ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات

فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين أنه يعزر مع تحريمه واختار فيمن حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه يمين بالاتفاق وخرجه على نصوص أحمد وهو خلاف صريحها وعنه يجوز لقوله عليه السلام للأعرابي الذي سأله عن الصلاة أفلح وأبيه ان صدق ولأن الله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته وجوابه ما قال ابن عبد البر إن هذه اللفظة غير محفوظة وأنما أقسم بمخلوقاته فإنها دالة على قدرته وعظمته ولله أن يقسم بما شاء وقيل في أقسامه إضمار القسم أي برب هذه الأشياء فعلى الأول يستغفر الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا أن من حلف بحق زيد أو عمرو وبحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه ولا تجب الكفارة باليمين به لأن الكفارة وجبت في الحلف بالله وصفاته

صيانة للاسم الأعظم وغيره لا يساويه سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي لاشتراكهما في الحلف الكفارة ثلاثة شروط احدها أن تكون اليمين منعقدة وهي التي يمكن فيها البر والحنث وذلك الحلف على مستقبل ممكن

[ج ٩ - ص ٢٦٣]

وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة

فصل

ويشترط لوجوب بغير الله تعالى وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة ونص عليه في رواية أبي طالب فقال فيمن حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة أشبه الحلف باسم الله تعالى والتزم ابن عقيل أن الحلف بغيره من الأنبياء كهو والأشهر أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لدخوله في عموم الأحاديث وكسائر الأنبياء وقول أحمد محمول على الاستحباب فرع لا يلزمه إبرار قسم في الأصح كإجابة سؤال بالله قال الشيخ تقي الدين إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس مرفوعا قال وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به فدل على إجابة من سأل بالله

فصل

ويشترك لوجوب الكفارة وهي على الحالف في قول ابن عمر وأهل المدينة والعراق وحكي عنه على المحنث ثلاثة شروط

أحدها أن تكون اليمين منعقدة لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها وإما لغو ولا كفارة في واحد منهما وهي التي يمكن فيها البر والحنث لأن اليمين للحنث والمنع وذلك الحلف على مستقبل ممكن لقوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم

الله باللغو في أيمانكم ﴾ بها كاذبا عالما بكذبه وعنه فيها الكفارة

[ج ٩ - ص ٢٦٤]

وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان يمين الغموس وهي التي يحلف ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ الآية المائدة 89 فأوجب الكفارة بالأيمان المنعقدة قال ابن جرير معناها أوجبتموها على أنفسكم فظاهره إرادة المستقبل من الزمان لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع هي اليمين على المستقبل من الأفعال وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك في الماضي متعذر وحاصله كما قاله في الرعاية أن الحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه والحلف على الماضي إما بر وهو الصادق وإما غموس وهو الكاذب أو لغو وهو ما أجر فيه ولا إثم ولا كفارة والأولى أنها عبارة عن تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته وهي نوعان يمين الغموس وهي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها حق غيره وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وغموس للمبالغة وهي التي يحلف بها على الماضي كاذبا عالما بكذبه ظاهر المذهب أن يمين الغموس لا كفارة فيها ونقله عن أحمد الجماعة وهو قول أكثر العلماء لأنها يمين غير منعقدة ولا توجب برا ولا يمكن فيها أشبهت اللغو ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها قال ابن مسعود كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بإسناد جيد وهي من الكبائر للخبر الصحيح التي لا تمحوها الكفارة وعنه فيها

الكفارة لأنها تجمع الحلف بالله تعالى والمخالفة مع القصد فوجبت فيها الكفارة الثاني لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها [ج ٩ - ص ٢٦٥]

ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه كالمستقبل وحينئذ يأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر فيكفر كاذب في لعانه ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أما المستحيل عقلا كصوم أمس والجمع بين الضدين فإذا حلف لم تنقعد يمينه قاله أبو الخطاب وقدمه في الكافي وغيره لعدم تصور البر فيها كاليمين الغموس وقال القاضي تنعقد يمينه موجبة للكفارة في الحال وهو قياس المذهب لأنها يمين على مستقبل ولا فرق بين أن يعلم استحالته أو لا وأما المستحيل عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان فإذا حلف على فعله انعقدت يمينه قاله القاضي وأبو الخطاب وقطع به السامري لأنه يتصور وجوده وتلزمه الكفارة في الحال لأنه مأيوس منه وقياس المذهب أنها غير منعقدة كالتي قبلها قاله في الكافي وجزم بهما في الوجيز وفي الرعاية أوجه ثالثها تنعقد في المحال عادة فقط

الثاني لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء ماض يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها وحكاه ابن عبد البر إجماعا وفي الكافي هو ظاهر المذهب لقوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ وهذا منة ولأنه يكثر فلو وجبت فيه الكفارة لشق وتضرروا به وهو منتف شرعا وكيمين الغموس وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين وذكره ابن عقيل بمعناه قالت عائشة أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على جد من الأمر

في غضب أو غيره إسناده جيد واحتج به الأصحاب وذكر ابن هبيرة عن الأكثر [ج ٩ - ص ٢٦٦]

فصل

الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه وإن سبقت أن لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه فيتبين بخلافه سواء قصده أم لم يقصده وخصه أحمد بالماضي فقط وقطع جماعة بحنثه في عتق وطلاق لوجود الصفة وقيل إن عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على فعل شيء وفعله ناسيا

فصل

الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ذكره الأصحاب لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وعنه تنعقد حكاها أبو الخطاب لخبر حذيفة رواه مسلم وككفارة الصيد وجوابه قوله عليه السلام ليس على مقهور يمين ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر وكفارة الصيد كمسألتنا وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه عرض الشيء بالضم جانبه وبالفتح خلاف طوله فلا كفارة عليه على الأصح وهو قول أكثرهم لأنها من لغو اليمين لما روى عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود قال ورواه الزهري وعبد الله بن أبي سليمان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة موقوفا وكذا رواه البخاري ولأن اللغو في

كلام العرب الكلام غير المعقود عليه وهذا كذلك وذكر ابن هبيرة أنه إذا جرى على لسانه يمين على قول مستقبل فإن يمينه تنعقد في رواية فإن حنث فيها مختارا ذاكرا وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه

[ج ٩ - ص ٢٦٧]

الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله وجبت الكفارة وفي المحرر والرعاية فلا كفارة عليه إن كان في الماضي زاد في الرعاية في الأشهر وإن كان في المستقبل فروايتان وذكر السامري وغيره أنه لا كفارة فيها سواء قلنا هي من لغو اليمين أم لا وذكر ابن عقيل أن فيها الكفارة إن قلنا ليس هو من لغو اليمين

الثالث الحنث في يمينه لأن من لم يحنث لا كفارة عليه لأنه لم يهتك حرمة القسم بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله لأن الحنث الإثم ولا وجود له إلا بما ذكر مختارا ذاكرا لأن غيرهما المكره والناسي ونبه عليهما بقوله وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه ذكره في الوجيز ونصر في الشرح أنه لا يحنث في يمين مكفرة ويحنث في عتق وطلاق قال السامري اختاره أكثر شيوخنا ولأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تكن عليه كفارة كما لو لم يفعله وقال أبو الخطاب الإكراه كالنسيان لشمول الحديث لهما وذكر في الشرح المكره على الفعل ينقسم إلى قسمين

أحدهما أن يلجأ اليه فلا يحنث في قول أكثرهم

الثاني أن يكره بالضرب ونحوه ففيه روايتان إحداهما يحنث ككفارة الصيد ونصر في الشرح عدمه ولا نسلم الكفارة في الصيد متصلا باليمين

وعنه على الناسي كفارة وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان بل إنما تجب على المكره وعنه على الناسي كفارة لأن الفعل ينسب إليه في الجملة أشبه الذاكر والفرق واضح وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ويسمى هذا استثناء لقوله عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي وقال سألت محمدا عنه فقال هذا خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق ورواه النسائي ولفظه قد استثنى وابن ماجة ولفظه فله ثنياه وعن ابن عمر مرفوعا قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال رواه غير واحد عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه عن أيوب السختياني والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين من غير فصل بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ والاستثناء ب إلا فعلى هذا لو سكت لانقطاع نفسه أو عطس ونحوه لم يمنع صحة الاستثناء وعنه مع فصل يسير ولم يتكلم جزم به في عيون المسائل قال في رواية أبي داود حديث ابن عباس والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم إنما هو استثناء بالقرب ولم يخلط كلامه بغيره ونقل عنه إسماعيل بن سعيد مثله ويحتمله كلام الخرقي فإنه قال إذا لم يكن بين اليمين

والاستثناء كلام وعنه وفي المجلس وحكاه في الإرشاد عن بعض أصحابنا قدم الاستثناء على الجزاء أو أخره من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك وإذا حلف على يمين فرأى [ج ٩ - ص ٢٦٩]

وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس وعن ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه وهو قول مجاهد وهذا لا يصح قال أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين الخبر ولم يقل فاستثن ولو جاز لأمر به وحمله في موضع آخر على قوله تعالى ﴿ ولا تقولن لشيء ﴾ الآية الكهف 23 فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر قال ابن الجوزي فائدته الخروج من الكذب وفي المبهج يصح ولو تكلم ويشترط نطقه إلا من مظلوم خائف نص عليه ولم يقل في المستوعب خائف لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركا ولم يعتبره الشيخ تقي الدين وإن شك في الاستثناء فالاصل عدمه قال الشيخ تقي الدين إلا ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلأن تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك لقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به ولأن المحلوف على فعله لم يتوقف بوقت معين وفعله ممكن فلم تحصل مخالفة ما

حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث لأن شرطه المخالفة وإذا حلف على يمين فرأى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب افتداء يمينه

[ج ٩ - ص ٢٧٠]

غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير ولا يستحب تكرار الحلف وإن دعي إلى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير كذا في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع لأخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني رواه البخاري وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى وسبق تقسيمه إلى الخمسة ولا يستحب تكرار الحلف كذا في المستوعب والفروع وظاهره الكراهة وصرح بها في الرعاية لقوله تعالى ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ القلم 10 هذا ذم له يقتضي كراهة فعله فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه إلا أن يقترن به ما يقتضي كراهته ونقل حنبل لا يكثر الحلف لأنه مكروه لقوله تعلى ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ البقرة 224 وبعضهم كرهه مطلقا وجوابه بأنه عليه السلام حلف في غير حديث ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه وأما الآية فمعناها لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس قال أحمد وذكر حديث ابن عباس بإسناده في قوله تعالى ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ الرجل يحلف ألا يصل قرابته وقد جعل الله له مخرجا في التكفير فليكفر عن يمينه ويبر وإن كان النهي عاد إلى اليمين فالنهي عنه الحلف على قول البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا على كل يمين وإن دعي إلى الحلف

عند الحاكم وهو محق استحب وفي الفروع وغيره فالأولى افتداء يمينه لما

[ج ٩ - ص ٢٧١]

فإن حلف فلا بأس

فصل

وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم روي أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان فقال عمر لقد أنصفك فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف فقيل له في ذلك فقال خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال يمين عثمان فإن حلف فلا بأس كذا في المحرر والوجيز قال بعض أصحابنا تركه أولى فيكون مكروها والأشهر أنه ليس بمكروه وإنما هو مباح كتركه لأن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن يحلف على تصديق ما أخبره في ثلاثة مواضع في القرآن في سبأ ويس والتغابن وقال عمر على المنبر وفي يده عصا أيها الناس لا تمنعنكم اليمين من حقوقكم ولأنه حلف صدق على حق أشبه الحلف عند غير الحاكم قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الأمر وغيره ومنه قوله عليه السلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها تطمينا منه لقلبه فرع ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك

فصل

وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال كطعام ولباس ونحوهما سوى الزوجة لم يحرم على المذهب لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴾ إلى قوله ﴿ قد فرض الله ﴾ وعليه كفارة يمين إن فعله ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة وإن قال ﴿ لكم تحلة أيمانكم ﴾ [ج ٩ - ص ٢٧٢]

واليمين على الشيء لا تحرمه فكذا إذا حرمه ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا وعليه كفارة يمين إن فعله نص عليه لقوله تعالى ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ التحريم 2 يعنى التكفير وسبب نزولها أنه عليه السلام قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه وزاد البخاري تعليقا وقد حلفت وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ومقتضاه أنه إذا ترك ما حرمه على نفسه أنه لا شيء عليه ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة هذا وجه لقوله تعالى ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ وكتحريم الزوجة وجوابه أنه إذا أراد التكفير فله فعل المحلوف عليه وحل فعله مع كونه محرما تناقض وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام نقله أبو طالب قال في الانتصار وطعامي علي كالميتة والدم واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهل تستحب على فعل طاعة أو ترك معصية فيه وجهان وإن قال هو يهودي أو كافر أو برىء من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك فقد فعل محرما لما روى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال متفق عليه وعن بريدة مرفوعا قال من قال إنه بريء من الاسلام وإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد وسواء كان منجزا أو معلقا بشرط وعليه كفارة يمين إن فعل

في إحدى الروايتين الله في كل ما أمرني أو محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة عليه [ج ٩ - ص ٢٧٣]

وإن قال أنا استحل الزنى ونحوه فعلى وجهين وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي قدمه في المستوعب والرعاية والمحرر وجزم به في الوجيز لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق إن فعله لإباحته في حال والثانية لا كفارة عليه وصححها المؤلف لأنه لم يرد ولا هو في معنى المنصوص عليه وعنه الوقف نقلها حرب وإن قال أنا أستحل الزنى ونحوه فعلى وجهين إذا قال هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان لأن استحلال ذلك أو تحريمه يوجب الكفر فيخرج على الروايتين قبلها وجزم في الوجيز وهو ظاهر ما قدمه في المحرر أنه إن فعل ذلك فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين

وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني أو محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة عليه نص عليه وقدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الكافي والشرح لأن هذه الأشياء لا نقص فيها يقتضي الوجوب ولا هي في معنى ما سبق فيبقى الحالف على البراءة الأصلية واختار في المحرر أنه إذا قال عصيت الله في كل ما أمرني أنه يمين لدخول التوحيد فيه وقال ابن عقيل في محوت المصحف هو يمين لأن الحالف لم يقصد بقوله محوته إلا إسقاط حرمته فصار كقوله هو يهودي

ولأنه إذا أسقط حرمته كان يمينا كذا إذا أتى بما في معناه إيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج فتشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال [ج ٩ - ص ٢٧٤]

وإذا قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء وعنه عليه كفارة إن حنث وإن قال وإذا قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء أي فلغو وكذا إن علقه لأن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق وإذا كان المطلق لا يوجب شيئا فكذا المعلق ولا يعتق العبد إذا حنث بغير خلاف لأنه لا يعتق بتنجيزه فالمعلق أولى ولا تلزمه كفارة لأنه حلف بإخراج مال غيره كما لو قال مال فلان صدقة وعنه عليه كفارة إن حنث لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع إلا بالحنث كما لو قال لله علي أن أعتق فلانا والأول أصح والفرق بينهما أن قوله لله علي إلى آخره أنه نذر فأوجب الكفارة لكون النذر كاليمين وتعليق العتق بخلافه فرع إذا قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقه أو فعل فلان الحج أو هو بريء من الإسلام وأشباه ذلك فليس بيمين ولا تجب به كفارة بغير خلاف نعلمه قاله المؤلف وذكر السامري فيه الخلاف

وإن قال أيمان البيعة تلزمني البيعة المبايعة أن يحلف بها عند المبايعة والأمر المهم وكانت البيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة فهي يمين رتبها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ولاه عبد الملك بن مروان قتال ابن الزبير فحاصره بمكة ثم قتله وأخرجه فصلبه فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين فوليها عشرين سنة فزلزل أهلها وروى ابن قتيبة عن عمر أنه قال يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ اللهم عجل

لهم الغلام الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم فتشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ذكره ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق [ج ٩ - ص ٢٧٥]

فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها وإلا فلا شيء عليه الأصحاب زاد بعضهم والحج فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها من الطلاق والعتاق لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية فكذا ما عداهما في قول القاضي وقدمه في الرعاية واستثنى في الوجيز اليمين بالله تعالى وهو قول القاضي وجزم به في الكافي لأن الكفارة إنما وجبت فيها لما ذكر فيها من اسم الله المعظم ولا يوجد ذلك في الكناية وإلا فلا شيء عليه أي إذا لم يعرفها ولم ينوها فلغو لأن ذلك إنما ينعقد بالكناية ولا مدخل لها في ذلك ولأنه لا يصح مع النية فيما لا يعرفه وسئل أبو القاسم الخرقي عنها فقال لست أفتي فيها بشيء ثم قال إلا أن يلتزم الحالف بجميع ما فيها من الأيمان فقال يعرفها أو لا يعرفها قال نعم فيؤخذ منه أنها تنعقد إذا نواها وإن لم يعرفها ويحتمل ألا تنعقد بحال لما ذكرنا إلا في الطلاق والعتاق لانعقدهما بالكناية وقيل والصدقة وفي الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق فرع لم يذكر المؤلف حكم أيمان المسلمين ويلزمه فيها عتق وطلاق وظهار ونذر ويمين بالله بنية ذلك وفي اليمين بالله الوجهان وألزم القاضي الحالف بالكل ولو لم ينو ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني من يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه نص عليه في طلاق وفي المكفرة وجهان وذكر السامري أنه إذا كانت يمين الأول مما ينعقد بالكناية كطلاق وعتق انعقدت يمين الثاني وإلا فلا وفي الكافي والشرح أن اليمين بالله لا تنعقد

وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه لأن الكناية لا تنعقد بغير نية وهذا ليس بصريح

فصل

وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخيره فيها بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة درع وخمار [ج ٩ - ص ٢٧٦]

وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين وجزم به في الوجيز لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال كفارة النذر أذا لم يسم كفارة يمين وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية

فصل كفارة اليمين

وهي تجمع تخييرا وترتيبا فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ المائدة 89 وفي السنة أحاديث

وأجمعوا على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى فيخير فيها بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وقد سبق ذكر العتق والإطعام في الظهار ويجزيء أن يطعم بعضا ويكسو بعضا نص عليه وفيه قول كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع غيره والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه الفرض نقله حرب وقاله في التبصرة كوبر وصوف وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته فإذا ذهبت منفعته

باللبس فلا يجوز كالحب المعيب وللمرأة درع وخمار لأن ما دون ذلك لا يجزيء لبسه في الصلاة ويسمى عريانا شرعا فوجب [ج ٩ - ص ٢٧٧]

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده أن لا يجزئ وقال أكثر العلماء يتقدر ذلك بأقل ما يقع عليه الاسم وجوابه أن الكسوة أحد أنواع الكفارة فلم يجز فيها ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق ولأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة أشبهت الصلاة ونص على الدرع والخمار كالخرقي وغيره لأن الستر غالبا لا يحصل إلا بذلك والا فلو أعطاها ثوبا واسعا يستر بدنها ورأسها أجزأ ذلك إناطة بستر عورتها في الصلاة فمن لم يجد أي إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة فصيام ثلاثة أيام للآية متتابعات أي بلا عذر في ظاهر المذهب وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات حكاه أحمد ورواه الأثرم فالظاهر أنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا وكصوم الظهار وعنه له تفريقها وقال ابن عقيل هل الدين كزكاة فيصوم أم لا كفطره فيه روايتان ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر نص عليه فإن كان ماله غائبا استدان إن قدر وإلا صام فرع تجب كفارة ونذر على الفور نص عليه إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده سواء كان صوما أو غيره وهو قول أكثرهم وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحنث عمر وابنه وابن عباس وسلمان وعن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات

ولأنه كفر بعد سببه فجاز ككفارة الظهار والقتل وعنه لكل يمين كفارة والظاهر أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فلكل يمين كفارة [ج ٩ - ص ٢٧٨]

ولا يجوز تقديمها على اليمين ومن كرر إيمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة بعد الجرح وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب والحنث شرط وليس بسبب وظاهره أنهما سواء في الفضيلة نص عليه وعنه بعده أفضل للخروج من الخلاف وهذا محله ما لم يكن الحنث حراما فإنه إذا كان كذلك كفر بعده مطلقا وفي الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته لا يجوز بل لا يصح وفي رواية لا يجوز بصوم لأنه تقديم عبادة كصلاة واختار في التحقيق أنه لا يجوز قبل الحنث كما لو كفر قبل اليمين وكحنث محرم في وجه ولا يجوز تقديمها على اليمين عند أحد من العلماء لأنه تقديم للحكم قبل سببه كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب مع أن ابن حزم ذكر أنهم اختلفوا في تقديمها ومن كرر أيمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة اختاره الأكثر وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره لأن الكفارة حد بدليل قوله عليه السلام الحدود كفارات لأهلها فوجب أن تتداخل كالحدود وعنه لكل يمين كفارة وقاله أبو عبيد فيمن قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فعليه ثلاث كفارات ولأن كل واحدة منهن ثم الأولى وكما لو اختلف موجبها كيمين وظهار وعنه إن حلف أيمانا على شيء واحد لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم والظاهر أنها إن كانت على فعل واحد كوالله لا قمت والله لا قمت فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت فلكل يمين كفارة هذا رواية ونصرها في الشرح لأنها إذا كانت على فعل واحد كان سببها

واحدا فالطاهر أنه أراد التأكيد وإن كانت على أفعال فلأنها أيمان لا يحنث في كفارتها وكفارة العبد الصوم [ج ٩ - ص ٢٧٩]

وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين إحداهن بالحنث في الأخرى فوجب في كل يمين كفارتها كالمختلفة والأول أصح لأنها كفارات من جنس فقد أحلت كالحدود وأجاب في الشرح بأن الحدود وجبت للزجر وتندرئ في الشبهة والموالاة بينها ربما أفضى إلى التلف لأنها عقوبة بدنية بخلاف مسألتنا فرع إذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة وحنث في الجميع فكفارة واحدة بغير خلاف نعلمه لأن اليمين واحدة والحنث واحد فإنه يحنث بفعل واحد من المحلوف عليه وتنحل يمينه فإن أخرجها ثم حنث في أخرى فكفارة أخرى لا نعلم فيه خلافا كما لو وطىء في رمضان فكفر ثم وطىء ثانية

تنبيه مثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله شيخنا نقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين وقال شيخنا فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره لم يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا وذكر المؤلف أنه يقع بها ثلاث إجماعا وكان الفرق أنه يلزمه من الشرط الجزاء فتقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط في اليمين ولانها للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ذكره في الفروع وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها لأنها أجناس

فلم تتداخل كالحدود من أجناس وكفارة العبد الصوم لأنه كفارة الحر الايمان

ويرجع في الأيمان إلى النية [ج ٩ - ص ٢٨٠]

وليس لسيده منعه منه ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار

باب جامع الايمان وإطعام بإذن سيده إن قلنا يملك بالتمليك وإلا فلا وهل له إعتاق نفسه على وجهين وليس لسيده منعه منه ولا من نذره كصوم رمضان وقضائه وفي الرعاية إن حلف أو حنث بإذنه روعي الحلف فقط ومن نصفه حر وعبارة المحرر والوجيز والفروع ومن بعضه وهو أولى فحكمه في الكفارة حكم الأحرار لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر الكامل وقيل لا يكفر بعتق لأنه لا يثبت له الولاء وجوابه بالمنع فرع يكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم

باب جامع الأيمان

ويرجع في الأيمان إلى النية أي إلى نية حالف ليس ظالما نص عليه ولفظه يحتملها فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه مثل أن ينوى موضوع اللفظ أو الخاص بالعام أو بالعكس أو غير ذلك لقوله عليه السلام وإنما لامرىء ما نوى فتدخل فيه الأيمان ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على ما أراده دون ظاهر اللفظ فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر ومع توسطه روايتان أشهرهما القبول مسألة [ج ٩ - ص ٢٨١]

وإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فإذا حلف ليقضينه حقه غدا يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة اختاره الأكثر وقيل لا ذكره الشيخ تقي الدين واختاره لأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال لا يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها قدمه في الخرقي والإرشاد والمبهج وجزم به في الوجيز وحكى رواية وقدمه القاضي بموافقته أو وضع وعنه يقدم عليه وذكرها القاضي وعليها عموم لفظه احتياطا ثم إلى التعيين وقيل يقدم عليه وضع لفظه شرعا أو عرفا أو لغة وفي المذهب في الاسم والعرف وجهان وذكر أنه النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا أو لغة فإذا حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه أو كان السبب يقتضيه لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء ولأن السبب يدل على النية فإن لم ينو ذلك ولا كان السبب يقتضيه فظاهر كلام الخرقي وقدمه في الرعاية وغيرها أنه لا يبرأ إلا بقضائه في الغد وقال القاضي يبرأ في كل حال لأن عرف هذه اليمين في القضاء التعجيل فتنصرف اليمين المطلقة إليه والأول أصح فلو حلف ليقضينه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث ذكره في المحرر والرعاية فإن كان كأكل شيء أو بيعه فإن عين وقتا ولم ينو ما يقتضي تعجيله ولا كان سبب يمينه يقتضيه لم يبرأ إلا أن يفعله في وقته نصره المؤلف وغيره وذكر القاضي أنه يبرأ بتعجيله عن وقته وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة يحنث بالحول في غيره وإن دعي إلى غذاء

فحلف لا يتغذى اختصت يمينه به إذا قصده وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش بقصد قطع المنة حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث [ج ٩ - ص ٢٨٢]

فباعه بأكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم فباعه بأكثر لم يحنث لأنه لم يخالف ما حلف عليه وإن باعه بأقل حنث لأن قرينة الحال تدل على ذلك كما لو حلف ما له علي وله علي شيء كثير وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره لأن العبرة في الأيمان بالنية ولأن اللفظ العام يصير بالإرادة خاصا ولو كانت يمينه خاصة كقوله لا دخلت دارا اليوم لم يحنث بالدخول في غيره فكذا إذا نواه وفي الفروع إن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم قبل حكما وعنه لا ويدين

وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به إذا قصده أي اختصت يمينه بالغداء عند الداعي إذا قصده لأن اللفظ وإن كان عاما لكن القصد خصصه فصار كما لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى عند الداعي وفيه وجه

وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه كقوله تعالى ﴿ ولا يظلمون فتيلا ﴾ النساء 49 يريد لا يظلمون شيئا

ولقول الشاعر % ولا يظلمون الناس حبة خردل %

ونص عليه أحمد في مواضع ذكره القاضي في الخلاف وذكر ابن عقيل لا أقل منه كقعوده في ضوء ناره وعلى ما ذكره المؤلف إن لم يقصد قطع المنة

لم يحنث إلا أن يكون ثم سبب وإن كان لهذه اليمين عادة وعرف فهو كمن حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث وكذا إن معها في غيرها حنث [ج ٩ - ص ٢٨٣]

وإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه فأوى انتفع بثمنه نص عليه في رواية أبي طالب وذكره القاضي في الخلاف وهو قول أكثرهم لقوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها ويحنث بالانتفاع به في غير اللبس لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة به وإن لم يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث إلا بما تناولته يمينه وهو لبسه خاصة فإن نوى اجتناب اللبس خاصة قدمت النية على السبب وجها واحدا قاله في المغني لأن النية وافقت مقتضى اللفظ ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منة جزم به في الكافي والشرح وقدمه في الرعاية لأن لكونه ثوبا من غزلها أثرا في داعية اليمين فلم يجز حذفه وقيل إن انتفع بما لها فيه منة بقدره أو ارتد حنث جزم به في الترغيب وذكر في التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشيء منها لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي

تنبيه إذا كان اللفظ أعم من السبب كرجل امتنت عليه زوجته ببيتها فحلف لا يسكن بيتا فقيل يحمل اللفظ على عمومه ككلام الشارع والأشهر أن العبرة بخصوص السبب لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص أشبه ما لو نواه لإقامة السبب مقام النية وإن حلف لا يأوى معها في دار يريد جفاءها ولم يكن الدار سبب هيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث أو لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها لمخالفته ما حلف على

تركه ومعنى الإيواء الدخول يقال أويت أنا وآويت غيري وقوله تعالى فأعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك انحلت يمينه وإن لم يكن له نية انحلت أيضا ذكره القاضي لأن الحال تصرف اليمين إليه [ج ٩ - ص ٢٨٤]

وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده ﴿ إذ أوى الفتية إلى الكهف ﴾ الكهف 10 ﴿ وآويناهما إلى ربوة ﴾ المؤمنون 50 فإن اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت لم يحنث سواء كانت الدار سبب يمينه أو لم تكن لأنه قصد جفاءها بهذا النوع ونقل ابن هانيء أقل الإيواء ساعة وجزم به في الترغيب

مسألة إذا حلف لا يدخل عليها بيتا فدخل عليها فيما ليس ببيت فإن قصد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه حنث وإلا فلا قاله في المغني والشرح فإن دخل على جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها حنث وكذا إن لم يقصد شيئا وإن استثناها بقلبه فوجهان فإن دخل بيتا لا يعلم أنها فيه فوجدها فيه فهو كالدخول عليها ناسيا وفيه روايتان فإن قلنا لا يحنث فأقام فهل يحنث على وجهين وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فأعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك انحلت يمينه لأن الخروج بعد ما ذكر بغير الإذن خروج لم يتناوله لتخصيص اللفظ بإرادة زمن العمالة والزوجية والعبودية فإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا ذكره القاضي لأن الحال تصرف اليمين إليه لأن السبب يدل على النية في الخصوص لدلالتها عليه في العموم ولو نوى الخصوص لاختصت يمينه به فكذا إذا وجد ما يدل عليها وقدم في الرعاية أنها لا تنحل لأن لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص وجب الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كذلك يمين الحالف لأن اليمين إذا

تعلقت بعين الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم فقال أحمد النذر يوفى به والأول أولى لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء وإن حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا وإن لم ينو احتمل وجهين [ج ٩ - ص ٢٨٥]

وذكر في موضع آخر ان السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به وإن اقتضى موصوفة تعلقت بالعين وإن تغيرت الصفة وذكر القاضي فيمن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أنها لا تنحل في قياس المذهب وهو وجه والأول أولى وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به وإن اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم فقال أحمد النذر يوفى به نظرا إلى عموم اللفظ فيجب أن يعتبر والأول أولى لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء لأن اصوله تقتضي تقديم النية والسبب على عموم اللفظ وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره على الحاجة فكذا تجب في هذه المسائل لكونها داخلة في القواعد الكلية

تنبيه إذا اختلف السبب والنية مثل أن امتنت عليه امرأته بغزلها فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها ينوي اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمنه وغيره قدمت النية على السبب وجها واحدا لأن النية وافقت مقتضى اللفظ وإن نوى بيمينه ثوبا واحدا فكذلك في ظاهر قول الخرقي وقال القاضي يقدم السبب لأن اللفظ ظاهر في العموم والسبب وهو الامتنان يؤكد ذلك الظاهر والأول أصح لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر فكان وجوده كعدمه فلم يبق إلا اللفظ بعمومه والنية تخصه على ما بيناه وإن حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا لأن الرفع بمنزلة

الخروج فيما إذا حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه ونوى ما دام عاملا وإن لم ينو احتمل وجهين

أحدهما [ج ٩ - ص ٢٨٦]

لا تخل قال القاضي هو قياس المذهب والثاني بلى وهو ظاهر الوجيز لأنه لا يقال رفعه إليه إلا في حال ولايته فعلى الأول إذا رفعه إليه بعد العزل بر وإلا فلا وإذا رأى منكرا في ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل لم يبر وهل يحنث بعزله فيه وجهان

أحدهما يحنث كما لو مات

والثاني لا لأنه لم يتحقق فواته لاحتمال أن يلي فيرفعه إليه وأن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث في الأصح وإن لم يعين الوالي أذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه وقيل لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأولى هي كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيه وفيه وجهان وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق فإنها تطلق معهم نص عليه أخذا بالأعم من لفظ وسبب

مسائل الأولى إذا حلف لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها وإن حلف لا يبيت عند فلانة فمكث عندها حتى مضى أكثر الليل حنث لأن البيتوتة تقع عليه وإن مكث أقل فعلى الخلاف في فعل بعض المحلوف عليه

الثانية إذا حلف لا يكفل بمال فكفل ببدن فقال أصحابنا يحنث وقال المؤلف والقياس عدمه وذكر السامري وابن حمدان يحنث إلا إذا شرط

البراءة من المال وصححنا هذا الشرط

الثالثة إذا حلف لا يأوي مع زوجته هذا العيد فقال أحمد في رواية إسماعيل [ج ٩ - ص ٢٨٧]

فصل

فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها بن سعيد إذا عيد الناس دخل إليها قلت فإن قال أيام العيد فقال على ما يعرفه الناس ويعهدون بينهم وقد روي عن ابن عباس قال حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم يعني من صلاتهم وقال ابن أبي موسى ويتوجه أن لا يأوي عندها في عيد الفطر حتى تغيب شمس يومه ولا يأوي في عيد الأضحى حتى تغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق

فصل

فإن عدم ذلك أي النية والسبب رجع إلى التعيين كذا في الكافي والوجيز وصححه في المحرر والرعاية لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم ولهذا لو شهد عدلان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهد على مسمى باسم لم يجب حتى يثبت أنه المسمى بذلك وكذا يقدم التعيين على الصفة والإضافة وقيل تقدم الصفة عليه فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا أو باعها فلان لأن التعيين يقتضي الحنث وزوال الاسم ينفيه والتعيين راجح على الاسم أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه لما ذكرنا أو لا كلمت

هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان أو صديقه فلانا أو غلامه سعدا فطلقت الزوجة وزالت الصداقة وعتق العبد وكلمهم لأن الإضافة فيها تقتضي وصف المحلوف على [ج ٩ - ص ٢٨٨]

أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا ++عدم كلامه بالزوجية والصداقة أو كونه غلاما والصفة كالاسم بل أضعف فإذا غلب التعيين على الاسم فلأن يغلب على الصفة أولى أو لا أكلت لحم هذا الجمل فصار كبشا أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا لأنه كسكنى الدار والقميص من غير فرق أو لا أكلت هذا اللبن فتغير أو عمل منه شيء فأكله لأن تغيره وخلط شيء آخر معه بمنزلة زوال الاسم وذلك لا يضر حنث في ذلك كله أي في المسائل السابقة كلها كقوله دار فلان فقط أو التمر الحديث فعتق أو الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة تنقض ثم تعاد ويحتمل ألا يحنث وقاله ابن عقيل لأنه لو حلف على ذلك كله ناويا للصفة التي حلف عليها لم يحنث إذا زالت وقرينة الحال تدل على إرادة ذلك فصار كالمنوي واختاره القاضي والمؤلف في نحو بيضة صارت فرخا وإن حلف ليأكلن هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها شرابا أو ناطفا فالوجهان وكذلك سائر المسائل ذكره في المحرر والفروع

فصل

فإن عدم ذلك أي التعيين مع عدم النية والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته عن المعارضة والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام شرعية وحقيقية وعرفية ما له مسمى واحد كالرجل والمرأة تنصرف اليمين

والزكاة والحج ونحوه فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث [ج ٩ - ص ٢٨٩]

فأما الشرعية فهي أسماء لها موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم إلى مسماه بغير خلاف وما له موضوع شرعي وموضوع لغوي كالوضوء فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي عند الإطلاق لا نعلم فيه خلافا وما له موضوع حقيقي ومجاز لم يشتهر كالأسد فتنصرف اليمين إلى الحقيقة ككلام الشارع وما اشتهر مجازه حتى صارت الحقيقة مغمورة فيه فهو أقسام منها ما يغلب على الحقيقة بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالراوية في العرف اسم للمزادة وفي الحقيقة لما يستقى عليه من الحيوانات والظعينة في العرف للمرأة وفي الحقيقة الناقة التي يظعن عليها فتنصرف اليمين إلى المجاز لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه أشبه الحقيقة في غيره وسيأتي بقية أنواعها فأما الشرعية فهي أسماء لها موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق لأن الشارع إذا قال صل تعين عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذا يمين الحالف وتتناول الصحيح منه لأن الفاسد ممنوع منه بأصل الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث نصره في الشرح وقدمه الجماعة وجزم به في الوجيز لأن اليمين على ذلك تتناول الصحيح منه ولأنه المشروع وعنه يحنث لوجوده صورة وعنه في البيع دون النكاح الفاسد قاله ابن أبي

موسى وقال أبو الخطاب إن نكحها نكاحا مختلفا فيه فوجهان وقال ابن حمدان إن اعتقد صحته حنث وإلا فلا ومقتضاه أنه إذا كان بيعا بشرط الخيار أنه يحنث أو الحر فيحنث بصورة البيع وذكر القاضي فيمن قال لا مرأته إن سرقت مني شيئا وبعته فأنت طالق ففعلت لم تطلق

[ج ٩ - ص ٢٩٠]

إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة مثل أن يحلف لا يبيع الخمر ونص عليه لأنه بيع شرعي فيحنث به كاللازم وإن حلف لا ملكت هذا فاشتراه شراء فاسدا لم يحنث وفيه احتمال إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر فيحنث بصورة البيع أي إذا قيد يمينه بممتنع الصحة كما ذكره فيحنث في الأصح بصورة البيع لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فتعين محلا لها وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق ففعلت لم تطلق قال في الرعاية هو أقيس وخرجه السامري على الخلاف الذي ذكره ابن أبي موسى والشراء كالبيع وخالف في عيون المسائل في إن سرقت مني 2 شيئا وبعتيه كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا وإن حلف لتبيعنه فباعه بعرض بر وكذا نسيئة وقيل ينقض يمينه فرع إذا حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب ولم يقبل المشتري والزوج لم يحنث لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يتم إلا بالقبول فلم يقع على الإيجاب بدونه وإن قبله حنث نص عليه وإن حلف ليتزوجن بر بعقد صحيح سواء كان له امرأة أو لا وسواء كانت نظيرتها أو أعلى منها إلا أن يحتال على حل يمينه بتزويج لا يحصل المقصود والمذهب يبر بدخوله بنظيرتها والمراد والله أعلم بمن تغمها وتتأذى بها لظاهر رواية أبي طالب وفي المفردات وغيرها أو مقاربها وقال الشيخ تقي الدين المنصوص أن يتزوج ويدخل ولا تشترط مماثلتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ولم يذكر دخولا وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي

بره برجعي خلاف وإن حلف لا تسريت فوطىء جارية ركعة وقال القاضي إن حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة [ج ٩ - ص ٢٩١]

وإن حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يصلي حنث قدمه في الرعاية والمحرر وقال القاضي لا يحنث حتى يطأ فينزل فلا كان أو خصيا وعنه إن عزل فلا حنث وجه الأول أن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ البقرة 235 لأن ذلك حكم تعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام والأول أولى وإن حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما لأن إمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي وهذا إذا لم ينو عددا وأقل ذلك يوم لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه لأنه اليقين والمذهب أنه يحنث بشروع صحيح وقيل إن حنث بفعل بعض المحلوف وما ذكره المؤلف حكاه في المحرر والفروع قولا كقوله صوما وكلفه ليفعلنه وإن كان صائما فدام فوجهان وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقاله أبو الخطاب لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة وقيل بلى إذا صلى ركعتين والمذهب كما قدمه في المستوعب والمحرر والرعاية وجزم به في الوجيز ونسبه في الفروع إلى الأصحاب أنه يحنث بالشروع الصحيح وقال القاضي إن حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة لأنه يطلق عليه أنه مصل فيجب أن يكون ما هو فيه صلاة قال في الشرح ويشبه هذا ما إذا قال لزوجته إن حضت حيضة فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض وشمل كلامه

صلاة الجنازة فيدخل في العموم وذكره أبو الخطاب وأما الطواف فقال المجد ليس صلاة مطلقة ولا مضافة لكن يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث [ج ٩ - ص ٢٩٢]

وإن حلف لا يصلي حنث بالتكبير وإن حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا في كلام أحمد إنه صلاة وقال أبو الحسين وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق ولم يذكر المؤلف حكم الحج وحاصله أنه إذا حلف لا يحج حنث بإحرامه به وقيل بفراغ أركانه ويحنث بحج فاسد وإن كان محرما فدام فوجهان وإن حلف لا يصلي حنث بالتكبير هذا قول القاضي لأنه يدخل في الصلاة بذلك ويطلق عليه أنه مصل فيجب أن يكون ما هو فيه صلاة والأول أصح لأن ما ذكر ثانيا موجود فيمن شرع وإن حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يهدي له ففعل ولم يقبل زيد حنث ذكره الأصحاب وقاله ابن شريح لأن ذلك لا عوض له فيحنث بالإيجاب فقط كالوصية وفي الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في بيع وقاله القاضي في إن بعتك فأنت حر ولأن الاسم يقع عليها بدون القبول لقوله تعالى ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ﴾ الآية البقرة 180 أراد الإيجاب لأن الوصية تصح قبل موت الموصي ولا قبول لها حينئذ فرع إذا نذر أن يهبه شيئا بر بالإيجاب كيمينه وقد يقال يحمل على الكمال ذكره الشيخ تقي الدين

وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث في الأصح لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحلف الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ولهذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم الهبة

ولا الهدية إلا عند أبي الخطاب وإن وقف عليه حنث وإن أوصى له لم يحنث وإن باعه وحاباه حنث [ج ٩ - ص ٢٩٣]

وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وقال أبو الخطاب لا يحنث وإن أعاره لم يحنث لحديث بربرة وقيل يحنث لما ذكرناه وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث لأنه من أنواع الهبة كما لو أهدى إليه أو أعمره فإن أعطاه من صدقة واجبة أو نذر أو كفارة لم يحنث لأن ذلك حق لله يجب إخراجه فليس هو هبة منه فإن تصدق عليه تطوعا حنث لم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وقال أبو الخطاب لا يحنث هذا رواية لأنهما يختلفان اسما وحكما وجه الأول أنه تبرع بعين في الحياة فيحنث به كالهدية ولأن الصدقة تسمى هبة واختلاف التسمية لكون الصدقة نوعا من الهبة فتختص باسم دونها كاختصاص الهدية والعمري باسمين ولم يخرجهما ذلك عن كونهما هبة وإن أعاره لم يحنث لأن العارية إباحة والهبة تمليك وهذا هو الصحيح قاله القاضي لأن المستعير لا يملك المنفعة وإنما يستحقها ولهذا يملك المعير الرجوع فيها ولا يملك المستعير إجارتها إلا عند أبي الخطاب فإنه يحنث لأن العارية هبة المنفعة وهي قائمة مقام هبة العين بدليل صحة مقابلة المنفعة بالعوض كالعين وإن وقف عليه حنث لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة وقيل لا يحنث كوصية له ولأنه لا يملك على رواية وبناه في المغني على الملك فإن قلنا يملكه حنث بمساواته الهبة وإن قلنا بعدم ملكه فلا قال ابن المنجا ولقائل أن يقول لا يحنث وإن قلنا يملكه لأن الانسان ممنوع من هبة أولاده الذكور والإناث بالسوية فلم يلزم من المنع من الهبة المنع من الوقف وإن أوصى له لم يحنث

لأن الهبة تمليك في الحياة بخلاف الوصية وإن باعه وحاباه حنث قاله أبو الخطاب وجزم به اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية والدماغ والقانصة لم يحنث

[ج ٩ - ص ٢٩٤]

ويحتمل الا يحنث

فصل

القسم الثاني الاسماء الحقيقية إذا حلف لا يأكل في الوجيز لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن ويحتمل ألا يحنث هذا وجه وهو أولى لأنها معاوضة يملك الشفيع أخذ جميع المبيع ولو كان هبة أو بعضه لم يملك أخذ كله وأطلق في الفروع الخلاف ويحنث بالهدية خلافا لأبي الخطاب وإن أضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباح له الأكل ولهذا لا يملك التصرف فيه بغيره وإن أسقط عنه دينا لم يحنث إلا أن ينوي لأن الهبة تمليك عين

فصل

القسم الثاني الأسماء الحقيقة وهي نسبة إلى الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في وضع أول

وأذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية والدماغ والقانصة لم يحنث لأنه لا يسمى لحما وينفرد علقه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من هذه لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء وقال كثير من العلماء يحنث بأكل ذلك لأنه لحم حقيقة قال في الشرح لا نسلم أنه لحم حقيقة بل هو من الحيوان كالعظم وعلى الأول يحنث إذا قصد اجتناب الدسم ولا يحنث

بأكل كارع وذنب فإن أكل من الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم لم يحنث في ظاهر قول الخرقي وقال القاضي وأبو الخطاب يحنث بأكله لأنه لا يسمى شحما ولا بائعه شحاما ويسمى لحما سمينا ولو وكل في شراء اللحم فاشتراه لزمه وجه الأول قوله تعالى الورع وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث [ج ٩ - ص ٢٩٥]

وإن أكل المرق لم يحنث وقد قال أحمد لا يعجبني قال أبو الخطاب هذا على سبيل ﴿ ومن البقر والغنم ﴾ الآية الأنعام 146 لأنه يشبه الشحم في صفته وذوبه ولا نسلم أنه لا يسمى شحما ولا أنه بمفرده يسمى لحما ولا يسمى بائعه شحاما بل لحاما لأنه يسمى ما هو الأصل دون التبع وفي كلا الدليلين نظر إذ بمجرد شبه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يسمى باسمه ويعطى حكمه على أن شبه سمين الظهر بالإلية أقرب من شبهه بالشحم فرع لم يتعرض المؤلف لحكم لحم الرأس واللسان والسنام وما لا يؤكل لحمه أو أكل السمين وفيه وجهان

أحدهما لا يحنث لأن اسم اللحم لا ينصرف عند الإطلاق إليه وعنه فيمن حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا أن ينوي

والثاني بلى لأنه لحم ويحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه ذكره في الشرح واقتصر عليه وإن أكل المرق لم يحنث في الأصح لأنه ليس بلحم وقد قال أحمد لا يعجبني وهو قول القاضي لأنه لا يخلو من قطع اللحم قال أبو الخطاب هذا على سبيل الورع لأنه ليس بلحم حقيقة ولا يطلق عليه فلم يحنث به كالكبد ولا نسلم أن أجزاء اللحم فيه وإنما فيه ماء اللحم ودهنه وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث أي إذا أكل بياض اللحم كسمين الظهر يحنث في قول الخرقي وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأن ذلك يسمى شحما ويشارك شحم البطن في اللون والذوب

وظاهر الآية والعرف يشهد لذلك وهو قول طلحة العاقولي وعلى هذا يحنث بأكل الإلية وقال القاضي وغيره الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره فعلى هذا لا يحنث بأكل الإلية أو اللحم الأبيض قال الزركشي وهذا هو الصواب فإن أكل اللحم وإن حلف على الزبد والسمن فأكل لبنا لم يحنث وإن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان حنث [ج ٩ - ص ٢٩٦]

وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا لم يحنث الأحمر لم يحنث لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم وقال الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا لم يحنث نص عليه اقتصر عليه في الكافي وقدمه في الرعاية وغيرها لأنه لا يسمى لبنا وهذا إن لم يظهر طعمه كما ذكره المؤلف بعد وعنه يحنث فيها وقال القاضي يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه لبن حنث بأكله وإلا فلا وعلى الأول لو أكل من لبن الأنعام أو الصيد أو لبن آدمية حنث حليبا كان أو رائبا مائعا أو جامدا لأن الجميع لبن وإن حلف على الزبد والسمن فأكل لبنا لم يحنث ذكره معظم الأصحاب لأنه لا يسمى زبدا ولا سمنا وفي المغني إن لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن ظهر حنث لأن ظهوره كوجوده وكذا إن حلف على الزبد فأكل سمنا وإن أكل سمنا وإن أكل جبنا لم يحنث وكذلك سائر ما يصنع من اللبن وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل شيئا مما يصنع من اللبن سوى السمن لم يحنث وفي الزبد وجه فإن أكل السمن منفردا أو في طبيخ يظهر فيه طعمه حنث وإن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل من ثمر الشجر غير بري كالجوز واللوز والتمر والرمان والموز والأترج والنبق والأصح ولو يابسا كصنوبر وعناب حنث لأن ذلك يسمى فاكهة عرفا وشرعا ويسمى بائع ثمرة النخل والرمان فاكهانيا لا يقال ينبغي أن يكونا ليسا من الفاكهة لقوله تعالى ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ لأنهما ثمرة شجرة

يتفكه بهما كسائر الأشياء والعطف لا يقتضي المغايرة بل لتشريفهما وتخصيصهما لقوله تعالى ﴿ من كان عدوا لله ﴾ الآية لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث وإن أكل تمرا أو بسرا أو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصبغ به

[ج ٩ - ص ٢٩٧]

وإن أكل البطيخ حنث ويحتمل إلا يحنث ولا يحنث بأكل القثاء والخيار وإن حلف البقرة 97 وليس منها زيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس وسائر ثمر بري لا يستطاب وإن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقط من تحتها وإن أكل البطيخ حنث جزم به في المستوعب والوجيز لأنه ينضج ويحلو أشبه ثمرة الشجر ويحتمل أن لا يحنث ذكره في الكافي والمحرر وجها لأنه ثمر بقله كالخيار ولا يحنث بأكل القثاء والخيار وسائر الخضروات كقرع وباذنجان وجزر ولفت وفجل وقلقاس لأنه لا يسمى فاكهة ولا هو في معناه وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا وهو الذي بدا فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسرا ومنصفا وهو الذي بعضه بسر وبعضه رطب أو لا يأكل بسرا فأكل ذلك حنث قدمه في المحرر ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز لأن آكله قد أكل الرطب وقال ابن عقيل لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا فرع حلف واحد ليأكلن رطبا وآخر ليأكلن بسرا فأكل الأول ما في النصف من الرطبة وأكل الآخر باقيها بر وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث لأنه ليس برطب أو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث ذكره في المحرر والوجيز لأنه ليس بثمر وإن أكل رطبا غير بسر قال ابن حمدان أو هما عن مذنب فلا حنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء نص عليه والجبن والملح في الأشهر فيه والزيتون واللبن وسائر ما يصبغ به أي ما يغمس فيه الخبز ويسمى ذلك المغموس فيه صبغا لأن ما جرت

العادة بأكل الخبز به هو التأدم نعلا حنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث [ج ٩ - ص ٢٩٨]

وفي التمر وجهان وإن حلف لا يلبس شيئا فابس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو قال الله تعالى ﴿ وصبغ للآكلين ﴾ المؤمنون 20 وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به رواه ابن ماجة ورجاله ثقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم رواه ابن قتيبة في غريبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف ولأنه يؤكل به الخبز عادة ويعد للتأدم فكان أدما وفي التمر وجهان كذا في المحرر والفروع

أحدهما هو أدم وجزم به في الوجيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال هذه إدام هذه رواه أبو داود والبخاري في تاريخه

والثاني لا لأنه لا يؤتدم به عادة وهو فاكهة قال في الفروع ويتوجه عليهما زبيب ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة وفي المغني والشرح لا يحنث فرع القوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه وقيل قوت أهل بلده ويحنث بحب يقتات في الأصح والطعام ما يؤكل ويشرب وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان والعيش عرفا الخبز وفي اللغة العيش الحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث لأنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب لكن لو أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث وإن

حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو اتزر بقميص لابطيه ولا بتركه على رأسه ولا بنومه عليه وإن تدثر به فوجهان وإن قال قميصا فاتزر به لم يحنث وإن ارتدى فوجهان وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وجهين وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما أستأجره فلا حنث

[ج ٩ - ص ٢٩٩]

وإن لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث وإن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى لقوله تعالى ﴿ وتستخرجون حلية تلبسونها ﴾ فاطر 12 وقوله تعالى ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ﴾ الحج 23 وقال ابن عمر قال الله تعالى للبحر الشرق إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب وكذهب وجده وإن لبس عقيقا أو سبجا وحريرا لم يحنث لأنه ليس بحلي نكرز الزجاج وفي الوسيلة تحنث المرأة بحرير وإن لبس الدراهم والدنانير زاد في الرعاية المفردين ومنطقة محلاة لا سيف في مرسلة فعلى وجهين

أحدهما لا حنث وجزم به في الوجيز لأنه ليس بحلي إذا لم يلبسه فكذا إذا لبسه

والثاني بلى كلبس سوار وخاتم ولأنها من حلي الرجال ولا يقصد بلبسها محلاة إلا التجمل بها فرع إذا حلف لا يلبس خاتما فلبسه في غير خنصر حنث لأنه لابس ولا فرق بين الخنصر وغيره إلا من حيث الاصطلاح على تخصيصه بالخنصر وكما لو حلف لا يلبس قلنسوة فجعلها في رجله وجوابه بأنه عيب ومشقة بخلافه هنا

وإن حلف لا يركب دابة فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلا حنث نقول إذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث بغير خلاف نعلمه لأن دار العبد ملك للسيد والثوب والدابة كالدار لأنهما

مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف وأما كونه يحنث إذا فعل ذلك فيما استأجره فلان لأن الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها لقوله تعالى ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ الطلاق 1 ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ الأحزاب 33 ولأن الإضافة للاختصاص ولأن ساكن الدار جعلت برسمه حنث وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث

[ج ٩ - ص ٣٠٠]

وإن ركب دابة استعارها فلان لم يحنث وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وأما الإقرار كما لو قال هذه دار زيد وفسر إقراره بسكناها احتمل أن يقبل تفسيره ولو سلم بقرينة الإقرار يصرفه إلى الملك ولو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها ولو قال هذا السكن لزيد كان مقرا له بها وإن ركب دابة استعارها فلان أو غصبها لم يحنث لأن فلانا لا يملك منافع الدابة وفارق مسألة الدار فغنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها أو غصبها وإنما يحنث لسكناه بها فأضيفت إليه ولو غصبها أو استعارها من غير أن يسكنها لم تصح إضافتها إليه وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة وذكره ابن عقيل في الفصول لوجود شرطه وفي الرعاية إن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه زيد من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان وفي الترغيب الأقوى إن كان سكنه مرة حنث وإن قال ملكه ففيما استأجره خلاف في الانتصار

وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث لأنه مختص بها حينئذ كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة ولا يبيعه وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة الاعتكاف فيه ومنع الجنب من اللبث فيه فوجب أن يحنث إذا دخله كما لو دخل الدار نفسها وإن حلف ليخرجن من الدار فصعد سطحها لم يبر فإن كان ثم نية أو سبب أو قرينة عمل بها فإن صعد على

شجرة حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها حنث وإن لم ينزل بين حيطانها فهل يحنث فيه احتمالان وكذا إن كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها فإن أقام على حائط الدار فوجهان

أحدهما يحنث ذكره [ج ٩ - ص ٣٠١]

وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان القاضي لأنه داخل في حدها أشبه القائم على سطحها

والثاني لا لأنه لا يسمى داخلا وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين

أحدهما يحنث لأنه دخل في حدها

والثاني لا وصححه في المغني لأنه لا يسمى داخلا وقال القاضي إن قام في موضع إذا أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث وجزم به في الوجيز وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان لأنها نكرة في سياق النفي فتعم ولفعله المحلوف عليه حتى لو سلم عليه حنث لأن السلام كلام تبطل به الصلاة فيحنث به كغيره وفي الرعاية إن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان وإن صلى المحلوف عليه إماما وسلم من الصلاة لم يحنث نص عليه وكذا إن أرتج عليه فيها ففتح عليه الحالف وإن زجره فقال تنح أو اسكت حنث لأن ذلك كلام فيدخل في ما حلف على عدمه وقياس المذهب لا فلو كاتبه أو راسله حنث إلا أن يكون أراد ألا يشافهه وقاله أكثر الأصحاب وعنه لا يحنث إلا أن يكون بنية أو سبب يمينه يقتضي هجرانه لأنه يصح نفيه ولو كانت الرسالة تكليما لتناول موسى وغيره من الرسل ولم يختص بكونه كليم الله تعالى واحتج الأصحاب بقوله تعالى ﴿ وما كان لبشر ﴾ الاية الشورى 51 لأنه وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب والصحيح أن هذا ليس بتكليم والاستثناء في الآية من غير الجنس كما في

الآية الأخرى ﴿ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾ آل عمران 41 والرمز ليس بتكليم لكن إن نوى ترك مواصلة أو سبب أو كان سبب يمينه يقتضي هجرانه فإنه يحنث وإن حلف لا يبتدئه بكلام أو لا كلمت فلانا حتى يكلمني أو حتى يبدأني بكلام فتكلما معا حنث في الأصح لأن كل واحد [ج ٩ - ص ٣٠٢]

وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا منهما مبتدىء إذ لم يتقدمه كلام سواه وفي الرعاية قلت لا لكن إذا قال لا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث جزم به في المحرر والوجيز لعدم البداية والثاني بلى لما تقدم وأطلقهما في الفروع وإن حلف لا يكلمه حينا ولم ينو شيئا فذلك ستة أشهر نص عليه لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال في الفروع ويتوجه أقل زمن يقع على القليل كالكثير لقوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ الروم 17 فإن قلت ترد للسنة لقوله تعالى ﴿ تؤتي أكلها كل حين ﴾ إبراهيم 25 ويراد به يوم القيامة لقوله تعالى ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ ص 88 ويراد به ساعة لقوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون ﴾ ويقال جئته منذ حين وإن كان أتاه من ساعة ويراد به مدة طويلة لقوله تعالى ﴿ فذرهم في غمرتهم حتى حين ﴾ المؤمنون 54 فالجواب أنه يصح الإطلاق في ذلك كله وإنما الكلام في الإطلاق الخالي عن الإرادة مع أن عكرمة وسعيد بن جبير وأبا عبيدة قالوا في قوله تعالى ﴿ تؤتي أكلها كل حين ﴾ إبراهيم 20 ستة أشهر واختلف فيها عن ابن عباس وما استشهدوا به من المطلق في كلام الله تعالى فما ذكرناه أقل فحمل على اليقين وقيل إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر أما إذا قيد لفظه أو بينه بزمن فإنها تتقيد به وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأن ما زاد

عليه مشكوك في إرادته والأصل عدمه وعند القاضي إن زمنا كحين وقال ابن عقيل في وقت ونحوه الأشبه بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤاخذة والزمان كحين واختار في كلها مثل الحين الا بعيدا أو مليا فإنه على أكثر من ستة أشهر وإن قال الأبد والدهر فذلك على الزمان كله والحقب ثمانون سنة والشهور إثنا عشر شهرا عند القاضي وعند أبي الخطاب ثلاثا كالأشهر والأيام ثلاثة وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث [ج ٩ - ص ٣٠٣]

وإن قال عمرا احتمل ذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما وقال القاضي هذه الالفاظ المحرر وقطع له في الوجيز أنه للأبد كالدهر وذكر ابن أبي موسى أنه إذا حلف لا يكلمه زمانا فهو إلى ثلاثة أشهر وإن قال عمرا احتمل ذلك أي يرجع فيه إلى أقل ما تناوله اللفظ واحتمل أن يكون أربعين عاما لقوله تعالى ﴿ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ﴾ يونس 16 وهو قول حسن قال أبو الخطاب ما ورد فيه من ذلك يرجع إليه كالحين فأما غيره فإن كانت له نية وإلا حمل على أقل ما يقع عليه الاسم من العمر والدهر وقال القاضي هذه الألفاظ كلها مثل الحين لما تقدم إلا بعيدا أو مليا زاد في الرعاية أو طويلا فإنه على أكثر من ست أشهر وإن قال الأبد والدهر والعمر فذلك على الزمان كله لأن الألف واللام للاستغراق وذلك يوجب دخول الزمان كله والحقب بضم الحاء ثمانون سنة نصره في الشرح وجزم به في المستوعب والوجيز روي عن علي وابن عباس في تفسير الآية وقاله الجوهري في صحاحه وقال القاضي وقدمه في الفروع هو أدنى زمان لأنه المتيقن وقيل أربعون عاما وقيل للأبد والشهور اثنا عشر عند القاضي وجزم به في الوجيز لقوله تعالى ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ﴾ التوبة 36 وعند أبي الخطاب وقدمه في الرعاية والفروع ثلاثا لأنه جمع كالأشهر فإنها ثلاثة وجها واحدا والأيام ثلاثة لأنها أقل الجمع وإن عين أياما تبعتها الليالي وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فخول ودخله

حنث لأنه فعل ما حلف مدته وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل [ج ٩ - ص ٣٠٤]

وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله ويحتمل أن يتناول جميع على تركه وكذا إذا جعل لها بابا آخر مع بقاء الأول أو قلع الباب ونصبه في دار أخرى لم يحنث بالدخول من الموضع الذي نصب فيه الباب وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث ويتخرج بلى إذا أراد بيمينه اجتناب الدار لكن إن كان الدار سبب هيج اليمين كما لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله لأن إلى لانتهاء الغاية فتنتهي عند أولها لقوله تعالى ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ البقرة 187 ويحتمل أن يتناول جميع مدته هذا رواية لأن إلى تستعمل بمعنى مع لقوله تعالى ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ الصف 14 ولأن الظاهر أنه قصد هجرانه واللفظ صالح لتناول الجميع وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث لأنه مال فوجب أن يحنث للمخالفة في يمينه والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح تصرفه فيه بالابراء والحوالة أشبه المودع ولأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قاله في الواضح والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين وعن أحمد إذا نذر الصدقة بجميع ماله إنما يتناول نذره الصامت من ماله لأن إطلاق المال ينصرف إليه فلو كان له مال مغصوب حنث وكذا إن كان ضائعا في وجه فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده لم يحنث في الأشهر ويحتمل ألا يحنث في كل

موضع لا يقدر على أخذ ماله وظاهره أنه إذا تزوج أو اشترى عقارا ونحوه لا يحنث وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل حتى غلب على الحقيقة كالرواية والظعينة [ج ٩ - ص ٣٠٥]

من فعله حنث إلا أن ينوي

فصل

فأما الأسماء العرفية فهي أسماء اشتهر مجازها من فعله حنث إلا أن ينوي اقتصر عليه أكثر الأصحاب لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به فحنث كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه وذكر ابن أبي موسى أنه يحنث إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه فلا وجزم به في الوجيز فإذا وكل فيه وأضاف إلى الموكل فلا حنث وإن أطلق فوجهان وإن حلف لا يكلم عبدا اشتراه زيد فكلم عبدا اشتراه وكيله أو لا يضرب عبده فضربه بأمره حنث

قاعدة تطلق امرأة من حلف لا يكلم زنديقا بقائل بخلق القرآن قاله سجادة قال أحمد ما أبعده والسفلة من لم يبال بما قال وما قيل له ونقل عبد الله من يدخل الحمام بغير مئزر ولا يبالي على أي معصية رئي

قال ابن الجوزي الرعاع السفلة والغوغاء نحو ذلك وأصل الغوغاء صغار الجراد

فصل

فأما الأسماء العرفية فهي أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة لأنها إذا لم تشتهر تكون مجازا لغة وسميت عرفية لاستعمال أهل العرف لها في غير المعنى اللغوي وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى ثم

يصير مدلوله على معنى آخر عرفي ولا شبهة في وقوع ذلك كالراوية للمزادة في العرف وفي الحقيقة الجمل الذي يستقي عليه والظعينة هي في العرف للمرأة على وطء امرأته تعلقت يمينه بجاعها وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسح والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسح فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس أنه لا يحنث وقال بعض أصحابنا يحنث

[ج ٩ - ص ٣٠٦]

والدابة والغائط والعذرة ونحوها فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة

وإن حلف وفي الحقيقة للناقة التي يظعن عليها والدابة اسم لذوات الأربع وفي الحقيقة اسم لما دب والغائط والعذرة في العرف الخارج المستقذر وفي الحقيقة الغائط المكان المطمئن من الأرض والعذرة فناء الدار ونحوها أي نحو هذه الأشياء فتتعلق اليمين بالعرف لأنه يعلم أن الحالف لا يريد غيره فصار كالمصرح به دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة ولا يعرفها أكثر الناس

وإن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها لأنه الذي ينصرف اللفظ في العرف إليه وإن حلف لا يتسرى حنث بوطئها أيضا وقد سبق وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها لأنها غير قابلة للجماع فوجب تعلق يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا لأن اليمين محمولة على الدخول وكذا إن حلف لا يضع قدمه في الدار وقال أبو ثور إن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم يضع قدمه فيها وهل يحنث بدخول مقبرة قال في الفروع يتوجه لا إن قدم العرف وإلا حنث وقد قال بعض العلماء في قوله عليه السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو الصحيح فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو كان يابسا أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما

أو ماء الورد فالقياس أنه لا يحنث وهذا قول القاضي وجزم به في الوجيز لأنه المسمى عرفا ويمينه تختص بالريحان الفارسي وقال بعض أصحابنا يحنث قدمه [ج ٩ - ص ٣٠٧]

وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى السامري والمجد وابن حمدان وصححه في الفروع وحينئذ يحنث بشم كل نبت ريحه طيب كمرزجوش لأنه يتناوله اسم الريحان حقيقة وعلم منه أنه لا يحنث بشم الفاكهة وجها واحدا فرع إذا حلف لا يشم طيبا فشم نبتا طيب الريح كالخزام ونحوه حنث في الأشهر

وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي قدمه السامري والجد والمجد وجزم به ابن هبيرة وصاحب الوجيز وهو المذهب لقوله تعالى ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ﴾ النحل 14 ولأنه جسم حيوان يسمى لحما فحنث بأكله كلحم الطير وتقديما للشرع واللغة ولم يحنث عند ابن أبي موسى إلا أن ينويه لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم ولو وكل في شراء لحم فاشترى له سمكا لم يلزمه ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقال ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا وكما لو حلف لا قعدت تحت سقف فإنه لا يحنث بقعوده تحت السماء وقد سماه الله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز كذا هنا والأول هو ظاهر المذهب والفرق بين مسألة اللحم والسقف أن الظاهر أن من حلف لا يقعد تحت سقف يمكنه التحرز منه والسماء ليست كذلك فعلم أنه لم يردها بيمينه ولأن التسمية ثم مجاز وهنا حقيقة لكونه من حيوان يصلح للأكل فكان الاسم فيه حقيقة كلحم الطير لقوله تعالى ﴿ ولحم طير مما يشتهون ﴾ الواقعة 21 وإن حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطير والسمك وبيض

السمك والجراد وغير ذلك عند القاضي قدمه في بائضه حال الحياة وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم

[ج ٩ - ص ٣٠٨]

وعند أبي الخطاب لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض يزايل الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا أشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فإنه يحنث بشرب الماء الملح والماء النجس ومن حلف لا يأكل خبزا حنث بكل خبز وفي الترغيب إن كان خبز بلده الأرز حنث به وفي حنثه بخبز غيره الوجهان وعند أبي الخطاب لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض يزايل بائضه حال الحياة لأنه لا ينصرف اليه اللفظ عرفا فلم يحنث كما لو حلف لا يأكل شواء فأكل بيضا ونقله في الشرح عنه وأنه قول أكثر العلماء وهو الصحيح وقيل بيض السمك والجراد يزايلهما في الحياة ولا يؤكل في حياتهما وفي المحرر والفروع كالمقنع وفي الترغيب إن كان بمكان العادة إفراده بالبيع فيه حنث وفي غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عادة الحالف وحاصله أنه لا يحنث بأكل شيء يسمى بيضا غير بيض الحيوان ولا بشيء يسمى رأسا غير رؤوس الحيوان لأن ذلك ليس برأس ولا بيض وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم حنث نص عليه لأنهما بيتان حقيقة لقوله تعالى ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ النور 36 وقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية آل عمران 96 وقوله عليه السلام بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله كبيت الإنسان وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرفا

لقوله تعالى ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ﴾ الاية النحل 80 فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد [ج ٩ - ص ٣٠٩]

أو لا يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا ويحتمل ألا يحنث فإن حلف لا يتكلم وظاهره أن الخيمة كذلك قدمه في الرعاية واقتصر عليه السامري وحكاه في الفروع منصوصا عليه وذكر في الكافي والشرح أنه لا يحنث بدخولها لكن إن عين خيمة اقتلعت وضربت في موضع آخر أو نقلها حنث وعلم مما سبق أنه لا يحنث بدخول دهليز دار أو صفتها لأنه لا يسمى بيتا أو لا يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا لأنه ركوب لقوله تعالى ﴿ اركبوا فيها ﴾ هود 41 ﴿ فإذا ركبوا في الفلك ﴾ العنكبوت 65 ويحتمل ألا يحنث وهو قول أكثرهم لأنه لا يسمى بيتا ولا ركوبا في العرف وظاهره أن الاحتمال في الصور كلها وظاهر المغني أنه في المسجد والحمام فقط قال لأن أهل العرف لا تسمي ذلك بيتا فإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث في قول أكثر العلماء لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ البقرة 238 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأمر الله تعالى زكريا بالتسبيح مع قطع الكلام عنه وقال إن قرأ في الصلاة لم يحنث وإلا حنث ومقتضى مذهبه أنه يحنث لأنه كلام كقوله تعالى ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾ الفتح 26 وقوله عليه السلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان الخبر والأول أشهر لأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجا منها

كالإشارة وما ذكروه يبطل بذكر الله تعالى المشروع في الصلاة وإن دق عليه إنسان بابه فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد [ج ٩ - ص ٣١٠]

تنبيه لم يحنث وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث تنبيه بالقرآن لم يحنث لأن هذا من كلام الله تعالى ويمينه إنما تنصرف إلى كلام الآدميين قال ابن المنجا فإن قيل لو قال ذلك في الصلاة لبطلت ولو لم يكن من كلام الآدميين لما بطلت قيل في ذلك منع وإن سلم فالفرق أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن وقد وقع التردد فيه أن ذلك قرآن ولا يصح مع الشك في شرطها بخلاف الحلف فإن شرط الحنث فيه كون المتكلم به كلام الآدميين وقد وقع التردد فيه فلا يحنث بالشك في شرطه وفي المذهب وجه وظاهره أنه إذا لم يقصد القرآن أنه يحنث ذكره الأصحاب لأنه من كلام الآدميين وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه ذكره في الانتصار قال الشيخ تقي الدين الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني فلهذا يجعل القول قسما للفعل وقسما آخر وينبني عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة هل يحنث فيه وجهان فرع إذا حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن فإنه يحنث إجماعا قاله أبو الوفاء

وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث لأنه قصد ترك تأليمها وقد آلمها وقال أبو الخطاب يحتمل ألا يحنث بذلك إلا أن يقصد ألا يؤلمها أومأ إليه في رواية مهنا وهو قول في الرعاية لكن لو عضها للتذذ ولم يقصد تأليمها لم يحنث

وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك بر لوجود المقصود بالضرب وإن ضربها بعد موتها لم يبر وهل اللطم والوكز ضرب يحتمل وجهين قاله ابن حمدان

فصل

وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل إن حلف ألا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر طعمه أو لا يأكل بيضا فاكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث [ج ٩ - ص ٣١١]

وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه

فصل

وإن حلف ليضرنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه نصره في الشرح واقتصر عليه السامري وصاحب الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأن هذا هو المفهوم في العرف لأن السوط هنا آلة أقيمت مقام المصدر وانتصب انتصابه لأن معنى كلامه لأضربنه مائة ضربة بسوط وهذا هو المفهوم من يمينه والذي يقتضيه لغة فلا يبر بما يخالف ذلك وعنه يبر اختاره ابن حامد لقول أحمد في المريض الذي عليه الحد يضرب بعثكال النخل يسقط عنه الحد وكحلفه ليضربنه بمائة وأجاب في الشرح عن قصة أيوب بأن هذا الحكم لو كان عاما لما خص بالمنة عليه وعن المريض المجلود بأنه إذا لم يتعد هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه فلأن لا يتعدى إلى اليمين أولى فرع إذا حلف ليضربنه بعشرة أسواط فجمعها فضربه بها بر

وإن حلف ليضربنه عشر مرات لم يبر بضربه عشرة أسواط دفعة واحدة بغير خلاف وكذا إن حلف ليضربنه عشر ضربات

فصل

وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل ان حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث قدمه في المستوعب و اللحم الأحمر وحده وقال غيره يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير [ج ٩ - ص ٣١٢]

وإن ظهر طعم السمن أو طعم شيء من المحلوف عليه حنث وقال الخرقي يحنث بأكل الكافي في اللحم الأحمر وصححه المؤلف وجزم به في الوجيز لأن المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه فلم يحنث بأكل المستهلك فيه كما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا ولأن المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه والظاهر من الحالف على ذلك أنه إنما حلف لمعنى في المحلوف عليه وإذا كان كذلك تعين عدم الحنث لانتفاء المعنى المحلوف من أجله وإن ظهر طعم السمن أو طعم شيء من المحلوف عليه حنث كما لو أكل ذلك منفردا وكحلفه على اللبن فإنه يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده لأنه لا يكاد يخلو من شحم فيحنث به وإن قل لأنه يظهر في الطبيخ فيبين على وجه المرق وفارق من حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر طعمه ولا لونه لأن هذا قد يظهر الدهن فيه وقال غيره يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير لأن الشعير يمكن تمييزه بتركه فيه وأكله له أكل لما منع نفسه من أكله مع القدرة عليه أشبه ما لو أكل منفردا وفي الترغيب إن طحنه لم حنث وإلا حنث في الاصح والمذهب الأول فلو حلف لا يأكل حنطة فأكلها خبزا أو طحينا حنث لأن الحنطة لا تؤكل حبا عادة فانصرفت يمينه إلى أكلها في جميع أحوالها

مسألة إذا حلف لا يأكل في هذه القرية فأكل فيها أو في حد من حدودها حنث ذكره في المستوعب قال أحمد فيمن حلف لا يدخل هذه

القرية فأوى إلى ناحية منها مما هو في حدها حنث لأن الناحية والحد من جملة القرية ذكره القاضي أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان وقال القاضي إن عين المحلوف عليه حنث وإن لم يعينه لم يحنث

فصل

وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي يحنث وقال

فصل

وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي يحنث هذا رواية لأن الحالف على ترك شيء يقصد به في العرف اجتناب ذلك الشيء بالكلية فحملت اليمين عليه ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالهم ﴾ النساء 2 فإنه يتناول تحريم شربها ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل كان ناهيا له عن شربه وبالعكس وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث هذه رواية ثانية نقلها مهنا وقدمها في المحرر لأن الأفعال أنواع كالأعيان وإن حلف على نوع من الأنواع لم يحنث بغيره كذلك الأفعال فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان مبنيان على الخلاف السابق وقال القاضي إن عين المحلوف عليه حنث وإن لم يعينه لم يحنث هذا رواية وجزم بها في الوجيز لأن تغير صفة المحلوف عليه لا ينفي الحنث فكذلك تغير صفة الفعل وإذا لم يعينه فلا حنث لأنه لم تحصل المخالفة من جهة الاسم ولا من جهة التعيين قال في الشرح ليس للتعيين أثر في الحنث وعدمه فإن الحنث في المعين إنما كان لتناوله ما حلف عليه وإجراء معنى الأكل والشرب على

التناول العام فيهما وهذا لا فرق فيه بين التعيين وعدمه وعدم الحنث معلل بأنه لم يفعل الفعل الذي

يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث

فصل

وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث [ج ٩ - ص ٣١٤]

وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه وإن ذاق ولم يبلعه لم يحنث وإن حلف لا حلف على تركه وإنما فعل غيره وهذا في المعين كهو في المطلق لعدم الفارق بينهما فرع إذا حلف لا يأكل ولا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو قصب سكر فروايتان أنصهما لا حنث ذكره في الكافي وذكر ابن عقيل أن أحمد نص فيمن حلف لا يأكل فمص قصب السكر أو الرمان حنث وإن حلف لا يأكل سكرا أو لا يشربه فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه فعلى الخلاف

وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لقوله تعالى ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ البقرة 249 ولأن ذلك كله طعم وإن ذاق ولم يبلعه لم يحنث في قولهم جميعا لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به فلو حلف لا يذوقه حنث بأكله أو شربه أو ذوقه لأنه ذوق وزيادة وفي الرعاية حنث بأكله وشربه ثم قال قلت فيمن لا ذوق له نظر

وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث لقوله عليه السلام كلوا الزيت ولأنه يسمى أكلا ويؤكل في العادة كذلك فرع إذا حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر وقال ابن عقيل يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتباره كحلفه لا يلبس هذا الثوب فتعمم به

فصل

وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب [ج ٩ - ص ٣١٥]

وإن حلف يركب ولا يلبس فاستدام ذلك وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام في قولهم جميعا لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة استدامته في تحريمه في الإحرام وإن حلف لا يركب ولا يلبس ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر فاستدام ذلك حنث وهو قول أكثرهم لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال ركب شهرا ولبس شهرا وقد اعتبر الشارع هذا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما أوجبها في ابتدائه وقال أبو محمد الجوزي في اللبس استدامة حنث إن قدر على نزعه ويلحق ما لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء نص عليه أو لا يطأ فاستدام ذلك ذكره في الانتصار أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه لأن المضاجعة تقع على الاستدامة ولهذا يقال اضطجع على الفراش ليلة قال القاضي وابن شهاب الخروج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا والنزع جماع لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره وجزم في منتهى الغاية لا يحنث بالنزع في الحال وفاقا وكذا إذا حلف لا يمسك ذكره في الخلاف أو لا يشاركه فدام ذكره في الروضة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي لم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع لأن استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم ولم يحنث عند أبي الخطاب لأن الدخول لا يستعمل

في الاستدامة ولهذا يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها شهرا فجرى مجرى التزويج ولأن الانفصال من خارج إلى داخل ولا يوجد في الإقامة قال أحمد أخاف أن يكون قد حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنة فلم يخرج في الحال حنث إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه وإن خرج دون متاعه وأهله حنث

[ج ٩ - ص ٣١٦]

وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين وإن حنث قال السامري فحمله أبو الخطاب على أنه قصد الامتناع من الكون في داخلها وإلا فلا يحنث حتى يبتدئ دخولها وقيل لا يحنث إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين لأن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة التي قبلها والأصح الحنث إن لم تكن له نية وإن حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها أو لا يركب دابة هو راكبها أو لا يلبس ثوبا هو لابسه أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فلم يخرج في الحال حنث لأن استدامة السكنى سكنى بدليل أنه يصح أن يقال سكن الدار شهرا إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال ويكون نقله على ما جرت به العادة لا ليلا وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث ذكره في الكافي ونصره في الشرح لأن هذا ليس بسكنى وقال القاضي يحنث إن دخلها وإن تردد زائرا فلا لأنها ليست سكنى ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا ولو طالت مدتها أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا فلم يدخل تحت النهي وإن خرج دون متاعه المقصود وأهله مع إمكان نقلهم وظاهر نقل ابن هانئ وهو ظاهر الواضح وغيره أو ترك له به شيئا حنث وهو قول أكثرهم لأن السكنى تكون بالأهل والمال ولهذا يقال فلان

ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه فيخرج وحده فلا يحنث وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائط وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحدة حجرة لم يحنث [ج ٩ - ص ٣١٧]

إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إكراهها وإن نزل بلدا بأهله وماله فيقال سكنه لكن إن خرج عازما على السكنى بنفسه منفردا عن أهله الذين في الدار لم يحنث زاد في الشرح فيما بينه وبين الله تعالى وقيل إن خرج بأهله فسكن بموضع وقيل أو وجده بما يتأثث به فلا فرع إذا أقام في الدار لإكراه أو ليل أو يحول بينه وبين الخروج أبواب مغلقة أو لعدم ما ينقل عليه متاعه أو منزل ينتقل إليه أياما ولياليي في طلب النقلة لم يحنث وإن أقام غير ناو لها حنث ذكره في الكافي والشرح

إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه أو تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إكراهها فيخرج وحده فلا يحنث لأن زوال اليد والعجز لا يتصور معهما حنث وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث هذا هو المذهب إذا كانا في دار حالة اليمين وتشاغلا ببناء الحائط لأنهما متساكنان قبل انفراد إحدى الدارين من الأخرى لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح وذكر السامري والمجد قولا بأنه لا يحنث فإن خرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة منهما بابا وبينهما حاجز وسكن كل واحد حجرة لم يحنث لأنهما غير متساكنين وقال مرة لا يعجبني ذلك ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار والأول أصح لأنه لم يساكنه فيها وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة ولا نية ولا سبب قاله في الرعاية

والفروع لم يحنث الدار فخرج دون أهله لم يبر وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له العودة إليها على روايتين [ج ٩ - ص ٣١٨]

وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون اهله بر وإن حلف ليخرجن من لأن كل واحد ساكن في حجرته فلا يكون مسكنا لغيره وكذا إن سكنا في دارين متجاورتين قال في الفنون فيمن قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك فكتبت له بعد ستة عشر يوما تقع الثلاث لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية

وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر لأن حقيقة الخروج لم يعارضها معارض فوجب حصول البر لحصول الحقيقة وكذا إن حلف ليخرجن من الدار ولا يأوي أو ينزل فيها نص عليهما أو لا يسكن البلد أو ليرحلن منه فكحلفه لا يسكن الدار قاله في الفروع وإن حلف ليخرجن من الدار فخرج دون أهله لم يبر لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد بخلاف البلد وإن حلف لا يسكنها وهو خارج عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه فوجهان وقيل إن قصد الامتناع من الكون فيها حنث وإلا فلا وقيل إن انتقل إليها برحله الذي يحتاجه الساكن حنث وإلا فلا وقال القاضي ولو بات ليلتين فلا حنث وفي الشرح إذا حلف على الرحيل عن بلد لم يبر إلا برحيل أهله وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له العود إليها على روايتين

إحداهما لا شيء عليه في العود قدمه في الرعاية ورجحه في الكافي والشرح وصححه في الفروع لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه وإذا كان كذلك صار بمنزلة حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث ويحتمل ألا يحنث وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي

[ج ٩ - ص ٣١٩]

فصل

إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع أو من لم يحلف ولقوله إن خرجت فلك درهم استحق بخروج أول ذكره القاضي وغيره

والثانية يحنث بالعود لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف على الرحيل منه والعود ينافي مقصود يمينه فأما إن كان له نية أو سبب أو قرينة عمل بها

فصل

إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث نص عليه ولا نعلم فيه خلافا فإن حمل بغير أمره ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث في المنصوص واختاره القاضي كما لو حمل بأمره وقال أبو الخطاب فيه وجهان

أحدهما يلي لما تقدم

والثاني لا يحنث كما لو لم يمكنه الامتناع وعلى الأول كيفما دخل باختياره حنث مطلقا ولو من غير بابها ويستثنى منه ما لو أكره بضرب ونحوه فالأصح أنه لا يحنث للخبر والمعنى أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث لأنه قصد اجتناب خدمته ولم يحصل

ويحتمل أن لا يحنث وهو وجه لأنه استخدمه والسكوت لا يدل على الرضى ولهذا يملك الذي شق ثوبه مطالبة الذي شقه وقيل إن كان عبده حنث لأن عبده يخدمه عادة فمعنى يمينه لأمنعنك خدمتي فإذا لم ينهه ولم يمنعه فإنه يحنث بخلاف عبد غيره وقال أبو الخطاب يحنث فيهما واقتصر عليه ابن هبيرة وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وصححه ابن المنجا وقدمه في الفروع كما لو حلف ليحجن يحنث على وجهين [ج ٩ - ص ٣٢٠]

ويحتمل ألا يحنث وإن مات الحالف لم يحنث وإن حلف ليقضينه حقه فأبراه فهل العام فلم يقدر على الحج لمرض أو ذهاب نفقة لأن الامتناع لمعنى في المحل أشبه ما لو ترك ضرب العبد لصغر به أو ترك الحالف الحج لصعوبة الطريق ويحنث عقيب تلفهما نص عليه وقدمه في المحرر والرعاية وجزم له في الوجيز وقيل في آخر الغد ويحتمل أن لا يحنث وقاله الأكثر لأنه تعذر فعل المحلوف عليه لا من جهته أشبه المكره أما لو تلف المحلوف عليه بفعله واختياره فإنه يحنث وجها واحدا قال في الشرح فإن تلف العبد في غد قبل التمكن من ضربه فكما لو مات في يومه وإن مات في غد قبل التمكن من ضربه حنث وجها واحدا وإن ضربه اليوم لم يبر نصره في الشرح وقدمه في الرعاية كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس وقال القاضي يبر وقال ابن حمدان إن أراد أنه لا يتجاوزه وإلا حنث وإن جن العبد فضربه بر وإلا فلا وإن مات الحالف أي قبل الغد أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد لم يحنث لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك فلا يمكن حنثه بخلاف موت المحلوف عليه والأصح أنه إذا مات فيه فإنه يحنث في آخر حياته فإن مات الحالف في غد بعد التمكن من ضربه فلم يضربه حنث وجها واحدا وكذا إن هرب العبد أو مرض أو الحالف فلم يقدر على ضربه وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه منه قبل مجيئه فهل

يحنث على وجهين هما مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل فعله

أحدهما الحنث لأن الحلف على القضاء والإبراء ليس بقضاء بدليل أنه يصح أن يقال يحنث عند ابن حامد وحنث عند القاضي وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر إن حلف لا فارقته حتى [ج ٩ - ص ٣٢١]

وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث وقال القاضي يحنث وإن باعه بحقه عرضا لم ما قضاني حقي وإنما أبرأته منه

والثاني وهو الأصح عدمه لأن الغرض من القضاء حصول البراءة منه فلا يحنث وفي الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في غد كرها لا يحنث على الأصح وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث قاله أبو الخطاب وقدمه السامري والمجد وجزم به في الوجيز لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في إبراء ذمته فكذلك في يمينه وقال القاضي يحنث كما لو حلف ليضربن عبده غدا فمات العبد اليوم والأول هو المنصور لأن موت العبد يخالف ذلك لأن ضرب غيره لا يقوم مقام ضربه وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد قدمه السامري والمجد وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع لأنه قضاه حقه وحنث عند القاضي لأنه لم يقض الحق الذي عليه بعينه فإن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث وجها واحدا وإن منع منه فالروايتان وهما في المذهب إن كره وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلاك أو مع رأسه أو إلى رأسه أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر على المذهب لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ذكره في المغني وذكر السامري وقدمه في الرعاية أنه إذا قضاه قبل الغروب في آخر الشهر بر وإن فاته حنث ثم قال في الرعاية قلت فيخرج ضده إن عذر ويحنث

إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه وفي الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن حلف لا فارقته حتى بفراقه خرج على الروايتين وإن حلف لا افترقنا فهرب منه حنث [ج ٩ - ص ٣٢٢]

استوفى حقي فهرب منه حنث وقال الخرقي لا يحنث وإن فلسه الحاكم وحكم عليه أستوفي حقي فهرب منه حنث نص عليه وذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقة وقد حصل وكإذنه ولقوله لا افترقنا وقال الخرقي لا يحنث هذا رواية قدمها في الكافي والترغيب ونصرها في الشرح وصححها ابن حمدان لأن اليمين على فعل نفسه ولم توجد المفارقة إلا من غيره واختار في المحرر وجزم به في الوجيز أنه إن أمكنه متابعته وإمساكه حنث وإلا فلا فإن أذن له الحالف في الفرقة ففارقه فالمذهب أنه يحنث وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين في الإكراه إذا فلسه الحاكم وصده عنه والمذهب الحنث وكذا إن لم يحكم بفراقه ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته نص عليه وإن لم يصده الحاكم بعد فلسه حنث وقيل إن قضاه حقه من غير جنسه وهو ناو الوفاء ففارقه فلا وقال القاضي إن كان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث وإن قال حتى أستوفي حقي منك حنث وكذا إن أحاله به فقبل وانصرف وإن ظن أنه بر فوجهان وإن فارقه عن كفيل أو رهن أو أبرأه منه حنث وإن وجدها مستحقها وأخذها خرج على الروايتين في الناسي فرع إذا حلف المطلوب ألا يعطيه شيئا فوفاه عنه غيره بلا إذنه فلا حنث وإن حلف لا فارقتك حتى آخذ حقي ففر الغريم حنث الحالف وإن أكره على إطلاقه فوجهان وإن فر الحالف فلا على الأشهر

وإن حلف لا افترقنا فهرب منه حنث لأن يمينه تقتضي ألا تحصل بينهما فرقة بوجه من جهة اللفظ والمعنى وقد حصلت وإن حلف لا أخذت حقك مني فأكره على دفعه [ج ٩ - ص ٣٢٣]

وقدر الفراق ما عده الناس فراقا كفرقة البيع

باب النذر يضمن بمثل هذا مال ولا صيد ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيك لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم وأخذه حنث نص عليه كقوله لا تأخذ حقك علي وعند القاضي لا كقوله ولا أعطيكه وقدر الفراق ما عده الناس فراق كفرقه البيع لأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين مقداره فوجب الرجوع فيه إلى العادة كالقبض والحرز

باب النذر

يقال نذرت أنذر بكسر الذال وضمها نذرا فأنا ناذر أي أوجب على نفسه شيئا تبرعا والأصل فيه بعد الإجماع قوله تعالى ﴿ يوفون بالنذر ﴾ الانسان 7 ﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ الحج 29 وقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري من حديث عائشة ويتعين الوفاء به ولا يستحب لنهيه عليه السلام عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه وهذا نهي كراهة لأنه لو كان حراما لما مدح الموفيين به لأن ذمهم من ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال ابن حامد ولا يصح إلا بالقول وإن نواه من غير قول لم يصح في

محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد

[ج ٩ - ص ٣٢٤]

وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمه وحرمه طائفة من أهل الحديث وقال ابن حامد المذهب مباح وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا يحترز به عن الواجب بالشرع فيقول لله علي كذا وقال ابن عقيل إلا مع دلالة حال وفي المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي ولا يصح إلا من مكلف فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار وكالطفل مسلما كان أو كافرا ذكر في المستوعب وغيره أنهما سواء وشرطه أن يكون مختارا أما الأول فظاهر وأما الثاني فيصح منه ولو بعبادة نص عليه لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك وهو قول المغيرة والمخزومي والبخاري وابن جرير وقال الأكثر لا يصح نذره وحملوا خبر عمر على الندب وقيل يصح منه غير عبادة لأن نذره لها كالعبادة لا اليمين ولا يصح إلا بالقول لأنه التزام فلم ينعقد بغيره كالنكاح والطلاق وإن نواه من غير قول لم يصح كاليمين ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد وفيه مسألتان

الأولى أنه لا ينعقد نذر المستحيل كصوم أمس قدمه في الكافي وجزم به في الوجيز وغيره لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به أشبه اليمين على المستحيل وقيل تجب الكفارة قال المؤلف والصحيح في المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله

بدليل قوله عليه السلام لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال لتكفر عن يمينها ولتركب وفي رواية ولتصم ثلاثة فتجب به كفارة يمين الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله [ج ٩ - ص ٣٢٥]

والنذر المعقد على خمسة أقسام أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر أيام قال أحمد أذهب إليه وعن عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع

الثانية أنه لا ينعقد نذر الواجب كصوم رمضان قاله أكثر أصحابنا لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم والمذهب أنه ينعقد موجبا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين فرع من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح انعقد نذره موجبا للكفارة إن لم يفعل مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهن كما لو حلف على فعل ذلك وعنه أنه لاغ ولا كفارة فيه

والنذر المنعقد على خمسة أقسام

أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر ولا نية له وفعله فتجب به كفارة يمين وفاقا للأكثر لما روى عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب وروى أبو داود وابن ماجة معناه من حديث ابن عباس وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم

الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما علقه بشرط يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو

الصدقة بمالي فهذا إن وجد شرطه فهو يمين يتخير بين فعله كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين [ج ٩ - ص ٣٢٦]

والتكفير الثالث نذر المباع كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو راكب دابتي فهذا والتكفير في ظاهر المذهب لما روى عمران بن حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى لأن هذا جمع للصفتين فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما وعنه يتعين كفارة يمين للخبر وفي الواضح يلزمه الوفاء بما قال نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ذكره الشيخ تقي الدين لأن الشرع لا يتغير بتوكيل قال في الفروع ويتوجه كأنت طالق بتة قال شيخنا وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بحجة إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة فرع إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق لأن العتق يصح تعليقه بشرط أشبه الطلاق وإن قال إن بعتك ثوبي فهو صدقة فقال فإن اشتريته فهو صدقة فاشتراه منه لزم كل واحد كفارة يمين ذكره السامري وابن حمدان

الثالث نذر المباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين لما سبق وعنه لا كفارة فيه واختاره الأكثر لقوله عليه السلام لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ولما روى ابن عباس قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالو أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا

يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري فلم يأمره بكفارة فإن وفى به أجزأه لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أضرب

وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع نذر المعصية كشرب على رأسك بالدف فقال فأوف بنذرك رواه أبو داود ورواه بمعناه أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله فكذا إذا نذره لأن النذر كاليمين

وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ليخرج عن عهدة نذره ولا يفعله لأن ترك المكروه أولى فإن فعله فلا كفارة عليه قال في الشرح والخلاف فيه كالذي قبله

الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض وفيه وجه كصوم يوم عيد جزم به في الترغيب ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر في الثلاثة وقاله ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة لقوله عليه السلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الخمسة من حديث عائشة ورواته ثقات احتج به أحمد وإسحاق وضعفه جماعة ولأن النذر حكمه حكم اليمين وعنه لا كفارة فيه وهي قول أكثرهم لقوله عليه السلام لا نذر فيما لا يملك العبد رواه مسلم من حديث عمران فهذا مما لا يملك وإن كفر فهو أعجب إلى أبي عبد الله ونقل الشالنجي إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفر في المعصية وإذا نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك فلا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ومثله نذر سراج بئر وشجرة مجاورة عنده

قال من يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو مقبرة إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا قاله الشيخ تقي الدين إلا أن ينذر نحر ولده ففيه روايتان المعصية [ج ٩ - ص ٣٢٨]

إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا

إحداهما أنه كذلك ذكر في الشرح أنه قياس المذهب وقدمه في المحرر والرعاية وهو قول ابن عباس لما سبق من قوله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ولأنه نذر معصية أشبه نذر ذبح أخيه وقال ابن عقيل ولأن ما يوجب كفارة يمين في حق الأجنبي أوجب كفارة يمين إذا علقه على ولده كالقسم وأبوه وكل معصوم كالولد ذكره القاضي وغيره واختاره في الانتصار ما لم نقس وفي عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية

والثانية يلزمه ذبح كبش جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وقال ابن هبيرة هي أظهر ورواه سعيد عن ابن عباس لأن الله تعالى جعل الكبش عوضا عن ذبح إسماعيل بعد أن أمر إبراهيم بذبحه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم بقوله تعالى ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ النحل 23 ونذر الآدمي كذلك لأنه يقتضي الإلزام كالأمر قبل إمكانه ويفرقه على المساكين وقيل كهدي ونقل حنبل يلزمانه وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نجزه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية قال الشيخ تقي الدين وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد فكيف لا يجزئه إذا نذر

معصية حالفا بها فعلى رواية حنبل يلزمان الناذر والحالف تجزئه كفارة فرع إذا كان بنوه ثلاثة ولم يعين أحدهم لزمه ثلاثة كباش أو ثلاث كفارات ذكره في الرعاية قال في الشرح لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى العموم ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا المعصية لحديث أبي إسرائيل معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه [ج ٩ - ص ٣٢٩]

ولا تجب به الكفارة ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب متفق عليه ولفظه للبخاري وذكر الآدمي نذر شرب الخمر لغو لا كفارة فيه وقدم ابن رزين نذر المعصية لغو قال ونذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة كحلفه بغيره ولا تجب به الكفارة لما تقدم والأول أولى لأن قوله عليه السلام لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله أي لا نذر يجب الوفاء به ولا خلاف فيه وإنما هو في انعقاده موجبا للكفارة ثم أكد الاحتمال بقوله ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين غير المساجد الثلاثة فله فعله في غيره ولا كفارة عليه فجعلوا ذلك منه وفيه نظر

فائدة قال في الفنون يكره إشعال القبور وتبخيرها وقال الشيخ تقي الدين فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيرانه عليه السلام قيمته وأنه أفضل من الختمة قال في الفروع ويتوجه كمن وقفه على مسجد لا يصح فكفارة يمين على المذهب وقيل يصح فيكسر وهو لمصلحته ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه اقتصر عليه في الكافي والشرح وجزم به في الوجيز لقول كعب لرسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليه بعض مالك فهو خير لك متفق عليه وفي قصة توبة أبي لبابة

وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزىء عنك الثلث رواه أحمد ولأن الصدقة [ج ٩ - ص ٣٣٠]

وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعها وعنه يجزئه ثلثه بالجميع مكروه قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزىء بعضه إلا هذا الموضع وفي الكفارة وجهان قطع به في المستوعب بوجوبها وعنه تلزمه الصدقة بجميعه ذكرها ابن أبي موسى لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه وإذا لم تكن له نية هل يتناول جميع ما يملكه أو الصامت خاصة فيه روايتان فرع إذا نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث فإن نفذ هذا المال وأنشأ غيره فقضى دينه فيجب إخراج ثلثه يوم حنثه وفي الهدي يوم نذره وهو صحيح وفيه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعها قدمه السامري وصححه في الشرح لأنه منذور وهو قربة أشبه سائر المنذورات وعنه يجزئه ثلثه قدمه في الرعاية لأنه مال نذر للصدقة فأجزأه ثلثه لجميع المال قال في الشرح وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه ولما في الصدقة بالمال كله من الضرر اللاحق به اللهم إلا أن يكون المنذور ها هنا يستغرق جميع المال فيكون كنذر ذلك وعنه ان زاد على ثلث الكل أجزأه قدر الثلث صححه في المحرر وفيما عدا ذلك يلزم المسمى رواية واحدة ونقل ابن منصور إن قال إن ملكت عشرة دراهم فهي صدقة إن كان على جهة اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر أجزأه الثلث فرع إذا حلف أو نذر لا رددت سائلا فقياس قولنا إنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق والعمرة ونحوها من

التقرب على وجه القربة سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط يرجوه فقال إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فلله علي كذا فمتى وجد شرط انعقد نذره ولزمه فعله [ج ٩ - ص ٣٣١]

فصل

الخامس نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج بثلثه الزائد وحبة بر ليست سؤال السائل والمقاصد معتبرة ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر لتعليق حكم الربا عليها ذكره في الفنون

فصل

الخامس نذر التبرر وهو التقرب يقال تبرر تبررا أي تقرب تقربا كنذر الصيام والصلاة والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة ونحوها من التقرب على وجه القربة كعيادة مريض ونحوه سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط برجوه لشموله لهما فقال إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فلله علي كذا فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله أقول نذر التبرر وهو نذر المستحب يتنوع أنواعا منها ما إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الشرع فلهذا يلزم الوفاء به إجماعا وكذا إن لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم الحاج قاله في المستوعب أو فعلت كذا لدلالة الحال ذكره ابن عقيل ونص أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا وكذا قال الشيخ تقي الدين فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة ولا أعلم فيه نزاعا وقول القائل لإن ابتلاني الله لأصبرن ولإن لقيت عدو الله لأجاهدن نذر معلق بشرط كقول الآخر ﴿ لئن آتانا من فضله ﴾ الآية التوبة 75 ومنها

التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم كذا فيلزم الوفاء

[ج ٩ - ص ٣٣٢]

به في قول أكثرهم وقال بعض العلماء لا يلزم الوفاء به لقول أبي عمرو غلام ثعلب النذر عند العرب وعد بشرط لأن ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه كالبيع وما التزمه بغير عوض فلا يلزمه بمجرد العقد كالهبة ومنها نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به في قول العامة لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه ولأنه تعالى ذم الذين ينذرون ولا يوفون ولآنه التزام على وجه القربة فلزمه لموضع الإجماع وكالعمرة فإنهم سلموها وهي غير واجبة عندهم وما حكوه عن أبي عمرو لا يصح فإن العرب تسمي الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط والجعالة وعد بشرط وليست بنذر

مسائل إذا نذر الحج العام وعليه حجة الإسلام فعنه يجزئه الحج عنهما وعنه تلزمه حجة أخرى أصلهما إذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان وإذا نذر صياما ولم ينو عددا أجزأه صوم يوم بلا خلاف وينويه ليلا اقتصر عليه في المحرر وصححه في الرعاية وإذا نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان على المذهب لأن الركعة لا تجزىء في فرض وعنه تجزئه ركعة بناء وعلى التنفل بها فدل أن في لزومها قائما الخلاف وإن نذرها قائما لم تجز جالسا ولو عكس جاز فإن صلى جالسا لعجز كفى ذكره ابن عقيل هي بموضع غصب مع الصحة وله الصلاة قائما من نذر جالسا ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم وفي النوادر لو نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ويتوجه عكسه إن عين لأنه أفضل والمنصوص لو حلف روايتان وعنه ما

يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر [ج ٩ - ص ٣٣٣]

وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين وفي أيام التشريق يقصد التقرب بأن قال والله لإن سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد شرطه لزمه فعله ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود أحد سببيه ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين لأنه لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره كالليل وفي أيام التشريق روايتان وهما مبنيان على أن صومها عن الفرض هل هو جائز أم لا وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق فيتناولها نذره وهذا على القول بتحريم صومها عن الفرض ويكفر في الأصح لقوله عليه السلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان فإن وجب ففي الكفارة وجهان وما أفطره بلا عذر قضاه مع كفارة يمين وقيل بستأنف قال ابن حمدان وفي الكفارة وجهان فإن قال سنة وأطلق فيصوم اثنى عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ويقضيهما قال ابن حمدان وكفر كفارة يمين في الأقيس وإن شرط التتابع في رواية وعين أولهما ففي القضاء وجهان ومع جواز التفرق تكمل أيامها وقيل بلى عدة الشهور قال في الترغيب يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما وقال ابن عقيل إن صامها متتابعة فهي على ما هي عليه من نقصان أو تمام وإن قال سنة من الآن فكمعينة وقيل كمطلقة في لزوم اثنى عشر شهرا للنذر وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر لأن الشرع حرم

صومه وقضى لأنه فاته ما نذر صومه وكفر وجزم به في الوجيز لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض وفي الرعاية وإن وافق أيام التشريق فهل يصح صومه على روايتين وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر [ج ٩ - ص ٣٣٤]

وعنه يكفر من غير قضاء ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه إن من ابتدأ بصوم كل إثنين وخميس لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى وقيل وكفر كما لو صادف عيدا وعنه تكفي الكفارة عنهما وقيل إلا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد وعنه يكفر من غير قضاء كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه لأنه وفي بنذره وإن وافق أيام التشريق فهل يصح صومه على روايتين وذلك مبني على جواز صومها عن الفرض لأن النذر إذا صادف زمنا قابلا للصوم وجب الوفاء به وإلا كان حكمه حكم يوم العيد وفي المغني رواية رابعة أنه يقضي ولا كفارة عليه وإن نذر صوم يوم يقدم فلان صح نذره وقال بعض العلماء لا لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه كما لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي قبل اليوم الذي يقدم فيه وجوابه أنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا وقال لله علي أن أصوم يومي ولا نسلم ما قاسوا عليه فإن علم قدومه من الليل فنوى صومه وكان صوما يجوز فيه صوم النذر أجزأه فقدم ليلا فلا شيء عليه عند الجميع لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته وفي المنتخب يستجب وإن قدم نهارا وهو مفطر فالمذهب يقضي وعنه لا يلزمه وقاله الأكثر كقدومه ليلا وجزم به في الوجيز فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره لأنه لا يمكنه صومه بعد وجود شرطه ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يمكن

أفطر كما لو قال لله علي أن أصوم بقية يومي وليس رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره وقال غيره عليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة [ج ٩ - ص ٣٣٥]

وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم وإن وافق قدومه يوما من ذلك مرتبا على عدم الانعقاد لأنه لا وجه له وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه أو صائم لأنه لم ينو الصوم من الليل وإن قدم ولم يفطر فنوى أجزأه بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه وعلى القضاء يكفر اختاره الأكثر وعنه لا كالأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه قضى في وجه وفي الانتصار ويكفر وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره لأنه نذر صومه وقد وفى به وكونه يجزئه صيام ذلك اليوم إشعار بأن النذر صحيح منعقد صرح به في المغني وصححه في الفروع وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي أن النذر غير منعقد لأن نذره وافق زمنا يستحق صيامه كما لو نذر صيام رمضان والأول أصح لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا وقال غيره عليه القضاء لأنه لم يصمه عن نذره وفي الكفارة روايتان كذا في المحرر والفروع

إحداهما تجب الكفارة وهي أشهر لتأخر النذر عن زمنه

والثانية لا لأنه أخره لعذر أشبه ما لو أخر صوم رمضان لعذر وعنه لا شيء عليه جزم به في الوجيز لما يأتي فعلى الأول يكفر إن لم يصمه وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذره وجهان وفي الفصول لا يلزمه صوم آخر لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه وذكر أيضا أذا نوى

صومه عنهما فقيل لغو وقيل يجزئه عن رمضان وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لو فاته [ج ٩ - ص ٣٣٦]

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين وإن لم

وبقي هنا مسائل

الأولى إذا قدم يوم عيد فعنه لا يصومه ويقضي ويكفر وقاله أكثر الأصحاب وعنه يقضي فقط كالمكره وعنه إن صامه صح كما لو نذر معصية وفعلها وقيل يكفر من غير قضاء كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها وعنه لا يلزمه شيء بناء على نذر المعصية

الثانية إذا وافق يوم حيض أو نفسا فكما لو وافق يوم عيد إلا أنها لا تصوم بغير خلاف فعلى هذا تقضي وتكفر على الأشهر

الثالثة إذا قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصومه في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق

الرابعة إذا قدم وهو صائم تطوعا فعنه يتمه ويعتقده عن نذره ولا قضاء ولا كفارة لأن سبب الوجوب وجد في بعضه كما لو نذر في صوم التطوع إتمام صوم ذلك اليوم وعنه يلزمه القضاء والكفارة وقيل عليه القضاء فقط كما لو قدم وهو مفطر

خاتمة نذر اعتكافه كصومه وفي عيون المسائل والفصول والترغيب يقضي بقية اليوم لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط الصوم فكنذر صومه وإن نذر صومه بعض يوم لزمه يوم وفيه وجه

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان وكفارة يمين لتأخر النذر عن وقته لأنه يمين وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء لما ذكرنا وفي الكفارة روايتان

إحداهما يكفر قدمها ويحتمل ان يتم باقيه ويقضي ويكفر [ج ٩ - ص ٣٣٧]

وإن صام قبله لم يجزئه وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر في المحرر وجزم بها في الوجيز لتأخير النذر عن وقته

والثانية لا كتأخير رمضان لعذر والأول أولى قاله في المغني لأن النذر كاليمين وإن صام قبله لم يجزئه وكذا الحج لأن العبادة إذا كان لها وقت معلوم لم يجز تقديمها على وقتها كالصلاة لكن إذا نذر أن يتصدق بشيء في وقت بعينه فتصدق قبله أجزأه وفاقا واختار الشيخ تقي الدين له الانتقال إلى زمن أفضل وأن من نذر أن يصوم الدهر أو صوم الإثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم كالمكان قال واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه أفضل وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه لأن صوم يجب متتابعا بالنذر كما لو اشترط التتابع ويلزمه استئنافه متتابعا متصلا بإتمامه وقدمه في المحرر والرعاية وصححه ابن المنجا لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم والفرق بين رمضان والنذر أن تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فوتها ويكفر قدمه في الكافي والمحرر والشرح لفوات زمن النذر وقيل لا يكفر وعنه لا يلزمه استئناف إلا أن يكون قد شرط التتابع لأن وجوب التتابع من جهة الوقت لا النذر فلم يبطله الفطر كشهر رمضان فعلى هذا يكفر عن فطره ويقضي أيام فطره بعد إتمام صومه وهذا أقيس وأصح قاله في الشرح ويحتمل هذا الاحتمال رواية في المحرر والرعاية أن يتم باقيه لأن التتابع فيما نذره وجب من حيث الوقت لا من حيث الشرط فلم يبطله

الفطر كصوم رمضان ويقضي كما لو أفطر يوما من رمضان ويكفر لفوات زمن النذر إلا أن يشترطه [ج ٩ - ص ٣٣٨]

وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع فرع لم يتعرض المؤلف لمن أفطر لعذر والمذهب أنه يبني ويقضي ويكفر وعنه لا كفارة وقاله أكثر العلماء كما لو أفطر رمضان لعذر والفرق ظاهر وفي وصل القضاء وتتابعه روايتان وقيل يستأنف متتابعا أو يبني ويكفر

تنبيه إذا جن جميع الشهر المعين لم يلزمه قضاؤه على الأصح ولم يكفر وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين فعليها القضاء كما لو حاضت في رمضان وفي الكفارة وجهان وإذا نذر صوم شهر خير بين أن يصوم شهرا بالهلال وبين أن يصوم بالعدد ثلاثين يوما ولزمه التتابع قدمه في المحرر وصححه في الرعاية وهو قول أبي ثور لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع وكمن نواه وعنه لا يلزمه لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين أو ثلاثين يوما ومحله ما لم يكن شرط ولا نية كما لو نذر عشرة أيام أو ثلاثين يوما وعلى الأول إن قطعه بلا عذر استأنف وبعذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع نص عليه قال ابن البنا رواية واحدة وجزم به في المحرر والوجيز لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ البقرة 184 وعنه فيمن قال لله علي صيام عشرة أيام يصومها متتابعا وهذا يدل على وجوب التتابع في الأيام المنذورة اختاره القاضي قال في الكافي والأول أولى وهذا محمول على من نوى التتابع إلا أن يشترطه فيلزمه للوفاء

بنذره وذكر ابن البنا هل يلزمه التتابع فيما دون الثلاثين على روايتين صحح في الرعاية [ج ٩ - ص ٣٣٩]

وإن نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه أنه يلزمه وقال بعض أصحابنا كلام أحمد على ظاهره ويلزمه التتابع في العشرة دون الثلاثين قال في الشرح والصحيح أنه لا يلزمه التتابع وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس

تنبيه إذا نذر صوم الدهر لزمه ولم يدخل في نذره رمضان والأيام المنهي عنها فإن أفطر لعذر لم يقضه ويكفر وإن لزمه قضاء من رمضان أو كفارة قدمه على النذر وإذا لزمته الكفارة وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب ولا تجب بفعلها كفارة وإن نذر صياما متتابعا غير معين فأفطر لمرض أو حيض قضى لا غير كما لو أفطر في رمضان والمرض والحيض لا يقطع التتابع فلم يجب الاستئناف لبقاء التتابع حكما وذكر الخرقي يتخير بين الاستئناف متتابعا بلا كفارة وبين البناء وقضاء ما ترك مع كفارة يمين وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإذا قلنا بالبناء فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان وفي التكفير وجه كشهري الكفارة ذكره جماعة وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف وفاقا ضرورة الوفاء بالتتابع من غير كفارة وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين أي إذا أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر فقيل لا ينقطع التتابع مع القدرة على الصوم كالمرض الذي يجب معه الفطر وقيل بلى لأنه أفطر باختياره كالفطر لغير عذر وعلى قول المؤلف يفرق بين المرض المبيح والسفر المبيح فإن المرض ليس باختياره بخلاف السفر فناسب أن يقطع

السفر التتابع لأنه من فعله بخلاف المرض وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل [ج ٩ - ص ٣٤٠]

لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه وإن نذر المشي إلى بيت الله أو يوم مسكينا مع كفارة يمين نص عليه وصححه القاضي وقدمه في الفروع لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه وعنه لا يجب إلا الإطعام فقط وهو ما ذكره في المتن كما لو عجز عن الصوم المشروع ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه هذا رواية ذكرها ابن عقيل وجزم بها في الوجيز وقدمها في الكافي وذكر أنها أقيس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه ابن ماجة والداقطني وإسناده ثقات ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفا على ابن عباس وكسائر النذور وقياس المنذور على المنذور أولى لأن رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت فكذلك في الحياة وهذا بخلافه ويتخرج ألا تلزمه كفارة في العجز عنه كما لو عجز عن الواجب بأصل الشرع وفي النوادر احتمال يصام عنه وسبق فعل الولي عنه ذكره القاضي وكذا إن نذره عاجزا عنه نقل أبو طالب ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين ومرادهم غير الحج وإلا فلو نذر معضوب أو صحيح ألف حجة لزمه ويحج عنه والمراد لا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي وقيل لا ينعقد نذره وظاهره أنه إذا كان لعارض يرجى زواله فإنه ينتظر فإن كان عن صوم معين وفات وقته قضاه وهل يلزمه لفوات الوقت كفارة على روايتين وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع

من الحرم لزمه الوفاء به بغير خلاف نعلمه وسنده قوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه يمين وعنه عليه دم [ج ٩ - ص ٣٤١]

لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة أي لزمه أن يمشي في أحدهما لأنه مشي إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيانه لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو من ميقاته فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين قدمه الأصحاب ونصره في الشرح لقول عقبة يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر يمينها رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد به شريك ولأن المشي غير مقصود ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي قال في الفروع فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا ولهذا ذكر ابن رزين رواية لا كفارة عليه وعنه عليه دم وأفتى به عطاء لما روى أحمد بسنده عن عمران قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وفيه وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب ولأنه أخل بواجب في الإحرام أشبه ما لو ترك الإحرام من الميقات وفي المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا وقال الشافعي لا يلزمه مع العجز كفارة إلا أن يكون النذر إلى بيت الله فهل عليه هدي فيه قولان وقد روى أبو داود أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها

النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا فرع إذا عجز عن المشي بعد الحج كفر وأجزأه وإن مشى بعض [ج ٩ - ص ٣٤٢]

وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان الطريق فيحتمل أن يكون كقول ابن عمر يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويحتمل أن لا يجزئه إلا حج يمشي في جميعه

أصل يلزمه الإتيان بالمشي والركوب من دويرة أهله إلا أن ينوي موضعا بعينه وقال الأوزاعي يمشي من ميقاته إلا أن ينوي قال والخبر فيه عطاء عن ابن عباس ورواه البيهقي ويلزمه المنذور منهما في الحج والعمرة إلى أن يتحلل لأن ذلك انقضاء قال أحمد إذا رمى الجمرة فقد فرغ وفي الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحللين على الأصح وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان كذا في المحرر والفروع لأنه مخالف لما نذر فهو بمعنى الركوب إذا نذر المشي ولأن الركوب في نفسه غير طاعة

إحداهما تلزمه الكفارة دون الدم لما ذكرنا واقتصر عليه في المغني

والثانية يلزمه دم لأنه ترفه بترك الإنفاق وفي الشرح وجزم به في الوجيز إلا أنه إذا مشى ولم يركب مع إمكانه لم يلزمه أكثر من كفارة يمين

فائدة لم يتعرض المؤلف لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى فإنه يلزمه إتيانهما والصلاة فيهما قال في الفروع مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح ومذهب مالك على ما في المدونة من قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس لم يأتهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما فرع إذا

أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه وإذا عين لنحر الهدي موضعا من الحرم تعين وكان لفقرائه ما لم يتضمن معصية للخبر وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه [ج ٩ - ص ٣٤٣]

وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا ان ينوي رقبة بعينها وإن نذر

مسألة إذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني قال في الفروع فيتوجه يصح وأن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب ذكره معظم الأصحاب لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة إلا أن ينوي رقبة بعينها فإنها تجزىء عنه لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية لكن لو مات المنذور أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق نص عليه وقيل بل تصرف قيمته في الرقاب على قياس قوله في الولاء إذ الأصل فيه ذلك وفي الرعاية من عين بنذره أو نيته شيئا من عدد صوم أو صلاة أو هدي رقاب كفاه ما عينه وعنه يجزيء باللفظ به لا ما نواه فقط وإن عين الهدي بغير حيوان جاز ويتصدق به أو بثمنه على فقراء الحرم قال في المستوعب فإن عين الهدي بما ينقل لزمه إنفاذه إلى الحرم ليفرق هناك وإلا بيع وأنفذ ثمنه ليفرق هناك وإن نذر الطواف فأقله أسبوع وإن نذره على أربع طاف طوافين نص عليه جزم به في المحرر والمستوعب والوجيز وقدمه في الفروع وهو قول ابن عباس رواه سعيد ولخبر رواه معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله

صلى الله عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك أخرجه الدارقطني قال الشيخ تقي الدين لأنه بدل واجب ولأن فيه على أربع مثله وعنه يطوف على رجليه واحدا قال في المغني والشرح وهو القياس [ج ٩ - ص ٣٤٤]

لأن غيره ليس بمشروع وفي الكفارة وجهان وقياس المذهب لزومها ومثله نذر السعي على أربع ذكره في المبهج والمستوعب والفروع وفي الرعاية يلزمه سعيان وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا وفى بالطاعة على الوجه الشرعي وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان

مسألتان

الأولى النذر المطلق على الفور نص عليه وقيل لا قال في المستوعب فإن نذر أن يهدي هدايا لزمه أن يهدي إلى الحرم لينحر هناك ويفرق فإن نذر أن ينحر هديا بغير مكة من المدينة وبيت المقدس أو يضحي أضحية في موضع عينه لزمه نحر ذلك ويفرق لحمه في الموضع الذي عينه

الثانية لا يلزمه الوفاء بالوعد نص عليه وقاله أكثر العلماء لأنه يحرم بلا استثناء لقوله تعالى ﴿ ولا تقولن لشيء ﴾ الآية الكهف 23 ولأنه في معنى الهبة قبل القبض وذكر الشيخ تقي الدين وجها يلزم واختاره ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل وقيل لأحمد بم يعرف الكذابون قال بخلف المواعيد وهو قول ابن شبرمة وعمر بن عبد العزيز لقوله تعالى ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ الآية الصف 20 ولخبر آية المنافق ثلاث وبإسناد حسن العدة عطية

وبإسناد ضعيف العدة دين ومذهب مالك يلزم بسبب كمن قال تزوج وأعطيك كذا واحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزم والله أعلم

10 [ج ٩ - ص ٣٤٥]